



لن تكون هُناك حضارة

ما لم تكن هُناك عدالة



جامعة أسيوط

كلية الحقوق

الوجيز في الجنسية ومركز الأجانب

(الجنسية – الوطن – مركز الأجانب)

إعداد

الأستاذ الدكتور

أحمد عبدالموجود الميري

أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد

رئيس قسم القانون الدولي الخاص

كلية الحقوق – جامعة أسيوط

الأستاذ الدكتور

ناصر عثمان أبوزايد

أستاذ القانون الدولي الخاص

وكيل كلية الحقوق السابق

كلية الحقوق – جامعة أسيوط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَلَدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي

بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

((سورة النمل - الآية ١٩))

صدق الله العظيم

المقدمة

يتناول القانون الدولي الخاص الروابط القانونية ذات العنصر الأجنبي أو ذات الطابع الدولي، ويقصد بالعلاقات ذات الطابع الدولي العلاقات القانونية المشتملة على عنصر أجنبي أو أكثر من عناصرها، ومن المعروف أن أى علاقة قانونية لها ثلاثة عناصر (الأطراف، المحل، السبب) فإذا كانت تلك العناصر جميعها وطنية فإن هذه العلاقة لا تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص، أما إذا تطرقت الصفة الأجنبية لعنصر أو أكثر من تلك العناصر فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الدولي الخاص، ونضرب مثلاً لذلك بأن يبرم مصري عقداً في لبنان مع سوري يكون موضوعه شراء منزل كائن في العراق، فهذه العلاقة تطرقت إليها الصفة الأجنبية في عناصرها الثلاثة، حيث إن أحد طرفي العقد أجنبي (سوري الجنسية)، وموضوع العقد يرد على مال كائن في دولة أجنبية (العراق) وسبب العلاقة وهو العقد أبرم في بلد أجنبي (لبنان)، وقد أثار العقد السابق مشكلات قانونية لا يضطلع بحلها إلا القانون الدولي الخاص، حيث إنه يحدد الصفة الأجنبية التي لحقت بالطرف الثاني في العقد، وكذلك المحكمة المختصة بنظر دعاوى المنازعات التي سوف تنشأ عن العقد والقانون الواجب التطبيق عليها، وكذلك كيفية تنفيذ الحكم الصادر فيها.

تعريف القانون الدولي الخاص:

كثرت التعريفات التي وضعت بصدد القانون الدولي الخاص وذلك على المستويين الوطني والدولي، فنجد بعض الفقه يعرفه بأنه ذلك القانون الذي يعنى بتنظيم علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي، وذلك عن طريق تحديد مدى قدرة الأجنبي على التمتع بالحقوق وتمييزه عن الوطني، وتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة والأثار التي تترتبها الأحكام الصادرة في المنازعات التي ينظمها^(١).

وعرف بأنه مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات ذات الطابع الدولي^(٢). وعرف بأنه قانون الحياة الخاصة الدولية^(٣).

ومن الفقه الفرنسي من عرفه بأنه مجموعة القواعد التي تحكم أشخاص القانون الخاص في علاقاتهم الدولية^(٤).

(١) راجع د. فؤاد رياض: الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، ١٩٩٢، ص ٧.

(٢) راجع د. إبراهيم أحمد إبراهيم: مركز الأجانب وتنازع القوانين، ١٩٩٢، ص ١.

(٣) راجع د. هشام صادق: الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، المجلد الأول، منشأة المعارف، ١٩٧٧، ص ٤.

(٤) راجع في ذلك

- BATIFFOL et LAGARDE " droit international prive " 7eme ed . tome I. L. G. D. J. paris. 1981. p.

وكذلك عرف بأنه مجموعة القواعد المطبقة على الأفراد في علاقاتهم الدولية^(١). إلا أنه بالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنها تتناسب مع القانون الدولي الخاص بطبيعته التقليدية، أما وقد تطور هذا القانون بتطور العلاقات الدولية الخاصة ودخلت في إطاره علاقات لم تكن تدرج ضمنه في الماضي، وأصبحت من أعمده الرئيسية مثل عقود الدولة والتحكيم الدولي الخاص، فإنه لابد من إيجاد تعريف يتناسب مع وظيفة القانون الدولي الخاص الجديدة، وهو ما يجعلنا نؤيد من عرفه بأنه " القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي أيا كان أطراف هذه العلاقات، سواء من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون العام"^(٢).

وقد عبر أحد الفقهاء عن التطور الذي حدث للقانون الدولي الخاص بأن هذا القانون لم يعد يعرف بأنه قانون الأشخاص الخاصة، فقد دخلت دائرة اختصاصه موضوعات جديدة من أهمها عقود الدولة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة^(٣).

مصادر القانون الدولي الخاص:

تستمد قواعد القانون الدولي الخاص مصادرها من القانون الداخلي، حيث نجد على سبيل المثال قواعد تنازع القوانين ضمن نصوص القانون المدني، وقواعد تنازع الاختصاص ضمن نصوص قانون المرافعات، أما قواعد الجنسية ومركز الأجانب فنجدتها في الغالب موجودة في قانون خاص بها، ولكن نظراً لأن العلاقات التي يحكمها القانون الدولي الخاص هي علاقات تتعدى حدود الدولة الواحدة، فإنه من المنطقي أن تستقى قواعد هذا القانون من مصادر دولية إضافة إلى المصادر الوطنية، ولذلك تقسم مصادر القانون الدولي الخاص من حيث قوتها في الإلزام إلى مصادر رسمية تتوافر لها صفة الإلزام، ومصادر غير رسمية لا تتوافر لها صفة الإلزام، وإنما يرجع إليها القاضي على سبيل الاستئناس وتسمى بالمصادر التفسيرية^(٤)، وسوف نتعرض لكل منها بالتفصيل على النحو التالي :

أولاً- المصادر الرسمية:

يندرج تحت هذه الطائفة التشريع الذي يصدره المشرع الوطني في الدولة، كما يندرج تحتها العرف أيضاً، وهذان المصدران الرسميان هما في الحقيقة مصدران عامان بالنسبة لمختلف فروع

(١) راجع في ذلك :

- LOUSSOUARN Yvon et BOUREL pierre " droit international prive " 4 eme ed . Dalloz. Paris. P. I.

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجنسية، مركز الأجانب، تنازع القوانين، اختصاص القضاء الدولي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، ٢٠٠١، ص ٢٧.

(٣) راجع في ذلك:

- BERLIN Dominique " le regime juridique international des accords entre Etats et ressortissants d'autre etats " these. 1981. p. 10

(٤) د. محمد السيد عرفة: القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في التنازع الدولي للقوانين، مكتبة العالمية بالمنصورة، ١٩٩٠ - ١٩٩١م، ص ٩.

القانون وليس القانون الدولي الخاص وحده، غير أن الطبيعة الدولية لعلاقات القانون الدولي الخاص أدت إلى وجود مصدر رسمي ثالث لقواعد هذا القانون هو الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وقد أضاف المشرع المصري لهذه المصادر الرسمية مصدراً يرجع إليه القاضي في حالة عدم وجود نص تشريعي أو اتفاقي أو قاعدة عرفية، وقد أطلق المشرع على هذا المصدر اسم مبادئ القانون الدولي الخاص^(١).

١ - التشريع:

هو القوانين المكتوبة التي تصدر عن الإرادة الشارعة والتي يأتزم بها القاضي فيما يعرض عليه من منازعات، ويعتبر التشريع المصدر الأول والأساسي لقواعد القانون الدولي الخاص، فإذا عرض على القاضي الوطني نزاع يحتوى على عنصر أجنبي وجب عليه أن يبحث أولاً عن النص التشريعي الذي يحكم هذا النزاع، فإذا لم يجد نصاً انتقل إلى المصادر الأخرى^(٢).

وقديماً لم تكن هناك أية أهمية للتشريع كمصدر للقانون الدولي الخاص، حيث ظل القضاء قروناً طويلة يعتمد على آراء الفقهاء في حل مسائل تنازع القوانين، ولم يبدأ الاهتمام بوضع قواعد خاصة له إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في أوروبا عندما وضعت قواعد قانونية لحل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص للمسائل المشوبة بعنصر أجنبي، وكيفية تعيين المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في مثل هذه المسائل، أما في الوقت الحاضر فإن القواعد المكونة للقانون الدولي الخاص مكتوبة ولكنها غير مجمعة في مجموعة واحدة^(٣).

وتختلف أهمية التشريع بالنسبة لكل موضوع من موضوعات القانون الدولي الخاص يقوم في إحداها بدور رئيسي بينما يكون دوره محدوداً في موضوع آخر، فبالنسبة للجنسية ونظراً لارتباطها بتكوين عنصر الشعب في الدولة فتستقل الدولة بوضع القواعد التي تنظم اكتسابها وفقدانها، والقانون المعمول به حالياً في مصر هو القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ والصادر في ١٤ يوليو ٢٠٠٤، أما الموطن فتتنظمه المواد من ٤٠ - ٤٣ من القانون المدني بالإضافة إلى عدة قوانين صادرة بشأن تحديد الموطن الخاص^(٤).

وفيما يتعلق بمركز الأجانب فهو لم يلق حظاً كبيراً من التنظيم التشريعي إلا بعد صدور القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ والخاص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر، والمعدل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٦٨

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة السابعة، ١٩٧٢، دار النهضة العربية، ص ١٩.

(٢) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٠.

(٣) د. غالب على الداودى: القانون الدولي الخاص (النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية)، ١٩٧٨، دار الحرية للطباعة، ص ٣٦.

(٤) د. بدر الدين عبد المنعم شوقي: الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري، الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، ١٩٩٣م، ص ١١.

والقانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٠، فهذا القانون والقوانين المعدلة له نظمت الحقوق والواجبات المقررة للأجانب في مصر^(١).

أما فيما يتعلق بتنازع القوانين فإن دور التشريع هو دور حديث إذ لم تتم صياغة قواعد التنازع في تشريع إلا في القرن التاسع عشر، وتم ذلك في التشريع الألماني الصادر سنة ١٨٩٦، أما في القانون المصري فقد كانت قواعد تنازع القوانين متناثرة في تشريعات متفرقة في القانون المدني الأهلي والمختلط ولائحة ترتيب المحاكم المختلطة وكانت قاصرة على مسائل الأحوال الشخصية، ولكن بعد صدور القانون المدني الجديد فقد عالج قواعد تنازع القوانين في المواد من ١٠ - ٢٨ مدني، حيث وضع قواعد إسناد لمسائل الأحوال الشخصية والأموال العينية والعقود والوقائع القانونية، بالإضافة إلى ذلك فقد نص على قواعد أخرى تتعلق بالنظرية العامة لتنازع القوانين كالتكييف والإحالة والدفع بالنظام العام والغش نحو القانون^(٢).

ولم يلق تنازع الاختصاص القضائي الدولي العناية الكافية في غالبية التشريعات إلا في تاريخ حديث نسبياً، وقد بدأ المشرعون يعنون منذ أواخر القرن التاسع عشر وبصفة خاصة خلال القرن العشرين بإرساء القواعد التشريعية الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي للمحاكم وتحديد آثار الأحكام الأجنبية، وهو ما فعله المشرع المصري في قانون المرافعات، حيث أفرد المواد من ٢٨ - ٣٥ والتي تحدد حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية، والمواد من ٢٩٦ - ٣٠١ والتي بينت كيفية وشروط تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية^(٣).

٢ - العرف:

العرف هو مجموعة القواعد القانونية الناتجة عن السلوك المضطرد في مسألة معينة على نحو معين اضطراداً مصحوباً بالاعتقاد بأن هذا السلوك يحمل صفة الإلزام، أو هو العادة التي تتأصل إلى حد الإلزام، فهو يتميز إذن عن العادة وعن مجرد تشابك الحلول بعنصر الإلزام^(٤).

ولا يختلف تعريفه في إطار القانون الدولي الخاص عن التعريف العام السابق ذكره، ويحتل العرف مكان التشريع عند غيابه، وله دور هام كمصدر للقانون الدولي الخاص، وهذا الدور يختلف حسب موضوعات هذا القانون^(٥)، فهو ضعيف في الجنسية، قليل في مركز الأجانب، عظيم في تنازع القوانين، وهو تدرج عكس ما عليه الحال بالنسبة للتشريع، مبناه مدى تحرك عنصر السيادة في

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجنسية، مركز الأجانب، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، ٢٠٠١، ص ١٧.

(٢) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١١.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢١.

(٤) د. عز الدين عبدالله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب)، الطبعة الحادية عشرة، مطبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦، ص ٥٢.

(٥) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٢.

الموضوع، فحيث تزداد أهمية عنصر السيادة تقل أهمية العرف وتزداد أهمية التشريع، كما هو الشأن في الجنسية، وحيث تقل أهمية عنصر السيادة تبقى للعرف أهمية، وإن برز بجواره التشريع، كما هو الشأن في تنازع القوانين، وقد ظلت قواعد تنازع القوانين قروناً طويلة تفيض من العرف، على أن نشاط المشرع في كثير من الدول في ميدان تنازع القوانين قد قلل من أهمية العرف بوصفه مصدراً مباشراً، حيث أخذ المشرع الكثير من قواعده وصاغها في نصوص تشريعية فصار التشريع هو مصدرها المباشر، ومن أمثلة القواعد التي أنشأها العرف في القانون الدولي الخاص قاعدة خضوع شكل العقد لقانون بلد إبرامه، وقاعدة خضوع الميراث في المنقول لقانون موطن المتوفي^(١).

وتجدر ملاحظة أن تشابه القواعد العرفية الوطنية في دول كثيرة لا يعنى وجود عرف دولي، ومع ذلك فإن فريقاً من الفقهاء يرى أن هناك بعض القواعد العرفية الدولية كذلك التي تقضى بوجود حد أدنى من الحقوق يجب على كل دولة عدم النزول عنها عند تحديد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب على أرضها، ومثالها أيضاً القاعدة التي تقرر مزايا وحصانات معينة لرجال السلك الدبلوماسي والقنصلي^(٢).

٣ - مبادئ القانون الدولي الخاص:

تنص المادة ٢٤ من القانون المدني "تتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص" وهو بذلك يعترف بمبادئ القانون الدولي الخاص كأحد المصادر الهامة لهذا القانون، وقد جاء نص المادة ٢٤ مدني بعد أن فرغ المشرع المصري من إيراد النصوص التي تعالج تنازع القوانين، وقد برر المشرع اعتماد هذه المبادئ كأحد مصادر القانون الدولي الخاص عندما ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني "بأن لهذه المبادئ من سمات الدقة والوضوح ما يجعلها تفضل مبادئ القانون الطبيعي بسبب تخصصها في ناحية معينة من نواحي القانون"^(٣).

ويتضح من ذلك أن هذا المصدر الثالث لقواعد القانون الدولي الخاص قاصر على موضوع واحد وهو تنازع القوانين فلم يرد ذكره بالنسبة لبقية موضوعات هذا القانون، ويلاحظ أن نص المادة ٢٤ السابقة قد أحال مباشرة إلى مبادئ القانون الدولي الخاص عند عدم وجود نص تشريعي دون أي إشارة إلى الرجوع إلى العرف، ولكن الأعمال التحضيرية للقانون المدني تقطع بأنه لا يرجع إلى مبادئ القانون الدولي الخاص إلا بعد الرجوع إلى التشريع فإن لم يوجد نص يرجع إلى العرف، ولا يرجع القاضي عند بحثه عن قواعد القانون الدولي الخاص إلى القانون الوطني بحسب، ذلك أن القانون الدولي الخاص في مصر حديث الظهور نسبياً بحيث يتعذر القول بوجود تراث قانوني كاف من المبادئ المهيمنة على هذا الفرع من فروع القانون، فضلاً عن ذلك فالغالبية العظمى من قواعد تنازع القوانين التي طبقتها المحاكم المصرية والتي أخذ بها المشرع قواعد مستمدة من المبادئ التي تبلورت خلال القرون الماضية في المجتمعات التي سبقتنا في هذا المجال، وعلى ذلك فالقاضي المطلوب منه تطبيق

(١) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٥٢.

(٢) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٢، ١٣.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٨.

مبادئ القانون الدولي الخاص سيضطر إلى اللجوء إلى المبادئ السائدة بالنسبة لتنازع القوانين في مختلف الدول في كثير من الأحيان^(١).

ويقصد بمبادئ القانون الدولي الخاص " مجموعة الحلول التي تستخلص من الأصول الفنية لمادة التنازع مقرونة أحياناً باعتبارات سياسية " ومثال ذلك وضع المشرع قاعدة إسناد خاصة بحالة الأشخاص وأهليتهم إذ تخضعان لقانون الجنسية، ولم ينص على قاعدة إسناد خاصة بالنسب وقد استخلص الفقه من نصوص قانون المرافعات قاعدة أن النسب يسرى عليه قانون جنسية من يراد الانتساب إليه سواء كان الأب أو الأم. وقد استعان الفقه بمبادئ القانون الدولي الخاص للتوصل إلى إخضاع آثار النسب لنفس القانون الذي يحكم نشأته أي قانون جنسية من يراد الانتساب إليه، ومن خلال تلك المبادئ يتضح لنا أن المشرع قد أعطى القاضي وسيلة مرنة لمسيرة تطور الأفكار في مجال تنازع القوانين فيمكنه أن يتوصل لمبادئ القانون الدولي الخاص من خلال القانون المقارن وذلك بالرجوع إلى المبادئ السائدة بالنسبة لتنازع القوانين في مختلف الدول^(٢).

٤ - المعاهدات الدولية:

المعاهدات نوعان : زوجية وجماعية، والأولى تتم بين دولتين، بينما تتم الثانية بين ثلاث دول فأكثر، على أن من الاتفاقات الجماعية ما يطلق عليه اتحاد تتفق به الدول المشتركة على اتباع اتجاه معين في موضوع معين كحماية الحقوق المدنية^(٣).

ولما كانت مسائل القانون الدولي الخاص ذات صبغة دولية، كان من الضروري أن تلجأ الدول إلى المعاهدات للاتفاق على ما ترى الاتفاق عليه من هذه المسائل، وكثيراً ما لجأت الدول فعلاً إلى هذه الوسيلة لمعالجة مختلف موضوعات القانون الدولي الخاص، وإن اختلف دورها في هذه الموضوعات، حيث تحرص الدول دائماً في مجال الجنسية على عدم التقيد في شأنها بمعاهدات دولية إلا في أضيق الحدود، حيث إن الأمر يتعلق هنا بركن من أركان الدولة وهو شعبها، وأكثر ما يكون الالتجاء إلى المعاهدات في مجال الجنسية في حالة تنازع الجنسيات الإيجابية أو السلبية^(٤).

وفي مجال مركز الأجانب تزداد أهمية المعاهدات الدولية، حيث إن تنظيم مركز الأجانب هو أمر يهم المجتمع الدولي، وفي مجال تنازع القوانين فإن المعاهدات تستخدم كوسيلة للقضاء على ظاهرة التنازع، وذلك بتوحيد قواعد الإسناد في الدول المختلفة كأن تتفق الدول مثلاً على أن الأحوال الشخصية يسرى عليها قانون الجنسية بدلاً من الموطن، وقد يتم استخدام المعاهدة كأداة لتوحيد القواعد

(١) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩.

د. بدر الدين عبدالمنعم شوقي: المرجع السابق، ص ١٣.

(٢) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٣.

(٣) د. جمال محمود الكردي: محاضرات في القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للقانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ١٩٩٥-١٩٩٦، ص ١٩.

(٤) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٥٦.

الموضوعية في بعض مسائل القانون الخاص، بحيث يرجع القاضي إلى قاعدة موضوعية يطبقها على النزاع مباشرة دون اللجوء لقاعدة الإسناد^(١).

ومن الاتفاقات الجماعية المعقودة بين الدول في موضوعات القانون الدولي الخاص، نذكر اتفاقيتي لاهاي لعامي ١٩٠٢، ١٩٠٥ بصدد الزواج والتفريق والطلاق ووصاية الصغار ووسن الرشد وأصول المرافعات، وكذلك اتفاقية لوزان الموقعة في ٢٤ تموز ١٩٢٣ بصدد الإقامة والصلاحية القضائية، وقد تضمنت الاتفاقية الأخيرة عدة نصوص متعلقة بالمركز القانوني للأجانب وتنازع القوانين^(٢).

ونلاحظ أن المعاهدة إذا ما استوفت شروط نفاذها فإنها تعتبر جزءاً من قوانين الدولة التي وقعتها، ولكن إذا حدث تعارض بين القواعد التي تقررها المعاهدة والقواعد التي يقررها المشرع الداخلي للدولة فهل تعتبر أحكام المعاهدة ناسخة لأحكام القانون الداخلي السابقة لإبرامها بالنظر لصبغتها الدولية؟ وهل أن المعاهدة تلغي ما تعارض مع أحكامها من أحكام القوانين الداخلية السابقة واللاحقة لإبرامها؟ هنا تجب التفرقة بين حالة إذا تعارضت المعاهدة مع تشريع سابق على نفاذها وحالة ما إذا تعارضت المعاهدة مع تشريع لاحق عليها.

أولاً: تعارض المعاهدة مع تشريع سابق، وفي هذه الحالة تطبق نصوص المعاهدة دون نصوص التشريع الداخلي، وذلك إما على اعتبار أن المعاهدة أقوى من التشريع بالنظر إلى صبغتها الدولية، وإما على اعتبار أن نصوص المعاهدة وهي جزء من التشريع الداخلي تتسخ نسخاً ضمناً ما يتعارض معها من نصوص تشريعية سابقة^(٣)، أما إذا كان التعارض بين المعاهدة ودستور الدولة فيفضل الدستور ويمتنع القاضي عن تطبيق قواعد المعاهدة التي تخالف الدستور^(٤).

ثانياً: تعارض المعاهدة مع تشريع لاحق، إذا كان التعارض ضمناً تكون المعاهدة أقوى من القانون الداخلي بالنظر إلى صبغتها الدولية، ولأنه لا يجوز للدولة أن تعدل أو تلغي أحكام المعاهدة بإرادتها المنفردة، وإنما يجوز لها ذلك بعد موافقة بقية أطراف المعاهدة من الدول التي وقعتها معها وإلا تكون عرضة للمسئولية الدولية طبقاً لقواعد القانون الدولي العام، أما إذا كان التعارض صريحاً فإن الحاكم الوطني لا يستطيع أن يطبع غير أوامر ونواهي المشرع الوطني في دولته ولا يطبق غير قوانينه الوطنية في هذه الحالة، لأنها لاحقة لانعقاد المعاهدة ما لم يصدر قانون داخلي آخر يزيل هذا التعارض،

(١) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٤.

(٢) د. غالب علي الداودي: المرجع السابق، ص ٤٤.

(٣) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٧٣.

(٤) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٥.

كما هو السائد الآن في أمريكا وفنزويلا وكولومبيا وبريطانيا^(١)، أما إذا كان التشريع اللاحق هو الدستور فيفضل الدستور أيضاً في هذه الحالة^(٢).

أما في الحالة التي يصدر فيها قانون آخر بإزالة التعارض بين التشريع الجديد اللاحق للمعاهدة وبين المعاهدة، أو أن الدستور كان ينص على سمو المعاهدة على القوانين الداخلية السابقة واللاحقة لانعقادها، فإن الغلبة حينذاك تكون لأحكام المعاهدة^(٣)، هذا في إطار القضاء الداخلي، أما في إطار القضاء الدولي فيذهب إلى أنه إذا ما تعارضت قاعدة منصوص عليها في معاهدة دولية مع قاعدة وطنية فإن القاعدة الاتفاقية تعلو على القاعدة الوطنية، حتى ولو كانت دستور الدولة ذاته، فلا يجوز للدولة أن تحتج بمخالفة المعاهدة التي وقعت لقواعدها الدستورية للتخلص من التزاماتها الدولية الناشئة عن المعاهدة^(٤)، وهذا ما قرره المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها الاستشاري الصادر في ٤ فبراير ١٩٣٢ بخصوص معاملة المواطنين البولنديين المقيمين في مدينة دانزج^(٥).

ثانياً- المصادر غير الرسمية:

ويقتصر الحديث في هذا المجال على كل من القضاء والفقه:

١ - القضاء:

يقصد بالقضاء كمصدر للقانون الدولي الخاص مجموعة الحلول التي استقرت عليها أحكام المحاكم بحيث تكون اتجاهاً واضحاً في مسألة معينة، وهو مصدر تفسيري لقواعد القانون الدولي الخاص شأنه في ذلك شأن سائر فروع القانون، ويختلف الدور الذي يقوم به القضاء باختلاف الدول. فمن الدول ما يقوم القضاء فيها بدور تكوين القاعدة القانونية كالدول المتأثرة بالنظام الأنجلوسكسوني والتي يعرف قانونها باسم القانون القضائي وهذه الدول تأخذ بمبدأ حجية السوابق القضائية وموداه أن السابقة القضائية تتمتع بقوة ملزمة، فالقاضي المطروح عليه النزاع يتعين عليه البحث عن الأحكام السابق صدورها في المنازعات المماثلة، فإذا تبين له وجود حكم قضائي سابق تعين عليه اتباع نفس المبدأ في النزاع المطروح أمامه، ويعتبر القضاء مصدراً رسمياً للقواعد القانونية في هذه الدول، أما في الدول خارج دائرة النظام الأنجلوأمريكي ومنها مصر، فلا يترتب على الحكم القضائي أي أثر ملزم بالنسبة لغير الحالة الصادر بشأنها الحكم، فلا يقيد الحكم الصادر القضاء فيما يعرض عليه من منازعات مماثلة في المستقبل، ومن ثم فالقاضي في هذا النظام لا يخلق قاعدة قانونية، بل إن دوره لا يتعدى تطبيقها وتفسيرها وتتنحصر أهمية القضاء حينئذ كمصدر للقانون في الدور

(١) د. غالب على الداودي: المرجع السابق، ص ٤٦، ٤٧.

د. حسن الجبلي: الوجيز في القانون الدولي العام، ص ١١٩.

د. شاب توما: شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، ٦٦، ٦٧.

(٢) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٥.

(٣) د. غالب على الداودي: المرجع السابق، ص ٤٧.

(٤) د. جمال محمود الكردي: المرجع السابق، ص ٣٩.

(٥) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٥.

التفسير الذي يلعبه، وتزداد أهمية القضاء كمصدر تفسيري بالنسبة للقاعدة العرفية حيث إنه كثيراً ما يكون مضمون هذه القاعدة مفتقراً إلى التحديد فيتكفل القضاء بهذه المهمة^(١).

وتلعب الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية ومحاكم التحكيم الدولي دوراً هاماً كأحد مصادر القانون الدولي الخاص^(٢)، وقد تعرضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي، والتي حلت محلها محكمة العدل الدولية منذ سنة ١٩٤٩، لمجموعة أحكام بصدد مسائل القانون الدولي الخاص أحدها خاص بالجنسية، وهو الحكم الصادر بتاريخ ٧ فبراير ١٩٢٣ في النزاع بين فرنسا وإنجلترا بخصوص المراسيم التي أصدرتها الحكومة الفرنسية بشأن الجنسية في تونس والمغرب، والذي ورد به مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية دون قيد، اللهم إلا ما تفرضه عليها الاتفاقات الدولية^(٣)، والآخر خاص بمركز الأجانب وهو الحكم الصادر بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٢٦، الذي قضت فيه بأن نزاع ملكية الأجنبي دون تعويض عادل يخالف القانون الدولي، وحكما أن أحران خاصان بتنازع القوانين، وقد صدرا في ١٢ يوليو ١٩٢٩ في المنازعات المتعلقة بالقروض التي عقدتها في فرنسا الحكومتان اليوغوسلافية والبرازيلية، والذي جاء به أن القانون الذي يحكم العقد تعينه القواعد المعروفة باسم قواعد القانون الدولي الخاص أو قواعد تنازع القوانين التي تكون جزءاً من القانون الداخلي^(٤).

وفي ٦ أبريل ١٩٥٥ أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يتعلق بالجنسية في نزاع بين دولة ليختنشتاين ودولة جواتيمالا أقرت فيه بأنه ليس للدولة الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية على فرد تعدد من وطنيتها إذا كانت رابطة الجنسية بينهما غير فعلية بصفة كافية^(٥).

وقد شكلت أحكام محاكم التحكيم المختلطة الصادرة طبقاً لمعاهدات الصلح التي أبرمت عقب الحرب العالمية الأولى للفصل في المنازعات الخاصة بين التابعين للدول الأعداء، والتي أتيحت لها فرصة الفصل في الكثير من مشاكل تنازع القوانين وخاصة المنازعات الناشئة بسبب عدم تنفيذ العقود مصدراً من مصادر القانون الدولي الخاص في هذا الإطار^(٦).

٢ - الفقه:

تمثل آراء الفقهاء المصدر المهم للقانون الدولي الخاص منذ القرن الثالث عشر، ويعود لهم الفضل في صوغ النظريات وتقديم الحلول لمعظم مشاكل القانون الدولي الخاص، وتفيد الآراء الفقهية المشرع والقاضي معاً، إذ يضطر المشرع نتيجة لهذه الآراء الفقهية إلى تسريعها ويستعين بالفقهاء

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٨، ٣٩.

(٢) د. حامد زكي: أصول القانون الدولي الخاص، فقرة ٤١.

(٣) الحكم منشور في

- J. de dr. int. 1928 . p. 4304

(٤) الحكمان منشوران في

- J. de dr. int. 1929. p. 572

(٥) د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص ٨١.

(٦) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٦.

لوضع مسودات القوانين، والمحاكم في كثير من الأحيان تجد نفسها ملزمة باعتناق هذه الآراء، لاسيما المتواترة والمتفق عليها عند معظم فقهاء العالم^(١).

ولا يشترك الفقه بصفة مباشرة في خلق القواعد القانونية، فأراء الفقهاء لا تتمتع بأية قوة ملزمة، ولكن هذا لا ينفي مالها من دور هام في تفسير القاعدة القانونية وتحديدتها، ومن الملاحظ أن الفقه لم يول مختلف موضوعات القانون الدولي الخاص نفس القدر من العناية، فبالنسبة لقواعد تنازع القوانين نجد أن الفقه قد تبوأ مكانة خاصة، فإليه يرجع الفضل في إبراز المشكلة ووضع الكثير من حلولها منذ القرن الثالث عشر، في حين أنه لم يعن بإرساء أسس قواعد تنازع الاختصاص القضائي، وذلك بالرغم من أن مشكلة تنازع الاختصاص قد سبقت في ظهورها مشكلة تنازع القوانين، كذلك يمكننا القول بأن دور الفقه في تطور قواعد الجنسية والقواعد المنظمة لمركز الأجانب أدنى من الدور الذي قام به بالنسبة لقواعد تنازع القوانين ولا يتناسب مع أهمية هذين الموضوعين^(٢).

وقد برزت مشكلة تنازع القوانين على يد بعض الفقهاء الإيطاليين في تعليقهم على نصوص القانون الروماني في القرن الثالث عشر، وتولى هذه المشكلة بعنايته بعدهم في القرون الوسطى الشراح الفرنسيون ثم الهولنديون^(٣).

ويمكننا أن نذكر من المجهودات الفقهية في إطار القانون الدولي الخاص إصدار موسوعة القانون الدولي التي اشترك فيها طائفة من العلماء الفرنسيين والأجانب، وكذلك أعمال معهد القانون الدولي الذي أنشئ بمدينة جاند ببلجيكا سنة ١٨٧٣، ويلقى فقهاء القانون الدولي الخاص من مختلف الدول محاضرات سنوية في أكاديمية القانون الدولي بلاهاي بهولندا التي أنشئت سنة ١٩٢٣^(٤).

ومن الخصائص المميزة لفقه القانون الدولي الخاص ميله دائماً إلى أسلوب المقارنة، حيث لا يقتصر الباحث على الرجوع إلى الفقه الوطني فحسب بل كثيراً ما تدعو طبيعة المسائل محل البحث إلى الرجوع إلى الفقه الأجنبي كذلك وهو ما يلاحظ بشكل متزايد لدى فقهاء القانون الدولي الخاص^(٥).

(١) د. مدوح عبدالكريم حافظ: القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، باب تمهيدي، الجنسية، المواطن، حالة الأجانب، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، وتنفيذ الأحكام المدنية الأجنبية، الطبعة الثانية، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٧، ص ٢٢، ٢٣.

(٢) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٠، ٤١.

د. بدر الدين عبدالمنعم شوقي: المرجع السابق، ص ٢٣، ٢٤.

د. جمال محمود الكردي: المرجع السابق، ص ٥٢.

(٣) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، ١٩٨٣، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص ٥٨، ٥٩.

(٤) د. محمد السيد عرفة: المرجع السابق، ص ١٨.

(٥) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤١.

طبيعة القانون الدولي الخاص:

نظراً لتعدد موضوعات القانون الدولي الخاص والذي أصبح مع تطوره يحتوى على موضوعات لا يجمع بينها رابط مثلما كان عليه الحال في ظل وضعه التقليدي المعقد أدى ذلك إلى إثارة الجدل بين الفقهاء في تحديد أو إعطاء وصف عام لطبيعة قواعده، وأهم ما أثير الجدل حوله يتعلق بمدى اعتباره من عداد القانون الدولي أم من القانون الداخلي وكذلك مدى اعتباره فرع من فروع القانون العام أم فرع من فروع القانون الخاص وهذا ما سنبحثه فيما يلي:

أولاً- هل القانون الدولي الخاص دولي حقاً؟

ذهب اتجاه فقهي إلى القول بأن القانون الدولي الخاص هو قانون داخلي ذو صفة وطنية استناداً إلى أن هذا القانون ينظم العلاقات الخاصة الدولية عبر الحدود، والمستفيد دائماً من تلك العلاقة هم الأفراد وليس الدول، إضافة إلى أن معظم مصادر القانون الدولي الخاص وطنية بحثة وذلك بسبب عدم وجود تنظيم سياسي دولي يعلو الدول وحتى المعاهدة لا تعدو أن تكون تشريع داخلي^(١).

علاوة على أن المشكلات التي يعالجها القانون الدولي الخاص تخص كل دولة وغالباً ما تكون حلولها حلولاً وطنية، فلكل دولة قانونها الدولي الخاص، أضف على ذلك أن بعض الدول أصدرت تشريعاً قائماً بذاته يضم كل قواعد القانون الدولي الخاص مثل بولونيا وتشيكوسلوفاكيا قبل تفككها^(٢).

في حين ذهب اتجاه فقهي آخر إلى تقرير أن القانون الدولي الخاص هو قانون دولي بحق، لأن القانون الدولي إما أن ينظم علاقات الدول والمنظمات الدولية وهو القانون الدولي العام، وقد ينظم علاقات الأفراد عندما تكون آثارها خارج حدود الدولة الواحدة وهذا هو القانون الدولي الخاص، ويحكم القانون الدولي الخاص علاقات الدول بصورة غير مباشرة لأنه يسعى إلى تحديد سلطان قانون كل دولة من الدول^(٣).

أضف إلى ذلك أن أهم موضوعات القانون الدولي الخاص وهي تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي يعالجان تنازعا بين السيادة المتعلقة بالدول المختلفة للمجتمع الدولي^(٤).

(١) د . ممدوح عبدالكريم حافظ: القانون الدولي الخاص وفق القانونيين العراقي والمقارن، الطبعة الثانية، ١٩٧٧، دار الحرية للطباعة، بغداد، ص ٢٥.

(٢) د . عز الدين عبدالله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، الطبعة الحادية عشر، ١٩٨٦، الهيئة المصرية للكتاب، ص ٩٣.

(٣) د . ممدوح عبدالكريم حافظ: المرجع السابق، ص ٢٥.

(٤) د . عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٢.

ثانياً- هل القانون الدولي الخاص خاص حقاً؟

ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون العام، استناداً إلى أن الموضوعات التي يعالجها هذا القانون تقترب كثيراً من فروع القانون العام، فالجنسية مثلاً هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة تخضع للاعتبارات العامة والسياسية في الدولة، وهي بذلك تحدد ركن من أركان الدولة وهو الشعب وبذلك فهي من فروع القانون العام^(١)، وكذلك مركز الأجانب والذي يحدد حقوق الأجانب وواجباتهم وفيها الحقوق العامة والواجبات العامة ولذلك فهو من فروع القانون العام، وكذلك قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين والتي تحدد حدود اختصاص السلطة التشريعية الوطنية والاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية من فروع القانون العام.

أما قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية فإن محاكم الدولة غير ملزمة بتنفيذ أحكام محاكم دول أخرى، وقد يمثل تنفيذ تلك الأحكام خروجاً على قوانينها، وقد يرجع فيها إلى مبدأ المعاملة بالمثل، والمعاهدات الدولية، والطرق الدبلوماسية، وكلها أمور متعلقة بالقانون العام^(٢).

وقد ذهب الرأي الفقهي الراجح إلى إدخال القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون الخاص، وذلك استناداً إلى نوع العلاقات القانونية التي نظمها هذا القانون سواء أكانت علاقات مدنية أو تجارية^(٣)، وأن غاية ما يبغيه هذا القانون هو تنظيم علاقات الأفراد الخاصة عبر الحدود، وأن موضوعاته لا تؤثر على سيادة الدولة بشئ لأن جميع القوانين لا يمكن أن تطبق في الدولة إلا بواسطة الدولة لا عليها، وفي الحالات التي يطبق فيها القانون الأجنبي فإن القانون الوطني هو الذي يحدد متى يطبق وكيفية ذلك التطبيق وهذه كلها أمور لا تحدث إلا بإرادة الدولة^(٤).

ومن جانبنا نسير مع الاتجاه الذي يضيف على القانون الدولي الخاص صفتي الدولية والخاصة، وذلك لسلامة الحجج التي تدعم ذلك والتي استند عليها القائلون بأن القانون الدولي الخاص دولي حقاً كما أنه قانون خاص حقاً.

موضوعات القانون الدولي الخاص:

في إطار التعرف على الموضوعات التي يحتويها القانون الدولي الخاص، نضرب مثالا بفرنسي باع أموالاً منقولة في مصر إلى إنجليزي، وثار بينهما نزاع بصدد تلك الأموال، فيجب على المحكمة أولاً أن تفصل في جنسية طرفي النزاع وأنهما ليسا بمصريين، ثم تبحث بعد ذلك في مدى حق

(١) راجع

- LOUSSOUARN et BOUREL . op. cit. p. 41 .

(٢) د . ممدوح عبدالكريم حافظ: المرجع السابق، ص ٢٧..

(٣) راجع في ذلك

_ LOUSSOUARN et BOUREL . op. cit. p.41 , 42 .

(٤) راجع د. ممدوح عبدالكريم حافظ: المرجع السابق، ص ٢٧.

الأجنبي في البيع في مصر وذلك في قواعد مركز الأجانب، ويجب على المحكمة أن تفصل أيضاً في مدى اختصاصها بنظر النزاع وهو ما تحدده قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وبعد ذلك لابد وأن تحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع وهو ما تحدده قواعد تنازع القوانين، هل يجب تطبيق القانون المصري؟ أم القانون الفرنسي؟ أم القانون الإنجليزي؟

وإذا ما انتهت المحكمة المصرية من إصدار الحكم، فإنه يجب البحث في كيفية تنفيذ الحكم خارج مصر إذا ما طلب تنفيذه هناك، وما هي الإجراءات الواجبة الإلتباع في تلك الحالة؟ هذا ما تحدده قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية.

ومن خلال هذا المثال يتضح لنا أن القانون الدولي يتضمن خمسة موضوعات رئيسية هي الجنسية - والتي يتفرع عنها فكرة الموطن في العلاقات الخاصة الدولية - بالإضافة إلى مركز الأجانب والاختصاص القضائي الدولي وتنازع القوانين وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وبالنظر إلى التطور الذي طرأ على القانون الدولي الخاص فإننا نجد أنه أصبح محتوياً على عنصر رئيسي آخر وهو التحكيم الدولي الخاص، وذلك في الحالة التي يتفق فيها الطرفان على اللجوء للتحكيم بدلاً من اللجوء للقضاء في إحدى المنازعات، والتي قد تتشابه مع المنازعة السابق الحديث عنها في المثال التوضيحي.

وبذلك فإن القانون الدولي الخاص يحتوى على سبعة موضوعات رئيسية هي:

١ - الجنسية.

٢ - الموطن في العلاقات الدولية الخاصة.

٣ - مركز الأجانب.

٤ - الاختصاص القضائي الدولي.

٥ - تنازع القوانين.

٦ - تنفيذ الأحكام الأجنبية.

٧ - التحكيم الدولي الخاص.

تلك الموضوعات هي موضوع الدراسة في هذا المقرر على الترتيب السابق نظراً لما يلي:

أولاً: لا خلاف على أسبقية المرحلة التمهيدية في العلاقات الدولية، والتي تنظمها قواعد الجنسية والموطن ومركز الأجانب، حيث إنها تنصب على دراسة وضع أطراف العلاقات ذات العنصر الأجنبي أو بعضهم، فقواعد الجنسية تبين مدى تمتع أطراف الدعوى بالجنسية الوطنية من عدمه، فإذا كان أحدهم أو كلهم أجنبياً تبين لنا قواعد مركز الأجانب مدى تحمل هؤلاء الأطراف بالالتزامات واكتسابهم للحقوق.

ثانياً: لا شك بأسبقية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لقواعد تنازع القوانين، حيث إن أول خطوة يجب البدء ببحثها هي مرحلة تحديد المحكمة المختصة بحل المشكلة قبل مرحلة تنظيمها قانونياً، فالمحكمة تبدأ بلا شك بتحديد اختصاصها بحل النزاع قبل أن تنتقل إلى تحديد القواعد التي ستطبق على النزاع.

ثالثاً: تأتي قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية أو الآثار الدولية للأحكام كمرحلة أخيرة من مرحلة الحصول على الحماية القضائية، ويعقبها دراسة التحكيم الدولي الخاص باعتباره بديلاً عن الثلاث مراحل الأخيرة والخاصة بالاختصاص القضائي وتنازع القوانين والآثار الدولية للأحكام.

— — —

القسم الأول

الجنسية

القسم الأول

الجنسية

تمهيد:

يتكون المجتمع الدولي من مجموعة من الدول لكل منها ثلاثة مكونات رئيسية: الشعب والإقليم والسلطة ذات السيادة، ولما كان عنصر الشعب يمثل العنصر الفاعل في تلك الدولة (إذ ما فائدة وجود الإقليم إذا لم يوجد الشعب الذي يعمره، وعلى من ستمارس السلطة إذا لم يوجد هذا الشعب)، ولما كان العالم لم يصل بعد إلى تحقيق فكرة الدولة العالمية، لذلك فلقد كان ضرورياً أن يصبح لكل دولة جنسية تميز شعبها عن شعوب الدول الأخرى، ومن هنا استمدت الجنسية أهميتها، وأصبحت أهم الموضوعات في إطار العلاقات الدولية الخاصة، وفي الأعم الأغلب من الأحوال تدرس كأول هذه الموضوعات، وسوف نتناول ذلك الموضوع من خلال بابين: أحدهما متعلق بالمبادئ العامة التي تحكم الجنسية، والآخر متعلق بأحكام الجنسية المصرية المنظمة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤م.

— — —

الباب الأول

المبادئ العامة للجنسية

= = =

في إطار المبادئ العامة للجنسية سوف نتعرض في الفصل الأول لماهية الجنسية، وفي الفصل الثاني نعرض لعناصر رابطة الجنسية، ونعقبه بالتعرض لمبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها وذلك في إطار الفصل الثالث، وسيكون الحديث في الفصلين الرابع والخامس متعلقاً باكتساب الجنسية وفقدانها، ونعقبه بالتعرض لمشاكل الجنسية وهو موضوع الفصل السادس والأخير من هذا الباب :

الفصل الأول: ماهية الجنسية.

الفصل الثاني: عناصر رابطة الجنسية.

الفصل الثالث: مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها.

الفصل الرابع: اكتساب الجنسية.

الفصل الخامس: فقد الجنسية.

الفصل السادس: مشاكل الجنسية.

الفصل الأول

ماهية الجنسية

= =

المبحث الأول

تعريف الجنسية

تتباين آراء فقهاء القانون الدولي الخاص بصدد تعريف الجنسية، حيث يعرفها البعض بأنها "الانتماء القانوني لشخص نحو الشعب المكون لدولة معينة"^(١) وقد انتقد هذا التعريف على اعتبار أنه يتجاهل تأثير العنصر السياسي على الجنسية مع أن تلك الاعتبارات هي المحرك الأول لتنظيم الجنسية^(٢).

ويعرفها آخرون بأنها "العلاقة السياسية بين شخص ودولة ما"^(٣).

وقد انتقد هذا التعريف أيضاً على اعتبار أنه على عكس التعريف السابق قد ركز على العنصر السياسي وتجاهل العنصر القانوني، مع أن التعريف السليم لا بد أن يحتوى على كل من العنصرين^(٤).

ومن الفقه المصري يعرفها البعض بأنها "المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي والذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها"^(٥)، في حين عرفها البعض الآخر بأنها "الصلة القانونية التي تربط فرد ما بدولة معينة"^(٦).

(١) من القائلين بهذا التعريف

- TERRE Francois : " réflexions sur la notion de nationalité " Revue critique de droit international privé – 1975 – p.198 .

- BATIFFOL et LAGARDE : op. cit . p. 60 .

حيث جاء تعريفه كالتالي :

" L'appartenance juridique d'une personne a la population constitutive d'un état .

(٢) د. أشرف وفا محمد: المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن والقانون المصري، الطبعة الأولى، ١٩٩٨، ص ١٤.

(٣) يقول بهذا التعريف

- NIBOYET (J.P) " Traite de droit international prive francais deuxieme edition – tome I – Recueil sirey paris – 1947 – p. 77 .

(٤) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ١٤.

(٥) انظر .. د. هشام صادق: الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، المجلد الأول، منشأة المعارف، ١٩٧٧، ص ١٩.

(٦) د. أحمد قسنت الجداوي: مبادئ القانون الدولي الخاص، ١٩٨٨، ص ١٩.

وفي محاولة للمزج بين كل من الاعتبارين القانوني والسياسي في تعريف الجنسية، فقد عرفها بعض الفقه الفرنسي بأنها " الانتماء القانوني والسياسي لشخص معين نحو الشعب المكون لدولة معينة"^(١).

ومن الفقه المصري من وضع تعريفاً جامعاً لفكرة الجنسية بتقرير أن " الجنسية صفة تلحق الفرد ذات طبيعة سياسية وقانونية تربط الفرد بدولة معينة وبمقتضاها يتم التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي"^(٢).

المبحث الثاني

أهمية الجنسية

لتحديد الجنسية أهمية عظمى من الناحيتين السياسية والقانونية، فمن الناحية السياسية نجد أن الوطني فقط هو الذي يملك حق مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقصر الدولة التمتع بها على المواطنين دون الأجانب الموجودين داخل إقليم تلك الدولة مثل حق الدخول والخروج منها دون قيد^(٣)، كذلك يتمتع الوطنيون بحماية دولهم أينما وجدوا، وهو ما يحدث عندما تسارع الدولة بالتدخل دبلوماسياً في حالة إذا ما لحق ضرر بأحد مواطنيها في إحدى الدول الأخرى وذلك للحصول على التعويض المناسب، وكذلك فإن الدولة لا تستخدم سلطتها في الإبعاد إلا بالنسبة للأجانب دون الوطنيين^(٤)، وفي المقابل تلزم الدولة مواطنيها بمجموعة من الالتزامات أهمها أداء الخدمة العسكرية، أما الأجانب فلا يلتزموا بتلك الالتزامات وذلك لكونهم لا يتمتعون بالحقوق السابق الحديث عنها.

أما من الناحية القانونية فنجد أن الجنسية لها أهمية بالغة، وذلك بالنظر إلى القانون الواجب التطبيق في كثير من المسائل المثارة في إطار تنازع القوانين، والذي يكون في كثير من الأحوال هو القانون الشخصي للفرد أي قانون الدولة التي يحمل جنسيتها^(٥).

(١) راجع في ذلك ..

- LAGARDE paul " la nationalite francaise " , deuxieme edition – Dalloz – paris – 1989 –p. 1 .

- PIGEONNIERE (paul lerebour) " _precis de droit international prive_ deuxieme edition , Dalloz . paris , 1933 . p. 43 .

(٢) د. عكاشة محمد عبدالعال: أحكام الجنسية المصرية، دراسة مقارنة، ١٩٩٣، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص ١٤.

(٣) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ١٥.

(٤) د. عوض الله شبية الحمد السيد، د. خالد رافت أحمد: دروس في القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، ٢٠٠٦، ص ٨٨.

(٥) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ١٥.

المبحث الثالث

طبيعة رابطة الجنسية

اختلف الفقه على اتجاهين فيما يتعلق بتحديد طبيعة رابطة الجنسية، فذهب الاتجاه الأول إلى إضفاء الطابع التعاقدى على هذه الرابطة، وذهب الاتجاه الثانى إلى إضفاء الطابع التنظيمى عليها، وفي ذلك تفصيل على النحو التالى:

الاتجاه الأول- الطابع التعاقدى لرابطة الجنسية:

يستند هذا الاتجاه على فكرة العقد الاجتماعى التي قال بها الفقيه الفرنسى "جان جاك روسو" حيث أن الفقيه الفرنسى "فايس" قد اعتمد على فكرة التراضى النابع عن العقد الاجتماعى كأساس لتحليل رابطة الجنسية التي تربط الفرد بالدولة، وتوصل إلى أن رابطة الجنسية تعود إلى عقد تبادلى بين الفرد والدولة^(١).

هذا العقد التبادلى ينتج عن اتحاد إرادتين هما: إرادة الفرد من ناحية وإرادة الدولة من ناحية أخرى، ويعبر الفرد عن إرادته بأحدى صور ثلاث، أولها الإرادة الصريحة وذلك عن طريق طلب التجنس بجنسية دولة ما إذا ما توافرت فيه شروط هذا التجنس، وثانيها الإرادة الضمنية وذلك في حالة اكتساب الجنسية بالزواج، وهو ما يحدث في حالة عدم اعتراض المرأة على الدخول في جنسية زوجها إذا ما أعطاهها تشريع تلك الجنسية الحق في ذلك، وثالثها الإرادة المفترضة وذلك بالنسبة للجنسية التي تثبت للشخص فور ميلاده، حيث إن المولود لا أهلية له ولا يتصور أن يكون له إرادة في اكتساب الجنسية عند الميلاد، فيفترض في هذه الحالة أن إرادة الطفل كانت ستتجه إلى اختيار هذه الجنسية لو أمكنه التعبير عن إرادته^(٢).

أما الدولة فتعبر عن إرادتها في هذا العقد من خلال صورتين: الأولى وهى الشكل العام حيث تحدد سلفا الشروط اللازمة لاكتساب جنسيتها، والثانية وهى الشكل الخاص وذلك في حالات اكتساب الجنسية اللاحقة أو الطارئة، حيث تحدد الدولة الشروط التي تخول من تتوافر فيه أن يكتسب جنسيتها بالرغم من أنه قد يكون متمتعاً بجنسية دولة أخرى^(٣).

(١) راجع في ذلك ..

- WEISS " Manuel de droit international prive " 9 ed . p. 2 .

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد: المرجع السابق، ص ١٣١، ١٣٢.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٥.

د. عوض الله شيبه الحمد: المرجع السابق ، ص ١٣٢.

ويترتب على هذا العقد مجموعة من الالتزامات والحقوق لكل من طرفيه، حيث تلتزم الدولة بحماية أفرادها في الداخل والخارج وتمنحهم حقوقهم السياسية والمدنية، على أن يلتزم الأفراد باحترام الدولة وقوانينها، والتحمل بالأعباء والتكاليف التي تفرضها عليهم كأداء الخدمة العسكرية ودفع الضريبة^(١).

وعلى الرغم من استناد تلك النظرية على فكرة العقد الاجتماعي ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أن هذه النظرية لم تسد في العصر الحديث، حيث أن فكرة العقد في القانون الخاص تستلزم وجود توازن في إرادة المتعاقدين وهو ما لا يتحقق في هذا الفرض، لأن الفرد لا يمكنه أن يتعاقد مع الدولة للحصول على جنسيتها في أي وقت يريد لأن الدولة تستقل بتقدير ما إذا كانت ستمنح جنسيتها للفرد أم لا؟ مبتغية في ذلك تحقيق مصلحتها، كما أن فكرة العقد تستلزم أن يكون الدخول فيها والخروج منها طبقاً لإرادة الطرفين، وهو ما لا يتحقق في هذا الفرض أيضاً، حيث إن الفرد قد يدخل في جنسية الدولة وقد يخرج منها دون توقف على إرادته^(٢).

ونظراً لما وجه لهذه النظرية من نقد فقد تركها الفقه واتجه إلى النظرية الثانية وفيها قرر الطابع التنظيمي لرابطة الجنسية.

الاتجاه الثاني - الطابع التنظيمي لرابطة الجنسية:

يذهب الفقه الحديث إلى أن الدولة هي التي تنفرد بتحديد ركن الشعب فيها طبقاً لمصالحها الجوهرية، وبذلك فإن الجنسية وثيقة الصلة بكيان الدولة ولا يصح أن تترك لمبدأ سلطان الإرادة الذي تكون الدولة فيه على قدم من المساواة مع الفرد، وطبقاً لذلك يصبح دور الفرد في مجال الجنسية قاصراً على الدخول فيها متى توافرت فيه الشروط التي تتطلبها الدولة، وهو ما أصبح معه الجنسية رابطة تنظيمية لا تعاقدية^(٣).

وأنه حتى وإن احترمت الدولة إرادة الفرد في بعض الأحيان إلا أن دورها يقتصر على تهيئة الوقائع التي يرتبط بها الأثر القانوني دون أن تكون مصدره المباشر^(٤)، وإذا كان لإرادة الأفراد دوراً في الجنسية وخاصة في حالات الجنسية المكتسبة، إلا أن ذلك لا يفسر أبداً على أنه عقد بين الفرد

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٦.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٦، ١٧.

راجع نقد هذه النظرية.

- LOUSSOUARN Yvon –BOUREL Pierre –SOMMIERES pascal de vareilles, " Droit international prive " 8 eme edition – 2004, Dalloz. p. 794.

(٣) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٢٧.

(٤) د. محمد كمال فهمي: القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، ١٩٨٠، بند ٦٠، ص ٨٠.

والدولة، حيث إنه لا يفسر إلا على أنه خضوع من قبل الفرد لنظام قانوني عام، وهو ما يماثل في بعض الجوانب طلب وظيفة عامة من أحد الأشخاص^(١).

ولكن إذا كان الرأي الراجح فقهيًا يقرر أن رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية، فهل يعنى ذلك انعدام أى دور لإرادة الفرد فيها؟ هذا ما سنتعرض له بالتفصيل في الفصل الثالث من خلال التعرض لمبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها.

= = =

(١) راجع في ذلك .. =

– LOUSSOUARN Yvon –BOUREL Pierre — SOMMIERES Pascal de vareilles op . cit.. n° . 527. p . 794 .

الفصل الثاني

عناصر علاقة الجنسية

من خلال تعريفنا للجنسية أتضح لنا أنها علاقة تربط بين الفرد والدولة، مما يؤكد أن عناصر تلك العلاقة هما الدولة والفرد، إضافة الى العلاقة التي تربط بينهما، وفي ذلك تفصيل على النحو التالي:

أولاً- الدولة:

الدولة هي الشخص الوحيد الذي يملك الحق في منح الجنسية، وذلك بما تملكه من القدرة على حماية مصالح مواطنيها على المستوى الدولي^(١).

وبذلك فإن الدولة تملك الحق في منح الجنسية، ولكن في إطار المعنى الدولي للكلمة، والذي يعنى أنها شخص معنوى معترف به من الدول الأخرى ويملك القدرة على حماية مصالح مواطنيه تجاه الدول الأخرى^(٢).

وبذلك فإنه ليس للأشخاص الدولية غير الدولة من الهيئات والمنظمات الدولية حق منح الجنسية، وهو ما ينطبق على هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، حيث لا يجوز لأى منها أن تمنح الجنسية، وإنما ينطبق على العلاقة التي تنشأ بين هذه الهيئات والأشخاص المنتمين لها أنها علاقة إدارية محضة، ولا توصف أبداً بأنها رابطة جنسية، وفي حالة منح هذه الهيئات والمنظمات لموظفيها جوازات سفر تمكنهم من حرية التنقل بسهولة ويسر من الدول المكونة للهيئة أو المنظمة، فإن ذلك لا يعدو أن يكون دليلاً على التبعية الإدارية، ولا يوصف بأنه دليل على منح رابطة الجنسية^(٣)، ويثور التساؤل فيما يتعلق بمدينة الفاتيكان وهل يجوز لها أن تمنح الجنسية باعتبارها مدينة مستقلة عن إيطاليا وتخضع لسلطة البابا أم أنها لا تملك هذا الحق ؟

في الحقيقة أنه لا يمكن اعتبار الفاتيكان دولة تتساوى مع غيرها من الدول، حيث إن أية دولة لا بد أن تتمتع بعمومية الاختصاص، وهو ما لا يتوافر بالنسبة لمدينة الفاتيكان التي تختص بالمسائل الدينية فقط، وبذلك فإنها لا تملك إلا الحق في منح المنتسبين إليها نوعاً من الرعاية بمناسبة أدائهم لمهامهم في تلك المدينة، ثم يعودون لجنسيتهم الأصلية بعد انتهاء تلك المهمة^(٤).

(١) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ١٩.

(٢) راجع في ذلك ..

- LOUSSOUARN Yvon -BOUREL pierre et SOMMIERES pascal de vareilles. op. cit p. 787 .

(٣) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ١٥.

(٤) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، ١٩٩٣، ص ٢٣.

وإذا ما تحقق للدولة هذا الوصف بالمعنى المتقدم، فيستوى أن تكون تلك الدولة دولة مركبة كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، أو تكون دولة بسيطة كفرنسا، حيث تثبت لتلك الدولة جنسية واحدة، ويتمتع الأفراد في حالة الدولة المركبة بنوع من الرعوية المحلية تجاه الولاية التي يقيمون فيها^(١).

وليس شرطاً أن تكون الدولة كاملة السيادة، فبعض الدول ناقصة السيادة يمكنها منح الجنسية، وهو الحال بالنسبة لسوريا ولبنان حينما كانتا خاضعتين للانتداب الفرنسي، غير أنه يجب ملاحظة أن نقص السيادة لا يجوز أن يصل إلى حد فقد الدولة لشخصيتها القانونية كلياً، ففي هذه الحالة لا تملك الدولة منح الجنسية، وهو الوضع بالنسبة للدول المستعمرة أو المضمومة إلى دولة أخرى، حيث لا تثبت جنسية مستقلة للأفراد المنتمين لهذه الأقاليم^(٢).

الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة وأثره على الجنسية.

يثار التساؤل فيما يتعلق بأثر الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة على حق الدولة في منح الجنسية، في إطار دراسة مسألة الاعتراف بأنظمة الحكم الجديدة، والتي قد تأتي نتيجة لثورة أو انقلاب، ومدى تأثيرها على حق الدولة في منح الجنسية؟ هذا الاعتراف لا يسلب الدولة أبداً حقها في منح الجنسية، حيث إن تغيير نظام الحكم في دولة ما ليس من شأنه المساس بشخصيتها الدولية التي تتمتع بها، وذلك حتى ولو لم تحصل على اعتراف بحكومتها الجديدة^(٣).

أما في إطار بحث تأثير عدم الاعتراف بالدولة على حقها في منح الجنسية، فإن الأمر لا يسير على نفس القدر من الوضوح مثلما هو الحال في إطار عدم الاعتراف بالحكومة، حيث يذهب رأى إلى أن عدم الاعتراف بالدولة يسلبها الحق في منح الجنسية، وعلى ذلك فإن مجموعة الدول العربية التي لم تعترف بإسرائيل تستطيع أن تنفي الجنسية الإسرائيلية عن يمتنعون بها، وذلك لأن الاعتراف بالدولة يعنى الاعتراف بنظامها القانوني كوحدة واحدة^(٤).

وعكس ذلك.. د. أحمد عبدالكريم سلامة: المبسوط في شرح نظام الجنسية، بحث تحليلي انتقادي مقارنة، الطبعة الأولى، ١٩٩٣، دار النهضة العربية، ص ٤١، د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ١٦.

(١) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ١٥.

(٢) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ١٥، ١٦.

(٣) راجع في ذلك:

-LOUSSOUARN Yvon –BOUREL pierre et SOMMIERES pascal de vareilles . op. cit . p. 787 .

وراجع : د. عوض الله شيبه الحمد: مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون المصري، ٢٠٠٢، ص ١٤٢.

د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ١٦، ١٧.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، ١٩٩٥، دار النهضة العربية، ص ١٥.

-LOUSSOUARN Yvon –BOUREL pierre et SOMMIERES pascal de vareilles. Op. cit. p. 787.

ويذهب البعض الآخر بأن عدم الاعتراف بالدولة لا يؤثر في حقها في منح الجنسية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات أولها: أن اعتراف دولة ما بدولة أخرى لا يمنحها الوجود الفعلي والواقعي، وأن عدم الاعتراف لا يعني أن الدولة غير المعترف بها ليس لها وجود فعلي وواقعي، وبذلك لا يترتب على هذا الاعتراف إعطاء الدولة الحق في منح الجنسية، ما لم يكن لها هذا الوجود والعكس صحيح^(١).

وبذلك فإن عدم الاعتراف بالدولة لا يخلع عنها تمتعها بالشخصية الدولية، طالما أنه توافرت لها كافة العناصر الأخرى من إقليم وشعب وسيادة، ويمكنها أن تحدد ركن الشعب فيها عن طريق منح الجنسية، ولو لم يتم الاعتراف بها من جانب بعض الأشخاص الدولية الأخرى^(٢).

ثانياً- الفرد:

يتكون عنصر السكان في أى دولة من مجموعة من الأفراد يتمتع كل منهم بجنسية تلك الدولة، وبذلك فإن الفرد يمثل العنصر الثاني من عناصر الجنسية، وتثبت الجنسية لكل شخص يتمتع بالشخصية القانونية، ولكنها لا تثبت لغير الشخص كالجماعة أو الأسرة حتى لو اتحدت جنسية أفرادها^(٣).

ثالثاً- العلاقة القانونية بين الفرد والدولة:

الجنسية وكما سبق تعريفها علاقة قانونية بين الدولة والفرد، وبذلك فإن القانون هو الذي يحدد نظامها القانوني، من حيث نشأتها وزوالها والآثار المترتبة عليها، ولكن هذه العلاقة تقوم على اعتبارات سياسية أو اجتماعية، وهو ما يتجسد في فكرة الولاء للدولة، وتوافر نوع من الصلة الروحية والاجتماعية بين الفرد والدولة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية نتباوم بتاريخ ٦ إبريل سنة ١٩٥٥، حيث أكدت أن " الجنسية علاقة قانونية تركز على رابطة اجتماعية بين الفرد والدولة، وعلى تضامن حقيقي في الوجود والمصالح والمشاعر يساندها تبادل في الحقوق والواجبات"^(٤).

وطبقاً لهذا الحكم فإن محكمة العدل الدولية تكون قد أقرت وجود تصالح فيما بين العنصر المادي والعنصر المعنوي المكونان لأساس الجنسية، والذان اختلف الفقه بشأن أفراد أحدهما كأساس للجنسية، حيث ذهب البعض إلى تأسيس الجنسية على العنصر المادي، والمتمثل في فكرة النفع المتبادل بين الفرد والدولة، وهي وجهة النظر الأنجلو أمريكية، بينما ذهب البعض الآخر إلى تأسيس الجنسية

(١) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ١٧.

(٢) د. أحمد عبدالكريم سلامة: المبسوط في شرح نظام الجنسية، المرجع السابق، ص ٤١.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٤١.

(٤) راجع في ذلك :

- Affaire Nattebohm (deuxieme phase) Recueil des Arrêts de la cour internationale de justice, p. 28, 1955 .

على العنصر المعنوي القائم على فكرة روحية جوهرها الشعور عند الفرد بالانتماء إلى جماعة سياسية معينة، وقد مزجت محكمة العدل الدولية بين هاتين الفكرتين في حكمها السابق^(١).

الفصل الثالث

حرية الدولة في تنظيم جنسيتها

= = =

يتكون المجتمع الدولي من مجموعة من الدول تعتبر كلا منها عضواً في هذا المجتمع وتتمتع كل دولة فيه بجزء من السلطة الممنوحة في هذا المجتمع، وتتحدد سلطة كل دولة في نطاق معين وتمارسها الدولة على شعبها وفي إقليمها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وقد قنن ميثاق الأمم المتحدة هذا المبدأ في المادة الثانية، الفقرة السابعة منه، والتي تنص على أن " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما " ويستنتج من هذا النص أن هناك نطاقاً متروكاً لمطلق تصرف الدولة، ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتدخل فيه سلطة أخرى، ويتحدد هذا النطاق بالمسائل التي تختص فيها الدولة باختصاصات عامة حيال شعبها وداخل إقليمها، ويعتبر تنظيم الدولة لجنسيتها من أهم هذه المسائل^(٢).

وبذلك أصبحت قاعدة اختصاص الدولة بمنح الجنسية للأفراد أو رفضها من القواعد المقررة في القانون الدولي وهي نتيجة مترتبة على فكرة السيادة، وقد ورد النص عليها في العديد من المعاهدات الدولية مثل المادة الأولى من اتفاقية لاهاي المبرمة في ١٢ إبريل ١٩٣٠ والمتعلقة ببعض المسائل الخاصة بتنازع القوانين في مجال الجنسية^(٣)، حيث تقضي تلك المادة بأن " كل دولة ينتمي إليها يترك لها تحديد - بواسطة تشريعاتها - من هم مواطنيها".

(١) راجع بالتفصيل في ذلك .. د. عوض الله شيبه الحمد السيد ، د. خالك رأفت: المرجع السابق، ص ١٠٠.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٨، ٢٩.

(٣) وقعت هذه الاتفاقية ٣٧ دولة في ١٢ إبريل سنة ١٩٣٠ بلاهاي في هولندا ، وقد دخلت هذه المعاهدة في دور السريان منذ أول يوليو سنة ١٩٣٧ ثم وصل عدد أطرافها إلى ٤٩ دولة في ٣١ يوليو سنة ١٩٤٦ .
انظر ..

- HERBERT Briggs " The law of nations " New york, second Edition . 1952, p.458 .

وقررت محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الاستشاري الصادر في ٧ فبراير ١٩٢٣ في النزاع بشأن مراسيم الجنسية في تونس ومراكش بين بريطانيا وفرنسا، حيث أكدت على أن "مسألة الجنسية تعتبر في الوضع الراهن للقانون الدولي داخلة كمبدأ عام في المجال الخاص لكل دولة"^(١).

ويترتب على هذا المبدأ مجموعة من النتائج المهمة:

أولاً: بما أن الدولة لها مطلق الحرية في تحديد من يتمتع بجنسيتها، فإنه يترتب على ذلك أنه لا يجوز للدولة أن تشرع للدول الأخرى فيما يتعلق بجنسيتها، وبذلك لا تملك الدولة إلا وضع القواعد القانونية التي تحدد بمقتضاها من يتمتع بجنسيتها، ولا يجوز لها أن تضع أي قواعد تقرر منح جنسية دولة أخرى لشخص ما، حيث أنها بذلك تتجاوز حدود الاختصاص الممنوح لها بمقتضى قواعد القانون الدولي، ومع ذلك فقد وجدت بعض الدول التي خرجت عن هذا المبدأ وقامت بالفعل بتحديد جنسية دولة أخرى^(٢).

ثانياً: أن كل دولة تملك الحق في اختيار الأسس الذي تبني عليها جنسيتها، فلها أن تختار ما بين حق الدم أو حق الإقليم، أو غيرها من الأسس التي تراها مناسبة لها وتحقق مصالحها الوطنية، وتتمشى مع ظروفها الاقتصادية والسياسية وتملك أيضاً الحق في وضع الشروط التي تراها مناسبة لنزع الجنسية أو التجريد منها^(٣).

ثالثاً: عدم إمكان قيام تنازع قوانين بخصوص مسائل الجنسية، لأن تنازع القوانين يفترض وجود أكثر من قانون قابل للتطبيق على المسألة المعروضة، والمبدأ السابق يقضى على عكس ذلك بأنه يرجع بصدد تحديد جنسية شخص ما إلى الدولة صاحبة الشأن وأنها تتمتع بكامل الحرية في ذلك، ولذا فإن القانون الدولي قد نظم المسألة بصورة محددة لا تترك مجالاً للتزاحم بين القوانين، وإذا كان يترتب على ترك الحرية للدولة في تحديد الأساس الذي تبني عليه جنسيتها نشوء ما يمكن أن يطلق عليه تنازع الجنسيات فإن ذلك مغاير تماماً لفكرة تنازع القوانين^(٤).

(١) وقد قدمت المحكمة هذا الرأي لعصبة الأمم سنة ١٩٢٣، بصدد النزاع الذي قام بين فرنسا وبريطانيا بشأن مراسيم الجنسية التي أصدرتها فرنسا في تونس ومراكش، وقد دفعت فرنسا بعدم اختصاص عصبة الأمم بنظر النزاع لتعلقه بمسائل الجنسية التي تعد من المجال الخاص لكل دولة مما يمنع الهيئة الدولية من التدخل فيها، ونازعت بريطانيا في ذلك على منح الرعايا البريطانيين امتياز عدم الخضوع للقوانين المحلية، وقد أقرت المحكمة في هذا الحكم مبدأ حرية كل دولة في تنظيم جنسيتها، ولكنها قيدت هذا المبدأ بما تكون الدولة قد تعهدت به من التزامات قبل الدول الأخرى بمقتضى اتفاقات دولية.

راجع بالتفصيل في ذلك .. د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٨.

(٢) راجع بالتفصيل في ذلك .. د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢٦ وما بعدها.

(٣) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٣٥.

(٤) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٣٥.

د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢٩.

رابعاً: أنه قد يترتب على استخدام الدولة في حريتها لتنظيم جنسيتها وقيامها بهذا التنظيم دون مراعاة لما تطبقه الدول الأخرى ما يعرف بتنازع الجنسيات، هذا التنازع قد يكون إيجابياً في حالة إذا ما تمتع الشخص بجنسية دولتين أو أكثر في نفس الوقت، نظراً لتوافر شروط اكتسابهما فيه وتعرف تلك الظاهرة بازدواج أو تعدد الجنسية، وقد يكون هذا التنازع سلبياً ويحدث ذلك في حالة عدم اكتساب الشخص لجنسية أى دولة على الإطلاق إذا لم تتوافر فيه الشروط اللازمة لذلك، وتترتب على هاتين الظاهرتين مشكلات عديدة سنعرض لها بالتفصيل المناسب في موضعها من الدراسة^(١).

خلاصة ما تقدم أن لكل دولة حرية تنظيم جنسيتها بمقتضى قوانينها الداخلية، ويعتبر هذا الاختصاص قاصراً على كل دولة دون غيرها من الدول، مع ما يترتب عليه من نتائج، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، ولكن هل يعنى ذلك أن الدولة تتمتع بحرية مطلقة في وضع قواعد جنسيتها؟ أم أنه توجد بعض المبادئ التي يجب على الدولة مراعاتها حتى يمكن لتشريع جنسيتها أن يصبح نافذاً في المجال الدولي؟ في الحقيقة أنه توجد بعض القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم جنسيتها نوردتها فيما يلي:

أولاً- القيود الاتفاقية:

يتفق فقه القانون الدولي الخاص على أن القيود التي تتضمنها اتفاقات بين الدول تقيد من حرية تلك الدول عند إصدارها لتشريعات الجنسية، إذ أن هذه القيود قد قبلتها تلك الدول بمحض إرادتها، ويؤدى مخالفتها إلى إيقاع الدولة في نطاق المسؤولية حيث إن هذه الاتفاقات تمثل أحد المصادر الرسمية للقانون الدولي^(٢).

وهذه الاتفاقيات قد تكون ثنائية، وقد تكون جماعية، وهو ما يندر في العمل ويبرر عدم اتساع دور المعاهدات الدولية في الحد من حرية الدولة في مجال الجنسية، نظراً لأن قوة تلك المعاهدات تظهر فقط في إطار الدول التي أبرمتها^(٣)، ومن أمثلة تلك المعاهدات أن تتفق دولتان تأخذ إحدهما بحق الدم كأساس لمنح جنسيتها، وتأخذ الأخرى بحق الإقليم على أن من يولد لأبوين وطنيين تابعين للدولة الأولى على إقليم الدولة الثانية لا يتمتع بجنسية الأخيرة وذلك تجنباً لتعدد الجنسيات^(٤).

وتتضمن تشريعات كثير من الدول هذا المبدأ، وخير مثال لها المادة ٢٦ من قانون الجنسية المصرى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والتي تنص على أنه "يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأجنبية، ويعمل كذلك بالاتفاقيات

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد: المرجع السابق، ص ١٣٧.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٦.

التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون"، وقد استقر القضاء الدولي على الأخذ بهذا المبدأ فهاهى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تقرر في رأيها الاستشاري الصادر بشأن مراسيم الجنسية السابق الإشارة إليه أن مسائل الجنسية، وإن كانت تدخل في المجال الخاص لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالالتزامات التي تكون قد تعهدت بها تجاه الدول الأخرى^(١).

ثانياً- القيود غير الاتفاقية:

يتناول فقهاء القانون الدولي الخاص مجموعة من القيود غير الاتفاقية التي تُرد على حرية الدولة في تنظيم جنسيتها أهمها:-

١ - القيود التي تستند إلى قواعد القانون الطبيعي، وإن ذهب الفقه المقرر لهذه القيود إلى أن تلك القيود غير ملزمة بطبيعة الحال، حيث إن القانون الطبيعي لا يضع أكثر من توجهات مقترنة بالأمل في التطبيق ومنها قاعدة حق الفرد في الجنسية^(٢).

٢ - القيود التي تستند إلى العرف الدولي اتساقاً مع نص المادة الأولى من اتفاقية لاهاي، يذهب غالبية فقه القانون الدولي الخاص إلى اعتبار العرف الدولي أحد القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، ويقدم لنا هذا الفقه مجموعة من القواعد العرفية التي يجب على الدول مراعاتها عند إصدار تشريعات الجنسية، ويمكننا أن نذكر منها:-

أ - القاعدة العرفية التي توجب على الدول الامتناع عن فرض جنسيتها على أبناء الممثلين الدبلوماسيين الذين يولدون على إقليمها، إذا كانت تشريعات الجنسية فيها تتبنى حق الإقليم كأساس لمنح الجنسية^(٣).

ب - القاعدة العرفية التي توجب على الدولة أن تضع إرادة الفرد في حساباتها وهي بصدد تنظيم القواعد الخاصة بالتجنس^(٤).

ج - القاعدة العرفية التي توجب أن تكون الجنسية التي تمنحها الدولة جنسية فعلية، بحيث تعبر عن رابطة حقيقية وفعلية بين الفرد والدولة التي تمنحه جنسيتها^(٥)، وهو ما قرره محكمة العدل

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩.

(٢) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٣٦.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد: المرجع السابق، ص ١٣٧، ١٣٨.

(٤) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٣٧.

(٥) راجع في ذلك ..

الدولية في حكمها الصادر بتاريخ ٦ إبريل سنة ١٩٥٥ في قضية المدعو نتباوم، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعو نتباوم قد حصل على الجنسية الألمانية منذ ميلاده في ألمانيا في ١٦ سبتمبر سنة ١٨٨١، ثم هاجر إلى دولة جواتيمالا عام ١٩٠٥، واستقر فيها وقبل شهور من اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، حصل على جنسية دولة ليشتنشتين وفقاً لقانون جنسيتها الصادر في ٤ يناير سنة ١٩٣٤، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها عاد إلى جواتيمالا التي اعتقلته عام ١٩٤٣، وصارت أمواله ثم أبعدته ورفضت عودته إليها أو تعويضه عن أمواله المصادرة، فلجأت دولة ليشتنشتين لمحكمة العدل الدولية بإقامة دعوى ضد جواتيمالا مطالبة بحماية نتباوم دبلوماسياً، فدفعت جواتيمالا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ أن المذكور لم يكتسب جنسية ليشتنشتين طبقاً لقانونها، وحتى إذا ثبت ذلك فإن أحكام هذا القانون لا تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي.

وقد رفضت المحكمة الاعتراف بالجنسية الشكلية الممنوحة من إمارة ليشتنشتين، رغم أنها اكتسبت بطريقة قانونية، وذلك لعدم توافر روابط فعلية وحقيقية بين تلك الدولة ونتباوم، حيث إنه لم يتقدم بطلب لاكتساب جنسيتها لشعوره بالولاء والإخلاص نحوها، وإنما لتجنب ويلات الحرب، وهو ما يجعل علاقة الجنسية في هذه الحالة علاقة وهمية^(١).

ومن قبيل الأحكام التي تم فيها الأخذ بفكرة الجنسية الفعلية قضية كانيفارو، حيث كان يحمل جنسية كلا من بيرو وإيطاليا، لأنه ولد في بيرو واستقر بها واكتسب جنسيتها عن طريق حق الإقليم، واكتسب الجنسية الإيطالية لأنه ولد لأبوين يحملان الجنسية الإيطالية فاكتسب تلك الجنسية عن طريق حق الدم، وقد قررت المحكمة أن الشخص يحمل جنسية حقيقية هي جنسية بيرو التي ولد واستقر بها^(٢).

د - القاعدة العرفية التي توجب على الدولة مراعاة مبدأ حسن النية عند تنظيمها لجنسيتها، بحيث لا تهدف من وراء وضع تلك القواعد إلى إلحاق الضرر بغيرها من الدول، كأن تسقط الدولة

(١) الحكم منشور في :

-Recueil de la cour international de justice 1955. p. 4.

وفي عرض تلك القضية بالتفصيل راجع .. د. عوض الله شبيبة الحمد: المرجع السابق، ص ١٣٨.

وللمزيد من الأحكام التي تؤكد تلك الفكرة راجع :

- LEURENT Bruno: Problemes soulevés par les demandes des doubles nationaux devant le tribunal des differends irano-américaines, Revue critique de droit international prive , 1985 . p. 490 et. s.

(٢) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٤.

جنسيتها عن مواطنيها المقيمين في دولة معادية، حتى لا تتمكن تلك الدولة من معاملتهم معاملة الأعداء^(١).

هـ - التزام الدولة بالألا تفرض جنسيتها على أفراد لا تربطهم بها رابطة نسب أو إقليم، مستندة إلى انتمائهم إلى ذات الجنس أو الدين أو اللغة السائدة فيها^(٢)، حيث إنه لا بد من توافر مجموعة من الروابط بين الفرد والدولة، ويرجع ذلك إلى أن تخلف كل صلة بين الفرد والدولة يعتبر مخالفا لقواعد القانون الدولي العرفي^(٣).

٣ - المبادئ العامة للقانون.

تنص المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن "وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:

ج - مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وبذلك تعد تلك المبادئ أحد المصادر الأساسية للقانون الدولي وقد عرفها البعض بأنها "المبادئ الشائعة في قوانين الجنسية لمختلف الدول"^(٤).

ويمكننا أن نستخلص من هذه المبادئ مجموعة من القواعد التي تقيد حرية الدولة في تنظيم جنسيتها مثل:

١ - القاعدة التي توجب على الدولة منح جنسيتها لمن يولد على إقليمها من والدين مجهولين أو عديمي الجنسية، وعلة هذه القاعدة تلافي ظاهرة انعدام الجنسية، وهو ما أكدته ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة ١٩٣٠ حيث قررت أن "المصلحة العامة للمجتمع الدولي تقتضي أن يتمتع كل فرد بجنسية ما وأن لا يكون له إلا جنسية واحدة".

وجاء نص المادة ١٥ الفقرة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقررًا لتلك القاعدة، حيث نصت تلك الفقرة على "حق كل فرد في التمتع بجنسية ما".

٢ - القاعدة التي توجب على الدولة عند تنظيمها لجنسيتها أن تحترم حقوق الدول الأخرى في ذلك، وينتج عنه أنه لا يجوز للدولة أن تفرض جنسيتها على من يتمتعون بجنسية دولة أخرى لمجرد انتمائهم إلى أصل معين، وكذلك يتعين على الدولة أن تقتصر على تحديد الأشخاص المتمتعين

(١) د. فؤاد رياض: الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، سنة ١٩٨٤، بند ٢٢.

(٢) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٣٧.

(٣) انظر في هذا المعنى:

- DERRUPPE Jean: La nationalite etrangere devant le juge francais, Revue critique de droit international prive, 1959, p. 222 et s.

(٤) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٤٠.

بجنسيتها دون أن تتعدى ذلك إلى تحديد من يتمتعون بجنسية الدول الأخرى^(١)، حيث تنص بعض الدول في تشريعاتها على دخول المرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي في جنسية زوجها، وخير مثال لذلك المادة ١١ من القانون المدني البوليبي، التي تنص على أن " المرأة البوليبية التي تتزوج من أجنبي تكتسب جنسيته " وهو ما لا يستقيم مع القاعدة السابق الحديث عنها فقد لا يرتب تشريع دولة الزوج هذا الأثر على الزواج في هذه الحالة^(٢).

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٣٥.

(٢) د. فؤاد رياض، د. سامية راشد: الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، ١٩٧١م، دار النهضة العربية، ص ٥٤ وما بعدها.

الفصل الرابع

اكتساب الجنسية

قد يكتسب الفرد جنسية الدولة فور ميلاده وقد يكتسبها في تاريخ لاحق على الميلاد، وتسمى الجنسية في الحالة الأولى بالجنسية الأصلية أو جنسية الأصل، ويطلق عليها البعض الجنسية المفروضة أو جنسية الميلاد، وتثبت تلك الجنسية للفرد بناءً على العديد من الوقائع مثل الولادة من اصل وطني، حيث يطلق عليها في هذه الحالة جنسية الدم أو البنوة أو بناء على واقعة الولادة في الإقليم، ويطلق عليها في هذه الحالة جنسية الإقليم، وفي كلتا الحالتين تكون تلك الجنسية جنسية أصلية طالما اكتسبها الشخص لحظة ميلاده^(١)، ويمكن رد اعتبار هذا النوع من الجنسية أنها جنسية أصلية إلى "أنها الجنسية التي تلحق الشخص عند اتصاله بالحياة"^(٢)، أما الجنسية التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على الميلاد فتسمى بالجنسية المكتسبة أو الجنسية الطارئة أو الجنسية اللاحقة أو الجنسية الثانوية أو الجنسية المشتقة كما يحلو لجانب من الفقه أن يسميها^(٣).

وقد اختلف الفقه بالنسبة للحالة التي يكتسب فيها فرد ما جنسية دولة في تاريخ لاحق على الميلاد، وكان سبب هذا الاكتساب يرجع إلى وقت الميلاد، وخير مثال لذلك أن يولد شخص لأب أجنبي على إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم، بشرط إعلان المولود رغبته في اكتساب جنسية تلك الدولة عند بلوغه سن الرشد، حيث إن اكتساب الشخص لهذه الجنسية لا يتحقق بمجرد الميلاد في إقليمها وإنما ببلوغه سن الرشد، فيرى فريق أن جنسية الفرد في هذه الحالة تعتبر جنسية أصلية تأسيساً على أن سببها قد تحقق وقت الميلاد^(٤)، في حين نجد أن الفقه الراجح يؤكد اعتبار الجنسية في هذه الحالة من قبيل الجنسية الطارئة " إذ العبرة ليست بتاريخ تحقق سبب اكتساب الجنسية بل بتاريخ تمام دخول الفرد في جنسية الدولة، فطالما أن هذا الدخول لم يتحقق إلا في تاريخ لاحق على الميلاد، فلا يمكن اعتبار جنسية الفرد من قبيل الجنسية الأصلية حتى ولو كان سبب دخوله فيها قد تحقق وقت الميلاد"^(٥).

ولا تخلو التفرقة بين الجنسية الأصلية والجنسية الطارئة من قيمة عملية، حيث إن المشرع قد لا يخول للوطني الطارئ جميع الحقوق التي يتمتع بها الوطني الأصل خلال فترة معينة، وذلك

(١) د. هشام على صادق: الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، المجلد الأول في " الجنسية والمواطن "، منشأة المعارف، ١٩٧٧، ص ٩٧.

(٢) د. شمس الدين الوكيل: الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الثانية، ١٩٦٠، ١٩٦١، ص ٧٧.

(٣) راجع في تفصيل هذه المسميات والقائلين بها . د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٩٨.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٥، ٤٦.

(٥) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٦. ومن الفقه المصري المؤيد لهذا الاتجاه .. د. عز الدين عبدالله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، فقرة ٦٤. د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، فقرة ٢٤. د. هشام صادق: المرجع السابق، ص ٩٩.

للاستيثاق من سلوكه قبل تقرير انضمامه إلى الجماعة الوطنية بصفة نهائية، ويظهر تأثير تلك التفرقة أيضاً عند تحديد الحل الواجب الاتباع بالنسبة لمشكلة تنازع قوانين الجنسية في الزمان^(١).

وطبقاً للتفرقة السابقة فإننا سنعرض أولاً لأسباب كسب الجنسية الأصلية، ونعقبه بالتعرض لأسباب كسب الجنسية الطارئة:

المبحث الأول

الأسس التي تبنى عليها الجنسية الأصلية

استقرت الدول منذ وقت طويل على تأسيس جنسيتها الأصلية طبقاً لأحد معيارين أساسيين هما حق الدم وحق الإقليم، وسنعرض لها تباعاً فيما يلي.

أولاً- حق الدم:

يقصد بحق الدم حق المولود في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها أبواه بصرف النظر عن مكان ولادته^(٢).

وقد أسس مبدأ حق الدم في بداية الأمر على فكرة وحدة الأصل ووراثته الجنس، وذلك تأسيساً على أن رابطة الدم هي أقوى قرينة على الاستيثاق من الشعور القومي والصلة الروحية التي تربط الفرد بالدولة التي ينتمي إليها أبواه، ونتيجة لاختلاط الأجناس (حيث أصبحت وحدة الأصل أو الجنس من المستحيلات) اتجه الفقه الحديث إلى رد حق الدم إلى أسس جديدة مثل فكرة التربية العائلية، والتي تغرس في الطفل مشاعر أبويه وأفكارهم وأنقاها فكرة الشعور بالولاء للدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم^(٣)، وينظرة إلى بناء الجنسية على حق الدم نجد أنه يحقق وحدة الجنسية وذلك في إطار الأسرة الواحدة، ويعتبر ذلك الأساس من الأسس النموذجية التي تتبعها الدول ذات الكثافة السكانية العالية والتي لا ترغب في الإكثار من سكانها^(٤)، ويحقق هذا الأساس أيضاً فائدة للدولة حيث تظل محتفظة بعلاقتها مع الأجيال المتعاقبة من أبنائها الذين يقيمون في الخارج^(٥).

على أن ذلك لا يخلو من النتائج السيئة حيث أن تكرار ولادة الوطنيين في الخارج قد يضعف صلتهم بوطنهم، وهو ما جعل بعض الدول تتجه إلى وضع تشريعات تتضمن قيوداً على حق الدم، بحيث يتسنى لها التأكد من وجود رابطة قومية بين الدولة والأفراد الذين ينتمون إليها، حتى أن بعض

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٩٩، ١٠٠.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٦.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٠٣.

(٤) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٧٦.

(٥) د. شمس الدين الزكي: المرجع السابق، ص ٨٧.

الدول تتمتع عن فرض جنسية الدم على الأبناء " الذين يولدون لأبوين وطنيين انقطعت صلتها بالدولة وتحقق لهما الاستقرار في الخارج"^(١).

وقد يثور التساؤل عن أى من الأبوين يتعين الاعتراف بجنسيته عند بناء الجنسية على أساس حق الدم؟ وهو ما يظهر جلياً في حالة اختلاف جنسية الأب عن جنسية الأم، فقد أخذت بعض التشريعات بمبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية، مثل التشريع الفرنسي الذي يمنح الجنسية الأصلية للمولود مادام أن أحد أبويه فرنسي دون التفرقة بين الأب أو الأم^(٢).

في حين ذهبت بعض التشريعات الأخرى إلى حد فرض الجنسية الأصلية على المولود لأم وطنية دون النظر إلى جنسية أبيه أو مكان ميلاده، وبذلك تتجاهل تلك التشريعات الأصول المثالية في مادة الجنسية حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تراكم الجنسيات على المولود^(٣).

وتتجه غالبية التشريعات إلى الأخذ بجنسية الأب كأساس لمنح جنسيتها الأصلية، مع الاعتراف بجنسية الأم بصفة ثانوية، وذلك تجنباً لحدوث ظاهرة انعدام الجنسية، ويحدث ذلك في حالة ما إذا كان الأب عديم الجنسية، أو لم يثبت نسب الطفل إليه قانوناً، وهو ما اتبعه المشرع المصري قبل صدور تعديل قانون الجنسية الحالي رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر في ١٤ يوليو ٢٠٠٤ بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ حيث قرر التعديل منح الجنسية المصرية لكل من يولد لأب أو أم مصرية، وبذلك يكون المشرع المصري بهذا التعديل قد ساوى بين كل من الأب والأم في منح الجنسية الأصلية^(٤).

ثانياً- حق الإقليم:

يقوم هذا المبدأ على أساس حصول الفرد على جنسية الدولة التي يولد في إقليمها بمجرد ميلاده، ويمكن رد " حق الإقليم إلى أساس اجتماعي حيث إن الطفل يتأثر بالمجتمع الذي ولد ونشأ فيه وبذلك يبدو منطقياً أن يكتسب جنسية الدولة التي ولد فيها"^(٥)، ولكن هذا المبدأ يفترض استمرار من ولد

(١) الدستور البوليفي الصادر سنة ١٩٤٥.

(٢) المادة ١٧ من تفتين الجنسية الفرنسية وفي شرح أحكامها بالتفصيل. راجع :

- BATIFFOL et LAGARDE . op. cit n° 95 .

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٠٥. وراجع أحكام القانون التركي مشاراً إليها في مؤلف، د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٩٠.

(٤) راجع في انتقاد التعديلات التي جاء بها القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ .

د. جمال محمود الكردي: التعديلات الجديدة على قانون الجنسية المصرية في الميزان، دار النهضة العربية، ٢٠٠٤م.

(٥) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٨٣.

في الإقليم في الإقامة فيه، وبذلك انتقد هذا الأساس بمقولة أن الميلاد على إقليم الدولة قد يقع مصادفة^(١). وتبرز أهمية هذا المبدأ في حالة الدول الناشئة التي تنقل إلى الوطنيين الأصول، وبالنسبة للدول التي تشجع الهجرة إليها لافتقارها لعنصر السكان^(٢).

ويرى البعض أنه لا يمكن الجزم بأن حق الإقليم يحقق مصلحة الدول المستوردة للسكان، وأن حق الدم يحقق مصلحة الدول المصدرة للسكان، لأن ذلك يتوقف على مقدار ما يقد إلى إقليمها من أجانب، ومقدار ما يخرج منها من وطنيين وقدر من يولد لهؤلاء وأولئك^(٣).

وقد حرصت بعض التشريعات على تعزيز حق الإقليم بشئ آخر مثل بقاء أسرة المولود في الدولة التي ولد فيها^(٤)، أو أن يكون الأب قد ولد بدوره في إقليم الدولة التي ولد فيها الطفل، وهو ما يطلق عليه فكرة الميلاد المضاعف^(٥)، أو أن تستلزم بعض التشريعات إقامة المولود في إقليم الدولة فترة معينة قبل أن تسمح له باكتساب جنسيتها أو عند بلوغه سن الرشد، وهو ما يجعل الجنسية الأصلية في هذه الحالة تختلط بالجنسية الطارئة^(٦)، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة لها مطلق الحرية في أن تمنح جنسيتها لكل من يولد على إقليمها، ولا يحدها في ذلك إلا قواعد العرف الدولي التي تفرض على الدولة عدم جواز فرض جنسيتها على أبناء رجال السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين يولدون على إقليمها، بالإضافة إلى توافر نوع من الالتزام الأدبي على الدولة بضرورة أن تقوم بمنح جنسيتها لكل من يولد على إقليمها من أبوين مجهولين وذلك تجنباً لحدوث ظاهرة انعدام الجنسية^(٧).

= = =

المبحث الثاني

الأسس التي تبنى عليها الجنسية الطارئة

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٧٧.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٠٧.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٧٧.

(٤) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ١٣٨.

(٥) راجع في ذلك المادة ٢٣ الفقرة الثانية من تفتين الجنسية الفرنسية الصادر سنة ١٩٤٥ والتي تنص على أن " يكون فرنسي الولد الشرعي المولود في فرنسا لأب أجنبي ولد فيها " راجع في ذلك :

- BATIFFOL et LAGARDE . op. cit. n° . 97 .

(٦) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٨١.

(٧) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٥٠.

مضت الإشارة إلى أن الجنسية الطارئة هي الجنسية التي يحصل عليها الشخص في تاريخ لاحق على الميلاد، ولو كان الميلاد عنصراً من عناصر اكتسابها، إذ أن العبرة هي بتمام الدخول في الجنسية ومدى تحقق ذلك وقت الميلاد أو في تاريخ لاحق، وإذا دخل الشخص في الجنسية بعد الميلاد فتعتبر الجنسية في هذه الحالة جنسية مكتسبة، ولو كان من بين شروطها ما يرجع إلى الميلاد، وحيث تركز الجنسية المكتسبة على ضرورة أن يتوافر قدر من الروابط الكافية بين الفرد والدولة بحيث يكفل له الدخول في مجتمعها، فإن كل ما تقره الدولة من وسائل للحصول على الجنسية المكتسبة يهدف إلى التحقق من توافر هذه الرابطة^(١).

وإذا كان تطور الحياة الخاصة الدولية ونمو الروابط والعلاقات بين مواطني الدول المختلفة والهجرة إلى دول أجنبية، قد أدى إلى ترك الأفراد لأوطانهم الأصلية وتغيير جنسيتهم الأولى والتجنس بجنسية الدول التي استقر بهم المقام فيها، إضافة إلى انتشار الزواج بين أشخاص من جنسيات متعددة، وهو ما يقتضى تيسير اكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها الوطنى أو العكس، أضف إلى ذلك أن تغيير السيادة الإقليمية على إقليم دولة معينة قد يؤدي أيضاً إلى اكتساب سكان الإقليم لجنسية الدولة التي فرضت سيادتها عليه، وحيث أفسحت التشريعات المعاصرة دوراً لإرادة الفرد في اكتساب الجنسية، فقد أدى ذلك إلى منح هؤلاء الأفراد خيار الاسترداد والذي يستطيع الفرد من خلاله أن يفصح عن رغبته في العودة إلى جنسيته المفقودة^(٢).

وبذلك تتجسد لنا أسس اكتساب الجنسية الطارئة أو اللاحقة في أربعة أسس هي التجنس، والزواج المختلط، وتغيير السيادة الإقليمية، وخيار الاسترداد، وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل التالى:-

المطلب الأول

التجنس

لم تعد رابطة الجنسية رابطة أبدية بين الفرد والدولة، وإنما أصبح إنهاء هذه الرابطة من جانب الفرد ممكناً ومتاحاً، وهو ما قرره المادة الخامسة عشر، الفقرة الثانية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث نصت على أنه "لا يجوز حرمان الفرد من الحق في تغيير جنسيته".

وترتباً على ذلك فإن الفرد إذا ما أراد تغيير جنسيته، فإن له أن يسلك طريق التجنس بأن يندمج في شعب دولة أخرى ويطلب الحصول على جنسيته، إذا ما توافرت فيه الشروط التي تضعها تلك الدولة لاكتساب جنسيته^(٣).

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٨٧، ٨٨.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١١١، ١١٢.

(٣) وهو ما قرره المادة ٩ من تشريع الجنسية الأرجنتيني الصادر سنة ١٩٥٤، حيث قررت أن "الأجنبي الذي يكون قد أقام في الأرجنتين مدة خمس سنوات بصفة مستمرة ولا يتوافر في شأنه مانع من الموانع المنصوص عليها في

ويعرف التجنس بأنه " كسب الجنسية كسباً لاحقاً للميلاد بناء على الطلب المقترن بتوافر شروط أخرى يحددها قانون الدولة والذي تملك الدولة إزائه حرية التقدير"^(١)، ويظهر من هذا التعريف أن أساس التجنس هو تحريك إرادة الفرد، حيث إنه منحه من الدولة بناء على طلب من الفرد، وبذلك فإن إرادة الفرد لا تكفي وحدها لاكتساب الجنسية، ولو توافرت فيه كافة الشروط المطلوبة للتجنس، وإنما يلزم له موافقة الدولة، وهو ما قرره القضاء في مصر حيث أكد على أنه " لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض منح الجنسية للأجنبي الذي طلبها لمجرد الاحتجاج باستيفاء هذا الشخص لكافة الشروط المطلوبة قانوناً"^(٢).

وتعهد الدولة لأحد سلطاتها بالحق في منح جنسيتها أو رفض منحها، حيث إن بعض الدول تفوض ذلك للسلطة التشريعية، وتفوضه بعض الدول الأخرى للسلطة القضائية، وفي الأعم من الأحوال فإن الدولة تعهد بذلك إلى السلطة التنفيذية، وهو ما يسير عليه المشرع المصري، الذي فوض كلا من وزير الداخلية في بعض الأحوال، ورئيس الجمهورية في حالات أخرى، بمنح الجنسية أو رفض منحها^(٣).

ويشترط في التجنس مجموعة من الشروط، يتقدمها شرط التوطن في إقليم الدولة مدة معينة، تختلف بحسب مدى تشدد الدولة أو تساهلها في منح الجنسية، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بأهلية طالب التجنس، وبوجوب تحقق قدر من التقارب بينه وبين الوطنيين، وقد تشترط الدولة في طالب التجنس ألا يكون من المجرمين الخطرين، أو ذوى العاهات، أو حصوله على إذن من الدولة التي ينتمى إليها، أو فقدته لجنسية تلك الدولة تلافياً لتعدد الجنسيات^(٤).

وتختلف الدول فيما بينها فيما تستلزمه من شروط في طالب التجنس، حيث تتساهل الدول المستوردة للسكان في تلك الشروط، مقابل تشدد الدول المصدرة للسكان فيما تتطلبه من شروط، وسوف نتناول أكثر تلك الشروط تطبيقاً في الواقع العملي على النحو التالي :

الشرط الأول- التعبير عن الإرادة:

المادة الحادية عشر يكتسب الجنسية الأرجنتينية بالتجنس تلقائياً " . راجع في ذلك د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٨٩.

(١) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص (الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع)، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م، مؤسسة الثقافة الجامعية، ص ٨٩.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٦/٦/١٩٥٢، مجموعة أحكام المحكمة السنة السادسة، ص ١١٨٩، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ١٢/٤/١٩٦٩ مجموعة أحكامها السنة الرابعة عشر، ص ٥٩١ .

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٠، ٩١.

(٤) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٩٠، ٩١.

حيث يعتبر التجنس جنسية مختارة فإن طالب التجنس لابد أن يختار الدولة التي يشعر باقترابه منها واندماجه فيها ويطلب اكتساب جنسيتها، وهو ما يتطلب دائماً وجود الإرادة والقدرة على التعبير عنها^(١).

ويتمثل التعبير عن الإرادة في صورة طلب يتقدم به طالب التجنس إلى الجهات المختصة، حتى يتمكن من إعلام الدولة برغبته في اكتساب جنسيتها، لأن التجنس هو امتياز أو منحه من جانب الدولة ينبغي إبداء الرغبة للحصول عليها^(٢).

في حين تكفي بعض التشريعات ببلوغ طالب التجنس سن الرشد، باعتبار أن ذلك العنصر هو العنصر الرئيسي في أهلية الشخص، فإن البعض الآخر يتطلب اكتمال أهلية طالب التجنس^(٣)، وحيث يلاحظ أن السن المتطلبة لبلوغ الأهلية تختلف من دولة إلى أخرى، فإن تقدير توافر شرط الأهلية في طالب التجنس يتم بالرجوع إلى قانون الدولة المراد التجنس بجنسيتها، وليس لقانون الدولة القديمة التي يتمتع الشخص بجنسيتها قبل طلب التجنس^(٤)، ويمكن تبرير ذلك بأن مجال تطبيق قانون الجنسية يتحدد بالأهلية المدنية، أما أهلية التجنس فهي أكثر تعلقاً بمسائل الجنسية، وهي من مسائل القانون العام التي تمس سيادة الدولة، مما يؤدي إلى تطبيق مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية، ويطبق ذلك القانون على الرغم من وجود اتجاه فقهي وتشريعي يذهب إلى أن العبرة بصدد تحديد أهلية طالب التجنس هي بقانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها، ولا يعتد بقانون الدولة التي يطلب اكتساب جنسيتها، حيث إن من شأن ذلك أن تكون أهلية الفرد لفقد جنسيته هي بذاتها أهليته لكسب الجنسية الجديدة، ويعتبر ذلك تطبيقاً للقواعد العامة والتي تخضع الأهلية لقانون الجنسية^(٥).

الشرط الثاني - الاندماج في مجتمع الدولة:

تتطلب الدول هذا الشرط في طالب التجنس، وذلك للتأكد من قدرته على الاستقرار في إقليم الدولة، وحتى تتمكن من فرض رقابتها عليه للتأكد من ولاءه وصلاحيته للدخول في جنسيتها، وتستطيع الدولة أن تتأكد من ذلك عن طريق العديد من المظاهر، مثل ميلاده في إقليم الدولة، أو ميلاده لأحد الوطنيين إذا لم يحصل على الجنسية الأصلية في هاتين الحالتين، وتتأكد الدولة أيضاً من توافر ذلك الشرط عن طريق إقامة طالب التجنس في إقليم الدولة قبل التقدم بطلب التجنس.

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٣.

(٢) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٧٣.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٣.

(٤) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٧٤.

(٥) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٤.

وتختلف الدول فيما بينها بصدد تحديد مدة الإقامة اللازمة للتجنس، فتشترط بعض الدول للإقامة خمسة عشر عاماً^(١)، بينما يتطلب البعض الآخر أن تكون تلك المدة عشر سنوات^(٢)، وتكتفي بعض الدول بأن تكون تلك المدة خمس سنوات^(٣)، وقد تصل تلك المدة إلى سنتين^(٤)، وتعفي بعض الدول طالب التجنس من شرط الإقامة كلياً بشرط تأدية خدمات استثنائية للدولة أو لرؤساء الطوائف الدينية^(٥).

الدينية^(٥).

ويلاحظ أخيراً أن الدولة قد تعفي من شرط الإقامة بالنسبة لطائفة اللاجئين، وهو ما قرره اتفاقية جنيف للاجئين المبرمة في ٢٨ يوليو سنة ١٩٥١، والتي تطلبت من الدول المختلفة أن تقوم بوضع التسهيلات التي تمكن اللاجئين من التجنس بجنسية الدولة التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة لذلك، وتخفيض الرسوم التي تفرض على طالب التجنس في هذه الحالة، وهو ما نصت عليه أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بانعدام الجنسية، والمبرمة في نيويورك بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٥٤ ولكن ذلك بالنسبة لعديم الجنسية فقط^(٦).

الشرط الثالث - صيانة مجتمع الدولة:

يجب ألا يتعارض فتح الدولة لباب التجنس أمام الأجانب مع تحقيق مصالحها، التي تقتضي عدم انضمام عناصر ضارة إلى مجتمعتها، وهي تهدف من وراء ذلك إلى حماية مصالحها السياسية والاقتصادية والعلمية والخلقية، فقد تشترط الدولة على طالب التجنس ألا يكون معتقلاً لمبادئ معينة تتنافى مع معتقدات الدولة ومبادئها، حيث يمثل انضمام مثل هذه الشخص إلى الدولة تقوية للعناصر المناهضة لها، وتبغى الدولة من وراء ذلك حماية مصالحها السياسية^(٧).

وقد تشترط الدولة ألا يكون فقيراً، وبالتالي يتعين أن يملك وسيلة للرزق تكفي لإعاشته ومن يعوله وهو ما يحقق مصلحتها الاقتصادية، وتقتضي مصلحة الدولة الصحية ألا يكون طالب التجنس مصاباً بمرض خبيث أو معدى أو عقلى وذلك محافظة على الصحة العامة بها، كذلك ترفض الدول دخول العناصر الضارة مثل معتادى الإجرام ومن صدر ضدهم أحكام جنائية، وذلك حفاظاً على مصلحتها الخلقية^(٨).

(١) قانون الجنسية الكويتي.

(٢) قانون الجنسية المصري.

(٣) قانون الجنسية الفرنسي.

(٤) قانون الجنسية الأردني.

(٥) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٣.

(٦) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٧٧، ٧٨.

(٧) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٦٥.

(٨) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٦.

وإلى جانب الشروط الثلاثة السابقة التي تتطلبها غالبية التشريعات وتعتبر هي الشروط الأساسية للحصول على الجنسية بطريقة التجنس، توجد بعض الشروط الأخرى التي تتطلبها بعض القوانين، ويمكن ردها في كثير من الأحيان تحت أحد الشروط الثلاثة السابقة، ولكن يوجد شرط لا يندرج تحت أى من الشروط السابقة، وتتطلبه قوانين بعض الدول وهو شرط التجرد من جنسية الدولة القديمة، حيث تأخذ بعض التشريعات بهذا الشرط كما هو الحال في ألمانيا وأسبانيا واليابان^(١).

كما أصدر معهد القانون الدولي قراراً سنة ١٨٩٦ نص في مادته الخامسة على أن "الشخص لا يمكنه الحصول على جنسية دولة ما بطريق التجنس إلا إذا أقام الدليل على تجرده من جنسية دولته الأصلية وكان قد أوفى بالتزام أداء الخدمة العسكرية وفقاً لقوانين هذه الدولة"^(٢).

ويرفض الرأي الراجح الأخذ بهذا الشرط مستندين إلى أنه إذا كان صحيحاً أن الاتجاه نحو تعليق تجنس الأجنبي على شرط أن يفقد جنسيته الأصلية يهدف إلى تلاقي ظاهرة تعدد الجنسيات، إلا أنه لا يوجد عرف دولي يلزم الدول بهذا الشرط، وهو ما يفسر لنا صدور العديد من تشريعات دول العالم خلواً من هذا الشرط، حيث أن خضوع الدولة للالتزام الدولي المنادى به في هذا الشأن قد يتعارض مع مصالحها، وما تبغيه من وراء سياستها التشريعية، ويترتب على الأخذ بهذا الشرط أيضاً أن يصبح تحديد الدولة لركن الشعب فيها معلقاً على مشيئة الدول الأجنبية التي ينتمى إليها طالب التجنس^(٣).

ويذهب البعض إلى أنه "إذا كان من العسير القول بوجود مبدأ عام يقضى بوجوب عدم دخول طالب التجنس في جنسية الدولة الجديدة دون إذن من دولته الأصلية، فإنه يجدر مع ذلك بكل دولة أن تعهد قبل منح جنسيتها إلى التحقق من خروج طالب التجنس من جنسية دولته الأصلية، وذلك منعاً لوجود حالات ازدواج في الجنسية، وهي حالات يجب العمل على تلافيها نظراً لما يترتب عليها من مشكلات عديدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عدم الاعتداد بإذن دولة طالب التجنس له بالخروج من جنسيتها سلب لرعايا هذه الدولة، خاصة وأنها قد تكون في حاجة ماسة لبقائهم لتدعيم نموها، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة هجرة العقول التي تعاني منها الدولة النامية"^(٤).

أثار التجنس:

(١) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٧٩، ٨٠.

(٢) انظر في هذا المعنى:

- HOTTELIER Michel: " Le nouveau droit de la nationalite Suisse" Revue internationale de droit compare 1991 – n° 3 , p. 579 .

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٢٥، ١٢٦.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٦٨، ٦٩.

تترتب على التجنس مجموعة من الآثار بعضها يخص المتجنس وبعضها يخص أفراد عائلته، وذلك على النحو التالي:-

١ - الآثار الفردية:

يترتب على تجنس الشخص بجنسية دولة ما أن يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها مواطنو تلك الدولة كما أنه يلتزم بالواجبات المفروضة عليهم، ولكن هل معنى ذلك أن يتمتع المتجنس بنفس القدر من الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة؟ أم أنه يحرم من بعض تلك الحقوق خلال فترة معينة تعقب تاريخ صدور القرار بمنحه الجنسية؟ نجد أن هناك بعض الدول التي تقرر المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين كل من الوطنيين الأصلاء والمتجنسين، ومن أخص الالتزامات التي ترد على المتجنس في هذه الحالة أداء الخدمة العسكرية، مثلهم في ذلك مثل الوطنيين الأصلاء، وإن أعفت بعض الدول المتجنس الذي أمضى الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة التابعة لدولته الأصلية^(١).

وهناك بعض الدول التي تحرم المتجنس خلال فترة معينة تالية لتجنسه من ممارسة طائفة هامة من الحقوق هي الحقوق السياسية، وذلك حتى تتأكد الدولة من ولاء المتجنس لها، وتعرف تلك الفترة بفترة الرتبة التي إذا ما انتهت أصبح المتجنس في مركز الوطنيين الأصلاء بشرط ألا يبدر منه خلال تلك الفترة ما يدل على عدم ولاءه لدولته الجديدة^(٢).

تذهب بعض الدول لما هو أبعد من ذلك، حيث تحرم المتجنس من حقوق معينة كحق تولي المناصب السياسية الهامة، وخير مثال لها الدستور المصري والذي يحرم الوطني الطارئ من تقلد رئاسة الجمهورية في أي وقت من الأوقات، وفي بعض الأحيان تحتفظ الدولة لنفسها بالحق في حرمان المتجنس من جنسيتها، وذلك عن طريق السحب خلال فترة معينة، وذلك لأسباب عدة كأن يكون المتجنس قد حصل على جنسية الدولة عن طريق الغش، أو أنه أثبت عدم ولاءه لها، أو أتى تصرفاً يدل على عدم اندماجه في مجتمعها، مثل عودته للاستقرار في دولته الأصلية^(٣).

مع ملاحظة أن الفرد يكتسب جنسية الدولة الجديدة بناء على التجنس دون أثر رجعي، بمعنى أن تاريخ صدور القرار بالموافقة على منحه الجنسية هو قرار بالنسبة للمستقبل وليس بالنسبة للماضي،

(١) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٨٣، ٨٤.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٢٨.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٠.

وبذلك فإن التمتع بالحقوق أو التحمل بالالتزامات التي تترتب على التجنس لا يبدأ إلا من تاريخ صدور هذا القرار^(١).

٢ - الآثار العائلية:

تخص الآثار العائلية للتجنس كلا من الزوجة والأولاد القصر، وتختلف التشريعات فيما بينها بصدد أثر التجنس على الزوجة، وذلك طبقاً لاعتبارين أحدهما متعلق بمراعاة وحدة الجنسية في العائلة تحقيقاً للتألف والانسجام بين أفرادها، والآخر متعلق بمراعاة إرادة الزوجة في اكتساب جنسية زوجها^(٢)، حيث كانت أغلب التشريعات فيما مضى تمد بقوة القانون جنسية الزوج الجديدة إلى الزوجة، وذلك تحقيقاً لمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، ويعاب على هذه التشريعات أنها تتجاهل تماماً إرادة الزوجة، مما يعد مخالفاً للأصول المثالية في مادة الجنسية، ويعد أيضاً خرقاً للعرف الدولي الذي يلزم الدول بعدم فرض جنسيتها على أجنب إذا لم يكن لإرادتهم دور فيها^(٣).

وتطبيقاً لمقتضيات التطور الاجتماعي فقد بدأت كثير من التشريعات تعدد بإرادة الزوجة كنتيجة لمبدأ المساواة بين الجنسين، فمن هذه التشريعات ما يعلل دخول زوجة المتجنس في جنسية زوجها على إرادتها الصريحة، ومنها ما يدخلها في تلك الجنسية مع إعطائها الحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية^(٤).

ويمثل الاتجاه الذي أخذت به بعض التشريعات الحديثة، والذي يتيح لزوجة المتجنس فرصة الدخول في جنسية زوجها دون حاجة لاتخاذ إجراءات جديدة للتجنس مع احترام إرادة الزوجة، وتخويلها الحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، من أفضل تلك الاتجاهات، خاصة في ظل اتجاه بعض التشريعات إلى عدم ترتيب أى أثر لتجنس الزوج على جنسية زوجته، وهو ما يقتضى أن الدولة لا تستطيع أن تدخل في جنسية زوجها إلا بالطرق المتاحة أمام جميع الأجانب مع التخفيف من بعض الشروط في مواجهتها^(٥).

أما بالنسبة للأولاد القصر فيقترب مركزهم من مركز الزوجة، فيما يتعلق بالآثار المتعلقة بتجنس رب الأسرة بجنسية جديدة، حيث إن اكتساب رب الأسرة لجنسية جديدة يقتضى تبعية كلا من الأبناء القصر والزوجة لرب الأسرة.

(١) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٨٤.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٢٩.

(٣) وهو ما قرره اتفاقية لاهاي سنة ١٩٣٠ بشأن الجنسية حيث أوردت " أن تجنس الزوج خلال قيام الزوجية لا يؤدي إلى تغيير جنسية الزوجة إلا بموافقتها " . راجع في ذلك .. د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٢.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٢.

(٥) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٢.

مع ملاحظة وجود فارق جوهري بين كل من الزوجة والأولاد القصر في هذا المجال، هذا الفارق يتمثل في أن هؤلاء الأولاد لم يبلغوا بعد سن الرشد وهو ما يجعل التعويل على إرادتهم في اكتساب الجنسية الجديدة أمراً صعباً، وقد دفع ذلك الفارق الكثير من التشريعات إلى فرض جنسية الأب الجديدة على أولاده القصر باعتبار أن إرادة الأب تحل محل إرادة الابن^(١).

وتتجه تشريعات أخرى إلى تعليق فرض جنسية الدولة على الأولاد القصر، بشرط ألا يكونوا محتفظين بإقامتهم في الخارج، وقد تمنحهم الجنسية في جميع الأحوال مع تمكينهم من ردها عند اكتمال إرادتهم ببلوغ سن الرشد^(٢)، أما أولاد المتجنس البالغون سن الرشد وقد تجنس والدهم بالجنسية الجديدة فإنهم لا يتأثرون بجنسية الوالد الجديدة، حيث إنهم يتمتعون بأهلية كاملة يجب التعويل عليها في تغيير جنسيتهم، بصرف النظر عن إرادة والدهم ولأنهم قد خرجوا من تبعية رب الأسرة، لذلك يتعين عليهم إذا ما أرادوا التجنس بجنسية والدهم أن يطلبوا ذلك استقلالاً، وقد تمنحهم الدولة الجديدة بعض الإعفاءات من بعض الشروط المطلوبة للتجنس، وذلك استناداً إلى سبق حصول والدهم على جنسية تلك الدولة^(٣).

المطلب الثاني

الزواج المختلط

الزواج المختلط هو الزواج الذي ينعقد بين طرفين من جنسيتين مختلفتين، وهذا الاختلاف في الجنسية قد يكون معاصراً للزواج وقد يطرأ في مرحلة لاحقة عليه، ويترتب على هذا الزواج آثاراً هامة بالنسبة لجنسية الزوجين، فقد يكون وسيلة لكسب الجنسية وعلى العكس قد يصبح وسيلة لفقدانها، فإذا تزوجت المرأة الوطنية بأجنبي فإن ذلك قد يترتب عليه زوال جنسيتها الأصلية، وقد تفقد المرأة الوطنية

(١) المادة ١٠ من تشريع الجنسية العراقي الصادر سنة ١٩٢٤ والمادة ١١ من تشريع جنسية شرق الأردن الصادر سنة ١٩٢٨ وفي أمثلة أخرى من التشريعات التي تدير في هذا الإطار. راجع د. عز الدين عبدالله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية وتمتع الأجانب بالحقوق، الطبعة الثامنة، ١٩٦٨، ص ١٧٧، ١٧٨ هامش رقم ١.

(٢) المادة ٦ من تشريع الجنسية المصري، رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥.

(٣) راجع في ذلك .. التعديل الصادر سنة ١٩٩٣ لتشريع الجنسية الفرنسي، وذلك في المادة ٦٤ والتي تقرر إعفاء الابن البالغ سن الرشد للمتجنس بالجنسية الفرنسية من شرط المدة إذا طلب التجنس. د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧١، د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ١٣٣.

وراجع أيضاً ما تنص عليه المادة ١٥ من قانون الجنسية البلجيكي الصادر سنة ١٩٣٢ والتي تقضي بأنه "يجوز لأبناء المتجنس بالجنسية البلجيكية البالغين، وكذلك لبناته البالغات غير المتزوجات، قبل أن يبلغوا الخامسة والعشرين أن يقرروا وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (١٠) برغبتهم في اكتساب الجنسية البلجيكية وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل العمل الذي تم به تجنس والدهم في السجل المعد لذلك". مشار إليه في مؤلف. د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ١٧٦.

جنسيتها أيضاً ولو كان زواجها من أحد الوطنيين، وذلك في حالة إذا ما اكتسب هذا الزوج جنسية دولة أخرى بعد قيام الزواج^(١).

وسنكتفي هنا بالحديث عن أثر الزواج المختلط في إكتساب الجنسية، ونؤجل الحديث عن أثره في فقد الجنسية لحين دراسة أسباب فقد الجنسية، وفيما يتعلق بأثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة فإن هناك مبدأين تتنازعهما التشريعات في هذا الصدد:-

أولهما: المعروف بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، والذي بمقتضاه تكتسب الزوجة جنسية زوجها بحكم القانون لحظة إنعقاد الزواج.

وثانيهما: وهو المبدأ المعروف باستقلال الجنسية في العائلة، والذي بمقتضاه تحتفظ الزوجة بجنسيتها بالرغم من زواجها ولا تدخل في جنسية زوجها^(٢).

وهناك بعض من التشريعات توسطت بين المبدأين السابقين، بحيث لا تزول جنسية المرأة المتزوجة عنها، إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك، وأن يكون قانون جنسية الزوج يمنحها هذه الجنسية، وهو ما يتفق مع الأصول المثالية في مادة الجنسية، وذلك لمراعاته إرادة الفرد وتجنبه لحدوث ظاهرة إنعدام الجنسية^(٣).

١- مذهب وحدة الجنسية في العائلة:

كان هذا المبدأ هو السائد خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهو يقضى بفرض جنسية الزوج على زوجته بحكم القانون وبمجرد إنعقاد الزواج، وتظل محتفظة بتلك الجنسية طوال قيام الزوجية، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى وجدت كثير من الزوجات اللاتي إكتسبن جنسية أزواجهن، وظلن مع ذلك محتفظات بولائهن لدولهم الأصلية وهى من دول الأعداء، مما جعل بعض التشريعات تحيد عن هذا المبدأ وساعدها في ذلك ظهور الحركات التي تنادى بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإتجهت تلك التشريعات إلى التخفيف من مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، وذلك بمنح الزوجة حق رفض جنسية زوجها التي من الممكن أن تكتسبها بالزواج، وإتجهت تشريعات أخرى إلى إعتماد مبدأ استقلال الجنسية في العائلة^(٤).

ويستند مبدأ وحدة الجنسية في العائلة إلى أن اتحاد جنسية الزوجين يترتب عليه تحقيق نوع من التوافق الروحي والأدبي في نطاق الأسرة، وهو شرط لقيام الوحدة في المنزل العائلي، حيث يجب أن

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٣٦.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ١٣٧.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٣٧.

(٤) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٩٢.

بنشأ الزواج وطناً واحداً للزوجين وتنتمي إليه الأسرة، ويتحقق بفضلُه إندام عوامل الفرقة والانفصال^(١).

ومما يرجح الأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة وجود صعوبات فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العلاقة الزوجية وأثارها، وكذلك بتحديد جنسية الأولاد في حالة ترك هذا المبدأ^(٢).

ويضيف أنصار مبدأ وحدة الجنسية في العائلة أن احتفاظ الزوجة بجنسيتها وعدم اكتساب جنسية زوجها قد يؤدي إلى خضوع كلا من الزوجين لسلطة سياسية مختلفة، وهو ما يؤدي إلى هدم كيان الأسرة وتفرقة أفرادها^(٣).

ومن التشريعات التي أعتنقت هذا المبدأ التشريع الإيطالي الصادر سنة ١٩١٢ في المادة العاشرة منه، التشريع اللباني الصادر سنة ١٩٢٥ في المادة الخامسة منه، التشريع الأردني الصادر سنة ١٩٢٨ في المادة العاشرة منه، وقد أخذت بهذا الاتجاه أيضاً المادة ٢٢ من القانون المدني الأسباني الصادر عام ١٩٣١، والمادة ٣ من تشريع الجنسية الفنلندي الصادر عام ١٩٤١، والمادة ٢١ من القانون المدني اليوناني الصادر سنة ١٨٥٦ والمعدل عام ١٩٢٧، والتي تنص على أن "المرأة الأجنبية التي تتزوج بيوناني تكتسب الجنسية اليونانية بمقتضى الزواج". وقد سار على نفس النهج تشريع الجنسية المصري الصادر سنة ١٩٢٩ والذي فرض الجنسية المصرية على المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري^(٤).

٢- مبدأ إستقلال الجنسية في العائلة:

يذهب هذا المبدأ وعلى عكس المبدأ السابق إلى استقلال الزوجة بجنسيتها عن جنسية دولة الزوج، ويرتبط هذا المبدأ بظهور الحركات النسائية الدولية المعاصرة والتي تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وإزالة كافة الظواهر القانونية التي تكرر تبعية المرأة للرجل^(٥).

وتطور مركز المرأة في العصر الحديث بمساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والتكاليف العامة مثل حق الانتخاب وتولى الوظائف، مما وفر لها الإستقلال السياسي والإقتصادي والاجتماعي، وهو ما دفع التشريعات إلى القول باستقلال جنسية الزوجة عن جنسية زوجها رغم الزواج من أجنبي^(٦).

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٣، ٧٤.

(٢) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٨٩.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣٠.

(٤) راجع في تفصيل التشريعات التي أخذت بذلك المبدأ د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ١٤٥، ١٤٦. د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣١.

(٥) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ١١٥.

(٦) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ١٤٧.

ويستند أنصار هذا المبدأ إلى أنه إذا كان من الأصح من وجهة نظر دولة الزوج أن تكتسب الزوجة جنسية زوجها، فإن الأمر يسير على عكس ذلك من وجهة نظر دولة الزوجة، حيث إن صيانة الدولة لركن الشعب فيها وخاصة الدول المستوردة للسكان تقتضى منع النساء من رعاياها من الانفصال عنها في حالة زواجهن من أجانب، وهو ما يعطى الفرصة لدخول الزوج في جنسية زوجته إذا كان يقيم في إقليم الزوجة وقد تم لأولاده اكتساب جنسية هذه الدولة بناء على حق الإقليم، وفي هذه الحالة سيكون أفراد الأسرة جميعهم باستثناء الزوج تابعين لجنسية الزوجة مما يدفعه إلى الدخول في تلك الجنسية^(١).

ومن التشريعات التي أخذت بهذا المبدأ تشريع جنسية اليابان الصادر سنة ١٩٥٠، وتشريع الجنسية اليوغسلافية السابق الصادر سنة ١٩٤٥، وتشريع جنسية الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة ١٩٥٢^(٢).

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أنه على الرغم من الاتجاه الحديث في كثير من المواثيق الدولية والتشريعات المعاصرة الذي يتجه إلى الإعتداد بإرادة المرأة، وذلك بعدم فرض جنسية زوجها عليها إلا أننا نجد أن الكثير من التشريعات تسعى إلى تشجيع إنضمام الزوجة الأجنبية إلى جنسية زوجها، حيث إن ذلك يحقق نوعاً من التآلف الروحي والفكري في نطاق الأسرة، وهو ما يعضد وحدتها وتماسكها ويتلافى المشكلات السياسية والقانونية التي تنتج عن الأخذ بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة^(٣).

٣- أثر الزواج المختلط على جنسية الزوج:

لا يخلو الزواج المختلط من أثر على جنسية الزوج فلا يقتصر تأثيره فقط على جنسية الزوجة، ويرجع في ذلك إلى قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة، وهذا الأثر يتصور في الفرض الخاص بالزواج الذي يتم بين أجنبي وإحدى الوطنيات، ففي بعض الأحيان وخاصة في الدول التي ترغب في زيادة عدد سكانها، أو تحقيق مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، يعتبر الزواج الذي يتم بين أجنبي وأحدى الوطنيات سبباً لإكتساب هذا الزوج الأجنبي لجنسية زوجته، وإن كان هذا الفرض من الفروض النادرة الحدوث، حيث إن المفترض هو أن الزوجة هي التي تكتسب جنسية زوجها بسبب الزواج باعتبار أن الزوج هو رب الأسرة، وتبرز أهمية إكتساب الزوج لجنسية زوجته في حالة إذا ما أتخذت الأسرة موطنها في دولة الزوجة وأستقرت فيها، وبذلك ينشأ الأولاد أكثر تعلقاً بدولة الأم، وتبرز تلك الأهمية

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٦.

(٢) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ١٤٩، ١٥٠ حيث يعرض سيادته بالتفصيل لكثير من التشريعات التي أخذت بهذا المبدأ.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٧٩.

أيضاً بصدد المصلحة التي تعود على الزوج من إكتساب جنسية زوجته، حيث إنه سيعامل معاملة الوطنيين ويتمتع بجميع الحقوق المقررة لهم^(١).

وتطبق هذا المبدأ الدول التي تطبق مبدأ وحدة الجنسية في العائلة بالنسبة للزوجة، حيث إن بعض هذه التشريعات تجعل للزوج أثراً مباشراً على جنسية الزوج، فيجوز له أن يكتسب جنسية زوجته إذا أبدى الرغبة في ذلك دون مرور فترة زمنية على الزواج، ومنها ما يعلق ذلك على إرادة الدولة، فتخضع مسألة منح الجنسية للزوج في هذه الحالة لسلطة الدولة التقديرية، أما الدول التي لا تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، فإنها لا تعطي الزوج الحق في الدخول في جنسية زوجته إلا عن طريق التجنس المباح لكل الأجانب، وإن كانت تضع هذا الزوج في منزلة أسمى من غيره من الأجانب الذين يطلبون التجنس دون توافر هذا الشرط فيهم^(٢)، وتتجلى تلك المنزلة الخاصة عادة في التخفيف من شرط الإقامة المطلوبة في التجنس العادي، وهو ما قرره كل من التشريع الفرنسي وتشريع الولايات المتحدة الأمريكية والتشريع اللبناني^(٣).

وتتجه تشريعات الجنسية في الدول العربية إلى عدم ترتيب أى أثر للزواج من وطنية على جنسية الزوج الأجنبي، ويتعين عليه في هذه الحالة الإلتجاء إلى طريق التجنس العادي، مع عدم وجود أى تخفيف بالنسبة له في الشروط المطلوبة لهذا التجنس^(٤).

في حين ذهبت بعض التشريعات إلى إعطاء الزوج الأجنبي الحق في الدخول في جنسية دولة الزوجة بمجرد الطلب المعلق على السلطة التقديرية للدولة، كما هو الشأن في التشريع الإيرلندي، وتذهب تشريعات أخرى إلى إعطاء الزوج الحق في إكتساب جنسية زوجته بمجرد الزواج وإبداء الرغبة في ذلك، متى توافرت الشروط المطلوبة للتجنس، مع عدم إعطاء الدولة أى سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهو ما نص عليه دستور السلفادور الصادر سنة ١٩٥٠^(٥).

المطلب الثالث

تغيير السيادة الإقليمية

وهو ما يطلق عليه ضم إقليم دولة إلى دولة أخرى، ويتحقق هذا التغيير في السيادة الإقليمية في عدة صور هي:

١- اندماج دولتين لتكوين دولة واحدة محل هاتين الدولتين.

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٥٣، ١٥٤.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٨٠.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٥٤ حيث يعرض سيادته باستفاضة لموقف التشريعات من تلك المسألة.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٨٠.

(٥) راجع في ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٥٥.

٢- الضم الكلى ويحدث في حالة ضم إقليم دولة بأكمله إلى دولة أخرى، ويترتب عليه فناء الدولة القديمة وانتقال السيادة كاملة على إقليمها إلى الدولة الضامة.

٣- الضم الجزئي ويترتب عليه إنتزاع جزء من إقليم دولة وإخضاعه لسيادة دولة أخرى.

وسنكتفي هنا بدراسة الحالة الثالثة حيث إن كلا من الصورة الأولى والثانية لا تثيران في الغالب أى مشاكل تتعلق بالجنسية.^(١) ففي الحالة الأولى تزول جنسية كل من الدولتين المندمجتين لتحل محلها جنسية الدولة الجديدة، وفي الحالة الثانية تزول جنسية الدولة المضمومة وتحل محلها جنسية الدولة الضامة، أما في الحالة الثالثة فتثور مشكلة تتعلق بالجنسية إذ تبقى الدولة التي أنتزع جزء من إقليمها قائمة وتبقى جنسيتها كما هي، وبذلك لا يمكن القول بجواز حلول جنسية الدولة الضامة محل جنسية الدولة المضمومة مباشرة، وعلى ذلك يثور التساؤل عما إذا كانت الدولة الضامة ستفرض جنسيتها على سكان الإقليم الذي قامت بضمه تطبيقاً لمبدأى السيادة الشخصية والسيادة الإقليمية اللذان تتمتع بهما الدولة على إقليمها؟^(٢)

ولكن إلى أى مدى ووفقاً لأى معيار "إذا كانت الدولة تتمتع بهذا الحق" يمكن للدولة الضامة إدخال سكان الإقليم المضموم في جنسيتها؟

جرى العمل الدولي على إعمال أحد معايير أربعة في هذا الصدد، تلك المعايير هي:

الأول: أن يبقى سكان الإقليم المضموم محتفظين بجنسيتهم الأصلية مع منح جنسية الدولة الضامة لكل من يولد في الإقليم المضموم بعد الضم.

الثانى: أن تفرض جنسية الدولة الضامة على أساس التوطن بالإقليم المضموم وقت تمام الضم.

الثالث: أن تفرض جنسية الدولة الضامة على كل من يتوافر فيه شرطى الميلاد والتوطن في الإقليم المضموم وقت الضم.

الرابع: أن تفرض جنسية الدولة الضامة على أساس توافر أحد معيارى الميلاد أو التوطن في الإقليم المضموم وقت الضم، وبذلك يدخل في جنسية الدولة الضامة كل من ولد بالإقليم المضموم ولو لم يكن مقيماً به وقت حدوث الضم، ويدخل أيضاً في تلك الجنسية جميع السكان المتوطنين

(١) د. هشام على صادق: آثار الاستخلاف الدولي في ضوء الوحدة المصرية الليبية سنة ١٩٧١، الإسكندرية، فقرة رقم ٥١، حيث يتعرض سيادته لبعض المشاكل المتصورة في حالة الإستخلاف الشامل المترتب على إدماج دولتين في دولة واحدة.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، ص ١٥٥، ١٥٦.

بالإقليم وقت حدوث الضم، وتسير أغلب المنازعات في إطار العمل الدولي في اتجاه الأخذ بهذا المعيار.^(١)

ومن الملاحظ أن هذه المعايير لا تطبق إلا بشأن رعايا الإقليم المضموم، فهم المعرضون فقط لفقد جنسيتهم واكتساب جنسية الدولة الضامة، أما رعايا الدول الأجنبية والموجودين بالإقليم المضموم فليس لهذا الضم أى أثر على جنسيتهم، كما أنه لا يترتب على الضم أى أثر بالنسبة للماضى، فهو لا ينتج أثره إلا ابتداء من التاريخ الذي تم فيه تغيير السيادة الإقليمية.^(٢)

ومن القواعد التي جرى عليها العمل الدولي عند تغيير السيادة الإقليمية عدم إكراه رعايا الإقليم المضموم على الدخول في جنسية الدولة الضامة، وإنما يعطى لهم الحق في الاختيار بين اكتساب جنسية الدولة الضامة أو الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.^(٣)

وفي حالة رفض سكان الإقليم المضموم الدخول في جنسية الدولة الضامة، فإنهم يعتبرون في هذه الحالة من الأجانب ويجوز للدولة الضامة في هذه الحالة إجبارهم على مغادرة إقليمهم باعتبارهم من الأجانب.^(٤)

ويرجع عدم فرض الدولة الضامة لجنسيتها على أهالي الأقاليم المضمومة، لخوفها من إحتفاظ سكان الأقاليم التي ضمت إليها بولائهم لدولهم الأصلية، أو استمرار ارتباطهم بها بالإضافة إلى خوفها من إحتفاظها بسكان يشكلون طائفة دخيلة عليها، تستقل بعاداتها وتقاليدها وأمانيتها وأهدافها عن تلك الدولة، وبذلك تفقد الدولة الضامة عنصر التجانس المطلوب في سكانها مما يشكل خطراً كبيراً على

(١) راجع في تفصيل ذلك

GORDON: les cessions de territoires et leurs effets sur la nationalite des habitants, in la nationalite dans la science sociale. P. 123 et. s

WEIS: Nationality and statelessness in international law p. 149. et. s.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٨٤.

BATIFFOL et LAGARDE . op. cit. p. 79

(٣) وقد أكدت هذا المبدأ مجموعة من الإتفاقيات الدولية وهو ما تقرر لأول مرة في إتفاقية استسلام أراس المبرمة في ٩ أغسطس سنة ١٦٤٠ راجع ذلك في

GHALI Paul, les nationalites detachers de l'Empire ottoman a la suite de la guerre. Paris. 1934. p. 15.

(٤) راجع في ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٥٩ و د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، فقرة ٣١. و د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٨٤. ومن المعاهدات التي أخذت بهذا الإتجاه معاهدة السلام المبرمة مع إيطاليا في ١٠ فبراير سنة ١٩٤٧، والتي نصت على أن يجوز لكل من تجاوز عمره ١٨ سنة وكانت اللغة الإيطالية هي لغته الأصلية أن يختار الجنسية الإيطالية خلال سنة من تاريخ العمل بالمعاهدة ويكون للدولة الضامة عندئذ الحق في أن تطلب منه مغادرة الإقليم بوصفه من الأجانب.

أسس مجتمعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يعطى للدولة التي اقتطع منها جزءاً من إقليمها أن تسترده من جديد.^(١)

المطلب الرابع

خيار الإسترداد

يعرف خيار الإسترداد بأنه "رخصة خولها القانون للشخص الذي فقد جنسية الدولة يجوز له بمقتضاها أن يسترد جنسيته المفقودة"^(٢).

ويعرف أيضاً بأنه "عودة لاحقة إلى جنسية سابقة"^(٣).

ويتميز خيار الإسترداد عن التجنس العادي بأنه يشترط في الشخص الذي يرغب في إكتساب جنسية الدولة أن يكون قد سبق له التمتع بها، وبأنه يوفر نوعاً من التيسير أمام طالب الجنسية لسبق توافر صفة الوطنية فيه.

وقد يتبادر إلى الذهن تساؤل متعلق بسبب دراسة خيار الإسترداد ضمن أسباب كسب الجنسية الطارئة أو اللاحقة مع أن الجنسية التي يكتسبها الشخص في هذه الحالة قد تكون جنسيته الأصلية لحظة ميلاده؟

وفي الإجابة على هذا التساؤل فإن "العناصر التي تؤهل الشخص لمباشرة خيار الإسترداد لا تتوافر إلا في تاريخ لاحق على ميلاده، وفضلاً عن ذلك فهو إذ يباشر هذا الخيار ويسترد الجنسية المفقودة لا يعتبر من قبيل الوطنيين إلا من تاريخ هذا الإسترداد، وبعبارة أخرى أن مباشرة الخيار لا ينسحب أثره على الماضي ولكنه ينتج أثراً مباشراً من تاريخ الإسترداد فقط"^(٤).

وبذلك يعتبر خيار الإسترداد من أسباب كسب الجنسية الطارئة أو اللاحقة وذلك في جميع الفروض، وطبقاً للمعيار الذي يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية الطارئة، والذي يستند إلى وجوب توافر سبب إكتساب الجنسية وقت الميلاد في حالة الجنسية الأصلية، أو في تاريخ لاحق على الميلاد لإكتساب الجنسية الطارئة أو اللاحقة.

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٥٩. د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، فقرة ٣١.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٦١.

(٣) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ١٢٥.

(٤) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ١٢٥ وفي الفقه الفرنسي الذي يرى عدم انسحاب أثر خيار الإسترداد إلى الماضي

وفيما يتعلق بموقف التشريعات التي تأخذ بخيار الإسترداد من حيث نطاقه، فإننا نجد أن فرنسا تعتبر خيار الإسترداد طريقاً عاماً للعودة إلى جنسية الدولة في جميع الفروض، باستثناء الحالات التي ينص فيها المشرع على عدم جواز الإلتجاء إلى هذه الوسيلة من وسائل كسب الجنسية اللاحقة أو الطارئة، وذلك في الحالات التي ينعدم فيها السبب المبرر للإسترداد،^(١) ونجد أن خيار الإسترداد قريباً جداً من التجنس من حيث خضوعه لسلطة الدولة التقديرية، ومن حيث الشروط المتطلبية فيه، مع ملاحظة الحالة التي يعتبر فيها طالب الإسترداد من الوطنيين السابقين، ففي هذه الحالة تخفف الشروط المتطلبية لدخوله في جنسية الدولة،^(٢) وذلك هو الإلتجاء الأول أما الإلتجاء الثاني فيرى في خيار الإسترداد طريقاً خاصاً للعودة إلى جنسية الدولة في حالات معينة من فقدها، أما في خارج هذه الحدود فلا يكون للوطنى السابق الذي يرغب في إسترداد جنسيته إلا أن يسلك طريق التجنس العادى، وتتمثل أهم حالات الإسترداد الخاص في صورتين.

أولهما: الصورة الخاصة بالأولاد القصر الذين زالت عنهم جنسيتهم الأصلية تبعاً لتجنس أبهم بجنسية دولة أخرى، إذ يحق لهم إسترداد جنسيتهم المفقودة عند بلوغهم سن الرشد.

وثانيهما: الصورة الخاصة بالمرأة التي تفقد جنسيتها نتيجة لزواجها من أجنبى ودخولها في جنسيته، وتعطى التشريعات المرأة في هذا الفرض الحق في إسترداد جنسيتها الأولى نتيجة لإنقضاء رابطة الزوجية إذا أبدت رغبتها في ذلك.

وفي كلتا الحالتين فإن الإسترداد يكون بقوة القانون، حيث إن الشخص في الحالة الأولى قد فقد جنسيته بقوة القانون دون أن يبدى أى رغبة، وهو نفس الحال بالنسبة للفرض الثانى الخاص بالمرأة الوطنية التي تفقد جنسيتها بقوة القانون بمجرد زواجها من أجنبى واكتسابها جنسيته، ويختلف الأمر بالنسبة للشخص الذي فقد جنسيته بناء على رغبته إذ تتمتع الدولة في مواجهته بحقها في تقدير هذا الطلب بقبوله أو رفضه، وخلاصة ما سبق "أن قبول الدولة لرغبة الشخص في إسترداد جنسيته المفقودة قد يكون قبولاً وجوبياً أو قبولاً جوازياً خاضعاً لمطلق تقدير سلطاتها المختصة فهو قبول وجوبى إذا كان الشخص قد فقد جنسيته بقوة القانون ورغماً عن إرادته وهو جوازى إذا كان فقد الجنسية قد تم بإرادة الشخص وموافقته"^(٣).

(١) راجع في ذلك

BATIFFOL at LAGARELE. Op. cit. n. 122

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٦٣.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٦٦.

الفصل الخامس

فقد الجنسية

= = =

قد لا يتمتع الفرد بجنسية الدولة التي ينتمى إليها طيلة حياته، فقد يفقدها في وقت من الأوقات، والمفترض في ذلك الفقد أن يتم بإرادتي الفرد والدولة، ولكن قد يحدث أن تنزع الدولة جنسيتها عن الفرد رغماً عنه، وقد يتطلب الأمر قبول دولة أخرى غير التي يحمل الفرد جنسيتها، وتكون تلك الدولة هي الدولة التي يرغب الفرد في اكتساب جنسيتها.

ويجرى بعض الفقه^(١) تفرقة بين فقد الجنسية بإرادة الفرد وفقدها بإرادة الدولة، بينما يرى آخرون أن إرادة الدولة لازمة في كلتا الحالتين، لأن تخلف إرادة الدولة يعنى أن يظل الفرد متمتعاً بجنسيتها حتى لو اكتسب جنسية أخرى.^(٢)

وتمثل جميع طرق كسب الجنسية الطارئة أسباباً لفقد الجنسية أصلية كانت أو طارئة، فالتجنس بجنسية أجنبية والزواج المختلط وإسترداد الجنسية والضم الإقليمي كلها تعتبر أسباباً لكسب الجنسية الجديدة من ناحية، ولفقد الجنسية القديمة من ناحية أخرى، ويضاف إلى هذه الطرق طريقاً آخر يفقد به الشخص جنسيته على سبيل الجزاء، ويتخذ هذا الطريق إحدى صورتين هما السحب والإسقاط.

ولما كنا قد تحدثنا عن التجنس والزواج المختلط وتغيير السيادة الإقليمية وخيار الإسترداد عند اكتساب الجنسية الطارئة، فإننا سنحيل إلى ما سبق ذكره عن تلك الحالات كأسباب لإكتساب الجنسية، حيث إنها تمثل نفس الشيء فيما يتعلق بفقد الجنسية الأخرى، ونكتفي هنا بدراسة فقد الجنسية من خلال السحب والإسقاط وهو ما يعرف بفقد الجنسية بالتجريد، وذلك فيما يلي:

أولاً- تعريف التجريد:

قد تزول الجنسية عن الفرد بإرادة الدولة، وذلك بأن تجرده من تلك الجنسية رغماً عنه، وقد تقصر الدولة هذا الإجراء على الوطنى الطارئ الذي دخل في جنسيتها حديثاً، وقد تجعله عام التطبيق فيمتد إلى الوطنيين الأصلاء، ويطلق على الحالة الأولى سحب الجنسية، بينما يطلق على الحالة الثانية الإسقاط^(٣).

(١) د. فؤاد رياض، د. أحمد عشوش: أحكام الجنسية ومركز الأجانب في القانون المصرى والقانون المقارن سنة ١٩٨٢، دار النهضة العربية، ص ٧٤.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٥٥، ١٥٦.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٨٥.

وقيام الدولة بتجريد الفرد من جنسيتها يرجع إلى أن الدولة قررت أن هذا الفرد لم يعد جديراً بحمل جنسيتها، فتسحبها منه أو تجرده منها كنوع من الجزاء، وقد كان هذا الإجراء في البداية مقصوراً على من دخل في جنسية الدولة في تاريخ لاحق على الميلاد ثم امتد إلى الوطنيين الأصلاء، ويطلق عليها في الحالة الأولى السحب وفي الحالة الثانية الإسقاط.

ويعرف السحب بأنه "عدول الدولة عن منح الجنسية للوطني الطارئ أو سحب جنسيتها منه، ويكون ذلك في خلال فترة معينة تالية على دخوله في جنسيتها"^(١).

ويعرف الإسقاط بأنه "تجريد الوطني أياً كان من الجنسية، ويمكن للدولة الإلتجاء إليه في أي وقت"^(٢).

وقد تكون السلطة المختصة بتجريد الأفراد من جنسيتهم على النحو السابق هي السلطة التنفيذية كما هو الشأن في مصر، وقد تكون السلطة القضائية كما هو الحال في بلجيكا.^(٣)

ثانياً- أسباب التجريد:

يمكن رد جميع الأسباب التي يمكن أن يرتكن إليها المشرع للتجريد من الجنسية إلى فكرة عدم الولاء للدولة أو عدم صلاحية الفرد لأن يكون عضواً في مجتمع الدولة، ويمكن التعرض لهذه الأسباب على النحو التالي.

١- عدم الولاء للدولة:

تأخذ معظم الدول بفكرة عدم الولاء للدولة كمبرر لتجريد الفرد من الجنسية سواء بالسحب أو الإسقاط، ومن مظاهر عدم الولاء للدولة الخدمة في القوات العسكرية^(٤)، أو القيام بعمل لصالح دولة أخرى تتعارض مصالحها مع مصالح دولته^(٥)، ومن مظاهر عدم الولاء للدولة أيضاً ارتكاب الفرد لجريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة.^(٦)

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٠٢.

(٢) المرجع السابق ص ٢٠٢، ٢٠٣.

(٣) د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص ٢١٦.

(٤) راجع في ذلك نص المادة ١٦ من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والمادة ١٥ من تشريع الجنسية السوري الصادر سنة ١٩٥٣ والمادة ٩٧ من تشريع الجنسية الفرنسي الصادر سنة ١٩٤٥ والمادة ٧ من تشريع الجنسية الدانمركي الصادر سنة ١٩٥٠.

(٥) راجع في ذلك نص المادة ١٥ من الدستور الكندي سنة ١٩٥٢ والمادة ١٦ من تشريع الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والمادة ١٢ من تشريع الجنسية الألباني الصادر سنة ١٩٤٦.

(٦) راجع في ذلك نص المادة ١٥ الفقرة الثانية من تشريع الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥.

٢- عدم الاندماج في الجماعة الوطنية:

ويستشف ذلك من عدة دلائل أهمها ترك إقليم الدولة والإقامة في الخارج، وهو ما يدل على ضعف شعور الفرد تجاه دولته وعدم قدرته على الاندماج في جماعته الوطنية، وتعتبر بعض الدول ذلك سبباً فقط للسحب^(١)، بينما تعتبره دولاً أخرى سبباً لكل من السحب والإسقاط على السواء^(٢).

وتعتبر بعض التشريعات تجنس الوطني بجنسية دولة أجنبية دون حصوله على إذن بالتجنس صادر منها دليلاً على عدم اندماجه في الجماعة الوطنية مما يعطيها الحق في تجريده من جنسيته^(٣).

٣- عدم الصلاحية للجماعة الوطنية:

من الدلائل على ذلك عدم سلامة خلق الشخص، ويتضح ذلك في حالة إذا ما أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدور أحكام ضده بعقوبات معينة، وغالباً ما تعتبره الدولة مبرراً للسحب دون الإسقاط^(٤).

ويعتبر قيام الشخص أيضاً بأعمال غير مشروعة كتجارة المواد المخدرة سبباً يبرر تجريده من جنسيته، وهو ما نصت عليه المادة ١٩ من تشريع الجنسية الأرجنتيني الصادر سنة ١٩٥٤^(٥)، وتذهب بعض التشريعات إلى تجريد الشخص من جنسيته لمجرد إنتمائه إلى دين أو جنس أو مذهب سياسي معين، وهو ما فعلته ألمانيا النازية ضد اليهود، والاتحاد السوفيتي ضد الروس المعارضين، وقد اعتبرته تلك الدول مبرراً لكل من السحب والإسقاط^(٦).

(١) راجع في ذلك نص المادة ١٥ الفقرة الثالثة من تشريع الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والمادة ٢١ من تشريع الجنسية البريطانية لسنة ١٩٤٨ والمادة ٢٠ من تشريع الجنسية الأسترالية لسنة ١٩٤٨.

(٢) راجع في ذلك نص المادة ٧ من تشريع الجنسية التشيكوسلوفاكي الصادر سنة ١٩٤٩ والمادة ٧ من تشريع الجنسية النمساوي الصادر سنة ١٩٤٩ والمادة ١٧ من تشريع الجنسية المجري لسنة ١٩٤٨.

(٣) المادة ١٦ الفقرة الأولى من تشريع الجنسية المصري الصادر سنة ١٩٧٥.

(٤) راجع في ذلك نص المادة ١٥ من تشريع الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والمادة ١٠ من تشريع الجنسية الليبي الليبي الصادر سنة ١٩٥٤ والمادة ٢١ من تشريع الجنسية الإنجليزي الصادر سنة ١٩٤٨ والمادة ٢٠ من تشريع الجنسية الأسترالي الصادر سنة ١٩٤٠.

(٥) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٠٥.

(٦) راجع في ذلك المبدأ وماوجه إليه من نقد. د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ١٨٣.

ومن مظاهر عدم الصلاحية أيضاً عدم أمانة الفرد في إكتساب جنسية الدولة، كما لو إكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو إخفاء الحقيقة، أو استخدام المستندات المزورة، وتصدق تلك الحالة بالنسبة للسحب دون الإسقاط.^(١)

ثالثاً- مشروعية التجريد من الجنسية وأثاره:

ثار الجدل في الفقه حول مشروعية التجريد من الجنسية ومدى مخالفته لقواعد القانون الدولي، فذهب إتجاه فقهي^(٢) إلى عدم مشروعية التجريد في الأحوال التي يؤدي فيها إندام الجنسية، مستندين إلى وجود الحق في الإستمرار في الجنسية، ويرى جانب آخر من الشراح أن الإسقاط الجماعي للجنسية ينطوى على مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي، على إعتبار أنه يؤدي إلى إلقاء عبء الرعايا الذين أسقطت عنهم الجنسية على عاتق الدولة الأخرى.^(٣)

ويذهب أغلب الفقه إلى عدم وجود ما يقيد حق الدولة في تجريد مواطنيها من الجنسية وفقاً لقواعد القانون الدولي، وأن القواعد التي تقرر ذلك تقوم في غالبيتها على إعتبارات إنسانية^(٤)، وتسير غالبية التشريعات في إتجاه تقرير حق الدولة في تجريد الأفراد من جنسيتهم، وهو ما جعل البعض يذهب إلى أن الأصل وفقاً لقواعد القانون الدولي المعاصر هو حرية الدولة في مسائل الجنسية، كما أن قواعد هذا القانون لا تتضمن ما يقيد من سلطة الدولة في تجريد مواطنيها من جنسيتهم سواء سحبها أو إسقاطها.^(٥)

أما فيما يتعلق بأثر التجريد فإنه يترتب عليه تجريد الوطني من الجنسية من تاريخ قرار السحب أو الإسقاط، ولا يمتد أثره إلى أسرة الشخص، وإن ذهب البعض إلى أن هؤلاء الأشخاص قد دخلوا في هذه الجنسية نتيجة لتجنسه هو فمتى زالت عنه وجب زوالها عنهم، وتتنوع حلول التشريعات في هذه المسألة بتنوع أسباب السحب أو الإسقاط، ويكون مد أثر التجريد إلى الأسرة غير متحقق إلا في حالة صدور إجراء به بإعتباره مسألة جوازية^(٦).

(١) راجع في ذلك نص المادة ١٥ من تشريع الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ والمادة ١٤ من تشريع الجنسية السوري الصادر سنة ١٩٥٣ والمادة ١٨ من تشريع الجنسية التايلاندي الصادر سنة ١٩٥٢

(٢) د. فؤاد رياض: الوسيط في القانون الدولي الخاص، فقرة ١٥٨.

(٣) راجع في تفسير هذا الرأي د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٨٦، ١٨٧.

(٤) راجع في تفصيل ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٨٧.

(٥) المرجع السابق: ص ٢٠٨.

(٦) راجع في تفصيل ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق: ص ١٨٤، ١٨٦.

الفصل السادس

مشاكل الجنسية

تقف الجنسية كنظام قانوني على الحد الفاصل بين نظامين قانونيين كلاهما يكمل الآخر، هما النظام القانوني الوطني والنظام القانوني الدولي، وحيث تحدد الجنسية ركن الشعب في النظام القانوني الداخلي، فإنها توزع مجموع البشر على دول العالم، والتي تشكل النظام القانوني الدولي، وحيث مرت الجنسية بكثير من التطورات أدت إلى تنوع الأسس التي تبنى عليها كل دولة جنسيتها الوطنية، ونتيجة لإختلاف موقف الدول من تلك الأسس، فقد أدى ذلك إلى نتيجة حتمية وهي إمكان تعدد الجنسية أو إنعدامها بالنسبة لبعض الأفراد.^(١)

ويطلق الغالب من الفقه على تعدد الجنسية وإنعدامها إصطلاحاً "التنازع الإيجابي، والتنازع السلبي"^(٢)، وهو ما جعل البعض يذهب إلى أن هذين الاصطلاحين تنقصهما الدقة، حيث أكد على أن "استعمال التنازع الإيجابي ينطوي على إسراف، على الأقل في ظل ما هو قائم وضعياً، وذلك في الفرض حيث تكون جنسية دولة القاضى المنظور أمامه المنازعة من بين الجنسيات المتزاحمة، والتي يحوزها شخص واحد، ففي هذا الفرض يذهب الإتجاه الغالب إلى عدم وجود تنازع بين جنسية دولة القاضى والجنسيات الأخرى التي يحملها الشخص، حيث لا محل للإعتراف إلا بالجنسية الأولى، وبالمثل فإن استعمال إصطلاح التنازع السلبي بدوره ليس فوق التجريح، فإذا كان عديم الجنسية في وضع لا يتمتع فيه بجنسية أى دولة من الدول، إذ قد أنكرت عليه سائر الدول تابعيته لها، فكيف نتصور أن في الأمر تنازعا؟ وهل ينشأ التنازع بين المعدم والمعدم؟"^(٣)

ونميل من جانبنا إلى إعتقاد الرأى الذي ينتقد إطلاق مصطلحي التنازع الإيجابي والتنازع السلبي على بعض المشاكل التي تحدث في مجال الجنسية، ونسير مع الإتجاه الذي يطلق على هاتين الظاهرتين إصطلاحى تعدد الجنسية وإنعدام الجنسية، وسوف ندرس كلا منهما في مبحث مستقل إضافة الى دراسة مشكلة جنسية الاشخاص الاعتبارية في مبحث ثالث، ومنازعات الجنسية والقضاء المختص بنظرها في مبحث رابع، على النحو التالى:

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ١٦١، ١٦٢.

(٢) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٠١ وما بعدها.

(٣) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٧٣.

المبحث الأول

تعدد الجنسية

يتحقق تعدد الجنسية معاصراً للميلاد أو لاحقاً عليه، فقد يولد الطفل في دولة تأخذ بحق الإقليم لأب ينتمي لدولة تأخذ بحق الدم، فيأخذ جنسية الدولة التي ولد فيها بالإضافة إلى جنسية دولة الأب، وقد يولد الطفل لأب وأم تأخذ دولة كلا منهما بحق الدم، فيتمتع بجنسية كل من الأب والأم، أما الفرض الثاني لتعدد الجنسية فهو اللاحق على الميلاد، ويحدث في الحالة التي يكتسب فيها الفرد جنسية دولة جديدة مع احتفاظه بجنسيته الأصلية، وقد تكتسب المرأة جنسية دولة الزوج إذا ما تزوجت بأجنبي مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وبذلك يتحقق تعدد الجنسية.^(١)

مساوئ التعدد:

حيث تقوم الجنسية على وجوب توافر نوع من الولاء والانتماء من جانب الفرد لدولته، وهو ما لا يمكن تصور إمكان حدوث تعدده، ومن شأن ذلك التعدد أن يثير مجموعة من المشاكل أولها مشكلة الحماية الدبلوماسية، وذلك في الفرض الذي ترغب فيه أكثر من دولة في حماية شخص ما دبلوماسياً نتيجة لتمتعه بجنسية كل منها^(٢).

وفي مجال الإلتزامات يترتب على تعدد جنسية الشخص تعارض موقفه بالنسبة لمباشرة التكاليف الوطنية في كل من هذه الدول، فقد يضطر إلى أداء الضرائب العامة في أكثر من دولة، ويزداد الأمر تعقيداً فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية، حيث سيجد الشخص نفسه ملزماً بأداء الخدمة في كل من الدولتين، والذي من الممكن أن يؤدي إلى محاكمته في إحدى الدول التي ينتمي إليها، وهو ما يتجسد في الحكم الصادر من المحكمة العليا الفدرالية الأمريكية في سنة ١٩٥٢، والتي حكمت بإدانة المدعو Tomey a Kawakita بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الجيش الياباني بالرغم من كونه أمريكياً، ولم تعدد المحكمة بكونه يتمتع بالجنسية اليابانية في نفس الوقت^(٣).

وفي مجال تنازع القوانين فإننا نجد أن مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق تثور بصدد بعض العلاقات التي يدخل فيها متعدد الجنسية، وذلك في الحالات التي يكون القانون الواجب التطبيق فيها هو قانون جنسية الشخص^(٤).

(١) راجع في تفصيل أسباب تعدد الجنسية د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٧٥، ٢٧٨. د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص ١٦٨ - ١٧١.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٥٤.

(٣) راجع في ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ١٩٧. د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٥٥.

(٤) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٥٦.

وفي مجال الإختصاص القضائي الدولي والإعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، تثار مشكلة تتعلق بالحالة التي يعتد فيها المشرع بضابط الجنسية كأساس لعقد الإختصاص المباشر لمحاكم دولته في المنازعات ذات الطبيعة الدولية، وأى من جنسيات متعدد الجنسية سيؤخذ بها عند تحديد ذلك الإختصاص^(١).

تلافي تعدد الجنسية:

يرى البعض إمكان تلافي ظاهرة تعدد الجنسية عن طريق توحيد أسس الحصول عليها، كأن تبني كافة الدول جنسيتها الأصلية على أساس حق الإقليم فقط أو حق الدم فقط، وبالمثل توحد الدول أسس إكتساب الجنسية اللاحقة بحيث تضع شروطاً مماثلة لإكتساب جنسيتها^(٢).

ولكن في الواقع يصعب وضع هذا الإقتراح موضع التنفيذ الفعلي، نظراً لإختلاف الدول بين الإعتداد بحق الدم وحق الإقليم في منح الجنسية، بل إن توحيد الأسس التي يقوم عليها إكتساب الجنسية الأصلية قد يؤدي في بعض الفروض إلى قيام ظاهرة التعدد، وهو ما حدث بالفعل بشأن جنسية CARLIER حيث ولد هذا الشخص في بلجيكا من أبوين فرنسيين، فحصل على الجنسية الفرنسية بناء على حق الدم، وعندما بلغ سن الرشد طلب الدخول في الجنسية البلجيكية فحصل عليها بموجب حق الإقليم والإختيار، فأصبح متعدد الجنسية بالرغم من وحدة أسس الحصول على الجنسية في هاتين الدولتين، حيث يقضى القانون في كل منهما بالأخذ بحق الدم من ناحية الأب، وبأن من يولد لأجنيين في إقليم الدولة يعتبر أجنياً، ولكنه يستطيع الدخول في جنسيته الدولة خلال سنة من بلوغه سن الرشد إذا ما طلب ذلك^(٣).

وإزاء عدم فاعلية الإقتراح الأول فقد أقتراح جانب آخر وضع ترتيب معين لأسس إكتساب الجنسية بحسب أهميتها وقوتها، كأن يوضع حق الدم في مرتبة أعلى من حق الإقليم وهكذا^(٤).

ويعاب على هذا الرأي أنه "يستلزم إنفاقاً دولياً على قوة الأسس، ويتعذر هذا الإتفاق، فضلاً عن تعذر الترجيح بين الأسس المعززة بشتى الإعتبارات^(٥).

ويقترح جانب آخر من الشراح لتلافي ظاهرة تعدد الجنسية أعمال فكرة التقادم المسقط كما هو الحال في مجال الحقوق الخاصة، فحينما لا يمارس الشخص حقوقه الوطنية في إحدى الدول التي يتمتع

(١) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٨١.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٥٦.

(٣) راجع في تفصيل وقلع تلك القضية وملابساتها. د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٥٧.

(٤) راجع في غرض هذا الرأي. د. أحمد مسلم: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، فقرة ١٣٨.

(٥) د. أحمد مسلم: المرجع السابق، فقرة ١٣٨.

بجنسيتها ولا يلتزم بالتكاليف العامة فيها تسقط عنه جنسية هذه الدولة، ويعاب على هذا الاقتراح بأنه لا يمنع نشوء ظاهرة تعدد الجنسية وإنما يكفي بعلاجها بعد أن نشأت بالفعل.^(١)

لذلك إتجه البعض أيضاً إلى الإعتداد أساساً باستقرار الأبوين في إقليم الدولة عند منح الجنسية، بحيث لا تمنح الدولة جنسيتها إذا ولد الطفل لأبوين وطنيين مستقرين خارج إقليم الدولة، ولمن يولد على إقليم الدولة لأبوين أجنبيين مستقرين في الخارج، ويعاب على هذا الرأي أنه يقتضى إبرام اتفاق دولي لكي تلتزم جميع الدول بهذا المعيار، وقد تصادفه في كثير من الأحيان صعوبات عملية متعلقة بتحديد جنسية من يولد لأبوين مستقرين في الخارج لإحتمال تعدد جنسيتيهما.^(٢)

ومن الملاحظ أن كثير من التشريعات لا تأخذ بأى من الحلول السابقة، وبذلك تبقى فرص تعدد الجنسيات قائمة نظراً لإختلاف صياغة أحكام الجنسية في كل دولة وفقاً لمصالحها الوطنية الخاصة.^(٣)

علاج مشكلة تعدد الجنسية:

حيث لا يمكن تلافي ظاهرة تعدد الجنسية مثلما سبق الحديث عن أسبابها، فإنه لا بد من مواجهة تلك الظاهرة بعد نشوئها، ويتمثل أول حل يمكن الأخذ به لعلاج تلك المشكلة في إبرام معاهدات ثنائية وجماعية لحل بعض مشكلات تعدد الجنسية، مثل تحديد دولة أداء الخدمة العسكرية أو تلافي الإزدواج الضريبي أو حل تعدد جنسيات المرأة المتزوجة.^(٤)

ولكن من الملاحظ على الإتفاقات الدولية أنها لم تضع إلا حلولاً جزئية لمشكلة تعدد الجنسية، حيث إكتفت بإزالة بعض من الآثار السيئة لتلك الظاهرة دون أن تضع معياراً واضحاً لتفضيل إحدى الجنسيات المتركمة على الشخص الواحد، وذلك نظراً لأهمية ذلك التحديد في مجال بيان القانون الواجب التطبيق، وتحديد مركز متعدد الجنسية بين الأجانب، لذلك فلا بد من وضع معيار للتفضيل بين الجنسيات المختلفة التي يحملها متعدد الجنسية.

توجد قاعدة مستقرة على المستويين الداخلي والدولي مفادها إعتداد الدولة بجنسيتها فقط، إذا كانت من بين الجنسيات التي يحملها الفرد، وهو ما أخذ به المشرع المصري في المادة ٢٥ من القانون المدني التي تنص في فقرتها الثانية على أن "الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٠٠، ٢٠١.

(٢) في تفصيل هذا الرأي والنقد الموجه إليه د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٥٨، ٢٥٩.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٠١.

(٤) راجع في ذلك

(4) RIGAUX Francois: Droit international prive, Bruxelles, 1968, p. 283

الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه".

وفي حالة ألا تكون جنسية الدولة التي يعرض أمام قضائها النزاع إحدى جنسيات متعدد الجنسية، فقد ذهب رأى إلى وجوب تفضيل أحكام القانون الأقرب في أحكامه إلى قانون القاضي، ويعاب على هذا الرأى بأنه يفترض أن قانون القاضي أفضل من غيره من القوانين، وذلك على الرغم من عدم وجود مصلحة وطنية لدولة القاضي، حيث إن جنسيتها ليست إحدى الجنسيات المتعددة.^(١)

ويذهب البعض الآخر إلى الأخذ بفكرة تكافؤ السيادة، وأساس هذا الرأى أن الدولة الغير لا تملك إنكار جنسية دولة أجنبية، مادام أن متعدد الجنسية قد اكتسبها إكتساباً صحيحاً وفقاً لقانون هذه الدولة الأخيرة، وبذلك يتعين على الدولة أن تعترف بهذه الجنسيات جميعاً، حيث أن في تفضيل إحداها على الأخريات مساس بسيادة الدولة الأخرى التي أنكرت الإعتراف بجنسيتها، ويستطيع متعدد الجنسية في هذه الحالة أن يتمسك بأى من هذه الجنسيات حسب مصلحته، ويعاب على هذا الرأى أنه يضع متعدد الجنسية في مركز قانونى مضطرب، بالإضافة إلى أن منح الشخص حرية الإختيار أمر لا يمكن التسليم به حيث إن "الجنسية من روابط القانون العام فلا يصح أن تكون محلاً للاختيار على هذا النحو، فضلاً عن أن الشخص قد تلحقه الوفاة دون أن يفصح عن إختياره، كما إذا أريد تحديد القانون الواجب تطبيقه على تركته مثلاً".^(٢)

وأمام الإنتقادات التي وجهت إلى هذا الرأى فقد ذهب رأى إلى وجوب الإعتداد بالجنسية التي اكتسبها أولاً.^(٣) وقد عيب على هذا الرأى أنه يتجاهل إرادة الفرد التي أتجهت إلى اكتساب جنسية دولة أخرى، كما أنه يمثل اعتناقاً لمبدأ الولاء الدائم الذي هجره الفقه منذ وقت طويل.^(٤)

وقد ترتب على الاعتراضات الموجهة إلى الحل السابق إتجاه البعض إلى الأخذ برأى عكسى، مقتضاه وجوب تفضيل أحدث جنسية أكتسبها الفرد، لأنها المعبرة عن إرادة الفرد الحقيقية والحالية، طالما أن الفرد قد دخل في هذه الجنسية الأخيرة بناء على طلبه، ولكن يعاب على هذا الرأى عدم إعتداده بالجنسية الأولى بالرغم من استمرار الفرد متمتعاً بها، وكأن خروج الفرد من جنسيتها يتم بدون إرادتها.^(٥)

(١) راجع في تفصيل هذا الرأى د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٦٣.

(٢) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٠٥. وفي تفصيل هذا الرأى راجع د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٣٨، ٣٣٩.

(٣) من القائلين بهذا الرأى

(3) PILLET Pierre "principes de droit international prive" n. 316

(٤) راجع في تفصيل هذا الرأى د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٢٢، ٢٢٣.

(٥) راجع في تفصيل هذا الرأى د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٦٤، ٢٦٥.

ولما كانت الحلول السابقة لم يكتب لها النجاح ووجهت إليها الانتقادات، فقد هجرها القضاء الدولي، ولم تأخذ بها المحاكم الوطنية في كثير من الدول.

وإتجه إلى ضرورة الإستعانة بالظروف الواقعية المحيطة بكل من الجنسيات المتنازعة، ليتبين مدى إرتباط الفرد من الناحية الفعلية بكل منها، وهو ما يطلق عليه مبدأ الجنسية الفعلية، وهي التي تتفق مع أسس قاعدة الجنسية وهي كون الفرد عضواً حقيقياً في مجتمع الدولة الوطنى، وتعتبر قضية De Brissot من أول القضايا التي أخذ فيها القضاء الدولي بفكرة الجنسية الفعلية، حيث طرحت تلك القضية سنة ١٨٥٥ على لجنة التحكيم المختلطة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وأعيد تطبيق ذلك المبدأ بصدد النزاع الذي ثار بين بيرو وإيطاليا حول جنسية شخص يدعى رافائيل كانيفارو، حيث إن ذلك الشخص ولد متمتعاً بجنسية كل من إيطاليا وبيرو في نفس الوقت، نظراً لميلاده لأب ينتمى إلى الجنسية الإيطالية القائمة على حق الدم في إقليم دولة بيرو التي تأخذ بحق الإقليم، ولما طالبته الحكومة البيرونية بسداد الضرائب المستحقة عليه رفض إستناداً إلى كونه إيطاليا وطالب بحماية الحكومة الإيطالية، وقد ترتب على هذا أن رفع النزاع بين الحكومة الإيطالية وحكومة بيرو أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، والتي أصدرت حكماً في ٣ مايو سنة ١٩١٢ باعتبار ذلك الشخص بيروياً وإستناداً إلى أنه قام في بيرو بمباشرة حقوقه السياسية مما يدل على أن جنسيته الفعلية هي جنسية بيرو.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في حكمها الصادر سنة ١٩٥٥ في قضية المدعو نتبام، وقد عرفت المحكمة في هذا الحكم الجنسية الفعلية بأنها "الجنسية التي تتفق مع الحالة الواقعية والتي تقوم على أقوى رابطة حقيقية وفعلية بين الفرد وإحدى الدول التي تتنازع جنسياتها" وقد أكد القضاء الدولي مبدأ الجنسية الفعلية في حكم حديث أصدرته محكمة التحكيم الأمريكية الإيرانية في ٢٩ مارس سنة ١٩٨٣ في قضية المدعو ناصر الأصفهاني ضد أحد البنوك.

وتذهب العديد من تشريعات الجنسية الحديثة إلى الأخذ بمعيار الجنسية الفعلية في تحديد القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسيات، ومنها القانون الدولي الخاص السويسرى الصادر سنة ١٩٨٧، وتشريع الجنسية البرتغالى سنة ١٩٨١، والقانون الدولي الخاص التركى لسنة ١٩٨٢، وهو ما أخذت به إتفاقية لاهاي المنعقدة سنة ١٩٣٠ بشأن الجنسية في المادة الخامسة منها، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بصدد التعليق على نص المادة ٢٥/١ من القانون المدنى المصرى أنه "يعد في حالة التنازع الإيجابى متى كانت الجنسية المصرية غير داخلة في النزاع بالجنسية التي يظهر من الظروف أن الشخص يتعلق بها أكثر من سواها" ومن هذا يتضح لنا تبنى المشرع المصرى فكرة الجنسية الفعلية كضابط يتم على اساسه تفضيل إحدى الجنسيات المتنازعة في حالة تعدد الجنسيات^(١).

==

(١) راجع في تفصيل هذا الرأى د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ١١٠ - ١١٥.

المبحث الثاني

إنعدام الجنسية

لا تعتبر مشكلة تعدد الجنسية هي المشكلة الوحيدة بصدد التنظيم الوضعي للجنسية، وإنما توجد مشكلة أخرى متعلقة بإنعدام الجنسية، ومع أن تلك المشكلة أقل حدوثاً في الواقع العملي، إلا أنها أشد إضراراً بحق الفرد ومركزه القانوني طبقاً للأثار والمخاطر المترتبة عليها من الأضرار المترتبة على تعدد الجنسية، وللتعرف على تلك المخاطر والآثار المترتبة على إنعدام الجنسية، فإننا سنتعرف أولاً على تعريف إنعدام الجنسية، ثم نعقبه بالتعرف على كيفية تلافي تلك الظاهرة، ونعرض أخيراً كيفية علاج تلك المشكلة.

أولاً- تعريف إنعدام الجنسية وأسبابه:

يذهب البعض إلى تعريف إنعدام الجنسية بأنه "وضع قانوني لشخص لا يتمتع بجنسية أية دولة على الإطلاق"^(١). وبذلك فإن عديم الجنسية لا يتمتع بعضوية أية دولة على الإطلاق، وبذلك فلا يستطيع طلب أية حماية دبلوماسية أو قنصلية، فهو دائماً معرض للترحيل والإبعاد من أقاليم جميع الدول التي ينزل بها.

وفيما يتعلق بأسباب إنعدام الجنسية فمنها ما يرجع إلى تاريخ معاصر للميلاد ومنها ما يتحقق في تاريخ لاحق عليه.

١- أسباب الإنعدام المعاصر للميلاد:

يمثل إختلاف الأسس التي تأخذ بها الدول في شأن فرض جنسيتها الأصلية أحد أسباب الإنعدام المعاصر للميلاد ومثاله أن يولد طفل لوالدين تأخذ دولتهما بحق الإقليم في دولة تعتق حق الدم كأساس لفرض جنسيتها الأصلية إذ سيولد الطفل في هذه الحالة معدوم الجنسية، حيث إنه لن يكتسب جنسية أبويه بناء على حق الدم، ولن يكتسب جنسية الإقليم الذي ولد فيه، وقد يتحقق إنعدام الجنسية رغم اتحاد الأسس التي تأخذ بها الدول في فرض جنسيتها الأصلية، فقد تأخذ الدولة بحق الدم المستمد من الأب فقد يولد طفل غير شرعي على إقليمها فيعتبر الطفل في هذه الحالة عديم الجنسية منذ ميلاده، ولن يفيد الأخذ بحق الدم المستمد من جهة الأم في منح الجنسية الأصلية في هذه الحالة إذا كانت الأم معدومة الجنسية بدورها^(٢).

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٢٣٨.

(٢) راجع تفصيل أسباب الإنعدام المعاصر للميلاد د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٢٤٢ وما بعدها.

٢- أسباب الإنعدام اللاحق على الميلاد:

قد يفقد الشخص جنسيته دون أن يتمكن من إكتساب جنسية دولة أخرى، ويصبح في هذه الحالة عديم الجنسية، وبذلك فإن جميع أسباب زوال الجنسية قد تكون في نفس الوقت أسباباً لإنعدامها، وقد يمثل تجريد الدولة للفرد سواء بالسحب أو الإسقاط أحد أسباب إنعدام الجنسية.^(١)

ولإنعدام الجنسية مساوئ عديدة حيث لن يجد عديم الجنسية أية دولة تحميه دبلوماسياً إذا ما تعرض للإنعدام من قبل إحدى الدول، كما أنه تثار مشكلة متعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية في حالة ما إذا كان هذا التحديد يتم على أساس جنسيته، وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، والتي تضع لها العديد من الدول ضابطاً للإسناد هو ضابط الجنسية، كما يتعرض عديم الجنسية لمشكلة البحث عن مأوى يتوطن فيه حيث لا يتمتع ذلك الشخص بجنسية أية دولة، فهو في حكم الأجانب بالنسبة لكافة الدول ويصبح معرض للإبعاد من إقليم أى من الدول التي يرغب بالإستقرار فيها.^(٢)

ثانياً- تلافي إنعدام الجنسية:

إقترح البعض لتلافي ظاهرة إنعدام الجنسية إستعارة فكرة التقادم المكسب المعروفة في القانون المدني، بمعنى أنه يحق لمن يقيم بإقليم الدولة خلال مدة معينة إكتساب جنسية هذه الدولة، وفي الحقيقة فإن تلك الوسيلة تمثل علاجاً للمشكلة بعد حدوثها، كما أنها تتوقف في نفس الوقت على موقف الدولة التي يقيم فيها عديم الجنسية.^(٣)

ويذهب البعض إلى القول بإمكانية تلافي ظاهرة إنعدام الجنسية المعاصر للميلاد عن طريق الأخذ بأساس احتياطي لفرض الجنسية الأصلية، ففي الحالة التي لا يستطيع فيها الشخص اكتساب جنسية الدولة عن طريق الأساس الأول عند ميلاده فيتم اللجوء إلى الأساس الاحتياطي.^(٤)

أما في مجال الإنعدام اللاحق على الميلاد فمن الممكن تلافيه عن طريق تنظيم تغيير الفرد لجنسيته، بحيث لا يؤدي هذا التغيير إلى جعله عديم الجنسية، ففي مجال التجنس يجب أن تعلق تشريعات الدول فقد الشخص لجنسيته على اكتساب جنسية الدولة الجديدة، وفيما يتعلق بالزوجة والأولاد القصر فيجب تعليق فقدهم لجنسيتهم على الدخول في جنسية الدولة الجديدة، وكذلك بالنسبة للزواج فيجب تعليق فقد الوطنية لجنسيتها بالزواج من أجنبي على دخولها في جنسية زوجها.

(١) راجع في تفصيل أسباب الإنعدام اللاحق على الميلاد د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٣٨.

(٢) راجع في تفصيل المشاكل المترتبة على إنعدام الجنسية ووسائل تلافيها د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١١٠ وما بعدها.

(٣) راجع في ذلك د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٧١.

(٤) راجع في تفصيل تلك الفكرة د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٤٢، ٢٤٣.

وكذلك يتعين على الدول أن تتحاشى سحب جنسيتها أو إسقاطها عن الوطنيين، إلا في الحالات التي يتمكن فيها البعض من الدخول في جنسية أجنبية.^(١)

ثالثاً- الوسائل العلاجية لإنعدام الجنسية:

تمثل مشكلتي مركز عديم الجنسية بين الأجانب، وتحديد القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، أهم مشكلتين يجب البحث عن حل لعلاجهما، وذلك على النحو التالي:-

١- مركز عديم الجنسية بين الأجانب:

لا يعتبر عديم الجنسية أجنبياً في مواجهة دولة بعينها، وإنما يعتبر كذلك بالنسبة لسائر الدول بلا استثناء، ولذلك فقد بعث هذا المركز الذي يتمتع به عديم الجنسية والذي يتسم بالقلق والإضطراب معظم الدول إلى تيسير الإقامة وتسهيل عمليات التنقل له عبر الحدود، كما جرت الدول على تزويد عديم الجنسية بوثائق السفر التي تجيز له التنقل عبر الحدود، وهو ما فعلته أيضاً هيئة الأمم المتحدة عن طريق وكالاتها المتخصصة في شؤون اللاجئين، وقد جرت العادة في كثير من الدول على السماح لعديم الجنسية بالتمتع بالحقوق الخاصة مثل غيره من الأجانب، وفي المقابل تفرض عليه الإلتزام بأداء بعض التكاليف العامة التي يخضع لها الوطنيون مثل الإلتزام بأداء الخدمة العسكرية.^(٢)

٢- القانون الواجب التطبيق على عديم الجنسية:

يتعلق البحث في هذا المجال بالقانون الواجب التطبيق بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لعديم الجنسية.

إنه جانب من الفقه إلى وجوب تطبيق قانون القاضي، حيث إنه لا يوجد في هذه الحالة تنازع قوانين، ولا محل بالتالي للأخذ بقواعد إسناد، ويعاب على هذا الرأي إحتمال عدم وجود أية صلة بين دولة القاضي والمسألة المطروحة، وبذلك فلا مبرر من تطبيق قانون القاضي في هذه الحالة.^(٣)

ويذهب جانب آخر من الفقه إلى ترجيح قانون آخر دولة كان يتمتع بجنسيتها عديم الجنسية، ويعاب على هذا الرأي أنه يعتد برابطة لم يعد لها وجود، وأنه لا يقدم الحل في الفرض الذي يتحقق فيه إنعدام الجنسية المعاصر للميلاد.^(٤)

(١) راجع في تفصيل كيفية تلاقي إنعدام الجنسية د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ١٢٥ - ١٢٨. د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٢٤٦ وما بعدها.

(٢) راجع في تفصيل المركز القانوني لعديم الجنسية بين الأجانب دكتور هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٢٤٥، ٢٤٧، د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٨١، ٣٨٣.

(٣) راجع في تفصيل هذا الرأي د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢٧٣.

ويُتجه فريق ثالث من الشراح إلى تطبيق قانون الدولة التي ولد فيها عديم الجنسية إذا كانت هذه الدولة معروفة، وإذا لم تعرف فإنه يجب الرجوع إلى قانون دولة محل إقامة عديم الجنسية، ويعاب على هذا الرأي أن واقعة الميلاد قد تكون واقعة عرضية لا تعبر عن أى ارتباط بين الشخص والدولة.^(٢)

ويميل الرأي الراجح في مصر والخارج إلى القول بفكرة شبيهة بفكرة الجنسية الفعلية التي قيل بها بصدد تعدد الجنسية، ومقتضى تلك الفكرة أن يعامل عديم الجنسية على أنه ينتمى إلى الدولة التي يرتبط بها أكثر من غيرها من الناحية العملية، وتتمثل بالنسبة له عادة في وجود موطنه أو محل إقامته والكشف عن وجود ذلك الارتباط يعتبر مسألة واقع، يستقل بتقديرها قاضى الموضوع مستعيناً بكافة العناصر المحيطة به.^(٣)

ونميل من جانبنا إلى ترجيح هذا الرأي، ونسير مع الفقه القائل بأن المشرع المصرى قد اعتمد هذا الرأي، وذلك طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥ من القانون المدنى، والتي تنص على أنه "يعين القاضى القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا يعرف لهم جنسية وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لهذا النص "أنه يراعى أن تخويل القاضى سلطة التقدير وفقاً لأحكام الفقرة الأولى خير من تقييده بضوابط تحد من إجهاده، والغالب أن يعتد القاضى في حالة التنازع السلبي للجنسية بقانون موطن الشخص".^(٤)

المبحث الثالث

مشكلة جنسية الاشخاص الاعتبارية

من المعروف ان الطرف الثاني في علاقة الجنسية مع الدولة هو الفرد أو الشخص، ولكن ما هو المقصود بالشخص؟ هل مطلق الشخص القانونى في المفهوم الفنى لهذه الكلمة؟ بحيث تشمل كل من يتمتع بالشخصية القانونية سواء الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية، أم أن هذا الوصف ينتفى عن الأشخاص الاعتبارية؟ .

يؤكد بعض الفقه أن الطرف الآخر في رابطة الجنسية هو الشخص الطبيعي وليس الشخص الاعتبارى، وذلك على أساس أن الجنسية هي نظام قانونى يتم به تحديد ركن الشعب في الدولة، وبذلك لا يمكن أن تسند لغير الأشخاص الطبيعية، وحيث أن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية ينتسب الفرد بمقتضاها إلى دولة معينة طبقاً لتعريفها السابق التوصل إليه، فإنه يتوافر دائماً وراء هذه الرابطة مجموعة من المشاعر القومية والاجتماعية والروحية والتي تعبر عن الولاء لتلك الدولة، وحيث أن

(١) راجع في تفصيل هذا الرأي والانتقادات الموجهة إليه د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٨٨.

(٢) راجع أيضاً في هذا الرأي والانتقادات الموجهة إليه. د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٨٩.

(٣) راجع في تفصيل تلك الفكرة د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٤٨، ٢٤٩.

(٤) راجع عكس هذا الرأي د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٣٩١، ٣٩٢.

الولاء لا يتصور بمعناه الواقعي إلا من إنسان، فإن رابطة الجنسية لا يجوز أن تمنح إلا لإنسان أى شخص طبيعي^(١).

ومن هنا يثور التساؤل حول مدى تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية؟ حيث أن استعمال تعبير الجنسية بالنسبة للشخص الاعتباري ينطوي على شئ من التفاضل عن الواقع، حيث أن طبيعة الشخص الاعتباري تتنافى مع إمكان أداء التكاليف الوطنية، ومع إمكانية الشعور بالولاء الذي تقوم عليه رابطة الجنسية^(٢)، ولذلك فقد اختلف الفقه حول مدى تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية، وعلى ذلك سنعرض أولاً للخلاف حول تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية، ونعرض ثانياً لضوابط تحديد جنسية تلك الأشخاص، ثم نوضح المعيار الذي تبناه المشرع المصري في هذا الإطار، وذلك على النحو التالي:-

المطلب الأول

الخلاف حول تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية

- - -

يتنازع هذه المسألة اتجاهان أحدهما يذهب الى عدم تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية والآخر يذهب الى تمتع تلك الأشخاص بالجنسية:

١- الاتجاه المنكر ل تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية:

حيث أن الجنسية هي علاقة بين الفرد والدولة تتضمن انتماء هذا الفرد إلى تلك الدولة، فإنها بهذا المعنى لا تتوافر إلا بالنسبة للشخص الطبيعي، وهو ما يراه بعض الفقه الذي ذهب إلى إنكار فكرة الجنسية عن الأشخاص الاعتبارية، وقصرها فقط على الأشخاص الطبيعية، واستند هذا الفقه على مجموعة من الحجج:-

أولها: أن طبيعة ووظيفة فكرة الجنسية بقصراتها على الأشخاص الطبيعية دون الأشخاص الاعتبارية، حيث تستخدم الدولة فكرة الجنسية لتحديد عنصر الشعب فيها، وحيث إن الأشخاص الاعتبارية لا تدخل ضمن ذلك الشعب، فإنها لا تتمتع بالجنسية، ومرد الأمر في ذلك أنه إذا أجرت الدولة تعداداً لسكانها فإن الأشخاص الاعتبارية لا تدخل فيه^(٣).

(١) د. هشام صادق: الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، المجلد الأول، ١٩٧٧، منشأة المعارف ص ٤٩، ٥٠.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ١٧.

(٣) د. أحمد عبد الكريم: المرجع السابق، ص ٥١.

ثانيها : أن كلاً من أسس منح الجنسية والآثار المترتبة عليها لا تتوافر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، فقد تمنح الجنسية على أساس حق الدم أو النسب كالميلاد لأب وطني أو أم وطنية، ومن أثارها أن يتمتع من يملكها بأهلية ممارسة الحقوق وتحمل الأعباء، وهو ما لا يصدق بالنسبة للأشخاص الاعتبارية^(١).

ثالثها : أن العنصر الفاعل في منح الجنسية هو الشعور بالولاء والانتماء، وهذا الشعور وذلك الانتماء لا يتوافران إلا لدى الشخص الطبيعي، ولا يمكن أن يتوافرا لدى الشخص الاعتباري وهذا الشعور " يستند إلى صلة من لحم ودم، ولا يخص إلا بشر، وليس سائر الكائنات القانونية " فهي علاقة تقوم على دعائم خلقية ونفسية وعضوية وترجع إلى أن الإنسان له جسد وروح"^(٢).

وخلاصة هذا الرأي أنه يستحسن استبعاد اصطلاح الجنسية فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، وأن يتم استبداله باصطلاح التبعية القانونية أو النظام القانوني للشخص المعنوي^(٣).

٢- الاتجاه المؤيد لتمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية:

نظراً لما تتمتع الأشخاص الاعتبارية من أهمية اقتصادية سواء في المجال الداخلي أو الدولي، فقد ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة الاعتراف بالجنسية للأشخاص الاعتبارية، واستند أنصار هذا الاتجاه على مجموعة من الحجج:-

أولها: أن عدم توافر فكرة الولاء للدولة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ليس مبرراً لعدم تمتعها بالجنسية، لأنه إذا كان الشعور بالولاء يمثل أساساً لرابطة الجنسية، إلا أنه ليس ركناً لقيامها، وخير دليل على ذلك تمتع المجنون والصغير غير المميز بالجنسية.

ثانيها: أنه إذا ترتب على رابطة الجنسية بعض الالتزامات التي لا تتمكن الأشخاص الاعتبارية من القيام بها، إلا أن ذلك ليس مقصوراً على الأشخاص الاعتبارية فقط، فالنساء على سبيل المثال ليس لديهن القدرة على أداء الخدمة العسكرية ومع ذلك فهن يتمتعن بالجنسية.

ثالثها: أنه إذا وجدت بعض الأسس المتعارف عليها بخصوص اكتساب الجنسية، والتي لا يمكن إعمالها بصدد الأشخاص الاعتبارية، مثل اكتساب الجنسية على أساس حق الدم، فمردود عليه بأن وجود الحق

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد، د. خالد رأفت: المرجع السابق، ص ٩٧.

(٢) راجع في ذلك

- SAVATIER (R.): cour de droit international prive L.G.D.J. 1947 n° 44. p. 31 et.s. n° 45. p. 32 .

(٣) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، ١٩٨٥، بند ٢٣٢، ص ٣٠٩، ٣١٠.

شئ وكيفية اكتسابه شئ آخر، كما أنه توجد أسس أخرى يتم على أساسها تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية مثل مركز الإدارة ومكان التأسيس^(١).

ومن جانبنا نسير مع الرأي الراجح فقهيًا، والذي يرى ضرورة الاعتراف بالجنسية للأشخاص الاعتبارية، نظرًا لما تمثله تلك الأشخاص في هذا العصر من أهمية في تشكيل كيان الدولة الاقتصادي، وما تمارسه من تأثيرات على اقتصاد الدولة، وقد أقرت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ منذ فترة طويلة، وذلك بحكمها الصادر في ٣١ يناير ١٩٤٦، حيث تقرر أن "كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد في مصر شخصًا اعتباريًا، والجنسية كما هي من لوازم الشخص الطبيعي هي من لوازم الشخص الاعتباري، فكل شركة تجارية غير شركة المحاصة لا بد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانوني وهذه الجنسية يعينها القانون"^(٢).

وهو ما أقره المشرع المصري بنص المادة ٤١ من القانون التجاري والتي جاء بها أن "جميع شركات المساهمة التي تؤسس في القطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي بالقطر المذكور".

ولكن نظرًا لتفرد بعض الأشياء بخصوصية معينة، فإننا نرى ضرورة أفراد مدى تمتعها بالجنسية في هذا الجزء، وتلك الأشياء هي السفن والطائرات، حيث يذهب الإتجاه الغالب فقهيًا إلى إنكار تمتع تلك الأشياء بالجنسية، وذلك على الرغم مما يجرى عليه العمل من إلحاق وصف الجنسية بهذه الأشياء، كان يقال بأن تلك الطائرة طائرة مصرية، أو أن هذه السفينة سفينة فرنسية، حيث إن ذلك لا يعدو أن يكون نوعًا من الارتباط بالدولة طبقًا لضوابط متعددة وأثار خاصة، فالحقيقة أن "الأشياء لا تصلح طرفًا في رابطة الجنسية إذ الأشياء لا تعدو كونها موضوعًا للحق وليس يراد بجنسية هذه الأشياء إلا كونها مقيدة في الدولة التي تحمل رايته ومن ثم تخضع لسيادتها".

فالجنسية في هذا المجال معناها الانطواء تحت العلم، وليس معناها تلك العلاقات الروحية التي تقوم عليها الجنسية بمعناها الحقيقي والتي يتمتع بها الأفراد^(٣)، وبذلك فإن هذه التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية هي تسمية خاطئة، نظرًا لارتباط فكرة الجنسية بفكرة الشخصية القانونية، وتلك

(١) راجع بالتفصيل في هذا الاتجاه د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٥٢، وما بعدها.

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٣ وما بعدها.

د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ١٤٦، وما بعدها.

(٢) الحكم منشور في مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض في ٢٥ عامًا من ١٩٣١ حتى ٣١ ديسمبر ١٩٥٥، الجزء الأول، ص ٦٩٠.

(٣) د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والموطن، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٨٦، بند ٦٢، ص ١٥١.

الفكرة منتفية فيما يتعلق بالأشياء، وبذلك لا تعدوا تلك المسألة إلا أن تكون تحديداً للنظام القانوني الذي تخضع له هذه الأشياء^(١).

أما الاتجاه الآخر فيذهب إلى تمتع تلك الأشياء بالجنسية، لما يمثله ذلك من أهمية بالنسبة لها، وتختلف تلك الأهمية في زمن السلم عنها في زمن الحرب، ففي زمن السلم يفيد تحديد الجنسية في كيفية تطبيق أحكام الرقابة على تلك الأشياء، ويفيد أيضاً في إسباغ نوعاً من الحماية التي توفرها الدولة التي تحمل تلك السفينة أو الطائرة علمها، أما في زمن الحرب فإن الدولة تستطيع أن تشرك تلك السفن والطائرات في معاركها ضد العدو، حتى ولو كانت سفناً أو طائرات مدنية^(٢).

ونظراً لما تمثله الجنسية للسفن والطائرات من أهمية فقد رأينا ضرورة التعرض لكيفية تحديد جنسية كل من السفينة والطائرة.

أ- كيفية تحديد جنسية السفينة:

تنص المادة الخامسة من القانون البحري الجديد رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ على أنه "تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص لمصريين"^(٣).

ويتضح لنا من استعراض نص تلك المادة أن المشرع المصري بصدد تحديد جنسية السفينة قد تبنى معياراً مزدوجاً، وهو أن يتم تسجيلها في أحد الموانئ المصرية وأن تكون مملوكة لمصري، وفي حالة تعدد الملاك يشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين، وفي حالة ملكيتها لشركة مساهمة فيشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة من المصريين، وذلك طبقاً لنص المادة ٩٢ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ب- كيفية تحديد جنسية الطائرة:

اعتمدت اتفاقية باريس طبقاً لتعديلها الصادر عام ١٩٢٩ على معيار تسجيل السفينة في الدولة، حتى يمكن أن تحمل جنسيتها وتخلت عن معيار الملكية التي كانت قد وضعت إلى جوار معيار التسجيل عند ظهورها في ١٠/٣/١٩١٩، وتسير اتفاقية شيكاغو للطيران المدني والموقعة في ١٢/٢/١٩٤٤^(٤)، على نفس منوال اتفاقية باريس الخاصة بتنظيم الملاحة الجوية السابق الإشارة إليهما من الاكتفاء بمعيار

(١) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٥.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٤٢، ٤٣.

(٣) القانون منشور بالجريدة الرسمية: العدد ١٨ تابع الصادر في ٣ مايو ١٩٩٠.

(٤) اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤ راجع ترجمة عربية لنصوصها في مؤلف د. إبراهيم شحاتة: القانون الجوي الدولي، ١٩٦٦، دار النهضة العربية، ص ٥٣٢.

تسجيل الطائرة، حيث نصت في مادتها ١٧ على أن " تحمل الطائرة جنسية الدولة التي سجلت في سجلاتها".

أما في مصر وطبقاً لنص المادة ٨ من المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٥ بشأن الملاحة الجوية، والتي جاء بها أن " كل طائرة مسجلة في السجل المصري للطائرات تكون مصرية الجنسية" والتي يتضح منها أن المشرع المصري قد تبني معياراً مزدوجاً لتحديد جنسية الطائرة بأنها مصرية، بأن تكون تلك الطائرة مسجلة في مصر وأن تكون مملوكة لمصري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وفي حالة تعدد الملاك يجب أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين، وإذا كان المالك شركة فيجب أن تكون تلك الشركة مصرية^(١).

المطلب الثاني

تحديد جنسية الشخص الاعتباري

إذا كان الحديث في هذا المطلب منصفاً على جنسية الشخص الاعتباري، فإننا لابد أن نعرض أولاً لكيفية تحديد الصفة الأجنبية للشخص الاعتباري، حيث إن الجنسية ما هي إلا الضابط الذي يتم الاستناد إليه لتحديد تلك الصفة، حيث تذهب أغلبية الآراء الفقهية إلى ترجيح ذلك^(٢).

وبذلك فإنه " طبقاً لضابط الجنسية يعد الشخص الاعتباري أجنبياً متى لم تتوافر فيه جنسية الدولة التي يتواجد على إقليمها، وبمعنى آخر نقول أن الشخص الاعتباري تتوافر له الصفة الأجنبية متى كان فاقداً لشروط المتمتع بجنسية الدولة التي يباشر نشاطه على إقليمها ولا يؤثر في تمتعه بالصفة الأجنبية كون هذا الشخص الاعتباري عديم الجنسية وهو فرض من النادر وقوعه، إذ طبقاً لضابط الجنسية المعمول عليه في هذا الصدد يتم تحديد الصفة الأجنبية بطريقة سلبية، أي أن الصفة الأجنبية صفة سلبية تلحق بكل شخص اعتباري لا يتمتع بجنسية الدولة"^(٣).

وإذا كان فقه القانون الدولي الخاص قد اتفق على ضابط الجنسية كأساس لتحديد هوية الأشخاص الاعتبارية الأجنبية، فإن ذلك يفيد ضمناً الاعتراف للأشخاص الاعتبارية بالجنسية، وهو ما تم في المجال الفقهي والقضائي والتشريعي، ومسألة الاعتراف تلك هي ما قضت على الجدل الذي كان ثائراً حول تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية، وقد اعترفت محكمة النقض المصرية بالجنسية

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٤٦.

(٢) راجع في ذلك

- RASHED Samia : " vers un droit international des investissement " Rev. Egy. DR.INJ. 1973. vol. 29 . pp 14 et . s

- LEBOULANGER Philippe " les contrats entre Etats et entreprises etrangeres " Economica – paris – 1989. p.13 .

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٧٧.

للأشخاص الاعتبارية منذ فترة طويلة، وهو ما قررته في حكمها الصادر في ٣١ يناير ١٩٤٦ والذي جاء به أن "كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد في مصر شخصاً اعتبارياً والجنسية كما هي من لوازم الشخص الطبيعي هي من لوازم الشخص الاعتباري، فكل شركة تجارية غير المحاصة لا بد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانوني، وهذه الجنسية يعينها القانون"^(١).

ولما حسم الخلاف حول إمكانية تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية بالاعتراف لها بهذه الجنسية،^(٢) فقد انتقل الجدل إلى مسألة أخرى تتعلق بتحديد الضابط الذي تبنى عليه جنسية الأشخاص الاعتبارية، وذلك لكثرة الضوابط التي تعتمد عليها الدول بصدد تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية، لذلك فإننا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتحدث في أولهما عن ضوابط تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية، وفي ثانيهما عن جنسية الأشخاص الاعتبارية في القانون المصري، وسوف نفصل كل منهما على النحو التالي :-

الفرع الأول

ضوابط تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية

=====

حيث أن الجنسية وكما سبق تعريفها هي رابطة بين الفرد والدولة، فإنه يجب أن يكون لهذه الدولة الصلاحية في تحديد الضابط أو الأساس الذي تمنح على أساسه جنسيتها، ولكن لا بد أن تختلف الضوابط التي يتم بمقتضاها تحديد جنسية الأشخاص الطبيعية عن الضوابط التي يتم بمقتضاها تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية، حيث أن الدولة وفي مجال الأشخاص الطبيعية تعمل على التأكد من توافر الروابط الحقيقية والواقعية بينها وبين الفرد، لأن الجنسية تبنى في هذه الحالة على ضوابط تحقق هذا المقصد كحقي الدم والإقليم، وذلك حيث الفرد متفاعلاً في المجتمع الذي يتمتع بجنسيته، وهو ما يدل على أنه سيدين له بالولاء والاحترام وكذلك للقيم والتقاليد السائدة فيه، أما في مجال الأشخاص الاعتبارية فإننا نجد أن كل دولة تبحث عن الضابط الذي يوضح لها ارتباط هذا الشخص بها اقتصادياً، وبذلك فقد تعددت الضوابط الموجودة والمعمول بها في هذا المجال، حيث إن الضابط الذي قد تراه إحدى الدول مناسباً قد لا تراه دولة أخرى مناسباً، كذلك نجد أن هناك بعض الظروف الاستثنائية مثل

(١) الحكم منشور في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في ١٥ عاماً من ١٩٣١، ٣١ ديسمبر ١٩٥٥، الجزء الأول، ص ٦٩٠.

(٢) د. سعيد عبد الماجد: المركز القانوني للشركات الأجنبية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، ١٩٦٩، ص ٥٩ وما بعدها.

د. غالب على الداودي: القانون الدولي الخاص، النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية، الطبعة الثانية، ١٩٧٨، ص ٢٠٠ وما بعدها.

الحروب والأزمات السياسية قد تجبر الدولة على اعتناق ضابط معين دون غيره، وهو الذي ترى فيه حماية لمصالحها الاقتصادية، وحتى تتمكن من فرض رقابتها وهيمنتها على اقتصادها وعدم السماح للأعداء بالتوغل داخلها^(١).

وقد ذهب الفقه بصدد تحديد ضوابط جنسية الأشخاص الاعتبارية مذاهب شتى، فذهب الفقه الفرنسي إلى وجوب تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية على أساس جنسية الأفراد المكونين لها، ويبررون ذلك بأن الشخص الاعتباري ما هو إلى مجموعة من الأشخاص الطبيعية^(٢).

بينما ذهب آخرون إلى الأخذ بمعيار التأسيس في مجال تحديد جنسية الشخص الاعتباري، بحيث يتمتع الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي تم تأسيسه فيها^(٣).

ويذهب فريق ثالث إلى ضرورة تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية على أساس مركز استغلاله أو نشاطه، وعلى هذا النحو يرتبط الشخص الاعتباري سياسياً بالدولة التي يباشر فيها نشاطه الرئيسي^(٤).

ويذهب آخرون وهم الرأي الغالب إلى اتخاذ مركز إدارة الشخص الاعتباري كأساس لتحديد جنسيته، حيث إن مركز الإدارة يمثل العقل المحرك للشخص الاعتباري، وفيه يتركز نشاط الشخص الاعتباري وحياته القانونية، وبذلك يتحقق قيام الجنسية على رابطة اقتصادية بين الشخص الاعتباري والدولة^(٥).

ويميل اتجاه فقهي إلى الاستعانة بضابط الرقابة، ويستند هذا الضابط على أنه لا يكفي بصدد تحديد جنسية الشخص الاعتباري الوقوف عند الإطار القانوني للشخص الاعتباري، وإنما لابد من البحث عما وراء الشخصية المعنوية من حقائق واقعية تتعلق بالأفراد الذين يملكون السيطرة على الشخص الاعتباري من الناحية الفعلية^(٦).

(١) د. عوض الله شيبية الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٧٩.

(٢) راجع في ذلك ..

- De vareilles – SOMMIERE : " La synthese du droit international prive " no . 764 .

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٠١.

(٤) المرجع السابق، ص ٤٠١.

(٥) راجع في ذلك ..

- LOUSSOUARN Yvon : " La personne morale en droit international prive " Rec. cours – 1959-1re partie – p. 471. et. s.

(٦) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٠٢.

ولذلك سنتولى دراسة أهم الاتجاهات الفقهية في صدد المعيار الواجب الإلتباع بصدد تحديد جنسية الشخص الاعتباري على النحو التالي:-

أولاً- معيار مكان التأسيس:

يذهب هذا الاتجاه إلى أن الشخص المعنوي يتمتع بجنسية الدولة التي تأسس فيها أو التي تكون فيها، وهذا المعيار مستمد من قاعدة محل إبرام التصرف والمتعلقة بشكل التصرفات القانونية^(١).

وقد قيل في تبرير هذا المعيار بأنه يستند إلى أن الدولة التي تم فيها تأسيس الشخص الاعتباري هي التي أنتت به إلى الوجود، ولذلك فهي أكثر الدول حقاً في حكم حياته ورعايته، مثلما يكتسب الشخص الطبيعي جنسية الدولة التي ولد فيها، وذلك بناء على حق الإقليم فإنه لا بد أن يكتسب الشخص الاعتباري جنسية الدولة التي تأسس فيها ومنحته وجوده القانوني، ويستند هذا المعيار في مجال تنازع القوانين على أن قانون الدولة التي تم فيها تأسيس الشخص الاعتباري هو القانون الأولي بحكم نظامه القانوني، حيث أن مشرع الدولة التي تم فيها التأسيس هو الذي منح دون غيره الشخصية القانونية لهذا الشخص الاعتباري^(٢).

ومن أهم المميزات التي يتسم بها هذا المعيار هو طابع الاستقرار، حيث إن مكان تأسيس الشخص الاعتباري هو معيار مادي ثابت، ومن شأن الأخذ بهذا المعيار توفير الكثير من الطمأنينة التي تلزم للمعاملات المتصلة بالشخص الاعتباري^(٣).

ويأتي في مقدمة الدول المؤيدة للأخذ بهذا المعيار الدول المصدرة لرأس المال، ويتمثل ذلك بصفة خاصة في الدول الأنجلوأمريكية والدول الاسكندنافية، حيث تتجه تلك الدول إلى منح جنسيتها للشركات التي تأسست وفقاً لقوانينها وتم تسجيلها بها^(٤).

وينتقد جانب من الفقه هذا المعيار على اعتبار أنه إعمال لقاعدة قانون المحل يحكم الشكل في مجال الجنسية، وتلك القاعدة لا بد أن يقتصر تطبيقها على شكل التصرف المنشئ للشخص الاعتباري وفقاً لقواعد تنازع القوانين^(٥).

-
- (١) د. عكاشة محمد عبدالعال: أحكام الجنسية المصرية، دراسة مقارنة، ١٩٩٣، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص ٤٦٣.
د. أحمد عبدالكريم سلامة: المبسوط في شرح نظام الجنسية، الطبعة الأولى، ١٩٩٣، دار النهضة العربية، ص ٥٩.
د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٦٤.
(٢) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٤٠٧.
(٣) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٢٧.
(٤) راجع في ذلك

- RABEL : " The conflict of laws " 2eme partie – 1957 . p. 31 .

- WOLFF : " private international law " 2eme edition . p. 308 .

وينتقد آخرون هذا المعيار على اعتبار أنه " يعلق جنسية الشركة على معيار شخصي هو إرادة الأفراد المكونين للشخص الاعتباري، فهم يستطيعون بحرية تامة اختيار المكان الذي يتم فيه تأسيس الشركة، وبالتالي تمنح الشركة جنسية الدولة المختارة إذا كان قانونها يعترف لها بالشخصية القانونية، فالشركة التي يتم اختيار مكان تأسيسها في فرنسا تكون فرنسية، وتلك التي يتم بالنسبة لها اختيار ذلك المكان في مصر تكون مصرية، وهكذا يتوقف تحديد جنسية الشركة على الأعضاء في اختيار مكان التأسيس، هذا في حين أن الجنسية يجب أن تتوقف بالدرجة الأولى على إرادة الدولة لا إرادة الأفراد، إذ أن الدولة لها الحرية في تحديد الشركات التي تعتبر منتمية إليها وتمنحها بالتالي ما تراه مقصوراً على أشخاصها المعنوية من حقوق، كما هو الحال تماماً بالنسبة لحريتها في تحديد القواعد الكفيلة بتحديد الأفراد الذين يتمتعون بجنسيتها"^(٢).

وينتقد الفقه الفرنسي في أغلبية هذا المعيار على اعتبار أن مشروع دولة التأسيس ليس هو المشرع الوحيد الذي يمكنه منح الشخصية الاعتبارية، لأن هذا القول يحتوى على خلط واضح بين كل من سلطة كل دولة في منح الشخصية الاعتبارية من الناحية النظرية، وبين وسائل حماية هذه الشخصية الممنوحة، وهي تنحصر بالضرورة في داخل إقليم الدولة الذي تمارس فيه تلك الدولة سيادتها^(٣).

ثانياً- معيار جنسية المؤسسين:

يؤسس هذا المعيار على اعتبار أن الشخص المعنوي يتمتع بجنسية الأفراد المكونين له، استناداً إلى أن هذا الشخص ما هو في حقيقة الأمر إلا مجموعة من الأفراد تجمع بينهم التزامات متبادلة ومنافع مشتركة، وبذلك فمن غير المعقول أن يكون له جنسية خلاف جنسية المؤسسين له^(٤)، ويستند أنصار هذا الاتجاه على اعتبار أنه يساعد الدول في أوقات الحروب والأزمات السياسية على حماية مصالحها الاقتصادية الوطنية، حيث أن هذا المعيار قد يساعد الدولة على الاستيلاء على الشركات التي يكون مؤسسوها من دول الأعداء^(٥).

وقد انتقد هذا المعيار على اعتبار أنه من الضروري أن يكون للشخص الاعتباري جنسية مستقلة عن جنسية الشركاء فيه، وذلك لكي يتوافر له الكيان الذاتي المستقل حتى يتمكن من مباشرة التصرفات اللازمة لأداء وظائفه^(٦).

(١) د. فؤاد عبدالمعزم رياض: المرجع السابق، ص ٣٢٧.

د. عكاشة محمد عبدالمعال: المرجع السابق، ص ٤٦٤.

(٢) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٦٤.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٠٧.

(٤) د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٥٨.

(٥) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨١.

(٦) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٦٢.

وقد انتقد آخرون هذا المعيار على اعتبار أنه يؤدي في الواقع إلى صعوبات عملية تجعل من العسير الأخذ به، حيث إنه قد تختلف جنسية الأفراد المكونين للشخص الاعتباري فكيف يتم تحديد جنسية الشخص الاعتباري نفسه؟ وكذلك قد يتغير الأفراد المكونين للشخص الاعتباري وبصفة خاصة شركات المساهمة والتي يتغير حاملوا الأسهم فيها بصفة دائمة، ويترتب على ذلك تغير جنسية الشخص الاعتباري بصفة مستمرة وهو أمر غير مقبول^(١).

ثالثاً- معيار مركز النشاط أو الاستغلال:

يقوم هذا المعيار على اكتساب الشركة جنسية الدولة التي يوجد بها مركز نشاطها أو استغلالها، فإذا كان هذا المركز موجوداً في مصر كانت الشركة مصرية الجنسية، وإذا كان هذا المركز في السعودية كانت الشركة سعودية الجنسية، وذلك بصرف النظر عن مكان التأسيس أو جنسية المؤسسين^(٢).

ويعتمد هذا المعيار على أساس أن المكان الذي يتواجد فيه مركز استغلال الشخص الاعتباري هو المكان الذي توجد به جميع الموارد البشرية والإمكانات المادية التي تملكها الشركة والتي تمارس أنشطتها من خلالها، وهو بذلك يحقق توافر الرابطة الاقتصادية الحقيقية بين الشركة والدولة التي تحمل تلك الشركة جنسيتها^(٣).

ويذهب آخرون إلى أن "مركز الاستغلال هو المكان الذي تتجمع فيه مصالح الشخص الاعتباري وهو أيضاً موطنه (وموطن الشخص الاعتباري وجنسيته متقاربان، على خلاف الشخص الطبيعي) وهو عنصر ثابت يصلح لبناء الجنسية عليه بمنجاة من إطلاق إرادة الأفراد (الذين أنشؤوا الشخص الاعتباري) ومحاولتهم التحايل على القانون^(٤)".

وقد انتقد هذا المعيار بسبب الصعوبات العملية التي تواجهه، وخاصة في الحالة التي يتوافر للشركة فيها مراكز أنشطة كثيرة ومتساوية في الأهمية، كما لو كانت لها عدة مراكز استغلال في أكثر من دولة تحتل نفس الدرجة من الأهمية، وبذلك فلا يتسنى تفضيل أحدها على الآخر في تحديد الجنسية، وخير مثال لذلك شركات البترول التي تعمل في أكثر من دولة^(٥).

(١) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٢٥، ٣٢٦.

(٢) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٧٤٤.

(٣) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٢.

د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٦١.

د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٤٦٥.

(٤) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٧٤٤.

(٥) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٤٦٥.

د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٢.

د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٦٢.

كذلك تثور نفس الصعوبة في الحالة التي يكون فيها نشاط الشخص الاعتباري غير مستقر في دولة بل ينتقل من دولة لأخرى، مثلما هو الحال لو تأسست شركة لإنشاء الموانئ تمارس نشاطها في دولة ثم أخرى، وهو ما يتعذر معه تحديد مركز نشاط لها^(١).

وينتقد آخرون هذا المعيار على اعتبار أن "مركز الاستغلال يكون تابعاً في أغلب الأحوال لمركز أو مقر الشركة الرئيسي، وهو المقر الذي يصدر القرارات ويدير الشركة بصفة عامة كما تتركز فيه كل مصالح الشركة، لذلك فإن المقر الرئيسي للشركة يكون أكثر أهمية من مركز النشاط الذي يعتبر تابعاً للأول ومنفذاً لقراراته"^(٢).

رابعاً - معيار الرقابة:

كان الحرب العالمية الأولى هي الباعث الدافع إلى وجود هذا المعيار، حيث اعتمدت عليه فرنسا لفرض رقابتها على الشركات التي كان يتواجد مركز إدارتها في فرنسا وتعتبر بذلك فرنسية الجنسية، ولكنها في الواقع تخضع لرقابة الأعداء وإشرافهم، ولا تستطيع فرنسا اتخاذ إجراءات في مواجهتهم مثل وضع أموالهم تحت حراستها، مادام أن مركز إدارة هذه الشركات في فرنسا، حيث لا يجوز - بحسب الأصل - اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية في مواجهة الوطنيين، ولم تجد فرنسا من سبيل قانوني لتبرير اتخاذ إجراءات استثنائية تقتضيها مصالح البلاد في مواجهة تلك الشركات، سوى تقرير تبعيتها السياسية للأعداء وتأكيد صفتها الأجنبية بمقتضى هذا المعيار^(٣).

ويستند الفقه في الأخذ بهذا الضابط على أنه ينشئ أساساً جديداً يحدد جنسية الأشخاص الاعتبارية يعتمد على جنسية الأشخاص المهيمنين عليها، ويذهب أنصار ذلك المعيار إلى أنه في الظروف التي يتم فيها أعمال هذا المعيار فإنه يجب ألا يعتد بمجرد وجود مركز الإدارة الرئيسي بإقليم الدولة ليتمتع بالصفة الوطنية، وذلك في الحالة التي يمثل فيها هذا الشخص الاعتباري رعايا دولة أخرى^(٤).

ويؤكد البعض على أن ضابط الرقابة هو ضابط مؤقت، حيث لا يؤخذ به إلا استثناء في ظروف خاصة كالحرب، أو بمقتضى نص صريح في التشريع^(٥).

وفي نقد هذا المعيار يذهب البعض إلى أن تحديد جنسية الشخص الاعتباري وفقاً لمعيار الرقابة، والذي يعتمد على جنسية الأشخاص المكونين للشخص الاعتباري ينطوي على إنكار للشخصية القانونية للشخص الاعتباري، والتي هي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين له^(٦).

(١) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٧٤٤.

(٢) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٦٦.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤١٦، ٤١٧.

(٤) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٣.

(٥) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٤٤٨.

ويذهب آخرون إلى أن هذا المعيار لا يعد أكثر المعايير اتفاقاً مع الأساس الذي يجب أن تؤسس عليه جنسية الأشخاص المعنوية، وتقرير غير ذلك غير صحيح بالمرّة، وذلك لأن تحديد انتماء الشخص الاعتباري للدولة لا بد أن يقوم على تواجد رابطة حقيقية كافية تؤهله لحمل جنسية هذه الدولة، وتلك الرابطة لا تتوافر بانتماء الأفراد المهيمنين على هذا الشخص للدولة بصورة مطلقة، حيث أن الشركة قد تمارس كافة نواحي نشاطها الاقتصادي بدولة أجنبية فتتعدى بذلك الرابطة بينها وبين هذه الدولة، بالرغم من انتماء كافة الأفراد المكونين للشركة لهذه الدولة، وعلى العكس قد ترتبط الشركة من الناحية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بممارسة كافة نواحي النشاط الاقتصادي لهذه الدولة، بالرغم من أن الأفراد المهيمنين عليها من الأجانب^(١).

وكذلك فإن من شأن الأخذ بهذا المعيار قيام صعوبة في التطبيق حيث إن ذلك الشخص قد يخضع لهيمنة الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارته وكذلك لهيمنة أصحاب رؤوس الأموال، فكيف يتم تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية في هذه الحالة طبقاً لهذا المعيار، والذي يتحدد طبقاً لجنسية الأفراد المهيمنين عليه، إذ سيثور التساؤل حول معرفة الأشخاص المهيمنين على الشخص الاعتباري، هل هم الأفراد القائمون على إدارته أم أصحاب رؤوس الأموال^(٢).

خامساً- معيار مركز الإدارة الرئيسي:

يقصد بمركز الإدارة الرئيسي المكان الذي يتركز فيه النشاط التوجيهي والإداري للشخص الاعتباري، ويتمثل هذا المكان عادة في المكان الذي تتخذة الشركة مقراً لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بوجه خاص، وكذلك يمارس منه الموظفون الموجهون لإدارة الشركة نشاطهم، ويتميز مركز الإدارة بهذا الشكل بأنه مقر ثابت وواحد، حيث إن الشخص الاعتباري قد يتحدد نشاطه ويتفرق على جهات متعددة، ولكن مركز الإدارة لا يتغير كقاعدة عامة، وهذا المركز أيضاً هو المعبر عن تبعية الشخص الاعتباري، لأنه المكان الذي تصدر عنه القرارات وتتجمع فيه رؤوس الأموال، وتتركز فيه أوامر وتوجيهات الشخص الاعتباري بصفة عامة^(٣).

وإذا كان الأصل في مركز الإدارة الرئيسي أنه ثابت صعب التغيير، فإنه لا يوجد ما يمنع من تغييره أو نقله إلى بلد آخر، ولكن يشترط أن يتم هذا التغيير صحيحاً وفقاً لقانون الدولة التي كان يوجد

(١) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٣.

(٢) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٣.

(٣) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٣، ٣٣٤.

(٤) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٤٣٦.

د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٦٣.

د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٤٦٦.

بها هذا المركز من الأصل، وكذلك أن يقوم الشخص الاعتباري بتعديل نظامه طبقاً للأحكام المقررة في قانون الدولة التي انتقلت إليها إدارته^(١).

وكما أنه من المتصور أن تتغير جنسية الشخص الاعتباري بانتقال مركز إدارته الرئيسي من دولة لأخرى، فإن هذا التغيير من الممكن أن يحدث أيضاً دون نقل مركز الإدارة الرئيسي، وذلك في الحالات التي تنقل فيها السيادة على إقليم الدولة إلى دولة أخرى، ويحدث ذلك غالباً في حالات الاستخلاف أو التوارث الدولي^(٢).

ولا يكفي في مجال تحديد مركز الإدارة الرئيسي أن يتم الاستناد إلى ما هو متفق عليه في نظامه الأساسي، وإنما تكون العبرة دائماً بطبيعة أو حقيقة الحال، ولذلك فلكي يعتبر المكان مركزاً رئيسياً للشخص الاعتباري فإنه لا بد أن يكون مركزاً حقيقياً له أو مركزاً فعلياً، وليس مجرد مركزاً افتراضياً غير حقيقي^(٣).

وقد برر الفقه الأخذ بهذا المعيار إلى أن "مركز الإدارة للشركة يعتبر بمثابة العقل المحرك لها حيث يتركز فيه نشاطها وحياتها القانونية، ومن ثم فهو يكفل قيام الجنسية على رابطة اقتصادية وثيقة بين هذه الشركة والدولة التي يتواجد على إقليمها مركز الإدارة الرئيسي، كما أن الأخذ بهذا الضابط يجعل الشركة تساهم بصورة أكثر فاعلية في الحياة الاقتصادية، كما أن هذا الضابط يتميز بالوضوح وسهولة تمييزه، إذ أنه من السهل معرفة مكان مركز الإدارة، فاجتماع الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الشركة أمر يتم بطريقة علنية، كما أن تحديد مكان الهيئات القائمة بشئون إدارتها أمر مادي سهل تحديده، بالإضافة إلى أنه يعد الأكثر مناسبة للظروف الاقتصادية للدول النامية"^(٤) ويشترط في مركز الإدارة أن يكون حقيقياً وجدياً، ويكون هذا المركز حقيقياً إذا توافرت فيه قرائن معينة مثل اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومكاتب الإدارة في دولة واحدة، أما في حالة عدم اجتماع العناصر السابقة في مكان واحد فإن القاضي يقوم بالموازنة بين تلك العناصر لتحديد أيها أكثر أهمية في خصوص الشركة، ويكون مركز الإدارة جدياً إذا تجنب القصد السيئ للشركاء في التهرب من قانون دولة معينة عن طريق تقرير أن مركز إدارة الشركة في دولة أخرى ليس لها صلة مع نشاط وأعمال الشركة، ويعتبر ذلك القصد السيئ دليلاً على عدم جدية مركز الإدارة المختار بواسطة الشركاء^(٥).

(١) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٤١٣، ٤١٤.

(٢) د. هشام علي صادق: آثار الاستخلاف الدولي في ضوء الوحدة المصرية الليبية، الإسكندرية، ١٩٧٣، فقرة رقم ٥٢ وما بعدها.

(٣) د. عز الدين عبدالله: المرجع السابق، ص ٧٤٥.

(٤) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٥.

(٥) د. أحمد عبدالكريم: المرجع السابق، ص ٦٤.

د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، ص ٤٦٨.

وينتقد هذا المعيار على اعتبار أنه يتيح الفرصة لتحليل الأفراد إذ قد يعمدون إلى اتخاذ مركز إدارة الشخص الاعتباري في دولة لا يتوافر بينه وبينها رابطة حقيقية، وبذلك لا يعتبر هذا الأساس معبراً تعبيراً صادقاً عن انتماء ذلك الشخص إلى الدولة من الناحية الاقتصادية^(١).

وتثور الصعوبة بصدد تحديد مركز الإدارة الرئيسي في حالة إدارة المشروع في أكثر من دولة فلا يمكن تحديد جنسية الشخص الاعتباري، ويذهب الفقه إلى وجوب الاعتداد بمركز الإدارة الرئيسي، حيث أنه ما دام هناك أكثر من مركز للإدارة فيتعين البحث عن أهم هذه المراكز أي أن الشخص الاعتباري يأخذ جنسية دولة مركز الإدارة العليا في حالة تعدد مراكز الإدارة^(٢).

ويسير الفقه والقضاء الفرنسي في الغالب على الأخذ بهذا المعيار^(٣)، وتؤيده غالبية الفقه اللاتيني وكثير من التشريعات الأوروبية^(٤).

وقد تثبت هذا الضابط محكمة استئناف باريس في حكم أصدرته بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٨٤، وقررت فيه أنه لما كان مركز إدارة الشركة الرئيسي والفعلي في مدينة لندن فإن هذه الشركة من ثم تعد متمتعة بالجنسية الإنجليزية^(٥).

الفرع الثاني

جنسية الأشخاص الاعتبارية في القانون المصري

— — —

على الرغم من أن المشرع المصري في قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ لم يتضمن نصاً يحدد جنسية الأشخاص الاعتبارية، إلا أنه أورد نص المادة ١١ الفقرة الثانية ضمن نصوص القانون المدني والتي تقضى بأن "النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسرى عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسرى".

د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٦٩، ٤٧٠.

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٢٩.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٥٤.

(٣) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، ص ٤١٥.

(٤) د. أحمد صادق القشيري: خلاصة محاضرات في الجنسية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ١٩٦٨، ١٩٦٩، ص ٦٤ .. مشار إليه في مؤلف د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٥٤.

(٥) الحكم منشور في ..

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بخصوص النص المتقدم أن " يرجع إلى القانون الذي يطبق على حالة الشخص المعنوي في شأن تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه، وبوجه خاص فيما يتعلق بتكوينه وإدارته، وبالتصرف المنشئ له وطريق تعديل هذا التصرف، وما يترتب من أثر قانوني على هذا التعديل وبكيفية انقضائه".

ومن خلال نص المادة ٢/١١ من القانون المدني يتضح أنها عيّنت بتحديد النظام القانوني للشخص الاعتباري، ويبدو من استخدام المشرع لعبارة الأشخاص الاعتبارية الأجنبية أنها تتعلق بالأشخاص الأجنبية فقط ولكنه يغفل تحديد الصفة الوطنية لها، وبذلك فإن المشرع لم يبين متى يعتبر الشخص الاعتباري وطنياً ومتى يعتبر أجنبياً، وعلى هذا النحو لا ينبغي الاعتداد بهذا الضابط لتحديد مشكلة التمتع بالحقوق أى المعاملة التي يلقاها الشخص الاعتباري في مصر بوصفه من الوطنيين أو الأجانب، وبذلك فإن عناية المشرع انصرفت إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري وفقاً لقاعدة الإسناد المصرية، ولكنه لم يضع معياراً للصفة الوطنية أو الأجنبية للشخص الاعتباري من حيث مدى تمتعه بالحقوق، وتركها للقواعد المأخوذ بها في التشريعات التي تحكم الأشخاص الاعتبارية المختلفة^(١).

ومما سبق يتضح أن نصوص القانون المدني تعرضت فقط للقانون الذي يحكم النظام القانوني للأشخاص المعنوية، ولا شأن لها بجنسية هذه الأشخاص^(٢).

ولذلك فإننا ونحن بصدد كيفية تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية في القانون المصري، فإننا سنرجع إلى التشريعات المختلفة التي تحكم الأشخاص الاعتبارية المختلفة، وخير مثال لذلك المادة ٤١ من القانون التجاري المصري التي تنص على أن " جميع شركات المساهمة التي تؤسس في القطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي بالقطر المذكور" ومن خلال ذلك النص يتضح لنا أن المشرع المصري قد اعتبر شركات المساهمة التي يتم تأسيسها في مصر وفقاً للقوانين المصرية شركات وطنية، بشرط أن تتخذ هذه الشركات مركز إدارتها بالإقليم المصري^(٣).

ومما سبق يتضح لنا أن المشرع المصري قد اعتد في الكشف عن جنسية شركة المساهمة بمعياري: أولهما معيار التأسيس، وثانيهما معيار مركز الإدارة الرئيسي، وبذلك فلا بد لكي تكتسب

(١) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٤٣٩.

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٧٥.

(٢) د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة العاشرة، ١٩٧٧، ص ٧٥٣، ٧٥٤.

د. هشام صادق: مركز الأجانب، ١٩٧٧، منشأة المعارف، ص ٤٣٦.

د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٦.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٥، ٣٣٦.

الشركة الجنسية المصرية أن يتم تأسيسها في مصر من ناحية، وأن تتخذ في الجمهورية مركز إدارتها الرئيسي من ناحية أخرى^(١).

ويقصد بمعيار التأسيس وجوب إنشاء الشركة في مصر، ولا يكفي في هذا المجال مجرد إبرام العقد المنشئ لها في مصر، وإنما لابد من استكمال كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية لقيام الشركة فيها، والحصول على الترخيص اللازم لها والاكتمال برأس المال^(٢).

ويقصد بمركز الإدارة الرئيسي في هذا المجال مركز الإدارة الحقيقي أو الفعلي كما هو مستقر عليه وفقاً للقواعد العامة^(٣).

ويذهب البعض إلى أن "عدم اكتفاء المشرع المصري بمجرد تأسيس شركة المساهمة في مصر واستلزامه فوق ذلك أن تتخذ الشركة مركز إدارتها الرئيسي في الجمهورية حتى تكتسب الصفة الوطنية، قد قصد به على ما يبدو، التيقن من ارتباطها الفعلي بالاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذا الارتباط هو الأساس الذي تهدف مختلف المعايير المقترحة للتبعية السياسية للأشخاص الاعتبارية إلى الكشف عنه على نحو أو آخر"^(٤).

ويثور التساؤل بالنسبة للشركة التي تم تأسيسها في مصر واتخذت مركز إدارتها في الخارج، والشركة التي تم تأسيسها في الخارج واتخذت مركز إدارتها الرئيسي في مصر؟

فيما يتعلق بالشركة التي تأسست في مصر واتخذت مركز إدارتها خارج مصر، يذهب البعض^(٥) إلى أن شركة المساهمة تعتبر مصرية بمجرد تأسيسها في مصر دون أي شرط آخر، وكل ما تلتزم به أن تجعل مركز إدارتها الرئيسي في مصر، ولكن عقاب مخالفة ذلك ليس الحرمان من الجنسية ولكن بطلان الشركة.

بينما ذهب آخرون إلى أن جنسية الشركة لا تتحدد فقط بمركز التأسيس وإنما يضاف إليه مركز الإدارة الرئيسي، بمعنى أن شركات المساهمة تكون مصرية متى تم تأسيسها وكان مركزها الأصلي في مصر^(٦).

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، ص ٤٣٧.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٥٩، ٦٠.

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٧٤.

(٣) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٤٧٤.

(٤) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٣٨.

(٥) د. حامد ذكي: القانون الدولي الخاص المصري، الطبعة الأولى، ١٩٣٦، مطبعة نوري، ص ٧٠٧.

(٦) د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٦٨.

د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٦١.

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٧٤.

ونحن نؤيد الاتجاه الثاني نظراً لموافقته لصريح نص المادة ٤١ من القانون التجاري المصري.

وفيما يتعلق بالشركة التي يتم تأسيسها في الخارج ولكنها تتخذ مركز إدارتها في مصر، يذهب البعض^(١) إلى أن " اتخاذ مركز الإدارة الرئيسي كأساس لتحديد جنسية الشركات المساهمة لا يتعارض مع حكم المادة ٤١ من القانون التجاري، ذلك أنه لا يستفاد من النص السابق الذكر أن المشرع أراد قصر التمتع بالجنسية المصرية على الشركات التي يتم تأسيسها بالإقليم المصري، فالنص وإن كان يلزم الشركات المؤسسة بمصر بأن تكون مصرية، إلا أنه لا يقضى بحرمان الشركات التي لم تؤسس بمصر من التمتع بهذه الجنسية، بل إن اشتراط المشرع اتخاذ الشركات المؤسسة بمصر مركز إدارتها بالإقليم الدولة ينطق في تقديرنا بالأهمية الخاصة التي عقدها المشرع على وجود مركز إدارة الشركة بالإقليم المصري، واعتداده بذلك ضمناً كشرط لازم لتمتع الشركة بالجنسية"، ويذهب رأى آخر نؤيده إلى أن " الاعتداد بمركز الإدارة الرئيسي كأساس لتحديد جنسية الشركات المساهمة لا يتعارض حقيقة مع حكم المادة ٤١ من القانون التجاري، بل أكثر من هذا فوقعه ليس الشرط الوحيد للتمتع بهذه الجنسية بل يجب أن يضاف إليه تأسيس شركة المساهمة في مصر، وبالتالي فإن الاكتفاء بوقوع مركز إدارة الشركة الرئيسي في مصر لتمتعها بالجنسية المصرية، يتعارض مع صريح نص المادة ٤١ من القانون التجاري التي توجب إلى جانب ذلك تأسيس شركة المساهمة في مصر"^(٢).

وتجب ملاحظة أن نص المادة ٤١ من القانون التجاري قد حدد معايير تمتع شركة المساهمة بالجنسية المصرية، دون أن يتعرض لمدى صلاحية هذه المعايير لاكتساب جنسية دولة أجنبية، حيث لا يجوز القول بأن الشركة التي تم تأسيسها في إيطاليا مثلاً واتخذت مركز إدارتها الرئيسي هناك تعتبر شركة إيطالية وفقاً لنص المادة ٤١ من القانون التجاري، وإنما يكفي القول أن الشركة وفقاً لهذا النص هي شركة أجنبية، حيث تكفي تلك المادة بتحديد متى تعتبر الشركة مصرية، دون أن تمتد صلاحيتها لتحديد جنسية الشركات غير المصرية^(٣).

ويلاحظ على نص المادة ٤١ أيضاً أنه قد حدد معايير جنسية شركات المساهمة، ولم يتعرض لكيفية تحديد جنسية غيرها من الشركات الأخرى، لذلك فقد ثار التساؤل حول المعيار الواجب التطبيق على جنسية تلك الشركات؟ في هذا ذهبت المحاكم المختلفة إلى اعتبار هذه الشركات مصرية إذا تم تأسيسها في مصر، وفقاً لأى من الأشكال المقررة بالقانون المصري، وكان مركز إدارتها في مصر وهو نفس المعيار المطبق بصدد شركات المساهمة^(٤).

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٧.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٦٢، ٦٣.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٤١.

(٤) راجع في ذلك .

د. محمد عبد المنعم رياض: مبادئ القانون الدولي الخاص، ص ٤٨٥.

إلا أن محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ ٣١ يناير ١٩٤٦ قررت أنه " إذا كانت الشركة شركة توصية أسست في مصر على النمط الذي يتطلبه قانون التجارة المصري، واستوطنت مصر فاتخذت منها ميداناً لنشاطها التجاري، وكانت تضم ثلاثة شركاء ليس منهم إلا أجنبي واحد ورأس مالها ليس للشريك الأجنبي فيه إلا حصة قليلة بالنسبة إلى مجموعة، وكان الشريك الموصى القائم على إدارتها وتمثيلها مصرياً فلا ريب في اعتبارها شركة ذات جنسية مصرية "(١).

ومن عبارات الحكم يتضح أنه لا يتبنى معياراً معيناً لتحديد جنسية شركات التوصية، حيث أنه يخلط بين العديد من المعايير، مثل مكان التأسيس ومركز الإدارة ومركز النشاط ومعيار الرقابة(٢).

وقد أعمل المشرع معيار الرقابة في المادة ٩٢ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حيث نصت على أنه " يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وإذا انخفضت - لأى سبب من الأسباب - نسبة المصريين في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة، وجب استكمال هذه النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، على أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها، ولا يخل ما تقدم بما نص عليه قانون استثمار المال العربي والأجنبي".

وخلاصة الاتجاهات القضائية والتشريعية السابقة تدفعنا إلى تبني المعيار المقرر بصدد شركات المساهمة فيما يتعلق بغيرها من الشركات وذلك في الظروف العادية، أما فيما يتعلق بظروف الحرب والأزمات السياسية والحالات التي تتعلق بحماية كيان الدولة الاقتصادية فإننا نرى الأخذ بضابط الرقابة(٣).

د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٨.

د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٤٤.

(١) الحكم صادر في الطعن رقم ٤٢ لسنة ١٤ ق جلسة ٣١ يناير ١٩٤٦، منشور في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ١٥ عاماً من ١٩٣١ وحتى ديسمبر ١٩٥٥، ج ١، ص ٦٩٠، ٦٩١.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٨.

(٣) نحن نتبع في ذلك أستاذنا الدكتور: عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٨٩.

المبحث الرابع

منازعات الجنسية

إذا كان الحديث في هذا المبحث متعلقاً بمنازعات الجنسية، فإننا سنقسمه إلى ثلاثة مطالب:-
نتناول في أولها الصور المختلفة لمنازعات الجنسية، وفي ثانيها للقضاء المختص بمنازعات الجنسية،
وفي ثالثها لكيفية إثبات تلك الجنسية، على النحو التالي.

المطلب الأول

صور منازعات الجنسية

تتخذ منازعات الجنسية في الواقع العملي ثلاث صور نشرحها فيما يلي:-

الصورة الأولى- الطعن في قرار إداري متعلق بالجنسية:

تقوم هذه الصورة على افتراض صدور قرار إداري متعلق بالجنسية كمسألة مبدئية، وبعد ذلك
ينازع صاحب الشأن في هذا القرار طالباً بإلغاء أو التعويض عنه أو الأمرين معاً،^(١) ومن الأمثلة على
ذلك أن يصدر قرار إداري بنزع جنسية شخص، أو يرفض منح الأجنبي الجنسية الوطنية رغم توافر
شروط اكتسابها فيه، أو القرار الصادر بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في جنسية الزوج على
الرغم من توافر شروط اكتسابها فيها.^(٢)

الصورة الثانية- المنازعة في الجنسية كمسألة أولية:

قد يتطلب الفصل في خصومة مطروحة أمام القضاء الفصل في مسألة الجنسية كمسألة أولية
لازمة للفصل في الخصومة الأصلية، وهي بهذا الشكل قد تثور أمام القضاء العادي (الجنائي أو المدني)
أو أمام القضاء الإداري.

١- المنازعة أمام القضاء الجنائي:

تثور المنازعة في هذه الحالة كما لو خالف الشخص القرار الصادر بإبعاده ولم ينفذه، فعندما
يقدم للمحاكمة يدفع بأنه وطني، ففي هذه الحالة ينبغي الفصل أولاً في جنسية الشخص بوصفها مسألة
أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية، وقد تثور هذه المسألة أيضاً أمام القضاء الجنائي في بعض
الجرائم الخاصة بقانون الشركات أو بقانون الاستثمار.^(٣)

(١) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٦٠١.

(٢) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٣٤، ٤٣٥.

(٣) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٣٦.

٢- المنازعة أمام القضاء المدني:

تتور المنازعة في هذا الفرض بصفة خاصة في مسائل تنازع القوانين، فقد يتنازع الورثة حول التركة ويدعى بعضهم أن المورث مصرى مما يوجب تطبيق القانون المصرى بشأن الميراث، ويدعى البعض الآخر أن المورث غير مصرى مما يستلزم تطبيق قانون أجنبى على الميراث، فهنا يجب على المحكمة أن تفصل أولاً في مسألة جنسية المورث كمسألة أولية قبل الفصل في النزاع الأصلي.^(١)

٣- المنازعة أمام القضاء الإدارى:

مثال ذلك أن يصدر قرار إدارى بإبعاد شخص عن البلاد استناداً لكونه أجنبياً ممن يجوز إبعادهم، فيجوز له في هذه الحالة أن يطعن في هذا القرار مرتكناً إلى كونه مصرى، ولا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار في مواجهته.^(٢)

الصورة الثالثة- الدعوى المجردة بالجنسية:

يقصد بالدعوى المجردة أو الأصلية بالجنسية تلك الدعوى التى يرفعها صاحب الشأن على الدولة، بصفة أصلية ومستقلة عن أى منازعة، مطالباً فيها الحكم بثبوت الجنسية أو نفيها عنه.^(٣)

ويعرفها البعض بأنها "الدعوى التى ترفع ابتداء إلى القضاء بطلب الحكم بثبوت الجنسية أو نفيها".^(٤)

ويطلق على هذه الدعوى بالدعوى الأصلية أو المجردة لعدم ارتباط موضوعها بأى قرار إدارى صادر فى شأن جنسية الشخص، كما أنها تقام بصفة مستقلة حيث إنها لا تنفرع عن نزاع قائم أمام القضاء.^(٥)

ولم تتضمن التشريعات المصرية النص على إمكان قبول هذه الدعوى، مما أثار جدلاً داخل القضاء حول إمكان قبولها، فذهب القضاء الإدارى إلى عدم قبولها بل إنه أنكر وجودها،^(٦) وأيده قليل

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٦٠٢.

(٢) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٣٥.

(٣) المرجع السابق: ص ٤٣٦.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٠٥.

(٥) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٧١.

(٦) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢٤ نوفمبر ١٩٥٤، مجموعة مجلس الدولة السنة الثامنة، ص ٩٠.

من الفقه فى ذلك، أما القضاء العادى فقد اتجه إلى قبول تلك الدعوى،^(١) مما دعا الفقه إلى الاختلاف حول اشتراط وجود منازعة حقيقية فى شأن الجنسية لإمكان قبول تلك الدعوى.^(٢)

ولكن بعد صدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم مجلس الدولة، فقد صار الاختصاص محسوماً له بصدد دعاوى الجنسية طبقاً لنص المادة الثامنة منه، وأصبح جواز رفع دعوى مبتدأه بالجنسية سواء بالإثبات أو النفى أمامه جائزاً، وحتى بعد إلغاء ذلك القانون بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ فما زال الاختصاص بدعاوى الجنسية مقصوراً على مجلس الدولة، ومنها الدعوى الأصلية التى سبق الحديث عنها، وذلك طبقاً لنص المادة العاشرة من ذلك القانون.

المطلب الثانى

القضاء المختص بمنازعات الجنسية

= = =

اختلفت الآراء حول ما إذا كانت منازعات الجنسية تتعلق بسيادة الدولة وبالتالي تخرج عن مجال رقابة القضاء، وما إذا كانت تعد من القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء، أكد القضاء المصرى على أن "لا جدال فى أن الجنسية وهى العلاقة القانونية بين الفرد والدولة، تدخل فى صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة، التى لها مطلق السلطان فى تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها ومن لا يكون، وفى فرض ما نشاء من التكاليف والقيود على مواطنيها، وبديهي أن الدولة حين تسن تشريعاً ينظم الجنسية ويعرف كنهها ويحدد شرائطها ويرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها، لا تنزل عن سيادتها لأنه منبعث منها وصادر عنها، ويتعين احترامه وتنفيذه ومن واجب المحاكم تطبيقه وليس فى ذلك أى مساس بسيادة الدولة، وما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً لهذا التشريع يندرج فى أعمال الحكومة العادية، ولا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسيادة العليا للدولة".^(٣)

كما أكدت محكمة النقض المصرية على أن "لا يترتب عليها أى مساس بسيادة الدولة - إذ الجنسية المصرية مقررّة بحكم القانون متى توافرت شروطها وليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة".^(٤)

(١) حكم محكمة النقض الصادر فى ٢٥ مايو ١٩٥٠، مجموعة الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدائرة المدنية لمحكمة النقض، السنة الأولى - ص ٥١٩.

(٢) بالتفصيل فى ذلك. د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٠٧ وما بعدها.

(٣) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢٦ ديسمبر ١٩٥٠، مشار إليه فى مؤلف د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٩٩.

(٤) حكم النقض بجلسته ٢٥ مايو ١٩٥٠، مجموعة الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية والدائرة المدنية لمحكمة النقض، السنة الأولى، ص ٥١٩.

وبذلك فإن مسائل الجنسية لا تتعلق بسيادة الدولة، وإنما تخضع لرقابة القضاء، ولكن أى من جهات القضاء تختص بها؟ هل هو القضاء العادى أم القضاء الإدارى؟

لم تتضمن تشريعات الجنسية الصادرة قبل القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ نصاً يحدد جهة القضاء المختصة بمنازعات الجنسية، وهو ما جعل الاختصاص بنظرها مشتركاً بين كل من القضاء الإدارى والقضاء العادى،^(١) غير أن الوضع تغير بعد صدور قانون مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ الذى نص فى مادته الثامنة على أن "يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة". تاسعاً - دعاوى الجنسية وبشترط فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وثامناً وتاسعاً أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة".

وفى ضوء هذا النص ذهب غالبية الفقه إلى أن القضاء الإدارى قد أصبح بعد صدور النص المذكور صاحب الولاية الوحيد فى جميع منازعات الجنسية على اختلاف صورها.^(٢)

إلا أن بعض الفقه ذهب إلى أنه لا يمكن تفسير نص المادة ٨ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ على أنه تقرير لإنفراد القضاء الإدارى بالاختصاص بكافة دعاوى الجنسية، وأن نص المادة يقيد الاختصاص للقضاء الإدارى بكون مرجع الطعن هو أحد الأسباب التى تسوغ الطعن فى القرارات الإدارية، ولا يمكن مد هذا الاختصاص إلى الدعوى الأصلية المتعلقة بالجنسية والتى تظل خاضعة لاختصاص القضاء العادى.^(٣)

وبصدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة فقد زال كل لبس أو غموض أو اختلاف لازم نص المادة ٨ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩، حيث نص فى مادته العاشرة على أنه "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:-

سابعاً: دعاوى الجنسية. ولم يشترط المشرع فى هذا النص أن تقوم الدعاوى على أحد أسباب الطعن فى القرارات الإدارية، مثلما كانت تقضى المادة ٨ من القانون السابق، وبذلك يصبح القضاء

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٠١.

(٢) د. سليمان الطماوى: القضاء الإدارى ورقابته على أعمال الإدارة، ١٩٦١ ص ٢٢١ وما بعدها، د. فؤاد العطار: رقابة القضاء لأعمال الإدارة ١٩٥٩ - ١٩٦٠، ص ٣٩٤، د. مصطفى أبو زيد فهمى: القضاء الإدارى، ١٩٥٩ ص ٥٦١، ٥٦٢، أ. محسن عبد الحافظ: الأحكام المستحدثة فى قوانين النظام القضائى الجديدة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثالثة، العدد الأول ص ١٥ وما بعدها.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤١٨، بحثه بعنوان "الاختصاص القضائى بمسائل الجنسية فى الجمهورية العربية المتحدة" مجلة الدراسات القانونية للشرق الأوسط، ١٩٦٨، ص ١٥٤ وما بعدها، د. هشام صادق: المرجع السابق، ص ٦٣٧.

الإدراى هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنازعات الجنسية أيا كانت الصورة التى تتخذها تلك المنازعات.^(١)

إلا أنه يجب ملاحظة أن المادة الثانية من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ قد نصت على أن "جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً " .

ومن هذا النص يتضح لنا أن المنازعات المتعلقة بالجنسية والتى كانت منظورة أمام القضاء العادى عند صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تظل منظورة أمامه حتى يتم الفصل فيها نهائياً ولا تتم إحالتها إلى القضاء الإدارى.^(٢)

المطلب الثالث

إثبات الجنسية

= = =

لم ينظم المشرع المصرى فى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ إثبات الجنسية تنظيمياً شاملاً حيث أنه لم يتضمن سوى نصين بخصوص هذا الموضوع: أحدهما يتعلق بتحديد عبء إثبات الجنسية المصرية، والآخر يتولى تحديد طريق الحصول على شهادة الجنسية ومدى حجيتها فى الإثبات، وقد سكت عن تحديد طرق الإثبات والأدلة المقبولة فى هذا المجال، تاركاً ذلك للقواعد العامة لتطبيق فى هذا الشأن،^(٣) ولكن أياً ما كان موقف المشرع المصرى، فإننا سوف نتعرض ونحن بصدد دراسة إثبات الجنسية لكل من محل الإثبات وعبئه ثم ننهى الموضوع بدراسة طرق الإثبات على النحو التالى:-

أولاً- محل الإثبات:

محل الإثبات هو الأمر الذى يجب إثباته، ففى الحالة التى يدعى فيها الشخص تمتعه بالجنسية المصرية فإن محل الإثبات هو توافر شروط حالة من حالات اكتساب الجنسية المصرية كما حددها القانون.

أما فى الحالة التى ينفى فيها الشخص تمتعه بالجنسية المصرية فيوجد فرضان فى هذه الحالة، إما أن يدعى الشخص أنه لم يدخل فى الجنسية المصرية أصلاً، وحينئذ يجب عليه أن يثبت أنه قد تخلفت فى حقه شروط كسب الجنسية المصرية كلها أو بعضها، وإما أن يدعى أنه كان متمتعاً بالجنسية

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤١٩.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٦٤٥.

(٣) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢٩٠.

(٣) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٦٣.

المصرية ثم فقدها، لأي سبب من أسباب الفقد فيجب عليه في هذه الحالة أن يثبت توافر شروط حالة من حالات فقد الجنسية كما قررها القانون.^(١)

ثانياً- عبء الإثبات:.

يخضع عبء الإثبات في مجال الجنسية للقواعد العامة في الإثبات، والتي مؤداها أن كل من يدلي بادعاء معين يتحمل عبء إثباته، وهو ما قرره المادة ٢٤ من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ حيث تقضى بأن "يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها".^(٢)

ويذهب البعض إلى عكس ذلك حيث يقررون أن عبء الإثبات يقع دائماً على عاتق الشخص الذي ثار النزاع في شأن جنسيته، وأنه إذا كان المدعى هو الذي يدعى بتمتعه بالجنسية المصرية فيتعين عليه إقامة الدليل على ذلك وهو ما يتفق مع القواعد العامة، أما إذا لو كان المدعى شخص غير الذي ثار النزاع بشأن جنسيته فإن عبء الإثبات سيقع في هذه الحالة على عاتق الشخص الآخر وهذا يخالف القاعدة العامة.^(٣)

وتذهب جمهرة الفقه^(٤) إلى أن نص المادة ٢٤ يتفق مع القاعدة العامة في الإثبات، والتي تلقى من حيث المبدأ عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الوضع الظاهر، حيث أنه "لا محل للخروج بالنسبة لمسائل الجنسية على القواعد العامة والتي تقرر إلقاء عبء الإثبات على من يدعى خلاف الظاهر، فهذه القاعدة من الدعايم اللازمة لحماية حقوق الأفراد ضد الدعاوى التعسفية التي لا تقوم على أى أساس وليس بمعقول عدم شمول الجنسية بهذه الحماية، فالجنسية هي بلا شك من الحقوق الأساسية التي يتوقف عليها كيان الفرد في مجتمع الدولة، وهي بهذا الوصف من أكثر الحقوق جدارة بالحماية".^(٥) ويستندون في ذلك على تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والذي ورد به أنه "إذا ثار نزاع بشأن الجنسية فإن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى على خلاف الظاهر".^(٦)

نقل عبء الإثبات:

إذا كانت القاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وأنه في مجال الجنسية فإن من يثور النزاع حول جنسيته يتحمل غالباً عبء الإثبات، فإنه توجد قرينتان يعفى بمقتضاها ذلك الشخص من عبء الإثبات، ويتم نقل ذلك العبء على عاتق الطرف الآخر، وهما:-

(١) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٢٤١.

(٢) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٢٤١.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٧٠.

(٤) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٩٠٠.

(٥) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٦٤.

(٦) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٧٢.

١ - شهادة الجنسية:

شهادة الجنسية هي "محرر رسمي أو وثيقة تمنحها الجهة القائمة على شئون الجنسية للشخص الذى يطلبها وتفيد تمتعه بالجنسية الوطنية فهي بمثابة إقرار بالجنسية للشخص من جانب الدولة وتتحدد قوة هذه الشهادة كدليل على الجنسية وفق قانون الدولة التى أصدرتها".^(١)

وبصدد شهادة الجنسية تنص المادة ٢١ من تشريع الجنسية المصرى على أنه "يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية ويصدر بتحديد الرسم قراراً من وزير الداخلية.

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطلبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب".

ومن النص المذكور يتضح لنا أن شهادة الجنسية قرينة قانونية تعين الشخص فى إثبات صفته الوطنية، وهى قرينة بسيطة حيث إنها وإن أعفت حاملها من عبء إثبات جنسيته ونقلته على عاتق الطرف الآخر إلا أنه يجوز له إثبات عكسها.^(٢)

والملاحظ من النص أنه جعل إعطاء شهادة الجنسية وجوبياً متى طلبها الفرد، وعلى أن يكون ذلك خلال سنة من تقديم الطلب، وفى حالة الامتناع من إعطائها خلال مدة السنة فإن ذلك يعد رفضاً للطلب يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى.^(٣)

٢ - الحالة الظاهرة:

يقصد بالحالة الظاهرة الظهور بمظهر الوطنى حيث إن الحالة الظاهرة هى "مجموعة من العناصر الظاهرة تتوافر فى حق شخص فيستشف منها ممارسته فعلاً للجنسية الوطنية وهو استنباط يقوم على افتراض هو أن الظاهر يترجم الحقيقة".^(٤)

ويمكن استخلاص الحالة الظاهرة من عناصر متعددة أهمها الاسم والشهرة والمعاملة، ولها دلائل متنوعة مثل أن يحمل الشخص جواز سفر مصرى، أو بطاقة شخصية مصرية، أو بطاقة انتخاب مصرية، أو أن يؤدى الخدمة العسكرية فى مصر، أو أن يتولى وظيفة عامة قصر المشرع توليها على

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٩٠٢، ٩٠٣.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٦٦.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٦٧.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤١٥.

المصريين دون الأجانب، والحالة الظاهرة بهذا الشكل تكفى وحدها لإثبات الجنسية، ولكنها كقرينة تنقل عبء الإثبات فهي قرينة قضائية، يتمتع القاضى إزاءها بحرية التقدير إلى أن يصل بها إلى الحقيقة.^(١)

ثالثاً- طرق الإثبات:

يذهب فقه القانون الدولى الخاص إلى القول بأن إثبات الجنسية يتم عادة بأحد طريقتين رئيسيتين: أولهما الطريق المباشر ويستند الإثبات فيه إلى دليل معد سلفاً، وثانيهما الطريق غير المباشر ويستند الإثبات فيه على إقامة الدليل على تحقق السبب الذى أدى إلى كسب الجنسية، وربما يرجع السبب فى أن قانون الجنسية المصرى لم ينظم طرق إثبات الجنسية تنظيمًا شاملاً إلى أنه أراد بذلك أن يترك الأمر للقواعد العامة، حتى يطول العهد بالجنسية المصرية ويرسّى القضاء المبادئ التى يستقر عليها، وحينئذ يتدخل المشرع لإقرار القواعد التى يسير عليها العمل.^(٢)

١- الإثبات بالطريق المباشر:

يطلق على هذا الطريق طريق الأدلة المعدة سلفاً، ويسميه بعض الفقه أيضاً بطريق الأدلة سابقة التجهيز، وهو الطريق الطبيعى لإثبات معظم حالات اكتساب الجنسية الطارئة، وخاصة فى حالة التجنس حيث يتوافر عادة الدليل المعد سلفاً أى الوثيقة التى تثبت اكتساب الشخص للصفة الوطنية، وتقوم هذه الطريقة فى الغالب من الحالات التى يكون دخول الشخص فى الجنسية الوطنية أو فقده لها قد تم بمقتضى قرار إدارى من الجهة المختصة، وفى هذه الحالة يعد القرار الإدارى دليلاً سابقاً على ثبوت أو فقد الجنسية^(٣).

وتجب ملاحظة أن المشرع المصرى قد ألزم جهة الإدارة بنشر القرارات الصادرة بمنح الجنسية أو فقدها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورهما، وذلك بهدف إعلام الغير بمن دخل فى الجنسية المصرية ومن فقدها، وبذلك فإن من يدعى اكتساب الجنسية المصرية يستطيع إثبات ذلك بإبراز الجريدة الرسمية التى نشر بها القرار الصادر بمنحه الجنسية^(٤).

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٦٧، ٢٦٨.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٦٩.

(٣) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٤٢٠.

(٤) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢٧١.

٢- الإثبات بالطريق غير المباشر:

الطريق غير المباشر هو الطريق الذى يتم فيه إثبات الجنسية عن طريق إثبات تحقق السبب المؤدى لاكتسابها، وبذلك تختلف طرق الإثبات حسب طبيعة السبب المكتسب للجنسية، وذلك على النحو التالى:-

أ- أن يكون الزواج هو السبب فى اكتساب الجنسية، فيجب حينئذ على الزوجة إقامة الدليل على توافر الشروط التى تتطلبها المادة ٧ من قانون الجنسية لاكتساب الجنسية فى هذه الحالة، لذلك يجب عليها أن تثبت أو تقيم الدليل على قيام الزوجية، وأنها أعلنت رغبتها فى اكتساب الجنسية إلى وزير الداخلية، وأنه قد مر عامان على هذا الإعلان دون صدور قرار بالرفض من قبل وزير الداخلية.^(١)

ب- أن تكون الجنسية مبنية على حق الدم، فإنه يجب على الشخص فى هذه الحالة أن يثبت ميلاده لأب مصرى وأن أبيه قد ولد لأب مصرى وهكذا.

ونظراً لصعوبة ذلك فتوجد عدة وسائل لتسهيل إثبات ذلك، حيث نص المشرع المصرى فى المادة الأولى من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن المصريين هم "أولاً: المتوطنون فى مصر قبل ٥ نوفمبر ١٩١٤ من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكاملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكاملة لإقامة الزوجة"، وبذلك يستطيع الشخص إثبات الجنسية المصرية بإثبات توطن عائلته فى مصر قبل ٥ نوفمبر ١٩١٤، مع إثبات استمرار ذلك التوطن حتى تاريخ العمل بهذا القانون ^(٢).

ج- أن تكون الجنسية مبنية على حق الإقليم، يكفى لإثبات الجنسية فى هذه الحالة إثبات واقعة الميلاد فى إقليم يخضع لسيادة الدولة التى يراد الانتساب إليها، وإثبات ذلك يتم عن طريق تقديم شهادة الميلاد،^(٣) فمثلاً إذا ادعى شخص فى مصر بأن له الجنسية المصرية بناء على حق الإقليم المدعم بحق الدم من جهة الأم، فإنه يكون عليه أن يثبت ميلاده فى مصر، وأنه من أم مصرية وأنه مولود لأب مجهول أو مجهول الجنسية أو عديمها،^(٤) مع ملاحظة أن تلك الحالة لا وجود لها فى قانون الجنسية بعد تعديله سنة ٢٠٠٤ وإنما ذكرت فقط على سبيل المثال.

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٦٩.

(٢) د. اشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢٧٢، ٢٧٣.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٧٧.

(٤) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٧٤.

(٥) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٦٩.

الباب الثانى

أحكام الجنسية فى القانون المصرى

= = =

متى تكونت الدولة فإنه يجب عليها أن تبين السكان الذين تثبت لهم صفة المواطنة فيها، ويسمى هؤلاء الأفراد بالأصول، وتسمى قواعد الجنسية فى هذه الحالة بأحكام جنسية التأسيس، وبذلك يوجد ارتباط بين نشأة الدولة ونشأة جنسيتها، وفى مرحلة لاحقة من التطور تتجه الدولة نحو وضع الأحكام الخاصة بجنسيتها فى المستقبل، وذلك حتى تحتفظ بركن الشعب فيها، فتضع القواعد التى تبين كيفية اكتساب هذه الجنسية وحالات فقدها، وتسمى الأحكام التى تنظم جنسية الدولة فى المستقبل بأحكام تنظيم الجنسية، والتى تظل قائمة ما بقيت الدولة، على عكس أحكام جنسية التأسيس والتى يقتصر دورها على فترة معينة وتبتهت بعد ذلك أهميتها بمرور الزمن،^(١) وقد تعاقبت القوانين المنظمة لأحكام الجنسية فى مصر منذ سنة ١٩٢٦، إلى أن صدر تشريع الجنسية المصرى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، والذى عدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، وستكون أحكام ذلك القانون محل دراسة فى هذا الباب من خلال ثلاثة فصول، يتحدث أولها عن كسب الجنسية المصرية، ويتحدث ثانيها عن زوالها، وفى الفصل الثالث والآخر نعرض لآثر انعدام الجنسية على تطبيق قواعد الجنسية.

= = =

(١) راجع فى تفصيل ذلك د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٥٨ وما بعدها. وراجع فى تفصيل تاريخ التنظيم الوضعى للجنسية المصرية د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٢٥٦ وما بعدها.

الفصل الأول

كسب الجنسية المصرية

حيث سبقت الإشارة إلى أن الفرد قد يكتسب جنسية الدولة فور ميلاده، وقد يكتسبها في تاريخ لاحق على الميلاد، وتسمى الجنسية في الحالة الأولى بالجنسية الأصلية، وفي الحالة الثانية بالجنسية الطارئة، وسوف نقسم دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثين، يتحدث أولهما عن أسباب كسب الجنسية المصرية الأصلية، وثانيهما عن أسباب كسب الجنسية المصرية الطارئة على النحو التالي:

المبحث الأول

كسب الجنسية المصرية الأصلية

سبقت الإشارة إلى أن الجنسية الأصلية تبنى عادة وفقاً لأحد معيارين أساسيين، هما حق الدم وحق الإقليم حيث يدل كل منهما على وجود رابطة فعلية بين الفرد والدولة، وقد اتخذ المشرع المصري موقفه من هذين المعيارين بإعتناق حق الدم بصفة أساسية مع الإعتداد بحق الإقليم في فروض استثنائية تلافياً لظاهرة إنعدام الجنسية أو لتدعيم حق الدم، وذلك في الحالات التي قدر فيها عدم كفايته لنقل الجنسية للابن إلى جانب اعتداده بحق الإقليم وحده في فروض استثنائية، وثبتت الجنسية المصرية الأصلية في كافة الفروض السابقة بقوة القانون، لذلك ينقسم البحث في هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول

الجنسية المصرية المبنية على حق الدم المطلق

جرى العمل في ظل أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على الإعتداد بالميلاد لأب يحمل الجنسية المصرية كأساس لاكتسابها، دون الإعتراف بحق الأم المصرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها إلا بشروط، تتمثل في ميلاد الطفل على الإقليم المصري، وأن يكون والده مجهول الجنسية أو عديمها أو لم يثبت نسبه إليه قانوناً، إلا أن الوضع تغير بعد صدور تعديل قانون الجنسية في ١٤ يوليو ٢٠٠٤، حيث تبنى المشرع المصري مبدأ المساواة الكاملة بين الأب والأم في نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء، وذلك بمقتضى القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، وذلك تفادياً للانتقادات التي كانت موجهة ضد القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥،^(١) وبذلك أصبح حق الدم سبباً لاكتساب الجنسية المصرية سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، وذلك على النحو التالي:

(١) راجع في تفصيل الانتقادات الموجهة إلى القانون قبل تعديله د. عوض الله شيبه الحمد السيد، د. خالد رافت أحمد: المرجع السابق، ص ١٢٣ وما بعدها.

أولاً- الجنسية الأصلية المبنية على الميلاد لأب وطني:

أعدت المشرع بصفة أساسية في ثبوت الجنسية المصرية على الميلاد لأب يحمل هذه الجنسية، وقد نص المشرع المصري على تلك الحالة في المادة الثانية، الفقرة الأولى من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، حيث ورد بها أن "يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية" ولكن يلزم لإكتساب الجنسية في هذه الحالة توافر شرطين:

الشرط الأول- الميلاد لأب مصري:

يشترط لإكتساب الطفل جنسية أبيه المصرية أن يكون هذا الأب متمتعاً بالجنسية المصرية، وذلك سواء أكانت هذه الجنسية أصلية أكتسبها منذ ميلاده، أم طارئة دخل فيها حديثاً، ومتى تحقق هذا الشرط اكتسب الإبن الجنسية المصرية حتى ولو زالت هذه الجنسية عن الأب في تاريخ لاحق على الميلاد، كما يعتبر هذا الشرط متحققاً متى كان الأب مصرياً وقت ميلاد الطفل، ولو كان أجنبياً وقت الحمل به، وكذلك لا أهمية لتعدد جنسية الأب بمعنى أنه لا يحمل الجنسية المصرية وحدها.

كذلك لا يعتد بمكان الميلاد فلا يحول ميلاد الطفل في الخارج دون تمتعه بالجنسية المصرية إذا كان الأب وطنياً، وفي حالة تغير جنسية الأب بين فترة الحمل ولحظة ميلاد الطفل فإنه يؤخذ في هذه الحالة بتوافر الصفة الوطنية للأب وقت ميلاد الطفل.^(١)

الشرط الثاني- ثبوت نسب المولود إلى أبيه قانوناً:

يشترط لإكتساب الإبن لجنسية أبيه المصرية أن يثبت نسب الولد إلى أبيه قانوناً، وللتحقق من صحة النسب يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المصري، والذي يقرر أن النسب يثبت بوسائل ثلاث هي الفرائش والإقرار والبيئة.

ويقصد بالفرائش الزوجية القائمة لحظة بداية الحمل، فوجود الزوجية قائمة وقت الحمل يكفي لثبوت نسب الطفل من أبيه، وذلك بغض النظر عن استمرار قيام الزوجية وقت الميلاد، كذلك قد يثبت النسب قانوناً بإقرار الأب بأبوته للمولود، كما تكفي أيضاً شهادة رجلين عدلين أو رجل وأمرأتين لإثبات النسب في هذه الحالة.

مع ملاحظة أنه في الفرض الذي لا يثبت فيه نسب الطفل لأبيه إلا في تاريخ لاحق للميلاد، فإن الجنسية الأصلية تثبت للطفل منذ الميلاد، مع عدم المساس بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص بوصفه أجنبياً^(٢).

(١) راجع في تفصيل ذلك د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٢٤، ٢٢٥.

(٢) راجع في ذلك د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٦٩.

ثانياً- الجنسية المصرية الأصلية المبنية على الميلاد لأم وطنية:

تلك هي الحالة التي أتى بها تعديل قانون الجنسية الصادر في ١٤ يوليو ٢٠٠٤، واشترط المشرع المصري في هذه الحالة كسابقتها شرطين:

الشرط الأول- الميلاد لأم مصرية:

يجب أن تكون الأم مصرية وقت ميلاد الطفل حتى يكتسب الجنسية المصرية، ويمكن الإحالة بصدد هذا الشرط إلى نفس الشرط المتعلق بالأب، حيث أن نفس القواعد ستطبق باستثناء أن الأم ستحل محل الأب في هذه الحالة، ولا عبء بجنسية الأب في هذه الحالة، فالشرط الوحيد هو تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت ميلاد الطفل.

الشرط الثاني- إثبات واقعة الميلاد في وثيقة رسمية:.

إذا كانت واقعة الميلاد قد تمت داخل الإقليم المصري فيكتفى بتقديم شهادة الميلاد، أما إذا وقعت الولادة في الخارج فيجب تقديم شهادة موثقة من إحدى القنصليات المصرية بالخارج تفيد وقوع ميلاد الطفل لأم مصرية، وقد قصد من وراء هذا الشرط منع أى فرصة للتحايل بادعاء الميلاد لأم مصرية للحصول على الجنسية دون توافر الحق فيها.^(١)

— — —

المطلب الثانى

الجنسية المصرية الأصلية المبنية على حق الإقليم المطلق

— — —

قاعدة إكتساب مجهول الأبوين لجنسية الدولة:

فى ذلك تنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن "يكون مصرياً من ولد فى مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس"، وطبقاً لهذا النص تؤسس الجنسية المصرية على حق الإقليم وحده دون الإعتداد بحق الدم، ويهدف المشرع من وراء تلك

(١) راجع فى تفصيل ذلك د. عوض الله شيبه الحمد السيد، د. خالد رأفت أحمد: المرجع السابق، ص ١٢٧.

القاعدة إلى الرغبة في تلافى ظاهرة إنعدام الجنسية لمن يولد من والدين مجهولين، وبذلك استجاب المشرع المصرى للأصول المثالية في مادة الجنسية والتي أوصت بها المؤتمرات الدولية.^(١)

ويشترط لإكتساب الجنسية في هذه الحالة شرطان:

١- تحقق واقعة الميلاد في مصر:

يشترط أن يكون ميلاد مجهول الأبوين على الإقليم المصرى سواء البرى أو البحرى أو الجوى، وحيث يكون إثبات حدوث تلك الواقعة على الإقليم المصرى في بعض الفروض من المتعذر عملاً، فقد افترض المشرع أن مجرد العثور على اللقيط في الإقليم المصرى قرينة على ميلاده فيه إلى أن يثبت العكس، فإذا أثبت العكس فيما بعد زالت الجنسية المصرية عنه من تاريخ الميلاد وليس من تاريخ إثبات العكس، مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص على أنه متمتع بالجنسية المصرية.^(٢)

٢- أن يكون الولد مجهول الوالدين أو لقيطاً:

يتمثل الشرط الثانى لمنح الجنسية في هذه الحالة في عدم معرفة أى من الوالدين، أى أن يكون الولد مجهول الأبوين فإذا أمكن معرفة إيهما إمتنع تطبيق تلك الحالة، وجهالة الأب تعنى عدم ثبوت نسب الولد لأبيه قانوناً، فيكفى لإعتبار الأب مجهولاً أن يكون نسب الولد لأبيه غير ثابت قانوناً، ولو عرف الأب من حيث الواقع، فإذا ثبت نسب الولد لأبيه فإن الجنسية الأصلية تلحق بالولد، وذلك طبقاً لحق الدم المستمد من جهة الأب وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥،^(٣) أما جهالة الأم فهي مسألة واقعية، فإذا كانت الأم معروفة من حيث الواقع وكانت مصرية الجنسية، وكان الأب مجهولاً فإن الولد يكتسب الجنسية المصرية الأصلية في هذه الحالة طبقاً لحق الدم المدعم بحق الإقليم، أما إذا كانت الأم معروفة من الناحية القانونية أمكن اعتبار الأب ابن مصرى الجنسية بناء على حق الدم من جهة الأم.

أما اللقيط فهو المولود الذى نبذه أهله خوفاً من العيلة أو هروباً من تهمة الزينة، وقد أكد المشرع المصرى بصده على أن "اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس" والحكمة من وضع تلك القرينة هي وضع اللقيط دائماً كمصرى، على الرغم من أنه قد يكون ولد في خارج مصر ثم نقل

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٣٨٠.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٣٨٠، د. فؤاد رياض: المرجع السابق، ص ٢٤٦، ٢٤٥.

(٣) راجع في تفصيل هذا الشرط د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٧٠، ١٧١.

إليها، لأنه لو ترك هذا اللقيط لتطبق عليه القاعدة المتعلقة بمجهول الأبوين لما استفاد منها في تلك الحالة (١).

المبحث الثاني

كسب الجنسية المصرية الطارئة

الجنسية الطارئة هي الجنسية التي يكتسبها الفرد في تاريخ لاحق على الميلاد، ولا أهمية في هذا المجال لتاريخ تحقق اسباب اكتساب الجنسية، وإنما العبرة دائماً بتاريخ الدخول فيها، فإذا كان هذا التاريخ لاحق على الميلاد فإنه يعد من قبيل الإكتساب الطارئ للجنسية، وطبقاً لما تم التعرض له ونحن بصدد دراسة الأحكام العامة في كسب الجنسية الطارئة، نجد أنها أفسحت مجالاً لإرادة الفرد في هذا الإكتساب وحظرت فرض الجنسية الطارئة عليه، وقد يكون دور تلك الإرادة إيجابياً في حالة الطلب الصريح، وقد يكون سلبياً في حالة امتلاك الدولة للحق في منح الفرد الجنسية الطارئة دون طلبه مع إعطائه الحق في ردها إن أراد.

وقد حرص المشرع المصري على أن يجعل أسباب كسب الجنسية الطارئة وسيلة للإستيئاق من توافر رابطة بين الفرد والدولة تبرر دخوله في جماعتها الوطنية، وقد نظم المشرع المصري التجنس بالجنسية المصرية في المواد ٣، ٤، ٥ من تشريع الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، ونظم الزواج المختلط في المواد ٧، ١٤ من نفس التشريع، ويعيب بعض الفقه على هذه النصوص الصياغة الرديئة التي وردت بها، بالإضافة إلى عدم الوضوح والتناقض فيما بينها، علاوة على أنه استعان ببعض الأفكار المفقوتة والتي عفا عليها الزمن في مجال الجنسية مثل فكرة الجنس. (٢)

ويمكننا أن ندرس أسباب كسب الجنسية الطارئة في القانون المصري من خلال التعرض للتجنس والزواج المختلط وخيار الاسترداد.

المطلب الأول

التجنس

تتباين طرق فقهاء القانون الدولي الخاص بصدد تقسيم حالات التجنس المنصوص عليها في القانون المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، ونميل من جانبنا إلى اعتماد طريقة الدراسة التي اتبعتها بعض

(١) راجع في تفصيل وضع اللقيط د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٧٤ وما بعدها

د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٧١.

(٢) راجع في نقد تلك النصوص. د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٩٦، ٩٧.

الفقه^(١) يصدد ذلك التقسيم، والتي جاءت متمشية مع التسلسل المنطقي للنصوص القانونية، وعلى ذلك سوف نقسم التجنس إلى الفروع الآتية:

الفرع الأول: التجنس المبني على حق الدم.

الفرع الثاني: التجنس المبني على حق الإقليم.

الفرع الثالث: التجنس المبني على حق الإقامة.

الفرع الرابع: التجنس الاستثنائي.

وفى الأمر تفصيل على النحو التالي:

الفرع الأول

التجنس المبني على حق الدم

تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه "يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية في مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من تاريخ وصول الإخطار إليه".

ولما كان المشرع المصري قد قرر المساواة بين كل من الأب والأم في منح الجنسية للمولود، فقد عدل نص تلك المادة في القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ ليصبح نصها على النحو التالي:

"يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدر قرار بذلك من الوزير، أو بإنقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض"

وبذلك فإن المشرع يقصد تطبيق تلك الحالة على الأبناء الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، أما من يولد بعد العمل بهذا القانون فيتمتع بالجنسية المصرية الأصلية طبقاً لما سبق توضيحه، مع ملاحظة أنه يشترط توافر أربعة شروط لكي نطبق نص المادة الثالثة بعد التعديل، تلك الشروط هي:

(١) ذلك هو التقسيم الذي أتبعه استاذنا الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم في المرجع السابق، ص ٩٧ وما بعدها.

١ - الميلاد لأم مصرية:

يعتبر المشرع المصري أن ميلاد الطفل لأم مصرية هو أحد القرائن القوية التي تدل على ارتباطه بمصر وتشعبه بتقاليدها، ولا عبرة بمكان ميلاد الطفل سواء حدث في مصر أو في الخارج، على خلاف الوضع قبل التعديل، والذي كان يشترط أن يكون ميلاد الطفل في الخارج، ويستوى أن تكون جنسية الأم المصرية هي جنسية أصلية أو جنسية طارئة، فالمعول عليه في ذلك أن تكون الأم مصرية فقط، ويتم إثبات الميلاد لأم مصرية بشهادة ميلاد صادرة من وزارة الصحة أو شهادة معتمدة من إحدى القنصليات المصرية بالخارج.

٢ - أن يكون الأب غير مصري:

بالإضافة إلى كون الأم مصرية لابد أن يكون الأب غير مصري، ويتم إثبات ذلك عن طريق وثيقة رسمية صادرة من إحدى السلطات المختصة بدولة الأب الأجنبي، ويذهب البعض^(١) إلى أنه مع صريح نص المادة ٣ والمضافة بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ فإنه "لا يجوز للطفل التمتع بالجنسية المصرية إذا كان الأب مجهول الجنسية أو عديمها إلا أنه حماية للطفل من إنعدام الجنسية يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية للطفل في هذه الحالة".

٣ - التقدم بطلب لوزير الداخلية:

لابد لإكتساب الجنسية في هذه الحالة أن يتم التقدم بطلب لوزير الداخلية لإعلان الرغبة في الحصول على الجنسية المصرية، ويتمتع الوزير بسلطة تقديرية بصدد قبول ذلك الطلب أو رفضه مع التزامه بتسبب قرار الرفض، وإذا كان الشخص الذي يرغب في اكتساب الجنسية المصرية قاصراً فإن الطلب سيقدم في هذه الحالة بواسطة نائبه القانوني أو الأم أو من يتولى تربيته في حالة عدم وجود أي منهما^(٢).

٤ - أن تتحقق واقعة الميلاد قبل ١٤ يوليو ٢٠٠٤م:

وعلة هذا الشرط أن الأبناء الذين يولدون بعد هذا التاريخ يتمتعون بالجنسية المصرية بقوة القانون، إعمالاً لنص المادة الثانية الفقرة الأولى من قانون الجنسية، وبذلك ينحصر مجال تطبيق تلك المادة على الأبناء الذين ولدوا قبل العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، ويؤكد البعض أن المشرع المصري بذلك النص يرغب في حصر تطبيق نص المادة الثالثة على حالات أبناء الأم المصرية الذين كانوا يعانون من عدم إمكانية تمتعهم بالجنسية المصرية في ظل القانون قبل التعديل^(٣).

(١) د. عوض الله شحبة الحمد السيد، د. خالد رأفت أحمد: المرجع السابق، ص ١٣٢.

(٢) المرجع السابق، ص ١٣٢.

(٣) المرجع السابق، ص ١٣٣.

ومن الملاحظ أن الجنسية تثبت في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية، أما في حالة عدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية برفض منح الجنسية فإن الجنسية في هذه الحالة تثبت بعد مضي سنة من تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية.

أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على اكتساب الجنسية المصرية الطارئة بمقتضى تلك الحالة فإن المادة الثالثة تنص على أن " يترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة، تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة".

ومن خلال ذلك النص فقد فرق المشرع بين الأولاد القصر والأولاد البالغين فيما يتعلق بالآثار العائلية لإكتساب الجنسية في هذه الحالة، حيث يتمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية بقوة القانون، أما الأولاد البالغون فيشترط بصدهم توافر الشروط الأربعة السابق الحديث عنها.

الفرع الثانى

التجنس المبني على حق الإقليم

— — —

اعتبر حق الإقليم أحد الأسس التي يتم بناء عليها منح الجنسية المصرية الطارئة، وذلك لأول مرة في القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وبشروط تدعيم هذا الأساس بمقومات أخرى تدل على اندماج الفرد في الجماعة الوطنية، ويصبح هناك نوع من الارتباط بين ذلك الفرد والدولة المصرية، ومن خلال نص المادة الرابعة من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ يتبين لنا أن حالات إكتساب الجنسية المصرية بناء على حق الإقليم يمكن إدراجها في إطار ثلاث حالات هي كالتالي:

أولاً- التجنس القائم على حق الإقليم المدعم بالأصل المصري:

تنص المادة الرابعة - الفقرة الأولى من قانون الجنسية المصري على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم طلب التجنس".

ويتضح من هذا النص أنه توجد أربعة شروط لابد من توافرها في الشخص لكي يجوز له طلب اكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة وتلك الشروط هي:

الشرط الأول - الميلاد في مصر:

طبقاً لنص المادة الرابعة - الفقرة الأولى فإنه يشترط أن يكون ميلاد طالب التجنس قد وقع على الإقليم المصري يستوى في ذلك الإقليم البرى أو البحرى أو الجوى.^(١)

الشرط الثانى - الإلتقاء بالأصل المصرى:

عرفت المادة ٢٣ من قانون الجنسية الحالى الأصل المصرى بأنه "يقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبية فى شأنه أو شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الإعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولوداً فى مصر".

وقد تعرض موقف المشرع بصدد هذا النص لانتقادات لأذعة من جانب الفقه حيث يذكر البعض^(٢) أن "المشرع قد ارتأى أن يحدد معنى الأصل المصرى المقصود فى هذا الصدد وذلك بالنص الصريح، ولكنه أتانا للأسف بتعبيرات قد تحتاج فى تفسيرها إلى قواميس من اللغة والحسابات اللوغاريتمية لفهم معناها أو حصر الفروض المتصورة بمقتضاها"

ويتضح من هذا النص أن المشرع وضع ثلاثة شروط لإعتبار الشخص من أصل مصرى هى:

١- أن يكون الشخص مصرى الجنس: وقد وجه الفقه المصرى سهام النقد إلى استعانة المشرع بفكرة الجنس، لتحديد الأصل المصرى أو السورى، وذلك فى ظل تشريع الجنسية الصادر سنة ١٩٥٨، حيث يصعب رد رابطة الجنسية إلى فكرة الجنس بوصفها فكرة مرنة لا تتضمن معنى علمياً محدداً ولا تعبر عن معنى اجتماعى واضح.^(٣)

حيث إنه من العسير الإعتماد على الجنس لتحديد أية جماعة وطنية نظراً لإختلاط الأجناس وتشابكها فى العصر الحديث، لذلك كان واجباً أو التزاماً، "أحرى بالمشرع أن يدلنا على المقصود بالجنس المصرى وخاصة بسبب طبيعة الجماعة المصرية المركبة التى لم تنج من تأثير الفتوحات العديدة التى تعرضت لها منذ القدم".^(٤)

ويذهب جانب من الشراح إلى أنه كان يجب على المشرع أن يستعين فى بيان الأصل المصرى بفكرة الحالة الظاهرة، بل إنه لا مفر من ضرورة تفسير المقصود بالأصل المصرى والجنس المصرى

(١) د. عوض الله شبية الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٧٥.

(٢) د. أحمد قسمت الجداوى: الوجيز فى لقانون الدولى الخاص، الجزء الأول، ١٩٧٧، دار النهضة العربية، ص ١٢٩.

(٣) فى تفصيل ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤١٧.

(٤) د. فؤاد رياض، د. سامية راشد: الوجيز فى القانون الدولى الخاص، القاهرة، ١٩٧١، ص ١٨٣.

في مفهوم النصوص القائمة في ضوء هذه الفكرة، فيعتبر بذلك من أصل مصري "كل من يظهر بمظهر المصري"^(١)

ويعتبر تحديد الحالة الظاهرة بهذا الشكل مسألة واقع تخضع لتقدير السلطة التنفيذية، وتستعين في ذلك بعدة عناصر مثل الأسم والشهرة والمعاملة، فقد يكون الشخص منحدرًا من أسرة تحمل أسما مصريًا أو اشتهرت بكونها مصرية خلال مدة طويلة، فيعتبر الشخص في هذه الحالة من وجهة نظر السلطة التنفيذية منتميًا إلى الجنس المصري.^(٢)

ويذهب البعض إلى أنه لا مانع من الرجوع إلى فكرة الرعوية المحلية القديمة التي كانت تربط الشخص بمصر، حينما كانت من الأقاليم التابعة للدولة العثمانية وذلك لضبط مدلول الأصل المصري.^(٣)

وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لتشريع الجنسية الحالي حيث قررت أن المقصود بالأصل المصري "هو الإنتماء إلى الكتلة السكانية الغالبة في البلد. والكتلة السكانية المصرية أمرها واضح، وهي التي تكون المصريين الأصلاء في الدولة المصرية ومن إدراج معهم من الوافدين إليها بحيث تمصروا فعلا، وهذه الكتلة السكانية الأصلية هي التي يعبر عنها قانون ١٩٢٩ بالمتوطنين في مصر قبل سنة ١٨٤٨، وكذلك عبرت عنها القوانين المختلفة بمن أقاموا بمصر إقامة طويلة المدة أدمجتهم في المصريين، فهو لاء جميعاً هم الجنس المصري".

٢- ميلاد أحد الأصول في مصر:

يستلزم هذا الشرط أن يكون أحد أصول الشخص أو أصول زوجته مولوداً في مصر، ويتصل بالأصل المصري للشخص الأب أو الجد وإن علا أو الأم والجدة وإن علت، فإذا تحقق ميلاد ابيهم في مصر توفّر هذا الشرط^(٤).

٣- عدم الحصول على الجنسية المصرية لتخلف ركن الإقامة:

(١) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٤١٧.

د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٣٢٢.

د. فؤاد رياض، د. سامية راشد: المرجع السابق، ص ١٨٣.

(٢) د. فؤاد رياض، د. سامية راشد: المرجع السابق، ص ٣٢٣.

(٣) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٤١٨.

د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٣٢٣.

(٤) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٧٤.

اشترط المشرع أخيراً أن يكون الشخص لم يدخل في الجنسية المصرية بسبب عدم إكمال مدة الإقامة اللازمة لإعتباره مصرياً، أو لإعتبار زوجته أو ابنه القاصر مصرياً، وكذلك الأمر إذا كانت هذه المدة متوافرة ولكن تعذر إثباتها، ولكن ما هو الحكم إذا كان عدم الحصول على الجنسية المصرية يمكن رده بسبب آخر غير تخلف ركن الإقامة؟

يذهب رأى من الفقه إلى أنه من المنطقي توحيد الحكم في الحالتين نظراً لتحقيق نفس النتيجة، وهي عدم الحصول على الجنسية رغم اختلاف الأسباب، مع ملاحظة أن التمسك بحرفية النص يؤدي إلى عدم توحيد الحلول في الحالتين^(١).

الشرط الثالث - الإقامة العادية في مصر:

يشترط المشرع أيضاً لمنح الجنسية في هذه الحالة أن تكون إقامة الولد المعتادة في مصر و ذلك قبل تقديمه طلب التجنس، وإن كان لم يحدد المدة المطلوبة في الإقامة في هذه الحالة حتى يمكن اعتبار الشخص مقيماً في مصر، فإنه يكفي توافر ركن الإقامة المادي ويقوم على توافر الإقامة العادية في مصر، والمعنوي ويقوم على توافر نية الاستقرار والإستمرار والبقاء فيها.^(٢)

الشرط الرابع - بلوغ سن الرشد:

لا بد من بلوغ الشخص لسن الرشد حتى يمكنه تقديم طلب التجنس، ومن الممكن رد اشتراط هذا الشرط إلى أن التجنس عمل من الأعمال الإرادية والتي يفصح فيها الشخص عن إرادته بقصد ترتيب اثر قانوني معين، ويجب تحديد سن الرشد وفقاً لأحكام القانون المصري.

متى توافرت الشروط الأربعة السابقة يجوز لمن توافرت فيه أن يطلب اكتساب الجنسية المصرية، ولا شك أن توافر كافة هذه الشروط المقترن بطلب اكتساب الجنسية لا يعنى التزام الدولة بمنحها لمن يطلبها، وإنما هي تتمتع في ذلك بالسلطة التقديرية المطلقة.^(٣)

ثانياً - التجنس القائم على حق الإقليم المقترن بالميلاد المضاعف:

تنص المادة الرابعة - الفقرة الثالثة من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضاً فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد".

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٠.

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٧٥.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١١.

ومن خلال ذلك النص أخذ المشرع المصري في بناء الجنسية المصرية الطارئة بحق الإقليم في صورته المشددة، والتي يطلق عليها فقه القانون الدولي الخاص "الميلاد المضاعف" إذ يلزم فيها أن يكون الأجنبي طالب الجنس ذاته وأبيه قد ولد كلاهما في مصر،^(١) ومن النص يتضح أيضاً أن المشرع اشترط ثلاثة شروط لتحقيق هذا الفرض:

الشرط الأول - الميلاد المضاعف في مصر:

ويقصد به ميلاد الشخص ووالده في إقليم الدولة، وهو ما يدل على الارتباط بالمجتمع المصري فميلاد جيلين متعاقبين في الإقليم الوطنى يدعم قرينة الاندماج فى الجماعة الوطنية،^(٢) ولا يكفى ميلاد أى من الشخص أو الأب فى مصر بل يجب ميلاد كلاهما فيها، كما لا يعتد بمكان ميلاد الأم سواء وقع فى مصر أم فى الخارج كما لا يغنى ميلادها فى مصر عن ميلاد الإبن أو الأب فيها.^(٣)

ولم يشترط المشرع لتوافر هذا الشرط التوطن ولا الإقامة فى مصر، وإن كان قد قصد به التحقق من ارتباط الأسرة بالدولة وهو ما لا يتحقق إلا بالتوطن فيها.^(٤)

ولكن يجب ان يثبت نسب الإبن الذى ولد فى مصر إلى أب ولد فى مصر، وهو ما يوجب كون الإبن شرعياً لأب مولود فى مصر، وتتحدد صحة البتوة كما ذهب البعض "بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق بمقتضى قواعد الإسناد المدرجة فى القانون المصرى، وليس بالرجوع إلى أحكام القانون المصرى الداخلية بوصفه قانون الجنسية المراد اكتسابها كما يفهم من قول الفقه المصرى فى جملته".^(٥)

الشرط الثانى - الإلتواء للأصل العربى أو الإسلامى:

لا يكفى توافر شرط الميلاد المضاعف السابق الحديث عنه بل يجب أن يكون الأجنبي منتظماً إلى غالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وبذلك لم يعتبر المشرع الميلاد المضاعف للأجنبي فى مصر قرينة كافية على اندماجه فى الجماعة الوطنية، وإنما لابد أن تربط الأجنبي بالجماعة المصرية روابط قوية، وذلك إما بالاشتراك فى اللغة أو الدين.^(٦)

(١) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٠٢.

(٢) د. فؤاد رياض. د. سامية راشد: المرجع السابق، ص ١٧٢.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٠٣.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٠٣.

(٥) المرجع السابق، ص ١٠٣.

(٦) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٢٥.

وقد عبر المشرع عن هذا الشرط بقوله "إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام" ولعل المشرع بذلك قد راعى أن مصر نفسها بلد لغته العربية ودينه الإسلام معاً، أو يشمل هذا الحكم أساساً العرب ولو كانوا غير مسلمين، والمسلمين ولو كانوا غير عرب متى كانوا من أهل بلد إسلامي^(١)، فيجوز أن يشمل غير العرب من ينتمون لبلاد تدين بالإسلام دون أن تتكلم العربية مثل أندونيسيا وباكستان وإيران، ومن الممكن أن يشمل بعض البلاد التي تتكلم العربية ولا يعتبر الإسلام دينها الرسمي مثل لبنان.^(٢)

ولابد أن يكون الإنتماء إلى غالبية السكان وليس إلى أقليتهم، وعلى هذا فلا يكفي الإنتماء إلى مسلمي الهند للقول بتوافر هذا الشرط، ويؤكد البعض على أنه لا فرق بين الإنتماء إلى غالبية السكان أو إلى البلد فالنتيجة واحدة.^(٣)

وتجب ملاحظة أن المشرع لم يشترط أن يحمل الأب جنسية البلد الذي ينتمي إليه، فقد يكون هذا البلد غير مستقل وليس له جنسية مستقلة " وإنما يكفي أن ينتسب إلى غالبية السكان في بلد عربي إسلامي".^(٤) وهو ما يعبر عنه "أن يكون البلد العربي أو الإسلامي محتفظاً بذاتيته من حيث الواقع"^(٥) ومن الممكن التمثيل لذلك بإنتماء الأب الأجنبي إلى تونس خلال خضوعها للحماية الفرنسية لا يحول دون تحقيق الشرط المطلوب في هذه الحالة.^(٦)

ولكن يوجد تساؤل متعلق بالرابطة التي يلزم توافرها لقيام الإنتماء إلى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، هل يكون الإنتماء بالجنس أو بالجنسية أو بالأصل؟.

من المؤكد أن تلك الرابطة ليست رابطة الجنس، حيث أن المشرع قد حذف كلمة الجنس بعد أن كان قانون سنة ١٩٥٨ وقبله قانون سنة ١٩٢٩ ينص على إشتراط الإنتماء بالجنس لغالبية السكان، ويؤكد البعض أن المشرع بهذا الحذف قد أحسن صنعا، حيث أن فكرة الجنس لا تصلح معياراً لبناء الجنسية في العصر الحالي، بالإضافة إلى أن هذه الرابطة ليست رابطة الجنسية، حيث أن النص يتطلب الإنتماء إلى غالبية السكان في البلد وليس الإنتماء للدولة، وبذلك فلا يتوافر هذا الشرط فيمن ينتمي

(١) د. أحمد مسلم: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، ١٩٥٦، مكتبة النهضة، ص ٢٠٠.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٠٤.

(٣) المرجع السابق، ص ١٠٤.

(٤) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٢٩٩.

(٥) د. فؤاد رياض، د. سامية راشد: المرجع السابق، ص ١٧٣.

(٦) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٢٥.

للأصل الروسى وحصل على الجنسية التركية،^(١) ويؤكد هذا الفقه أن تلك الرابطة هي الإنتماء بالأصل بمعنى أن يكون الشخص منحدرًا من أصل من غالبية السكان في بلد عربى أو اسلامى.

ويذهب آخرون^(٢) إلى أن أقصى ما يمكن قوله في ظل تشريع الجنسية القائم، هو أن المشرع قد ألقى على الفقه والقضاء بمهمة البحث عن معيار إنتماء الأجنبى لغالبية السكان في البلد العربى أو الإسلامى عند تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وهو اتجاه أفضل على أى حال من تحديد فكرة الجنس كأساس للكشف عن هذا الإنتماء كما كان الحال فى تشريع ١٩٥٨.

ويؤكد هذا الفقه على أنه يستحسن ترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء أو جهة الإدارة، عند تطبيق الحكم الوارد بالنص فى كل حالة على حدة، لمحاولة الكشف عن مدى الإنتماء الاجتماعى والتاريخى للأجنبى إلى غالبية السكان فى دولة عربية أو إسلامية، ويمكن الكشف عن ذلك الإنتماء من خلال فكرة الحالة الظاهرة.^(٣)

ويبقى التساؤل المتعلق بالمقصود بالإنتماء لغالبية السكان فى بلد دينه الإسلام ولكن لغته غير العربية، وهل يشترط فى هذه الحالة لإعتبار الشخص منتمياً إلى غالبية السكان أن يدين بالإسلام؟

يذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب لإعتبار الشخص منتمياً إلى غالبية السكان أن يكون الأب الأجنبى مسلماً، مادام أنه ينتمى إلى دولة إسلامية غير عربية مثل تركيا.^(٤)

ويذهب آخرون^(٥) إلى القول بأن اشتراط إنتماء الأب إلى الدين الإسلامى فى هذه الحالة هو تقييد لا يحتمله النص، وعلى هذا النحو فإن ما يشترط فى الأب الأجنبى هو "أن يكون عربياً ينتمى إلى بلد معظم سكانه من العرب وذلك بصرف النظر عن كونه مسلماً أو مسيحياً (وهو ما ينطبق على كافة البلاد العربية الواقعة بين المحيط والخليج)، أو أن يكون الأب منتمياً إلى السواد الأعظم من الشعب فى بلد يدين بالإسلام، حتى ولو لم يكن بلداً عربياً (مثل تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان) ولا يشترط فى هذه الحالة أيضاً أى شرط متعلق بالدين، فقد يكون الأب الأجنبى مسلماً أو مسيحياً".^(٦)

وإذا كان الأب الأجنبى منتمياً إلى أقلية السكان، فإن الشرط المطلوب فى هذه الحالة لا يكون متوافراً، فالإنتماء إلى أقلية السكان لا يكفى ولو كان سكان البلد يتكلمون العربية أو يدينون بالإسلام،

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٠٥.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٢٧.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٢٧.

(٤) د. أحمد مسلم: المرجع السابق، فقرة رقم ٢٠٢.

(٥) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٢٧، ٤٢٨.

(٦) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٢٩٩.

كما لو كان الأب يهودياً فلسطينياً أو أرمينياً تركيا، وسبب ذلك أن الانتماء إلى الأقلية، قد يذهب برابطة اللغة أو الدين التي أرادها المشرع في ربط الولد بجماعة الجمهورية، لأن البلد الذي تكون لغته العربية أو دينه الإسلام، تكون غالبية سكانه تتكلم العربية أو تدين بالإسلام وذلك على خلاف الأقلية التي قد لا تكون لغتها العربية أو دينها الإسلام.^(١)

الشرط الثالث - التقدم بطلب للدخول في الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغ سن الرشد:

يقوم التجنس على إرادة الشخص في اكتساب الجنسية، لذلك فقد اشترط المشرع أن يعبر الشخص عن إرادته فيطلب اكتساب الجنسية المصرية، كما يجب أن تكون له إرادة يعتد بها قانوناً، بأن يكون بالغاً سن الرشد، ويراعى أن المشرع قد حدد فترة زمنية يتعين طلب الجنسية في خلالها وهي فترة سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، وعلى هذا فيسقط حق الشخص في طلب اكتساب الجنسية إذا مضت عليه سنة بعد بلوغه سن الرشد دون أن يتقدم بطلب لإكتساب الجنسية.

وتجدر ملاحظة أن توافر الشروط السابقة لا تعني حتمية منح الجنسية المصرية لطالب التجنس بها، فقد ترك المشرع منح الجنسية لسلطة الدولة التقديرية، إذ أن منح الجنسية في هذه الحالة يخضع للسلطة التقديرية لوزير الداخلية، ومن ثم يحق له الإمتناع عن إصدار هذا القرار وذلك على الرغم من توافر الشروط السابقة.^(٢)

ثالثاً - حق الإقليم المقترن بالإقامة العادية:

تنص المادة الرابعة - الفقرة الرابعة - من القانون ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:

- ١- أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- ٢- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ٣- أن يكون ملماً باللغة العربية.

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٢٨.

د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، في الجنسية وتمتع الأجانب بالحقوق، الطبعة الثامنة، ١٩٦٨، ص ٣٩٧.

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٧٧.

٤- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب."

ومن خلال ذلك النص يتضح لنا أن المشرع المصرى فى هذه الحالة قد قرن الميلاد فى مصر بشروط أخرى، بهدف التحقق من أهلية طالب التجنس، وأنه لائق لكسب الجنسية، ولديه القدرة على الاندماج بسهولة فى المجتمع المصرى، تلك الشروط هى:

الشرط الأول - الميلاد فى مصر:

ويتحقق الميلاد فى هذه الحالة فى صورته البسيطة بالإكتفاء بميلاد طالب التجنس وحده، دون اشتراط ميلاد والده أيضاً فى الإقليم المصرى، ويتحقق الميلاد فى هذه الحالة على الإقليم المصرى فى أى من مكوناته الثلاثة البرى والبحرى والجوى.

الشرط الثانى - الإقامة العادية فى مصر:

تقوم الإقامة العادية فى هذه الحالة على عنصرين: أولهما العنصر المادى ويتمثل فى الوجود على الإقليم المصرى، وثانيهما العنصر المعنوى ويتمثل فى نية البقاء أو الإستقرار على الإقليم المصرى، ولا يشترط فى هذه الحالة أن تقيد الإقامة بمدة معينة، وإنما يكفى أن تكون إقامة معتادة فيكتفى بصدها يتوافر ركنيها السابق الحديث عنهما.^(١)

وبهذا الشرط أراد المشرع التحقق من قيام رابطة حقيقية بين الدولة والشخص الذى ولد بإقليمها، وذلك بغرض إخراج الأشخاص الذين يقع ميلادهم على إقليم الدولة بصفة عارضة من نطاق تلك الحالة، وكذلك يتم استبعاد الأشخاص الذين تركوا مصر بعد ميلادهم وقبل اندماجهم فى الجماعة الوطنية، وقد قيد هذا الشرط أيضاً بقيد زمنى متمثل فى ضرورة إقامة الشخص المعتادة فى مصر عند بلوغه سن الرشد،^(٢) وأن يقدم طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، وبالتالي لا يقبل طلب التجنس إذا قدم بعد مرور سنة من هذا التاريخ، حيث إن مرور تلك المدة دون التقدم بالطلب يدل على عدم اهتمام الفرد بالحصول على الجنسية المصرية،^(٣) ويتم تحديد سن الرشد طبقاً لأحكام القانون المصرى، وذلك بمقتضى نص المادة ٢٣ من قانون الجنسية الحالى.^(٤)

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٢.

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٧٨.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٢، ١١٣.

(٤) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٨٠.

الشرط الثالث - الإلمام باللغة العربية:

يعد إلمام الشخص باللغة العربية أحد الدلائل على إدماجه أو إمكانية إدماجه بسهولة في مجتمع الدولة، حيث أن تلك اللغة هي اللغة الرسمية في مصر، وهذا الشرط هو شرط مكمل للشرطين السابقين، فمن يولد في إقليم الدولة ويقيم فيها عادة يجب أن يكون محيطاً بلغة الدولة لكي يكون ارتباطه بهذه الدولة ارتباطاً حقيقياً.^(١)

ولكن يجب تحديد المقصود بالإلمام باللغة العربية، وهل يقصد به مجرد القدرة على فهم اللغة أم يلزم القدرة على القراءة والكتابة بها أيضاً؟

في الحقيقة إن عبارة الإلمام باللغة العربية عبارة مطاطة تحتمل الكثير من التفسيرات، التي تبدأ من القدرة على التفاهم باللغة العربية حتى إجادتها قراءة وكتابة ويذهب البعض^(٢) إلى " أن المشرع قد أحسن بعدم التقيد بتفسير محدد للإلمام باللغة باعتباره أن هذا الإلمام يختلف من شخص لآخر على حسب ظروفه ومجال عمله ومستواه العلمي".

بينما فسر البعض الآخر الإلمام باللغة العربية بأنه معرفة هذه اللغة قراءة وكتابة حسب حالة الشخص وليس فقط فهمها بالسماع، وذلك تحقيقاً للمراد من هذا الشرط وهو التأكد من إدماج ذلك الشخص في المجتمع المصري.^(٣)

ومؤدى ما سبق "أن معرفة اللغة العربية شرط مطلوب لكن مدى المعرفة هذه يخضع للتقدير، فإذا كان المتجنس بحكم سنه لم يصل إلى درجة عالية من الإلمام باللغة، ولكنه كان قادراً على التفاهم بها، فإنه لا مانع في هذه الحالة من اعتبار المتجنس " ملماً باللغة العربية" متى كان في تجنسه بالجنسية المصرية فائدة للمجتمع المصري وكان له مثلاً أبناء قصر في الجامعات المصرية يجيدون العربية، وكان من المرغوب فيه قبول تجنس الأسرة كلها في مصر".^(٤)

الشرط الرابع - صيانة مجتمع الدولة:

أدرج المشرع تحت هذا الشرط بندين هامين، فقد نص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة على أن " ٢ - أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، حيث أن صدور أى من هذه

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٣.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٣.

(٣) د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، الطبعة الحادية عشر، ١٩٨٦، الهيئة المصرية للكتاب، ص ٤١٥.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٢٣.

الأحكام ضد طالب التجنس يجعله عضواً غير مأمون الجانب في مجتمع الدولة مما يهدد أمنها وحياتها الاجتماعية، كما ينص أيضاً في نفس الفقرة على أن " ١ - أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع..... ٤ - أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب "، وتطلب مثل هذا الشرط أمر منطقي، فليس من مصلحة الدولة أن تدخل في الجماعة الوطنية أفراداً يمثلون عالة عليها مستقبلاً وذلك لأنهم غير قادرين على كسب رزقهم أو لإصابتهم بعاهة، ولأنهم سيشكلون خطراً على أمنها أيضاً بسبب عدم وجود أى مورد للرزق بالنسبة لهم، وتجدر الإشارة أن تشريعات الجنسية لبعض الدول العربية تتضمن نصوصاً أكثر حماية للجماعة الوطنية من ذلك النص الذي أتى به المشرع المصري، حيث تطلب أن يكون الأجنبي طالب التجنس ذو إختصاص أو خبرة يمكن الإستفادة منها،^(١) كما تتطلب خلو الأجنبي من الأمراض ولا تقتصر على عدم إصابته بعاهة.^(٢)

وتجدر ملاحظة أن توافر الشروط الأربعة السابقة التي قررها المشرع المصري للتجنس بالجنسية المصرية بمقتضى تلك الحالة لا يلزم الدولة بمنح الجنسية لمن توافرت فيه، وذلك لأن الأمر جوازى للسلطة التنفيذية التي يحق لها أن ترفض منح الجنسية للأجنبي الذي يطلبها لأنها تتمتع بسلطة تقديرية في ذلك.^(٣)

الفرع الثالث

التجنس المبني على الإقامة

تنص المادة الرابعة - الفقرة الخامسة من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة لتقديم طلب التجنس، متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت الشروط الآتية:

- ١- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- ٢- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ٣- أن يكون ملماً باللغة العربية.

(١) وهو ما قرره تشريع الجنسية السوري الصادر سنة ١٩٦٩ في المادة الرابعة منه.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٥٧، ٢٥٨.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٥.

٤- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب".

وتتص الفقرة الثانية من تلك المادة على أن "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغاً سن الرشد" ومن استقراء الفقرتين السابقتين يتضح لنا أن المشرع فرق بين حالتين لإكتساب الجنسية بالإقامة.

الحالة الأولى: ويتم اكتساب الجنسية فيها بمضى عشر سنوات على الإقامة فى الإقليم المصرى، ويطلق على هذه الحالة التجنس القائم على الإقامة الطويلة أو بمقتضى الإقامة العشرية.

الحالة الثانية: ويتم فيها اكتساب الجنسية بمضى خمس سنوات على الإقامة القصيرة أو التجنس بمقتضى الإقامة الخمسية.

أولاً- التجنس المبني على الإقامة الطويلة:

يشترط لإكتساب الجنسية فى هذه الحالة عدة شروط ورد النص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من تشريع الجنسية الحالى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، تلك الشروط هى:

الشرط الأول- الإقامة فى مصر مدة عشر سنوات:

وهذه المدة طويلة نسبياً وهو ما يتفق مع الوضع فى مصر بإعتبارها دولة مصدرة للسكان وليست مستوردة لهم، حيث يزيد تعداد وطنيها أكثر من مليون نسمة كل عام، وبالتالي يتعين التشدد فى منح الجنسية.^(١)

ويذهب بعض الفقه إلى إنقضاء طول هذه المدة، حيث أن ذلك يمثل إضراراً بالصالح العام، لأن الدولة لن تتمكن من منح جنسيتها لمن ترى منحها له بسبب خبرته غير العادية، وتمثل تلك المدة عائقاً لضمه فى هذه الحالة، وأن النص لم يفرق بين الأجنبى العربى وغير العربى من حيث مدة الإقامة، حيث أن الأجنبى العربى قد لا يحتاج إلى نفس المدة التى يحتاجها الأجنبى غير العربى للإندماج فى المجتمع المصرى، وهو ما فعلته بعض التشريعات العربية.^(٢)

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٦.

(٢) راجع بالتفصيل فى ذلك د. فؤاد رياض: الجنسية المصرية، ١٩٩٠، دار النهضة العربية، ص ٢٣١.

وقد اشترط المشرع المصري أن تكون مدة الإقامة مستمرة، فنص على أن تكون مدة العشر سنوات متتالية، أى يجب أن تكون تلك المدة متصلة بمعنى استمرارها دون إنقطاع،^(١) ولكن هل يعنى ذلك أن سفر طالب التجنس خارج الإقليم المصري من شأنه أن يقطع مدة الإقامة؟

استقر الفقه والقضاء^(٢) على أن شرط استمرار المدة لا يحتم استمرار البقاء في مصر طوال مدة العشر سنوات، فغياب طالب التجنس عن الإقليم المصري غياباً مؤقتاً لا يقطع مدة الإقامة المطلوبة، ويعتبر ذلك الغياب مؤقتاً متى أقرن بنية العودة، مثل السفر للخارج للعلاج أو السياحة أو لأداء الخدمة العسكرية أو طلب العلم، في كل الحالات السابقة فإن الغياب المؤقت لا يقطع مدة الإقامة ما دام أن طالب التجنس قد عاد بعد إنتهاء الغرض الذي سافر من أجل القيام به.

ويؤكد البعض على أن " كل غيبة عن مصر طالت أم قصرت تكون قاطعة للمدة المتطلبة، متى تمت بنية عدم العودة إلى مصر، فإن أقام الأجنبي في مصر تسع سنوات وغادرها نهائياً إلى الخارج بأن نقل مركز أعماله مثلاً، وشهد حاله بإنقطاع كل وصل بينه وبين مصر، فإن مثل هذا الشخص إذا عاد إلى مصر ورغب في الدخول في الجنسية المصرية فإن عليه أن يقيم في مصر مدة عشر سنوات، والمدة السابقة التي سبق أن قضاها عندنا لا يكون لها أدنى اعتبار".^(٣)

ولما كان المشرع المصري قد تطلب أن تكون مدة الإقامة المطلوبة سابقة على تقديم طلب التجنس، فقد تساءل الفقه عن الوقت الذي يبدى فيه طلب التجنس؟ وعما إذا كان من اللازم أن يبادر طالب التجنس بتقديم الطلب فور اكتمال مدة العشر سنوات؟ أم يجوز أن يتراخى طالب التجنس في تقديم طلبه إلى تاريخ لاحق على ذلك؟

(١) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٨١.

(٢) راجع في موقف الفقه :

د. أحمد قسنت الجداوى: الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، دار النهضة العربية، ١٩٧٧، ص ١٣٣.

د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة العاشرة، ١٩٧٧، ص ٤١٣.

د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٧.

- وقد أكدت على ذلك محكمة القضاء الإدارى في حكمها الصادر بتاريخ ٢٥ نوفمبر ١٩٥٢، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإدارى في خمسة عشر عاماً. ١٩٦٤ ١٩٦٥، الجزء الأول، ص ٣٣.

- وحكمها الصادر في ١٨ يناير ١٩٥٣ حيث قررت أنه " إذا كانت المدعية الإيطالية قد غادرت مصر لعلاج زوجها لا يقطع إقامتها في مصر طالما أنها كانت تنوى العودة إليها. وإذا كانت الحرب العالمية الأخيرة قد حالت بينها وبين العودة عقب وفاة زوجها مباشرة فلا تعتبر مدة إقامتها منقطعة طالما أنها قد عادت بالفعل بعد إنتهاء الحرب " .
المجموعة ص ٣٥.

(٣) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٢٠.

يذهب البعض إلى أنه يجب على طالب التجنس أن يتقدم بطلبه بعد مرور العشر سنوات مباشرة وألا يتراخى في ذلك، حيث يعتبر أنه لا يستطيع التشبه بأهل البلد أو أنه لا يرغب في ذلك، فلا يجوز له أن يقدم طلب التجنس بعد ذلك، وخاصة في الحالة التي يقوم فيها بنقل مركز أعماله للخارج^(١).

بينما يذهب آخرون^(٢) إلى القول "بالتفرقة بين استمرار إقامة الأجنبي في الإقليم المصري لمدة تزيد عن عشر سنوات، وبين انقطاع مدة الإقامة بعد اكتمال العشر سنوات، ثم تقديم الطلب بعد ذلك، ففي الحالة الأولى يجوز تقديم طلب التجنس بلا شك ولو بعد عشرين عاماً أو أكثر، وذلك طالما كانت الإقامة متصلة، ولقد صرح المشرع بهذا الحكم حين نص على أن مدة العشر سنوات هي الحد الأدنى للإقامة المطلوبة في مصر، وبالتالي فيجوز أن تزيد الإقامة في مصر على هذه المدة دون أن يؤثر ذلك على حق الأجنبي في طلب التجنس، أما في الحالة الثانية وهي التي يقطع فيها الأجنبي إقامته في مصر بعد اكتمال العشر سنوات، كأن يغادر الإقليم المصري بنية عدم العودة إليه، فإن ذلك يهدم قرينة اندماجه في المجتمع المصري، هذه القرينة المستفادة من إقامته لمدة عشر سنوات في مصر، وبالتالي فلا يقبل من الأجنبي طلب التجنس بالجنسية المصرية الذي يقدمه في تاريخ لاحق على ذلك بإعتبار أن مدة الإقامة ليست سابقة على طلب التجنس ويتعين عليه (إذا ما أراد التجنس) قضاء مدة إقامة جديدة"^(٣).

ويذهب جانب من الفقه إلى أنه من العسير الأخذ بفكرة وجوب قضاء مدة إقامة جديدة على إطلاقها، حيث أن خروج الأجنبي من مصر لا يدل على عدم قدرة الأجنبي على الاندماج في الجماعة المصرية، حيث إن الخروج قد يكون لأسباب قهرية لا تعبر عن رغبته في الاستقرار في الخارج ولا ينفي نية العودة، ولذلك ففي مثل هذا الفرض لا توجد حاجة لقضاء مدة جديدة، حيث إن قرينة الاندماج في الجماعة المصرية تبقى قائمة، أما إذا كانت مغادرة الأجنبي لإقليم الدولة بعد إنقضاء العشر سنوات مقترنة بنية عدم العودة، كأن يكون الأجنبي قد غير مركز أعماله لدولة أجنبية مثلاً، فذلك مما يهدم قرينة اندماجه في الجماعة المصرية، ومن ثم لا يجوز له طلب التجنس إلا بعد قضاء مدة إقامة جديدة^(٤).

(١) راجع في تفصيل هذا الرأي. د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص ٤١٣.

(٢) من هذا الرأي د. أحمد قسمت الجداوى: المرجع السابق، ص ١٣٤.

(٣) د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص ٤١٤.

(٤) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١١٩، ١٢٠.

(٤) راجع في ذلك الرأي والمؤيدون له د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٨٣.

الشرط الثاني- بلوغ سن الرشد:

يعول المشرع كثيراً على إرادة طالب التجنس وهو ما دعاه إلى اشتراط بلوغ طالب التجنس سن الرشد، حيث أن من يبلغ سن الرشد يملك كقاعدة عامة إرادة يعتد بها قانوناً، ولكن هل يعتبر بلوغ الشخص سن الرشد دليلاً على اكتمال أهليته؟ في الواقع قد يبلغ الشخص سن الرشد ومع ذلك يعتبر ناقص الأهلية، إذ ما اعتراه جنون أو سفه أو غفلة، وهو ما جعل بعض الفقه^(١) يذهب إلى أن "بلوغ سن الرشد وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون طالب التجنس كامل الأهلية"، ويرجع في تحديد سن الرشد إلى أحكام القانون المصري حيث تنص المادة ٢٣ من تشريع الجنسية المصرية على أن "يحدد سن الرشد طبقاً لأحكام القانون المصري" أي أن العبرة دائماً هي بأحكام القانون المصري، ولا رجوع في ذلك إلى قانون جنسية طالب التجنس، وينبغي دائماً بلوغ طالب التجنس سن الرشد وقت تقديم طلب التجنس، وبذلك فلا يشترط توافر هذا الشرط عند بدء الإقامة أو أثناءها.^(٢)

الشرط الثالث- الإلمام باللغة العربية:

حيث سبق الحديث عن شرط الإلمام باللغة العربية فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الرأي الفقهي^(٣) الذي كان يفضل "أن يحذو المشرع المصري حذو المشرع السوري الذي يشترط أن يتكلم طالب التجنس اللغة العربية ويقرأها ويكتبها".

وهناك رأي فقهي آخر^(٤) ذهب إلى أنه من الأفضل "أن يتبع المشرع ما فعله المشرع الفرنسي في تقنين سنة ١٩٤٥ إذ نص بالمادة ٦٩ على أنه "لا يمكن لشخص التجنس بالجنسية الفرنسية ما لم يثبت تشبهه بالجماعة الفرنسية وخاصة بمعرفته اللغة الفرنسية معرفة كافية حسب حالته".

وذلك لأن العبارة التي أوردها المشرع المصري تفتح الباب أمام كثير من التفسيرات وتترك مجالاً أوسع للتقدير، ويرى البعض^(٥) أن درجة معرفة اللغة تختلف من شخص لآخر حسب ما يتقلده من وظائف وما حصل عليه من الدرجات العلمية.

(١) د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص ٤١٦.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٢١.

(٣) د. فؤاد رياض: المرجع السابق، طبعة ١٩٧١، ص ١٤٩.

(٤) د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص ٤١٥.

(٥) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٢١.

الشرط الرابع - حماية مجتمع الدول:

لحماية مجتمع الدولة استبعد المشرع كل ما يمكن أن يكون عالة على المجتمع بضعه أو خلقه أو فقره، فنص على وجوب أن يكون الشخص سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، وقد سبق الحديث عن كل تلك الأشياء عند دراسة التجنس المبني على حق الإقليم المقترن بالإقامة العادية، ونكتفى هنا بما سبق ذكره ونحيل له منعاً للتكرار الذي لا فائدة من وراءه.

إذا ما توافرت في الأجنبي كافة الشروط السابقة فإنه يجوز له أن يطلب اكتساب الجنسية المصرية، مع تمتع السلطة التنفيذية بسلطة تقديرية بشأن طلب التجنس في هذه الحالة، حيث يجوز لها أن ترفض طلب التجنس بالجنسية المصرية.

ثانياً - التجنس المبني على الإقامة القصيرة:

اشترط المشرع لجواز طلب التجنس في هذه الحالة ثلاثة شروط، وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الجنسية المصري، وتلك الشروط هي:

الشرط الأول - الإقامة في مصر مدة خمس سنوات:

اكتفى المشرع المصري في هذه الحالة باشتراط إقامة الأجنبي في مصر خمس سنوات فقط، مع تطبيق ما سبق ذكره عن اتصال مدة الإقامة واستمرارها بصدد الحالة الأولى، وربما يرجع تخفيض المدة إلى وجوب توافر الشرط الثاني في طالب التجنس وهو الإنتماء للأصل المصري.

الشرط الثاني - الإنتماء للأصل المصري:

وقد سبق الحديث عن فكرة الإنتماء للأصل المصري عند دراسة حالة التجنس القائم على حق الإقليم المدعم بالأصل المصري، فنكتفى بما سبق ونحيل إليه منعاً للتكرار الذي لا يحقق فائدة.

الشرط الثالث - بلوغ سن الرشد:

وهو شرط بذهني وضعه المشرع في هذه الحالة مثلها مثل غيرها من الحالات التي عول فيها المشرع على إرادة طالب التجنس، والتي لا تتحقق إلا ببلوغه سن الرشد وكمال أهليته ويرجع في ذلك إلى أحكام القانون المصري.^(١)

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٢٢، ١٢٣.

بقى أن نشير إلى أن توافر الشروط السابقة لا يفرض أى إلزام على السلطة التنفيذية بمنح الجنسية، وإنما الأمر جوازى لها كما سبق ذكره فى كافة صور التجنس.

الفرع الرابع

التجنس الإستثنائى

توجد مجموعة من الإعتبارات دعت المشرع المصرى إلى تفضيل طوائف من الأجانب بخصهم بوضع متميز يقتضى منحهم الجنسية المصرية، دون استلزام توافر أى شرط فى شأنهم من الشروط المعتادة للتجنس مثل استلزام توافر عنصر الإقامة حيناً، وعنصر الميلاد أحياناً أخرى أو كلاهما معاً فى بعض الأحوال.

فقد بين المشرع الشروط التى تطلبها للتجنس فى كافة صوره فى المادتين ٣، ٤ من تشريع الجنسية، وبعدها نص فى المادة الخامسة على أن "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون التقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية".

ويتضمن هذا النص حالتين لمنح الجنسية المصرية :

الحالة الأولى: الأجانب الذين يؤدون لمصر خدمات جليلة.

الحالة الثانية: رؤساء الطوائف الدينية المختلفة.

وفى الأمر تفصيل على النحو التالى:

١ - الأجانب الذين يؤدون لمصر خدمات جليلة:

وجد المشرع المصرى أن من يؤدى خدمات جليلة لمصر يستحق أن يكتسب الجنسية المصرية تقديراً لما قدمه، لذلك فقد جاء نص المادة الخامسة ليعطى لرئيس الجمهورية الحق فى منح الجنسية دون التقيد بالشروط الواردة فى المادة الرابعة وهى شروط التجنس العادى.^(١)

وقد كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من تشريع الجنسية الصادر سنة ١٩٥٨ بخصوص الجمهورية العربية المتحدة لا تكفى بمنح هذه الجنسية للأجنبى فى حالة إسداء خدمات جليلة للدولة فقط، وإنما أيضاً فى حالة إسداء الخدمات للقومية العربية أو للأمة العربية،^(٢) ولكن المشرع

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٢٤.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٣١.

اقتصر في التشريع الحالي على أداء الخدمات الجبلية لمصر دون غيرها، وقد قرر البعض^(١) أن "يتفق ذلك مع الإتجاه الحالي نحو التركيز على المشكلات الوطنية وإعطائها الأولوية على المشكلات العربية والإستقلال بالشخصية المصرية".

وبصدد الإختلاف بين تشريع سنة ١٩٥٨ وتشريع ١٩٧٥ فإننا نجد أن المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة ١٩٧٥ قد أغفلت تماماً ذلك الإختلاف، حيث قررت أن "النص يطابق حكم المادة ١١ (ثانياً) و (ثالثاً) من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ مما جعل جانباً من الفقه^(٢) يقرر أن "أقل ما سيقال فيه أنه لا يتسم بالدقة بقدر ما يبتعد عن الواقع".

وقد أكد البعض^(٣) أن المشرع لم يهدف بهذا التغيير في النص إلى إيجاد أى تغيير في الحكم، حيث أن إغفال ذكر القومية العربية والأمة العربية إنما يمكن رده إلى ركافة الصياغة التي أعترت كثيراً من نصوص تشريع الجنسية الحالي، وأنه إذا تم تجريد المشرع من العبث فإنه من غير المعقول أن يقوم المشرع باستبدال القومية العربية والأمة العربية بمصر، دون أن يهدف من وراء ذلك إلى شئ معين، خاصة وأنه قد ألغى غالبية الأحكام المرتبطة بالقومية العربية في التشريع الحالي.

ومن جانبنا نرى أن هذا التغيير لا يعود إلى رداءة الصياغة، وإنما قصد المشرع من وراءه الإهتمام بصورة أكبر بمصر والإبتعاد عن المصالح القومية، خاصة وأن التشريع الحالي وضع بعد إنتهاء الحرب مع إسرائيل وأيضاً إنتهاء الوحدة مع سوريا.

ولكن ما هو المقصود بالخدمات الجبلية التي تعطى لرئيس الجمهورية الحق في منح الجنسية المصرية للأجنى الذي أداها، دون استلزام أى شرط آخر من شروط التجنس السابق الحديث عنها؟

من استقراء النص يتضح أن المشرع يترك سلطة التقدير في هذه الحالة لرئيس الجمهورية، ويمكن اعتبار اكتشاف مورد من موارد الثروة الاقتصادية، أو التوصل إلى علاج لمرض منتشر في البلاد، أو التنازل للدولة عن الحق في استغلال اختراع جديد في المعدات الحربية، أو الإدلاء بمعلومات عسكرية خطيرة تعين القوات المصرية في حربها مع العدو، و إلى غير ذلك من الخدمات الجبلية التي تبرر منح الجنسية في هذه الحالة.^(٤)

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٢٥.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٣١.

(٣) د. أحمد قسنت الجداوى: المرجع السابق، ص ١٥٨.

(٤) د. محمد كمال فهمى: المرجع السابق، ص ١٩٣.

بقى أن نشير إلى أن الإجراء الذي يمنح به الجنسية في هذه الحالة هو قرار رئيس الجمهورية وليس قراراً من وزير الداخلية، وذلك نظراً لأهمية الإعتبارات التي تبرر منح الجنسية في هذه الحالة.^(١)

٢- رؤساء الطوائف الدينية:

يقصد برؤساء الطوائف الدينية في هذا النص رؤساء الطائفة الدينية المصرية غير الإسلامية المنظمة شئونها قانوناً، وهو ما ذكرته المذكرة الإيضاحية للقانون، وهذا النص منقول من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر من تشريع الجنسية الصادر سنة ١٩٥٨، ومرد الأمر في هذه الحالة ما يتمتع به رؤساء الطوائف الدينية عادة من مركز أدبي في المجتمع.^(٢)

على أنه من المتفق عليه أن التجنس بناء على النص المذكور لا يخرج عن الأصل العام، والذي يقضى بأن التجنس لا يفرض فلا بد أن يتم تقديم طلب من صاحب الشأن أو على الأقل أن يقبله وذلك إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة.^(٣)

ويراعى أن منح الجنسية في هذه الحالة أيضاً يخضع للسلطة التقديرية للدولة ممثلة في رئيس الجمهورية فهو يعتبر مسألة جوازية له.^(٤)

- رقابة القضاء على سلطة وزير الداخلية في تقدير طلبات التجنس:

أعطى المشرع لوزير الداخلية سلطة التقدير في منح الجنسية الوطنية من عدمه في كافة صور التجنس السابق الإشارة إليها، حتى لو توافرت في طالب التجنس كافة الشروط المطلوبة، وذلك مع مراعاة الحالة التي ورد النص عليها في المادة الخامسة، والخاصة بالتجنس الاستثنائي والتي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

ونتيجة لسلطة الجواز والعدم الممنوحة لوزير الداخلية فإنه لا يجوز لطالب التجنس أن يطعن في قرار وزير الداخلية برفض طلبه استناداً إلى توافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون في شأنه.^(٥)

ولكن هل يعنى ذلك تحصن قرارات وزير الداخلية وعدم جواز الطعن عليها بأي شكل ولأى سبب؟ في الواقع إن قرار وزير الداخلية هو قرار إداري مثله مثل غيره من القرارات الإدارية التي

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٣٢.

(٢) المرجع السابق: ص ٤٣٣.

(٣) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٩٤.

(٤) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٢٧.

(٥) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٣٩، ٤٤٠.

يجب أن تنقيد دائماً بمشروعية الغاية منها، وبذلك إذا إنحرف القرار الإدارى عن غايته واستخدم لتحقيق هدف غير مشروع جاز الطعن عليه بناء على عيب الإنحراف فى استعمال السلطة،^(١) وقد استعان القضاء فى مصر بمعيار الإنحراف بالسلطة "وبسط رقابته على قرارات الإدارة التى تتمتع فيها بسلطة التقدير".^(٢)

وقد قرر القضاء الإدارى أن منح الجنسية المصرية هو أمر جوازى من حق السلطة التنفيذية وحدها وبمطلق سلطتها التقديرية، ما لم يثبت بالدليل وجود إساءة فى استعمال السلطة،^(٣) وإنما يقع عبء إثبات عدم المشروعية فى القرار الإدارى على عاتق من يدعيه.^(٤)

المطلب الثانى

الزواج المختلط

قد يعتبر زواج إحدى الأجنبيات من وطنى سبباً مبرراً لحصولها على الجنسية المصرية، متى كان هذا الزواج يدل على ارتباطها بالمجتمع المصرى ورغبتها فى الاندماج فى شعبه، ولذلك فقد نشأ مبدأ وحدة الجنسية فى العائلة، ونتيجة لأن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه قد يؤدى إلى ازدواج جنسية المرأة، فى الحالة التى تحتفظ فيها بجنسيتها السابقة مع حصولها على الجنسية المصرية، وقد يؤدى أيضاً إلى التعارض مع إرادة الزوجة التى تريد أن تتزوج من شخص أجنبى مع الإحتفاظ بجنسيتها وعدم اكتساب جنسيتها، ذلك أدى إلى نشأة المبدأ الثانى الذى يعرف بمبدأ استقلال الجنسية فى العائلة، وكان من نتيجة هذين المبدأين أن اختلفت الدول فى الأخذ بأى منهما،^(٥) وذلك طبقاً لإعتبارات مختلفة تضعها كل دولة عند الأخذ بأيهما ولذلك سنعرض لكلا المبدأين باختصار فيما يلى:

١- مبدأ اتحاد الجنسية فى العائلة:

يقضى هذا المبدأ أن تدخل المرأة الأجنبية فى جنسية زوجها بمجرد الزواج كأثر مباشر وحتمى يتحقق بقوة القانون، ويهدف ذلك المبدأ إلى تحقيق مصلحة الأسرة، والتى تقتضى توحيد عواطف ومشاعر أفرادها لخلق نوعاً من التجانس الروحى والفكرى والعاطفى بينهم، وهو ما يؤدى إلى

(١) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٣٣٦.

(٢) الإشارة السابقة

(٣) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ١٦ يونيو ١٩٥٢، مجموعة أحكام المحكمة السنة ٦٠، ص ١١٨٩.

(٤) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٣٣٦.

(٥) راجع فى ذلك :

تحقيق مصلحة الدولة من ناحيتين: الأولى وهى أنه يترتب على هذا التجانس توحيد انتماءهم للدولة وولائهم لها وتقوية مشاعرهم الوطنية، وصلتهم بالآخرين فى تلك الجماعة، والثانية أن ترابط عناصر الأسرة يؤدى إلى صلابة ركن السكان فى الدولة وترابط مجتمعا، كما أنه فى بعض الفروض توجد مصلحة للزوجة فى اكتساب جنسية زوجها، وهو ما يجعلها تتمتع بسائر الحقوق المقررة للوطنيين فى الدولة.

ومن ناحية أخرى نجد أن احتفاظ الزوجة بجنسيتها من شأنه أن يؤدى إلى خضوع كل من الزوجين لسلطة سياسية مختلفة، وهو ما يؤدى إلى هدم كيان الأسرة وتفرقة أفرادها، ومن شأنه أيضا وجود صعوبة فيما يتعلق بتحديد جنسية الأبناء، وخاصة فى الدول التى تأخذ بحق الدم، ومن شأنه أيضا إثارة صعوبة عند تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الزواج، كل تلك الصعوبات هى التى أدت إلى رواج مبدأ اتحاد الجنسية فى العائلة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.^(١)

٢- مبدأ استقلال الجنسية فى العائلة:

يستند هذا المبدأ على وجود مساواة بين المرأة والرجل فى التمتع بالحقوق وتحمل التكاليف، لذلك يجب عدم فرض جنسة الزوج على الزوجة وجعل ذلك متوقفاً على إرادته، حيث يتعين أن يتم الإعتداد بإرادة الزوجة قبل منحها جنسية الزوج، "فكل شخص يجب أن تكون له جنسية واحدة ويحق لها تغييرها ولا يوجد سبب يبرر استثناء المرأة المتزوجة من هذه القاعدة"^(٢).

وقد ساعد على إنتشار هذا المبدأ ظهور الحركات النسائية فى العالم التى تنادى بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل، وأيضاً الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى نص فى مادته الخامسة عشرة على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" ونص فى مادته الثانية على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان.... دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وقررت نفس المبدأ أيضاً معاهدة نيويورك لسنة ١٩٥٧ حيث نفت أن يكون للزواج أثر حتمى أو تلقائى على جنسية الزوجة، وبالنظر إلى ما يطلق عليه مبررات وجود مبدأ وحدة الجنسية فى العائلة، فإننا نجد أن الإستناد إلى وجوب تحقيق نوع من التجانس الروحى والعاطفى بين أفراد الأسرة، وهو ما لا يتحقق إلا فى ظل مبدأ وحدة الجنسية فى العائلة، غير صحيح حيث أن ذلك من الممكن أن يتحقق بالرغم من اختلاف الزوجين فى الجنسية، أما القول بأن مصلحة الدولة تقتضى منح جنسيتها

(١) راجع فى تفصيل هذا المبدأ أو الدول التى أخذت به د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣٠، ١٣١.

(٢) راجع فى ذلك

للأجنبية التي تتزوج من وطنى فهو غير صحيح، فقد يودى ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة في حالة احتفاظ الأجنبية بولائها لدولتها القديمة، وهو ما يضعف ركن الشعب في الدولة.^(١)

أما بصدد الوضع في مصر فقد نصت المادة السابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه "لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل إنقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".

وباستقراء النص يتضح لنا أن المشرع المصرى قد اتخذ موقفاً وسطاً بين كل من مبدأى وحدة الجنسية واستقلال الجنسية في العائلة، حيث لم يبين أى منهما على إطلاقه، فهو يعتد بإرادة المرأة المتزوجة وذلك بعدم منحها الجنسية المصرية دون تعبير صريح من جانبها، وفي المقابل ترك لها الباب مفتوحاً للدخول في الجنسية المصرية، وذلك لتوفير نوع من التوافق الروحي والفكرى في النطاق العائلى، إلا أنه اشترط توافر مجموعة من الشروط لكي تكتسب الجنسية المصرية، تلك الشروط هي:

الشرط الأول- أن ينعقد الزواج صحيحاً وأن يكون ثابتاً في وثيقة رسمية:

أغفل المشرع النص على وجوب إنعقاد الزواج صحيحاً، ربما لأن هذا الشرط يمثل نقطة بداية تفترضها القواعد العامة، ويثور تساؤل يتعلق بالقانون الذى يجب أن ينعقد الزواج صحيحاً وفقاً لأحكامه، فذهب رأى^(٢) إلى أن الزواج يجب أن ينعقد صحيحاً وفقاً لأحكام القانون المصرى بما يحتويه من قواعد تنازع، وبذلك يجب أن ينعقد الزواج صحيحاً من الناحية الشكلية والموضوعية وفقاً للقانون المختص بمقتضى قواعد الإسناد المصرية، سواء كان هذا القانون هو القانون المصرى أو قانون أجنبى، بينما ذهب اتجاه آخر^(٣) إلى كفاية أن يكون الزواج قد إنعقد صحيحاً وفقاً لأحكام القانون المصرى، فلا يكفى أن ينعقد صحيحاً وفقاً لأحكام القانون الأجنبى إذ أن الأمر يتعلق بالجنسية المصرية وليس بالجنسية الأجنبية.

وفيما يتعلق بوجوب أن يكون الزواج ثابتاً في وثيقة رسمية، فقصد به تلافى أى تحايل قد تلجأ إليه الزوجة بالإدعاء على غير الحقيقة وتوخيها للدقة، وقد نصت على هذا الشرط المادة ٢٥ من التشريع

(١) راجع بالتفصيل في مبدأ استقلال الجنسية في العائلة والدول التي أخذت به د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣١ وما بعدها.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٤١.

د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٥٧.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصرى المقارن. ص ٢٧٠، ٢٧١.

المصرى حيث ورد بها أن "لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة".

ويرجع إلى السلطات المختصة بتوثيق الزواج فى عملية إثبات الزواج فى وثيقة رسمية، وفى هذا الصدد يمكن الإكتفاء بوثيقة إبرام الزواج فى مصر إذا كان الزواج قد تم فى مصر، أو طلب هذه الوثيقة من الجهات المختصة فى خارج مصر إذا كان قد اتبع فى إبرامه الشكل المصرى.^(١)

الشرط الثانى - أن تطلب الزوجة اكتساب الجنسية المصرية:

يتطلب المشرع المصرى لاكتساب الزوجة الجنسية المصرية فى هذه الحالة ان تعلن عن رغبتها فى ذلك، وهو بذلك يعتد بإرادتها حيث أنها طالما لم تعبر عن تلك الرغبة فلا مجال للبحث عن إمكانية اكتسابها الجنسية المصرية، وإعلان الرغبة هذا يوجه إلى وزير الداخلية طبقاً لأحكام المادة ٢٠ من قانون الجنسية التى تنص على أن "الإقرارات وإعلانات الإختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدتها"، وهذا الإعلان لا يشترط تقديمه بمجرد إنعقاد الزواج، أو فى تاريخ معين بعد هذا الإنعقاد، ولكن يمكن توجيهه فى أى وقت أثناء قيام الزوجية.^(٢)

ولم ينص المشرع على كون الزوجة بالغة سن الرشد وقت إعلان الرغبة، وهو ما ترك فرصة لإختلاف الفقهاء، فهناك من يرى^(٣) أنه يكفى أن تكون الزوجة أهلاً لإبرام الزواج حتى ولو لم تبلغ سن الرشد، بينما يذهب آخرون^(٤) إلى أن الزوجة يجب أن تكون بالغة سن الرشد وقت إعلان الرغبة، لأن المشرع المصرى قد اشترط بلوغ سن الرشد فى كل من يطلب اكتساب الجنسية المصرية، ولأن الإعتداد بإرادة المرأة يقتضى ان تتوافر تلك الإرادة، وتلك الإرادة لا تتوافر إلا إذا بلغت المرأة سن الرشد، وأيضاً لأن إعلان الرغبة عمل إرادى يقتضى توافر الأهلية، وتلك الأهلية تقتضى بلوغ سن الرشد.

الشرط الثالث - استمرار الزوجية مدة سنتين من تاريخ إعلان الرغبة:

يهدف المشرع من وراء هذا الشرط إلى التأكد من أن الزوجة جادة فى زواجها، ولم تقصد منه فقط الحصول على الجنسية بشروط ميسرة، ويتم إحساب تلك المدة ابتداء من تاريخ إعلان الرغبة وليس من تاريخ الزواج، ولذلك إذا استمرت الزوجية مدة عشر سنوات دون إبداء الرغبة فى إكتساب

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٩١.

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد: المرجع السابق، ص ١٩٢.

(٣) د. فؤاد رياض: الوسيط فى الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الخامسة، ١٩٨٨، دار النهضة العربية، ص ١٩٠.

(٤) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣٨.

الجنسية إلا بعد إنتهاء تلك المدة، فلابد من إستمرار الزوجية لمدة سنتين تحسبان من تاريخ تقديم الطلب.^(١)

ولم يستلزم المشرع إقامة الزوجة الأجنبية في مصر خلال مدة السنتين الواجب مرورهما بعد إعلان الرغبة، ولذلك يحق للزوجة الأجنبية أن تكتسب الجنسية المصرية بعد مرور سنتين من إعلان الرغبة، حتى ولو لم يتوافر شرط الإقامة في الإقليم المصري خلال تلك الفترة.^(٢)

وقد يكون إنقضاء الزوجية بسبب الطلاق أو الوفاة، وهو ما يقتضى التفريق بين هاتين الحالتين، ففي حالة إنقضاء الزواج بسبب الطلاق قبل فوات مدة السنتين فلا يحق للزوجة أن تكتسب الجنسية المصرية في هذه الحالة، أما في حالة إنقضاء الزواج بسبب وفاة الزوج قبل إكمال مدة السنتين فإنه يحق للزوجة أن تكتسب الجنسية المصرية، طالما أعلنت رغبتها في ذلك قبل وفاة الزوج.^(٣)

الشرط الرابع - عدم إعتراض وزير الداخلية:

أورد المشرع هذا الشرط في المادة السابعة بالنص على أنه إذا إعترض وزير الداخلية على ذلك فيجب أن يكون قراره مسبباً، وأن يكون محمولا على أسباب جدية كافية على حمل الموضوع، وألا يصدر بعد فوات مدة السنتين، بمعنى أن القرار لا بد أن يصدر خلال سنتين من تاريخ إعلان الرغبة، حيث أن تلك المدة هي مدة سقوط فلا تقبل الوقف أو الإنقطاع، أما إذا لم يعترض وزير الداخلية على هذا الطلب أو يرفضه خلال مدة السنتين، فلا يجوز له بعد ذلك العودة للإعتراض على دخول تلك الزوجة في الجنسية المصرية^(٤).

متى توافرت الشروط السابقة فإن الزوجة الأجنبية تكتسب الجنسية المصرية في اليوم التالي لإكمال مدة السنتين من تاريخ إعلان الرغبة في إكتساب الجنسية المصرية.

الإستثناء الخاص بالأجنبية ذات الأصل المصري:

تنص المادة ١٤ من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن "الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك" وتظهر الحكمة من ذلك الإستثناء في أن هذه الزوجة ليست في حاجة إلى دليل جديد على رغبتها في الدخول

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣٨.

(٢) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٩٢.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٣٩ وفي تفصيل هذا الشرط راجع

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٤٣ - ١٤٦.

(٤) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٩٣.

فى الجماعة الوطنية، أو على قدرتها على الاندماج فيها، وبمقتضى هذا الإستثناء يكون دخول الزوجة التى من أصل مصرى رهن بتعبيرها عن إرادتها فى ذلك دون حاجة إلى فوات السنتين، وتعفى كذلك من كافة الشروط المطلوبة للدخول فى الجنسية المصرية، وكذلك لا يستطيع وزير الداخلية أن يمنع اكتسابها الجنسية المصرية متى أرادت ذلك.

ويطبق هذا الإستثناء على طائفتين من الأجنيات، الأولى هى الزوجة التى سبق لها التمتع بالجنسية المصرية ثم فقدتها لأى سبب من أسباب الفقد، والثانية هى الزوجة التى تنتمى إلى الأصل المصرى.^(١)

المطلب الثالث

خيار الإسترداد

خيار الإسترداد هو رخصة خولها المشرع للشخص الذى فقد جنسيته يجوز له بمقتضاها أن يسترد جنسيته المفقودة، حيث إنه كما سبق الحديث عودة لاحقة إلى جنسية سابقة ولا يترتب على هذا الخيار أى أثر رجعى، حيث أن العودة اللاحقة لجنسية سابقة لا تزيل عن الشخص صفة الأجنبى فى الفترة التى تقع بين فقد الجنسية وإستردادها.^(٢)

ويتضمن قانون الجنسية المصرى عدة صور لإسترداد الجنسية، وتتحقق فيها فكرة الكسب الطارئ للجنسية بناء على إختيار الفرد وفقاً لمفهوم خيار الإسترداد.

الصورة الأولى- الوطنية التى زالت عنها جنسيتها ثم تزوجت بوطنى أو اكتسب زوجها الأجنبى الجنسية المصرية:

وقد سبقت الإشارة إلى تلك الصورة عند الحديث عن الإستثناء الخاص بالزوجة ذات الأصل المصرى بصدد اكتساب الجنسية بالزواج المختلط، وهى التى نصت عليها المادة ١٤ من تشريع الجنسية المصرى الحالى، ولكن من الممكن إعتبار تلك الصورة هى إحدى صور خيار الإسترداد، وذلك فى حالة التركيز على ضرورة أن تعلن الزوجة رغبتها فى العودة إلى الجنسية المصرية إلى وزير الداخلية، وبذلك تصبح متصلة بفكرة خيار الإسترداد، وذلك بإعتبار أن إختيار الزوجة العودة إلى الجنسية المصرية التى فقدتها هو السبب الرئيسى لمنحها هذه الجنسية، والملاحظ على هذا الإسترداد أنه إسترداد وجوبى، بمعنى أن يتحقق بمجرد توافر شرائطه التى حددها القانون دون أدنى سلطة تقديرية

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٤٢ وبالتفصيل فى هذا الإستثناء راجع

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٤٨ وما بعدها.

(٢) د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٣٤٧.

لوزير الداخلية، ويحقق هذا الإسترداد أثره بالنسبة للمستقبل دون الماضي طبقاً لنص المادة ١٩ من قانون الجنسية المصري الحالي^(١).

الصورة الثانية- الوطنية التي زالت عنها جنسيتها لزواجها من أجنبي أو لتجنس زوجها الوطنى بجنسية أجنبية:

من المتصور أن تفقد المرأة الوطنية جنسيتها بزواجها من أجنبي أو نتيجة لتجنس زوجها الوطنى بجنسية أجنبية، وذلك لو أبدت رغبتها فى ذلك وكان القانون الأجنبى يدخلها فى تلك الجنسية،^(٢) وذلك طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر، والفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من تشريع الجنسية الحالى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥.

لذلك فقد أجاز المشرع المصرى لهذه المرأة التي زالت عنها جنسيتها المصرية فى أى من الحالتين السابقتين أن تستردها إذا أبدت رغبتها فى ذلك، وتحققت الشروط الواردة بالمادة (١٣) من قانون الجنسية المصرى، وفى هذا تنص المادة (١٣) من هذا القانون على أنه "يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة (١١) وللفقرة الأولى من المادة (١٢) أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية. كما أنها تسترد الجنسية المصرية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك".^(٣)

وبذلك فإنه ينبغى التفرقة بين استرداد الجنسية حال قيام الزوجية، واستردادها بعد إنقضاء تلك الرابطة، على النحو التالى:

١- استرداد الجنسية المصرية حال قيام الزوجية:

يجوز للمرأة إذا كانت رابطة الزوجية قائمة وطبقاً لنص المادة (١٣) السابق الحديث عنها أن تسترد جنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها فى ذلك ووافق وزير الداخلية، وبذلك يكون المشرع قد منح السلطة التنفيذية نوعاً من السلطة التقديرية بصدد إجابة هذا الطلب أو رفضه.^(٤)

٢- استرداد الجنسية المصرية بعد انحلال الزوجية:

وهو ما قرره الفقرة الثانية من المادة (١٣) التى قررت حق المرأة فى استرداد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية، إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك،

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٦٩ وما بعدها.

(٢) وذلك ما لم تحتفظ بجنسيتها الوطنية رغم إكتسابها للجنسية الأجنبية

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٧٢.

(٤) د. محمد كمال فهمى: المرجع السابق، ص ٢٠٣.

واسترداد المرأة لجنسيتها في هذه الحالة هو حق لها وليس مجرد رخصة تخضع للسلطة التقديرية لوزير الداخلية، وذلك بشرط أن تكون المرأة مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها.^(١)

الصورة الثالثة- الأولاد القصر للوطني المتجنس بجنسية أجنبية:

قد يؤدي تجنس الأب بجنسية أجنبية إلى زوال الجنسية المصرية عنه وبالتبعية عن أولاده القصر، وحيث لا دخل لإرادة هؤلاء القصر في ذلك، فقد أجاز المشرع لهم أن يعلنوا عن رغبتهم في استرداد الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١١) من تشريع الجنسية الحالي، ويكون الاسترداد في هذه الحالة وجوبياً يتم بمجرد إبداء الرغبة في الاسترداد وفقاً للإجراءات القائمة، بمعنى أنه استرداد بقوة القانون ولا تملك السلطة التنفيذية أى تقدير بصدده، ولا يترتب عليه أى أثر بالنسبة للماضى، حيث يعتبر الولد القاصر أجنبى في الفترة ما بين زوال الجنسية عنه وعودته إليها.^(٢)

الصورة الرابعة- الوطني الذى زالت عنه الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية:

قد تزول الجنسية المصرية عن الشخص بقوة القانون نتيجة لتجنسه بجنسية أجنبية بعد حصوله على إذن من وزير الداخلية، وطبقاً لنص المادة العاشرة من تشريع الجنسية الحالي لطالب الإذن بالتجنس أن يطلب اجازة الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإذا صدر الإذن وبه تلك الإجازة فإنه لا بد أن يعلن الشخص عن رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، أما إذا صدر الأمر بالتجنس ولم يتضمن الإذن بالإجازة، أو تضمن هذه الإجازة ولم يطلبها المتجنس خلال السنة التى حددها المشرع، تزول الجنسية المصرية عن ذلك الشخص بقوة القانون بمجرد دخوله في الجنسية الأجنبية، وفي الحالة الأخيرة فإنه يجوز لهذا الشخص أن يسترد جنسيته المصرية إذا رغب في ذلك، حيث نص المشرع المصري في المادة (١٨) من تشريع الجنسية الحالي على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدتها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك".

ومن النص يتضح لنا أن استرداد الجنسية في تلك الحالة جوازى يخضع للسلطة التقديرية لوزير الداخلية، بحيث إذا وافق على الطلب استرد طالب الجنسية المصرية جنسيته المصرية، وذلك

(١) راجع في تفصيل ذلك د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ١٩٤ وما بعدها.

د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٢٠٤.

(٢) بالتفصيل في ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٧٥.

د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٢٠٦.

د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٠٣.

إعتباراً من تاريخ موافقة وزير الداخلية دون أثر رجعى عملاً بالمادة (١٩) من تشريع الجنسية الحالي.^(١)

المطلب الرابع

آثار اكتساب الجنسية المصرية الطارئة

يترتب على دخول الشخص في الجنسية المصرية اعتباره وطنياً بعد أن كان أجنبياً، إلا أن هناك تساؤل متعلق بمدى تمتعه بكل الحقوق التي يتمتع بها الوطني الأصل من عدمه؟ كما يثور التساؤل حول مدى تأثير ذلك على جنسية تابعيه من زوجة وأولاد قصر؟

لذلك فإن الآثار التي تترتب على اكتساب الجنسية المصرية الطارئة تنقسم إلى نوعين على النحو التالي:-

أولاً:- الآثار المتعلقة بشخص الوطني الطارئ:

فيما يخص الآثار المتعلقة بشخص الوطني الطارئ فإننا نجد المادة ٩ من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ تنص على أنه "لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد ٣، ٤، ٦، ٧ من هذا القانون حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيد من المذكورين معاً.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيد من المذكورين معاً من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها، ويعفى من هذين القيد من أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس المليّة التي يتبعونها وعضويتهم بها".

ومن النص يتضح لنا أن المشرع المصري قد تبنى الاتجاه الذي يخضع الأجنبي لمركز خاص خلال الفترة التي تلي دخوله في جنسية الدولة، ويحرم خلالها من مباشرة طائفة معينة من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون، كما أنها تملك الحق في سحب الجنسية منه خلال تلك الفترة، إذا تبين لها عدم جدارته بجنسيتها، وبانتهاء تلك المدة يصبح الوطني الطارئ مثل الوطنيين الأصليين، ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتعون بها ولا يجوز سحب الجنسية منه.^(٢)

(١) راجع بالتفصيل في ذلك د. هشام علي صادق: المرجع السابق، ص ٤٧٦ وما بعدها.

د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٢٠٥.

(٢) راجع بالتفصيل في ذلك د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٨٨.

وقد كان قانون ١٩٢٩ مساوياً بين المصريين الأصلاء والمصريين الدخلاء فيما يتعلق بالحقوق، حيث كان يرتب على اكتساب الجنسية المصرية الطارئة أثراً فورياً وهو التمتع بنفس الحقوق التي تثبت للمصري الأصلي، ولكن بسبب تغير الظروف السياسية وإلغاء الإمتيازات فقد أصبحت الجنسية المصرية هدفاً لكثير من الأجانب، وهو ما يهدد مصالح البلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهو ما جعل تشريع سنة ١٩٥٠ يورد القيد المتعلق بالحرمان من الحقوق خلال فترة الرتبة، وهي التي تلى اكتساب الجنسية، وتكرر النص على هذا القيد في قانون ١٩٥٦ وقانون ١٩٥٨ وأخيراً في التشريع الحالي^(١).

وفيما يتعلق بالأحكام الواردة بنص المادة ٩ من القانون الحالي فإننا نجد أن التقسيم الأمثل لدراستها على النحو التالي^(٢) :

١- الغرض من حرمان الوطني الطارئ من بعض الحقوق في فترة الرتبة:

باعتبار أن مصر من الدول المصدرة للسكان فقد أخضع المشرع المصري الوطني الطارئ لأحكام خاصة بعد قبوله عضواً في مجتمع الدولة، ولفترة قد تصل إلى عشر سنوات بصدد بعض الحقوق، وقد استهدف المشرع من ذلك إلى جعل تلك الفترة بمثابة فترة اختبار للتحقق من ولاء الوطني الطارئ، وللتأكد من أن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لم يكن يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق غاية يخشى فيها على كيان المجتمع الوطني من الناحية السياسية، لذلك قرر المشرع حرمان الوطني الطارئ خلال الفترة التالية لدخوله الجنسية من الحقوق السياسية، وقرر أن تكون مدة الحرمان كقاعدة عامة خمس سنوات من تاريخ الدخول في الجنسية، غير أن المشرع تشدد بالنسبة لنوع معين من هذه الحقوق هو حق الترشيح أو التعيين في إحدى الهيئات النيابية، نظراً لما ينطوي عليه من اشتراك فعلي في الحكم، وهو أمر على درجة كبيرة من الخطورة، فقرر حرمان الوطني الطارئ من التمتع بهذه الحقوق خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه جنسية جمهورية مصر العربية^(٣).

٢- الأشخاص الذين يسرى عليهم الحرمان:

يسرى الحرمان من الحقوق السياسية خلال فترة الرتبة المحددة بخمس أو عشر سنوات في شأن كافة من اكتسبوا الجنسية الوطنية الطارئة، لأي من الأسباب التي سبق الحديث عنها مثل التجنس

(١) راجع في ذلك. د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ٢٠٧، ٢٠٨.

(٢) نسير في هذا التقسيم مع ما أتبعه أستاذنا الدكتور : هشام على صادق، ومن بعده أستاذنا الدكتور: عوض الله شيبه الحمد السيد. راجع في ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٤٣ وما بعدها، د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ٢٠٠٢، ص ١٩٦ وما بعدها.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٨٩.

والزواج المختلط، كما أنه يسرى بالنسبة للزوجة التي تكتسب الجنسية المصرية نتيجة لتجنس زوجها بهذه الجنسية وكذلك يسرى هذا الحرمان على الزوجة التي تدخل الجنسية الوطنية نتيجة للزواج من أحد الوطنيين.^(١)

٣- الحقوق التي يرد الحرمان عليها ومدة الحرمان منها:

يقصر الحرمان من الحقوق بصدد الوطنى الطارئ على الحقوق السياسية دون غيرها من الحقوق، وقد فرق المشرع بين حقوق يرد الحرمان عليها لمدة خمس سنوات، وهى حق الانتخاب فى المجالس النيابية أو حق تقلد الوظائف العامة، وحقوق يرد الحرمان عليها لمدة عشر سنوات، وهى حق الترشيح أو التعيين فى أحد الهيئات النيابية، وذلك لما تنطوى عليه تلك الحقوق من مشاركة فعلية فى النظام السياسى للدولة.^(٢)

٤- إعفاء الوطنى الطارئ من الحرمان:

استثنى المشرع من حكم المادة ٩ كل من اكتسب الجنسية المصرية وفقاً لنص المادة الخامسة من تشريع الجنسية المصرية (أى كل أجنبى اكتسب الجنسية المصرية بقرار من رئيس الجمهورية نتيجة لأدائه خدمات جليلة لمصر أو لكونه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية) وكذلك للزوجات اللاتى اكتسبن الجنسية المصرية وفقاً لنص المادة ١٤ من نفس التشريع (الزوجات اللاتى من أصل مصرى واللاتى اكتسبن الجنسية المصرية بهذه الصفة).

ويمكن رد هذا الاستثناء إلى أنه "من التناقض أن تحرم الأجنبى الذى تم منحه الجنسية لقيامه بأداء خدمات جليلة للدولة من الحقوق السياسية حتى تتحقق من ولائه للجماعة الوطنية، إذ أن منحه الجنسية فى ذاته تم مكافأة له على خدمات جليلة تنطق بهذا الولاء، كذلك فإنه من غير المستساغ حرمان رؤساء الطوائف الدينية الذين اكتسبوا الجنسية المصرية من الحقوق السياسية التى يتمتع بها أفراد الطائفة التى يضطلعون برئاستها، نظراً لمكانتهم بين أفراد الطائفة بل وفى المجتمع الوطنى بأسره".^(٣)

و إلى جوار هذا الاستثناء العام فقد قرر المشرع المصرى استثناءاً خاصاً بأفراد الطوائف الدينية المصرية، حيث أجاز لهم خلال فترة الرتبة الحق فى الاشتراك فى انتخابات المجالس المليّة التى يتبعونها وفى عضويتهم بها، وذلك لأن تلك الحقوق لا صلة لها بكيان الدولة السياسى.

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٤٥.

(٢) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٩٧، ١٩٨.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩٠.

كذلك يجوز إعفاء من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها من قيد مرور الخمس سنوات أو من قيد مرور العشر سنوات وذلك بقرار من وزير الداخلية،^(١) وتكمن الحكمة من وراء هذا الاستثناء في أن الشخص الذي يقبل أن يضحي بدمه من أجل الدولة، لا يترك أى مجال للشك في ولائه للدولة المصرية، وبذلك فلا حاجة لوضعه موضع التجربة خلال مدة معينة.^(٢)

وبالإضافة إلى ذلك فقد أعطى المشرع المصرى لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الوطنى الطارئ من الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية وحق الترشيح والتعيين في الهيئات النيابية.^(٣)

ثانياً- الآثار العائلية لاكتساب الجنسية المصرية:

تنص المادة ٦ من قانون الجنسية على أنه "لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوجو ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقاً لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقاً لقانونها".

ومن خلال النص يتضح أن الحكم يختلف فيما يتعلق بالزوجة عنه بالنسبة للأولاد القصر على النحو التالي :

أولاً- بالنسبة للزوجة:

لم يشأ المشرع المصرى أن يفرض الجنسية المصرية على زوجة المتجنس وذلك احتراماً لإرادتها في ذلك، حيث عرض عليها هذه الجنسية مع تعليق دخولها فيها على إرادتها الصريحة، متى توافرت في حقها الشروط الواردة في نص المادة السادسة، ومن الملاحظ أن تلك الشروط هي التي تطلبها المادة السابعة لاكتساب الأجنبية التي تتزوج من مصرى للجنسية المصرية وتتحصر تلك الشروط في خمس شروط هي انعقاد الزواج صحيحاً وفقاً للقانون المختص، وأن يكون ثابتاً في وثيقة

(١) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢١٤.

د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٩٩.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩١.

د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٤٧.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ١٩٩.

رسمية، وأن تعلن الزوجة عن رغبتها في ذلك، وأن تمضى سنتان من تاريخ ذلك الإعلان، ويجب فى النهاية ألا يعترض وزير الداخلية على ذلك قبل فوات مدة السنتين.^(١)

وقد استثنى المشرع المصرى من الأحكام المتقدمة الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدتها وكذلك الزوجة التى من أصل مصرى، حيث أكدت المادة ١٤ من قانون الجنسية المصرية على أن "تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك"، وبذلك تعفى تلك الزوجة من شرط استمرار الزوجية لمدة سنتين بعد إعلان الرغبة، وكذلك من الشرط المتعلق بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية فى ذلك، وتكمن حكمة هذا الاستثناء فى أن الزوجة التى سبق لها التمتع بالجنسية المصرية أو التى من أصل مصرى، ليست فى حاجة إلى دليل على صدق رغبتها فى الدخول فى الجماعة الوطنية أو اندماجها فيها.^(٢)

ثانياً - بالنسبة للأولاد القصر:

وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة فإن لاكتساب الأب الجنسية المصرية أثراً مباشراً على أولاده القصر، حيث أنهم يدخلون فى الجنسية المصرية بقوة القانون وذلك بمجرد اكتساب أبيهم لتلك الجنسية.

ولكن لما وجد المشرع المصرى أن هناك طائفة من الأولاد القصر الذين بقوا مقيمين بصفة عادية فى الخارج، ويحتفظون فى نفس الوقت بالجنسية الأصلية لأبيهم، مما يتضح معه ابتعادهم عن المجتمع المصرى، ففى هذه الحالة لا تمتد الجنسية المصرية إليهم، وبذلك فإنه لكى لا يتمتع هؤلاء الأبناء بالجنسية المصرية فيشترط احتفاظهم بجنسية أبيهم الأصلية إضافة إلى إقامتهم العادية فى الخارج.^(٣)

واحتراماً للأصول المثالية فى مادة الجنسية والتى تقضى بعدم فرض جنسية على شخص دون إرادة منه، فقد منح المشرع المصرى الأولاد القصر من الوطنى الطارئى الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بطريق التبعية لأبيهم الحق فى اختيار جنسيتهم السابقة خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، فإذا اختاروا جنسيتهم الأصلية زالت عنهم جنسيتهم المكتسبة، وذلك بشرط استرداد الجنسية الأصلية بالفعل لتلافى انعدام الجنسية، وذلك كله مع مراعاة أن زوال الجنسية المصرية فى هذه الحالة يتم دون أثر رجعى، وذلك وفقاً لنص المادة ١٩ من قانون الجنسية المصرى التى تقضى بأن "لا يكون للدخول

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٢٩٢، ٢٩٣.

(٢) بالتفصيل فى ذلك د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٤٥٠.

(٣) بالتفصيل فى ذلك د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٥٢، ١٥٣.

في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في القانون".^(١)

(١) بالتفصيل في ذلك د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، ص ١٩٧، ١٩٨.

د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٠١.

د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢١٨.

الفصل الثانى

فقد الجنسية المصرية

سنقوم بدراسة فقد الجنسية المصرية من خلال مبحثين أحدهما متعلق بفقد الجنسية المصرية نتيجة لاكتساب جنسية أخرى، والآخر متعلق بفقد الجنسية المصرية على سبيل الجزاء، وذلك بنزعها عن الشخص لإتيانه فعل يدل على عدم ولائه للدولة أو عدم اندماجه فى مجتمعها.^(١)

المبحث الأول

فقد الجنسية المصرية الناتج عن اكتساب جنسية أخرى

تدرج تحت هذا البند حالتان رئيسيتان أحدهما تتعلق بالوطنى الذى يتجنس بجنسية أجنبية، والثانية تتعلق بالمرأة الوطنية التى تتزوج من أجنبى، وذلك فى مطلبين على النحو التالى:-

المطلب الأول

الفقد الناتج عن التجنس بجنسية أجنبية

تنص المادة ١٠ من تشريع الجنسية المصرية فى فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة ١٦ من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه".

وباستقراء النص تتضح لنا شروط التخلّى عن الجنسية المصرية بالتجنس وتلك الشروط هى:

الشرط الأول- أن يحصل الفرد مقدماً على إذن من جهة الإدارة:

وقد تطلب المشرع المصرى هذا الشرط حتى يكون التجنس صحيحاً، وأن يحصل عليه الفرد قبل الإقدام على التجنس، ويصدر هذا الإذن من وزير الداخلية، ويذهب البعض إلى أن العلة فى تطلب هذا الشرط تكمن فى تحقيق قدر من التوازن بين مبدأ حق الفرد فى تغيير جنسيته ومصلحة الدولة فى عدم تهرب الأفراد من أحكام قوانينها والإلتزامات التى تفرضها عليهم،^(٢) وبضيف آخرون أن الهدف من ذلك هو "تمكين الدولة من ضبط حركة الأفراد والحد من تناقص عدد أفراد شعب الدولة، أو

(١) ونحن نتبع فى هذا التقسيم د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٠٧.

(٢) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، ص ٢٢١.

هجرتهم إلى الخارج والحفاظ على الثروة البشرية اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى للبلاد".^(١)

وينتقد بعض الفقه استلزام هذا الشرط على اعتبار أن "عدم منح الإذن أو عدم طلب الشخص له كلية لن يشل من قدرته على اكتساب الجنسية الأجنبية، كان من الأفضل الاكتفاء بإخطار السلطات المصرية إذا ما أراد المصرى تغيير جنسيته، لأنه ليس من مصلحة الدولة الإبقاء على صلتها بوطنى قد هجرها واكتسب جنسية أجنبية، لذا فإن السلطة التقديرية فى منح الإذن هو دور ضئيل ما كان يجب على المشرع المصرى أن يعهد به إلى سلطات الدولة، وكأنه يريد به زيادة حالات ازدواج الجنسية وهى ظاهرة كان يجب عليه أن يعمل على تلافيها".^(٢)

ويثور التساؤل حول الحكم فى حالة تجنس المصرى بجنسية أجنبية دون حصوله مسبقاً على إذن بذلك من وزير الداخلية؟

فى الإجابة على هذا التساؤل أوردت المادة ١٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ أن "المصرى يظل حينئذ معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الحالات" وذلك لأن شرط الإذن يعتبر متخلفاً، وبذلك لا ينتج أثره من جميع الوجوه بصدد زوال الجنسية.

وقد أجازت تلك المادة لمجلس الوزراء معاقبة هذا الشخص بإسقاط الجنسية عنه، وذلك طبقاً لحكم المادة ١٦ من نفس القانون والتي أدرجت هذه الحالة ضمن الحالات التى يجوز فيها إسقاط الجنسية.^(٣)

الشرط الثانى - اكتساب الجنسية الأجنبية بالفعل:

طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ١٠ من القانون والسابق ذكرها يتضح أن النص يذهب إلى أن الإذن بالتجنس غير كاف للتخلى عن الجنسية المصرية وزوالها، بل يلزم فوق ذلك أن يكتسب المصرى فعلاً جنسية دولة أجنبية، ويترتب على ذلك أن فقد الجنسية المصرية لا يكون إلا من لحظة الاكتساب الفعلى للجنسية الأجنبية، وحتى لو صدر الإذن بالتجنس قبل ذلك بوقت طويل، إضافة إلى أن اتخاذ صاحب التجنس لإجراءاته وتقديم طلب بذلك إلى سلطات الدولة كل ذلك لا يفيد فى ترتيب الأثر المرجو وهو زوال الجنسية المصرية.^(٤)

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٦٧٧.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٧١.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٠٦.

(٤) بالتفصيل فى ذلك د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٦٨٠ وما بعدها.

ويذهب بعض الفقه إلى أنه يتعين أن يكون اكتساب المصري الجنسية الأجنبية قد تحقق عن طريق التجنس، وبذلك فإن دخول المصري في الجنسية الأجنبية عن غير طريق التجنس، مثل اكتسابها نتيجة لميلاده بإقليم دولة أجنبية أو لميلاده لأم أجنبية لا يترتب عليه زوال الجنسية^(١).

- رخصة الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

تنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٠ من قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن "ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية" وقد برر المشرع سبب لجوئه لهذا النص في المذكرة الإيضاحية للقانون، حيث ذكرت أن هذا الحكم أملت "الضرورات العملية وخاصة في السنوات الأخيرة من حرص كثير من المصريين الذين استقروا في الخارج واكتسبوا جنسية المهجر على بقاء الارتباط بوطنهم الأصلي كاملاً، وأن يظل باب العودة مفتوحاً أمامهم، مما يعطيهم قوة نفسية كبيرة في نضالهم في المهجر، لهذا أجاز المشرع أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وأسرته بالجنسية المصرية"^(٢).

ويشترط للاحتفاظ بالجنسية وفقاً لنص المادة ١٠ توافر شرطان:

الشرط الأول - موافقة السلطة التنفيذية:

حتى يتمكن الفرد من الاحتفاظ بالجنسية المصرية لابد من موافقة السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية، وينتقد البعض الصياغة التي جاء بها نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة حيث يؤكد على أنه "أتى نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة معكوساً، ويبدو أن حداثة الحكم هي السبب في ذلك، فهو يجعل قرار الاحتفاظ بالجنسية سابقاً على طلب الفرد لهذا الاحتفاظ"^(٣). حيث أن النص بهذا الشكل يجعل قرار الإذن بالتجنس يصدر متضمناً جواز الاحتفاظ بالجنسية، وبعد ذلك يحق للمتجنس أن يقبل هذا الاحتفاظ أو يرفضه كما يحلو له.

كما يجب أن يصدر الإذن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية صريحاً، مثله مثل التجنس بجنسية أجنبية يجب ألا يفترض، وإنما يجب أن يتم إدراجه صراحة من قبل جهة الإدارة في الإذن الصادر منها، ويجب أن يكون ذلك إجابة منها على طلب الراغب في الاحتفاظ بالجنسية المصرية.^(٤)

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٠٣.

(٢) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ - ص ٢٣٣٨.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٧٢.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢١٨.

الشرط الثاني- إعلان الرغبة فى الاستفادة من هذه الرخصة:

حيث إن الاحتفاظ بالجنسية المصرية عمل إرادى لا يتم بدون رغبة صاحبه، فلا بد أن يطلب المتجنس الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو يملك هذا الحق لمدة سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، فإذا لم يطلب المتجنس الاحتفاظ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية فقد هذا الحق، وزالت عنه الجنسية المصرية.^(١)

وفى تبرير سقوط الحق فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا لم يمارس خلال عام من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، فيمكن رد ذلك إلى أنه يستند إلى قرينة مؤداها أنه لم يتجنس بالجنسية الأجنبية فى الغالب عن اختيار كامل، وإنما تحت ضغط العوز والحاجة والرغبة فى صنع طموحه، وهو ما عجزت الدولة عن أن تحققه له، إلا أن هذه القرينة تنقوض إذا لم يمارس المعنى بالأمر هذا الحق فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى خلال العام المذكور، لأن ذلك يعنى تراجع كل معانى الولاء والارتباط بالجماعة الوطنية، فلا يغدو أهلاً لمواصلة الاحتفاظ له بالجنسية المصرية.^(٢)

ولكن إذا لم يحتفظ المتجنس بجنسية أجنبية بالجنسية المصرية. فما هو تاريخ فقدته لها؟

بصدد الإجابة على ذلك السؤال يوجد فرضان:

الأول: من تعطيه السلطة التنفيذية الحق فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ولكنه لا يستعمل تلك الرخصة أو يستعملها بعد فوات سنة على اكتساب الجنسية الأجنبية، فإنه فى هذه الحالة يفقد الجنسية المصرية من تاريخ مضى سنة على تجنسه بالجنسية الأجنبية.

الثانى: من تعطيه السلطة التنفيذية الحق فى التجنس دون الحق فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإنه يفقد الجنسية المصرية اعتباراً من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية.^(٣)

- الامتياز المقرر للمهاجر هجرة دائمة:

صدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالهجرة ورعاية المصريين فى الخارج، والذى تقرر العمل به اعتباراً من ١٢ أغسطس ١٩٨٣ مقررأ فى المادة العاشرة منه أن "للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٧٤.

(٢) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢١٨.

(٣) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٧٥.

د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣١٣، ٣١٤.

المهاجرين معه، ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية".

وطبقاً للنص السالف فإن المصرى الذى هاجر هجرة دائمة يحق له، ولأولاده القصر وزوجته وكذلك زوجته الأجنبية، الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم الدخول فى جنسية المهجر، ورغم احتفاظ زوجته الأجنبية بجنسيتها الأجنبية، ولكن بالنظر إلى الفقرة الأخيرة من تلك المادة يتضح لنا أنها تحيل إلى قانون الجنسية بصدد الأحكام والإجراءات المقررة فيه، وهو ما يجعل هذا النص لغواً لا قيمة له، إذا ما تم إعمال هذه الحالة، لذلك يؤكد البعض على "وجوب تفسير نص المادة ١٠ من قانون الهجرة على أنه يخول للمهاجر هجرة دائمة حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية بمجرد صدور الإذن له باكتساب جنسية دولة المهجر دون حاجة للترخيص له بذلك فى الإذن المذكور، وذلك تحقيقاً للهدف الذى توخاه المشرع من وضع المصرى الذى توافر له وصف المهاجر هجرة دائمة فى مرتبة أسمى من باقى المصريين الراغبين فى التجنس بجنسية أجنبية".^(١)

ويذهب آخرون إلى عدم الأخذ بهذا رأى حيث إنه من غير المعقول وضع المصرى الذى يهجر وطنه فى مرتبة أسمى من باقى المصريين، وذلك لأن "هجرة الوطن إن لم تدل على عدم الولاء للوطن فهي بلا شك تدل على عدم الارتباط به، وتشريع الجنسية السابق (الصادر سنة ١٩٥٨) كان يجعل مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر بقصد عدم العودة مبرراً لإسقاط الجنسية عن المصرى".^(٢)

وإذا كان هذا الاستثناء مقرر للمهاجر هجرة دائمة وزوجته وأولاده القصر، فإنه ينبغى تعريف المهاجر هجرة دائمة، وتحديد شروط استفادته من هذا الاستثناء، على النحو التالى.

أولاً- تعريف المهاجر هجرة دائمة:

فى تعريف المهاجر هجرة دائمة تنص المادة ٨ من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج على أنه "يعتبر مهاجراً هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة".

ومن النص يتضح لنا أن الحالات التى يكتسب فيها الشخص صفة المهاجر هجرة دائمة هى الحالات التالية:

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣١٦.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ١٨١.

- ١- أن يكون قد اكتسب جنسية دولة أجنبية وجعل إقامته العادية خارج مصر.
- ٢- أن يكون قد حصل على إذن بالإقامة الدائمة في الدولة الأجنبية، وأن يكون قد جعل إقامته العادية الدائمة خارج مصر.
- ٣- أن يقيم بدولة أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
- ٤- أن يحصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر المحددة بقرار من الوزير المختص، وأن يجعل إقامته العادية الدائمة خارج مصر.^(١)

ثانياً- شروط استفادة المهاجر من هذا الاستثناء:

يشترط لاستفادة المهاجر من هذا الاستثناء عدة شروط هي:

- ١- أن يتعلق الأمر بمصري مهاجر هجرة دائمة للخارج.
- ٢- الحصول على موافقة دولة المهجر.
- ٣- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.^(٢)

المطلب الثاني

الفقد الناتج عن الزواج المختلط

تنص المادة ١٢ من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن "المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية، إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها جنسية زوجها. وإذا كان عقد زواجها باطلاً طبقاً لأحكام القانون المصري، وصحياً طبقاً لأحكام قانون الزوج، ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها".

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣١٨، ٣١٩.

(٢) بالتفصيل في تلك الشروط، د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢١٩ - ٢٢١.

ومن خلال النص يتضح لنا أن المشرع قد اشترط عدة شروط لفقد الجنسية المصرية نتيجة للزواج بأجنبي يمكن حصرها فيما يلي:

١- إعلان الزوجة رغبتها في اكتساب جنسية زوجها، وذلك إما في وثيقة الزواج أو في طلب لاحق تتقدم به الزوجة خلال قيام الزوجية، و يبنى هذا الشرط على احترام إرادة الزوجة، وعدم إجبارها على الخروج من الجنسية المصرية طالما ترغب في الالتحاق بجنسية زوجها.^(١)

٢- أن يمنحها قانون جنسية الزوج هذه الجنسية، وذلك حماية لها من أن تصبح عديمة الجنسية، وبذلك فإن خروج المرأة المصرية من الجنسية المصرية لا يتوقف فقط على إرادتها، حيث إنها وعلى الرغم من إيداء تلك الرغبة تظل محتفظة بالجنسية المصرية حتى لحظة دخولها فعلاً في جنسية الزوج الأجنبية.^(٢)

٣- أن يكون الزواج ثابتاً في وثيقة رسمية، ويستخلص هذا الشرط من نص المادة ٢٥ من قانون الجنسية التي تقضى بأنه "لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية المصرية أو فقدها، إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة".^(٣)

٤- أن يكون عقد الزواج صحيحاً وفقاً لأحكام القانون المصري، أى وفقاً لقاعدة الإسناد المصرية الخاصة بالشروط الموضوعية والشكلية للزواج، وبذلك فإذا كان الزواج صحيحاً طبقاً لقانون الزوج وغير صحيح طبقاً للقانون المصري، فلا تفقد الزوجة الجنسية المصرية في هذه الحالة وتظل مصرية من جميع الوجوه.

مع ملاحظة أن المشرع المصري نص على جواز اعتبار المرأة المصرية فاقدة للجنسية المصرية، وذلك على الرغم من عدم قيام الزوجية من وجهة نظر القانون المصري، طالما أنها اكتسبت الجنسية الأجنبية فعلاً، ويكون فقد الجنسية في هذه الحالة بقرار من وزير الداخلية، دون اشتراط وقت معين لصدوره، وما ذلك إلا تلافياً لظهور حالات ازدواج في الجنسية.^(٤)

وقد بررت المذكرة الإيضاحية لقانون الجنسية هذا الحكم بقولها "عدم جعل هذه المرأة في وضع أفضل من المصرية التي تتزوج من أجنبي زواجا صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المصري، حيث إن هذه الأخيرة تفقد الجنسية متى دخلت جنسية زوجها وفقاً للشروط المتطلبة في الحالات المعروضة"^(٥).

(١) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٠٩.

(٢) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٢١.

(٣) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢١٠.

(٤) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٢١، ٣٢٢.

(٥) بالتفصيل في ذلك راجع د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢١١.

فقد الجنسية بالتجريد

= = =

التجريد من الجنسية هو "جزاء توقعه الدولة على الوطنى الذى يبدر منه ما ينبئ على عدم ولائه لها أو عدم صلاحيته للاندماج فى جماعتها الوطنية"،^(١) ويأخذ المشرع المصرى بجزاء تجريد الوطنى من جنسيته فى حالات معينة، وذلك عن طريق سحب الجنسية أو إسقاطها، والسحب جزاء يوقع على الوطنى الطارئ فقط، ويمكن توقيعه خلال فترة معينة من دخوله فى الجنسية أما الإسقاط فيوقع على أى وطنى فى أى وقت وتختلف الآثار التى تترتب على كل منهما،^(٢) لذلك سندرسهما على النحو التالى.

المطلب الأول

سحب الجنسية المصرية

سحب الجنسية " إجراء قانونى تحرم أو تنزع بمقتضاه الدولة الجنسية عن الشخص الذى اكتسبها فى تاريخ لاحق على الميلاد بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال مدة معينة من اكتسابه لها إذا ثبت سوء خلقه أو خطورته على أمن الدولة أو عدم أمانته فى تحصله على الجنسية".^(٣)

وبصدد السحب تنص المادة ١٥ من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه "يجوز بقرار مسيب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو الزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها وذلك فى حالة من الحالات الآتية: أ- إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

ب- إذا حكم عليه قضائياً فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥١٢.

د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢١٣.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٢١٠.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٤٤.

جـ- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

ومن خلال النص يتضح لنا أن أسباب السحب تنقسم إلى ثلاثة مجموعات رئيسية،^(١) على النحو التالي:

أولاً- السحب لاكتساب الجنسية بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ:

هناك سوابق في تشريعات الجنسية السابقة قررت نفس الحكم، ومنها المادة ١٠ الفقرة الأولى من المرسوم بقانون لعام ١٩٢٩، والمادة ١٤ الفقرة الأولى من قانون الجنسية لعام ١٩٥٠، والمادة ١٧ الفقرة الأولى من قانون عام ١٩٥٦، والمادة ٢١ الفقرة الثانية من قانون عام ١٩٥٨.^(٢)

ويشترط لسحب الجنسية من الشخص طبقاً لأحكام النص السابق ما يلي:

١- أن يكتسب الشخص الجنسية المصرية الطارئة، وذلك لأن السحب يعنى عدول الدولة عن قرار سبق واتخذته، وبذلك فلا يتصور سحب الجنسية إلا من سبق له أن اكتسبها عن طريق قرار إداري فيجوز سحبه، ولذلك فإن من يكتسب الجنسية المصرية الأصلية لا يجوز تجريده منها إلا عن طريق الإسقاط وليس السحب.^(٣)

٢- أن يكون اكتساب الجنسية قد تم عن طريق الغش، وبأخذ حكم الغش الأقوال الكاذبة والتزوير والتزييف في المستندات والخطأ، ومن أمثلة ذلك أن يقدم طالب التجنس شهادات مزورة لإثبات عدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو لإثبات ميلاده في الخارج من أم وطنية وأب مجهول أو لا جنسية له.^(٤)

ويخضع تقدير توافر الغش وما شابهه لسلطة الجهة صاحبة الحق في توقيع عقوبة سحب الجنسية وهي هنا مجلس الوزراء،^(٥) مع ملاحظة أنه يجب أن يكون قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مسبباً وإلا كان محلاً للطعن عليه لعيب في الشكل.^(٦)

(١) قال بهذا التقسيم واتبه في ذلك أستاذنا الدكتور: هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥١٥ وما بعدها.

(٢) بالتفصيل في تلك التشريعات راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٥٦.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٥٧.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٤٩.

(٥) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٥٧.

(٦) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٥٠.

ثانياً- السحب لمغادرة إقليم الدولة والاستقرار فى الخارج:

رأى المشرع المصرى أن من ينقطع عن الإقامة فى مصر لمدة سنتين متتاليتين دون عذر يقبله وزير الداخلية، يعبر بذلك عن عدم ولائه للدولة وعدم قدرته على الاندماج فى مجتمعاتها الوطنية، فنص فى الفقرة الثالثة من المادة ١٥ من قانون الجنسية المصرية على جواز سحب الجنسية منه، مع مراعاة ضرورة أن يكون الانقطاع لمدة سنتين متتاليتين عن الإقامة فى مصر، وبذلك لا يتوافر هذا الشرط إذا انقطع لمدة عام ثم عاد إلى مصر وعاود الانقطاع بعد ذلك، لأن التوالى الذى تطلبه المشرع لا يتوافر فى هذه الحالة، ويشترط أيضاً أن يتم السحب خلال السنوات الخمس التالية لاكتساب الشخص للجنسية المصرية، وأن يبدأ العاومان ويكتملا خلال الخمس سنوات.^(١)

وقد راعى المشرع أن الانقطاع عن الإقامة فى مصر قد يكون له ما يبرره من أعذار، مثل طلب العلم أو الاستشفاء أو التجارة أو العمل، فمنح وزير الداخلية سلطة تقدير هذه الأعذار وقبولها من عدمه، وهو يخضع فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى.^(٢)

ثالثاً- السحب لارتكاب جرائم تضر بمجتمع الدولة:

ويندرج تحت هذه الطائفة حالتان هما:

١- الحالة التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون الجنسية، وتتعلق بالحكم على المتجنس بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، وذلك على أساس أنه يعد دليلاً على عدم صلاحية الشخص للانضمام للجماعة الوطنية.^(٣)

٢- الحالة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١٥ من نفس القانون، وتتعلق بالحكم على المتجنس قضائياً فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، ومرد الأمر فى ذلك "أن من يقترب مثل هذا الجرم إنما يعبر عن أقصى درجات الغدر والخيانة لوطنه، ومثله لا يرجى منه خير وهو الحديث العهد بالجنسية المصرية ومن ثم يكون سحب الجنسية جزاء وفاقاً على فعلته".^(٤)

(١) المرجع السابق: ص ٢٥٣، ٢٥٤.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥١٨.

(٣) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٣٥.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٥٢، ٢٥٣.

وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع الأحوال السابقة يجب أن يكون قرار السحب مسبباً، وبذلك فإذا صدر خالياً من التسيب جاز الطعن فيه أمام القضاء الإداري، وذلك لأنه صدر مشوباً بعيب في الشكل.^(١)

ويجب أيضاً ملاحظة أن الحالات التي يجوز فيها السحب قد وردت على سبيل الحصر، وبذلك فلا يمكن سحب الجنسية في غيرها ولا تجوز الإضافة إليها عن طريق القياس وغيره، ولكن تملك جهة الإدارة سلطة الملاءمة داخل حدود تلك الحالات، فقد تتوافر إحدى هذه الحالات ومع ذلك لا تسحب جهة الإدارة الجنسية من المتجنس، لأنها قد قدرت عدم ملاءمة اتخاذ هذا الإجراء في هذه الحالة.^(٢)

المطلب الثاني

إسقاط الجنسية المصرية

إسقاط الجنسية هو "إجراء قانوني تحرم أو تنزع بمقتضاه الدولة جنسيتها عن أحد الأفراد، إذا ثبت، في أي وقت، عدم ولائه للدولة، أو استهتاره بقوانينها، أو تهديده لنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي".^(٣)

وبصدد الإسقاط تنص المادة ١٦ من قانون الجنسية على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

- ١- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
- ٢- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- ٣- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- ٤- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

(١) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٢٠.

(٢) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٥٥.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٤٤.

٥- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

٦- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.

٧- إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .

يتمتع الإسقاط بصفة العقوبة حيث إنه يحتوى على معنى الردع لكل وطنى يخل بواجباته تجاه دولته، ويطبق هذا الجزاء على كل مصرى يفعل ذلك سواء أكانت جنسيته أصلية أو مكتسبة، وتكون أدواته قرار من مجلس الوزراء، وقد كانت تلك الأداة قراراً جمهورياً فى تشريع ١٩٥٨، وقراراً من وزير الداخلية فى قانونى ١٩٥٦، ١٩٥٠، وقبل ذلك أى فى ظل قانون ١٩٢٩ كان أداة تلك العقوبة هو المرسوم، وقد ذكر القانون حالات الإسقاط على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وتلك الحالات هى نفس الحالات التى تضمنها تشريع الجنسية الصادر سنة ١٩٥٨، مع حذف الحالة المتعلقة بالعمل فى الهيئات الأجنبية دون الحصول على إذن سابق، ويلاحظ أيضاً أن قانون الجنسية قد ألغى حالة من حالات الإسقاط استخدمها قانون ١٩٥٦، وكذلك قانون ١٩٥٨، وهى المتعلقة بمغادرة البلاد نهائياً بنية عدم العودة إليها، ويبدو أن السبب فى ذلك أن المشرع رأى أنها لا تتفق مع سياسة رعاية مصالح المصريين فى المهجر والتى تحرص الدولة عليها.^(١)

وكذلك فإن الحكم الوارد بالمادة (٢٣) من تشريع ١٩٥٨ والمتعلق بإسقاط الجنسية للمغادرة النهائية للبلاد لم يعد له ما يبرره، فى ظل سماح المشرع المصرى باحتفاظ المصرى بجنسيته الوطنية رغم اكتسابه لجنسية دولة أجنبية، فالسماح بالاحتفاظ بالجنسية المصرية مع اكتساب جنسية أجنبية، يقتضى بدهاءه السماح لهذا الشخص بالإقامة المستمرة فى الدولة الأجنبية التى اكتسب جنسيته.^(٢)

ومن الملاحظ على نص المادة ١٦ من تشريع الجنسية المصرية أنها قد حددت سبع حالات حصراً يتم فيها إسقاط الجنسية المصرية وهى:

الحالة الأولى- إذا دخل المصرى فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠ من قانون الجنسية المصرى:

فقد سبق ذكر أن الجنسية المصرية لا تزول عن المصرى الذى يتجنس بجنسية دولة أجنبية مختاراً، إلا إذا حصل على إذن بذلك من جهة الإدارة، ودخل بالفعل فى جنسية الدولة الأجنبية، أما إذا

(١) د. محمد كمال فهمى: المرجع السابق، ص ٢٢٥، ٢٢٦.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٢٥، ٥٢٦.

لم يأذن لذلك الشخص فى ذلك فإنه يحتفظ بصفته المصرية من جميع الوجوه، ولكن المشرع أعطى لمجلس الوزراء الحق فى إسقاط الجنسية عن هذا الشخص، حيث أن عدم حصوله على الإذن لهو دليل على اندثار كل الدلائل التى تثبت ارتباطه بالجماعة المصرية.^(١)

وهناك من يرى أن الإسقاط فى هذه الحالة يتضمن معنى العقاب من وجهين:^(٢)

الأول: الاستهتار بأنظمة وقوانين الدولة وعدم احترامها، ويتمثل ذلك فى مخالفته لنص المادة ١٠ من قانون الجنسية، الذى يوجب التزود مسبقاً بإذن قبل اكتساب أية جنسية أجنبية.

الثانى: فتور - إن لم يكن انعدام الولاء للدولة - وعدم الرغبة فى الاستمرار فى عضوية جماعتها الوطنية، هذا فضلاً عن أن الشخص، الذى يحصل مسبقاً على الإذن بالتجنس وتعرض للإسقاط قد فوت على نفسه مكنة الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهذا وجه آخر لمعنى العقوبة فى الإسقاط.

الحالة الثانية - إذا دخل الوطنى فى الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص من وزارة الدفاع:

من خلال النص والأعمال التحضيرية له يتضح لنا ضرورة أن يكون دخول الوطنى فى الخدمة العسكرية لدولة أجنبية قد تم بعمل إرادى من جانبه، وبذلك فلا محل لإعمال الحالة المعروضة إذا كان هذا الدخول قد فرض عليه جبراً من قبل الدولة الأجنبية، ويمكن تبرير هذه الحالة بأن من يؤدى الخدمة العسكرية فى دولة أجنبية، فإنه بذلك يعبر عن أقصى درجات الولاء للدولة الأجنبية، وهذا الولاء يستشف منه غياب مشاعر الولاء تجاه دولته الأصلية مصر، ولكن ذلك ليس قرينة قطعية على غياب الولاء من قبل ذلك الشخص لمصر، لذلك فقد جعل المشرع إسقاط الجنسية عنه فى هذه الحالة جوازياً، وليس وجوبياً، ويشترط لتحقيق هذا الفرض شرطان على النحو التالى:

١- أن يقبل المصرى اختياراً الدخول فى الخدمة العسكرية لدولة أجنبية.

٢- عدم الحصول على إذن سابق من وزير الحربية بذلك.^(٣)

ويستحسن البعض^(٤) لو أن "أخرج المشرع من عداد هذه الحالة المصرى الذى يقبل مختاراً دخول الخدمة العسكرية لدولة عربية متى لم تكن فى حالة حرب مع مصر، على أنه يمكن بلوغ ما ندعو إليه من خلال السلطة الجوازية التى تملكها جهة الإدارة فى هذا الصدد، إذ لا يتصور أن يكون المصرى الذى يقوم بهذه الخدمة فى دولة عربية زاهداً فى الجنسية المصرية ومستحقاً لسحبها منه".

(١) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦١.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٧٨.

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٢٢.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦٢.

الحالة الثالثة- الإدانة فى إحدى الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج:

يلزم لإعمال هذه الحالة شرطان :-

١- أن يحكم بإدانة الشخص فى إحدى الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وهو ما يستلزم صدور حكم قضائى نهائى بالفعل ضد هذا الشخص، وذلك سواء من محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية أو من محكمة عادية تملك سلطة الفصل فى القضية، ولا يكفى فى هذا المجال مجرد إحالته إلى التحقيق أو مجرد الاتهام، كما يشترط أن يصدر الحكم بعقوبة فى إحدى الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، ولا يقتصر فى هذه الحالة على الجنج، وإنما لابد أن تكون جنابة وذلك لعدم خطورة الجنج.^(١)

٢- أن يكون الوطنى المحكوم عليه قد اتخذ إقامته العادية فى الخارج.

ويستحسن البعض هذا الشرط على اعتبار أنه "يحد من حالات إسقاط الجنسية ويتمشى على هذا النحو مع الأصول المثالية فى مادة الجنسية، إذ لو كان الشخص المحكوم عليه مقيماً فى مصر، فإنه يكفى ما سيلاقه من عقوبة جنائية نظير ارتكابه لإحدى الجرائم السابقة، فليس هناك ما يدعو إلى إسقاط الجنسية عنه فى هذه الحالة وتعرضه لخطر انعدام الجنسية".^(٢)

وبذلك فإن الإقامة العادية للفرد فى الخارج واستحالة وضعه تحت طائلة العقاب، تجعل من إسقاط الجنسية عنه خط دفاع أخير تتمكن به الدولة من التخلص من مواطنيها الذين يثبت خطرهم على أمنها وسلامتها، وتملك الإدارة سلطة تقديرية بصدد تلك الحالة كما أنها لا تنقيد بوقت معين لتوقيع ذلك الجزاء.^(٣)

الحالة الرابعة- قبول وظيفة فى الخارج لدى دولة أو هيئة دولية:

يشترط لإسقاط الجنسية المصرية فى الحالة المعروضة ما يلى:-

- ١- أن يقبل المصرى وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية تعمل فى الخارج.
- ٢- أن يصدر إليه أمر مسبب من مجلس الوزراء بترك تلك الوظيفة، وأن يرفض تنفيذ هذا الأمر خلال الستة أشهر التالية لإخطاره به.
- ٣- أن يمثل استمراره فى تلك الوظيفة ما يهدد المصالح العليا لمصر.^(٤)

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٨٢.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٣٢.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٨٣.

(٤) د. عوض الله شيبه الحمد السيد: المرجع السابق، ص ٢٢٣.

وينتقد بعض الفقه هذا النص على اعتبار "أن النص على هذا الشرط بدون تحديد المقصود بالمصالح العليا للدولة، يتنافى مع الوضوح الواجب توافره في أسباب الإسقاط، فالإسقاط بوصفه عقوبة يجب أن يقوم على أسباب واضحة المعالم يعرفها الوطنيون مقدماً، كي لا يؤاخذوا على أفعال يخضع تحديد كونها تهدد المصالح العليا لسلطة الدولة التقديرية".^(١)

وقد استهدف المشرع من اشتراط أن يكون القرار الصادر من مجلس الوزراء مسبباً، تفادى تحكم السلطة التنفيذية وإعطاء الفرصة للمصرى لمعرفة أسباب اتخاذ ذلك القرار، أما اشتراط مضي ستة أشهر من تاريخ إخطار الوطنى به فيهدف إلى إعطاء الوطنى الفرصة الكافية لتدبير أموره، وأيضاً إجبار السلطة التنفيذية على التروى والتدبر قبل اتخاذ قرار الإسقاط.^(٢)

الحالة الخامسة- الانضمام إلى هيئة من أهدافها تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى لمصر:

ويشترط لإسقاط الجنسية في هذه الحالة ما يلى:-

١- إقامة الشخص فى الخارج، ويراد بالإقامة فى هذا المجال الاستقرار الدائم أو التوطن بالخارج، حيث أن الإقامة المؤقتة لا تبرر الإسقاط، بل تدعو إلى الانتظار حتى عودة الشخص وتقديمه للمحاكمة الجنائية عما بدر منه.

٢ - أن ينضم الشخص إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى لمصر، ويراد بالهيئة الأجنبية هنا كل حزب أو مكتب أو جمعية أو تنظيم أو معهد، وأن تهدف إلى هدم أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى لمصر، ويرجع بصدد تحديد مفهوم النظام الاجتماعى أو الاقتصادى لمصر إلى أحكام الدستور المصرى، والذي تضمن المواد من ٧ إلى ٣٩، والتي تحدد أحكام النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة.^(٣)

وقد وجهت سهام النقد لهذا النص على اعتبار "أن العبارات المستخدمة فى هذا الشأن من العمومية وعدم التحديد بحيث قد تفتح المجال أمام السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراء الإسقاط فى حالات لا يرقى الأمر فيها مرقى يعرض مصالح الدولة للخطر، وعلى أى حال فإن علو الإدارة التى تتخذ هذا الإجراء وهى مجلس الوزراء، وضرورة أن يكون القرار مسبباً، كلها عوامل تتيح للقضاء الإدارى مكنة مراقبة جهة الإدارة فى مسلكها من جهة، وضمان جدية اتخاذه من جهة أخرى".^(٤)

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٣٤٢.

(٢) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦٤.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٨٧.

(٤) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦٦.

الحالة السادسة: العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر:

يشترط لإعمال هذه الحالة ما يلي:-

١- أن يعمل الشخص لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، ولا يكفي في هذا المجال قبول العمل لدى تلك الأخيرة، وإنما لابد من القيام الفعلي بهذا العمل، ويشترط أن يكون ذلك العمل لدى دولة أو حكومة، وبالتالي لا ينطبق النص إذا قام بالعمل لدى مؤسسة أو شركة أو ما شابهها، ولا يهم في هذا المجال نوع العمل الذي تمت ممارسته، سواء كان اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي أو طبي، وسواء كان بأجر أو بدون أجر سواء كان في مصر أو في الخارج^(١).

٢- أن تكون الدولة أو الحكومة الأجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وعلى ذلك فمجرد توتر العلاقات بين مصر والدولة أو الحكومة المذكورة لا يكفي لإسقاط الجنسية^(٢).

٣- أن يكون من شأن العمل لدى الدولة أو الحكومة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، أو المساس بأية مصلحة وطنية أخرى، ويستحسن بعض الفقه هذا الشرط على اعتبار أنه "يشكل قيدا على جهة الإدارة في توقيع عقوبة إسقاط الجنسية، بما لا يسمح بالتوسع والإسراف غير المرغوب فيه، ذلك أن العمل في حد ذاته لصالح دولة أجنبية، لا يعد إثما يعاقب عليه الفرد، ولكنه يعد كذلك، إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها، وكان يترتب على ذلك الإضرار بالمصالح الحيوية للدولة"^(٣) مع ملاحظة أن اتخاذ قرار إسقاط الجنسية يخضع لتقدير السلطة المختصة، مع ضرورة أن يبنى على أسباب معقولة وإلا كان معيباً^(٤).

الحالة السابعة- الاتصاف بالصهيونية:.

الصهيونية كما عرفتھا المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٣٥٦ لسنة ٥ قضائية "رابطه روحية ومادية تقوم بين من يتصف بها وبين إسرائيل"^(٥) وبذلك فهي ليست ديناً حيث أن جميع المصريين لدى القانون سواء حتى وإن اختلفت دياناتهم، ويؤكد البعض على أنه "إذا كان الاتصاف بالصهيونية - وهو مبرر الإسقاط هنا - يقوم على ما يربط الشخص مادياً وروحياً بإسرائيل، فإن الذى

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٩٠.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، ص ٥٢٨.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٩١.

(٤) المرجع السابق، ص ٧٩١.

(٥) الموسوعة الإدارية الحديثة. القاعدة رقم (٣٥). الطعن رقم ١٣٥٦ لسنة ٥ ق. جلسة ١٩٦١/٤/٢٢، ص ٤٩ وبما بعدها.

يبدو لنا الآن أن هذا الحكم قد غدا من النصوص المينة في قانون الجنسية بعد الاتفاقات الحديثة التي ربطت بين مصر وإسرائيل، ولا نستبعد أن تصدر نصوص قانون الجنسية عند تعديلها خالية منه^(١).

ويخضع تقدير توفر وصف الصهيوني أو اتصاف الفرد بالصهيونية من عدمه للسلطة التقديرية لجهة الإدارة، ويمكنها الاستدلال على ذلك من الظروف والملابسات المقترنة بكل حالة، ولكنها في ذلك تخضع لرقابة القضاء الإداري^(٢).

ومن الملاحظ أن تلك الحالة لا يوجد لها نص مقابل في تشريعات الجنسية في أى من الدول العربية، وقد أدخلت على تشريع الجنسية المصرية لأول مرة في تشريع عام ١٩٥٦، وبقيت ضمن نصوص تشريع سنة ١٩٥٨ وذلك في المادة ٢٢ الفقرة (ز) من هذا التشريع^(٣).

(١) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، ص ٢٦٧.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة: المرجع السابق، ص ٧٩٣.

(٣) المرجع السابق: ص ٧٩٢.

الفصل الثالث

أثر انعدام الجنسية على تطبيق

قواعد الجنسية

يتحدد البحث حول مدى ثبوت جنسية دولة ما لشخص معين أو نفيها عنه، في إطار قواعد الجنسية في هذه الدولة، وذلك سواء كانت تلك القواعد مدرجة في دستور الدولة^(١)، أو مدرجة في تشريع عادي، كما يجب الرجوع إلى قوانين الدولة ذاتها للتعرف على كيفية تطبيق قواعد الجنسية من حيث الزمان^(٢).

ولما كانت قواعد الجنسية تعنى بصفة أساسية بدراسة كيفية اكتساب الجنسية والآثار المترتبة عليه، ودراسة كيفية فقد الجنسية والآثار المترتبة عليه، ولما كنا نتحدث عن انعدام الجنسية أي أننا نتحدث عن شخص فاقد الجنسية، فلا مجال لتأثير انعدام الجنسية على فقد الجنسية — وخاصة أن فقد قد يكون سبباً لانعدام الجنسية وليس العكس — وإنما سيقصر الحديث على دراسة أثر انعدام الجنسية على قواعد اكتساب الجنسية.

ولما كان الشخص قد يكتسب الجنسية في تاريخ معاصر للميلاد وتسمى الجنسية الأصلية^(٣)، وقد يكتسبها في تاريخ لاحق على الميلاد وتسمى الجنسية الطارئة، وكانت الجنسية الأصلية قد تبنى على حق الدم، وقد تبنى على حق الإقليم، وكانت الجنسية الطارئة قد تبنى على التجنس، أو الزواج المختلط، أو خيار الاسترداد، أو تغيير السيادة الإقليمية^(٤)، فإننا سندرس أثر انعدام الجنسية على تطبيق قواعد اكتساب الجنسية الأصلية، ثم نردفه ببيان أثر انعدام الجنسية على تطبيق قواعد اكتساب الجنسية الطارئة، على النحو التالي:-

(١) من الدول العربية التي اعتمدت وضع القواعد الخاصة بالجنسية في إطار دستوري دولة قطر. راجع في ذلك: د. حسن بن عبد الرحيم السيد: الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ٣، السنة ٣٢، سبتمبر ٢٠٠٨، ص ٣٣٧ وما بعدها.

(٢) د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، أحكام الجنسية المصرية، ص ٣٩.

(٣) ظلت الدول لفترة طويلة تعتبر الجنسية رابطة أبدية بين الفرد والدولة التي ولد متمتعاً بجنسيتها بحيث لا يمكنه التحلل منها، وقد عرف هذا المبدأ بمبدأ الولاء الدائم أو مبدأ عدم تغيير الولاء.

- VANEL: La notion de nationalité, Evolution historique en droit interne et comparé, Rev. crit. 1951, p.25.

- TERRE (F.): Reflexions sur la notion de nationalité, Rev. crit, 1975, p. 204. et s.

وقد تغير هذا المبدأ في الوقت الراهن وأصبح من حق الفرد تغيير جنسيته واكتساب جنسية جديدة.

(٤) بالتفصيل في التمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة. راجع د. عكاشة محمد عبد العال: المرجع السابق، أحكام الجنسية المصرية، ص ٦٠ وما بعدها.

المبحث الأول

أثر انعدام الجنسية

على تطبيق قواعد اكتساب الجنسية الأصلية

تؤسس الجنسية الأصلية كما سبق بيانه على أساسين رئيسيين هما حق الدم وحق الإقليم.

المطلب الأول

حق الدم

حق الدم هو حق المولود في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي إليها أبواه بغض النظر عن مكان ولادته^(١)، وفي هذا الصدد يجب البحث عن أي من الأبوين يعتد بجنسيته في هذه الحالة؟ وتظهر قيمة هذا التساؤل في الحالة التي تختلف فيها جنسية الأب عن جنسية الأم، وتزداد هذه القيمة في الحالة التي يكون فيها أحد الأبوين عديم الجنسية.

فقد أخذت بعض التشريعات بمبدأ المساواة الكاملة بين الأب والأم في منح الجنسية، ومثالها التشريع الفرنسي الذي يمنح الجنسية الفرنسية للطفل متى كان أحد الأبوين فرنسياً لا فرق في ذلك بين الأم والأب، ومما لاشك فيه أنه في إطار هذا القانون لن تكون هناك مشكلة إذا كان أحد الأبوين عديم الجنسية وكان الطرف الآخر متمتع بالجنسية الفرنسية لأن الطفل سوف يكتسب الجنسية الفرنسية في هذه الحالة، أما لو كان الأبوان كلاهما عديم الجنسية فسيولد هذا الطفل على الإقليم الفرنسي وهو عديم الجنسية.

ويسير في نفس اتجاه المشرع الفرنسي كل من المشرع الألماني في المادة الرابعة — الفقرة الأولى من قانون سنة ١٩٧٩^(٢)، وكذلك قانون الجنسية الإيطالي الجديد الصادر في ١٩٨٣ في المادة

(١) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، الجنسية المصرية، ص ٣٩ وما بعدها.

المادة ١٧ من تشريع الجنسية الفرنسية، راجع في التفاصيل:

- BATIFFOL Henri et LAGARDE Paul: Droit international privé, 7^{eme} éd, Tome. I. L.G.D.J. Paris, 1981. n95.

- LAGARDE Paul: La nationalité française, deuxième édition, Dalloz, Paris, 1989.

(٢) تم تعديل قانون الجنسية الألماني ليصبح بهذا الشكل بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا في ٢١ مايو ١٩٧٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الجنسية والذي يكسب المولود لأب ألماني وأم أجنبية الجنسية الألمانية، بينما لا يكسب المولود لأب أجنبي وأم ألمانية هذه الجنسية إلا لو كان الأب معدوم الجنسية.

الخامسة منه^(١)، وتشريع الجنسية في تونس والصادر في ١٩٦٣ وذلك في الفصل ١٢ منه^(٢)، والتشريع التركي الصادر عام ١٩٨١^(٣).

وأخذت تشريعات أخرى بجنسية الأم كضابط لمنح الجنسية الأصلية دون النظر لجنسية الأب أو مكان الميلاد^(٤)، ولذلك إذا كان الأب عديم الجنسية فلن يؤثر ذلك في قدرة الطفل على اكتساب جنسية الأم^(٥)، أما إذا كانت الأم عديمة الجنسية فلن يستطيع ذلك الطفل التمتع بأية جنسية على الإطلاق، وسيصبح عديم الجنسية في هذه الحالة، على الرغم من أن أبيه متمتع بجنسية إحدى الدول.

ويذهب فريق ثالث من التشريعات التي تبني حق الدم من جهة الأب كأساس لمنح الجنسية الأصلية، مع الاعتداد بحق الأم بصفة ثانوية، تجنباً لحدوث ظاهرة انعدام الجنسية^(٦)، وهو ما كان يأخذ به المشرع المصري قبل ١٤ يوليو ٢٠٠٤^(٧)، حيث كان يأخذ بحق الدم من جهة الأب كضابط أساسي،

(١) تنص تلك المادة على أنه " يعتبر مواطناً إيطالياً الطفل القاصر - حتى لو كان ابناً بالتبني، المولود لأب أو لأم إيطالية".

(٢) والذي تم تعديله في عام ١٩٧٥ ليضيف فقرة جديدة إلى المادة السادسة منه وهي الفقرة الثالثة والتي تقرر أنه " يعتبر تونسياً الطفل المولود لأم تونسية وأب أجنبي".

(٣) د. حفيظة السيد الحداد: المرجع السابق، مدخل إلى الجنسية ومركز الأجانب، ص ١١٦ وما بعدها.

(٤) راجع أحكام القانون التركي قبل تعديله، مشار إليها في مؤلف د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، الجنسية ومركز الأجانب، ص ٩٠.

(٥) تسير في هذا الاتجاه الكثير من التشريعات الوطنية ومنها تشريع الجنسية الجزائري الصادر في سنة ١٩٧٠ والذي تقضى مادته السادسة بثبوت الجنسية الجزائرية فور الميلاد لكل من ١- الولد المولود الجزائرية من أم جزائرية وأب مجهول. ٢- الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية ولا يشترط لثبوت الجنسية الجزائرية في هذه الحالة وقوع الميلاد بإقليم الدولة.

(٦) د. أبو العلا النمر: المرجع السابق، النظام القانوني للجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، ص ٧٣.

(٧) تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ والمعدل للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وفي الانتقادات الموجهة للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، راجع د. جمال محمود الكردي: التعديلات الجديدة على قانون الجنسية المصرية في الميزان، ٢٠٠٤، دار النهضة العربية.

ويسير في هذا الاتجاه تشريع الجنسية المغربي في شق منه حيث تقضى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه بثبوت الجنسية للمولود لأم مغربية وأب مجهول أي كان مكان ميلاده، وكذلك تشريع الجنسية الكويتي الصادر سنة ١٩٥٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه والتي تنص على أنه " يكون كويتي من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً".

وكذلك تشريع الجنسية الأردني الصادر في ١٩٥٤ والمعدل بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٧ حيث يقرر أنه يتمتع بالجنسية الأردنية من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً وذلك في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة منه، وكذلك تشريع الجنسية العراقي الصادر في ١٩٦٤ والذي يقرر أنه يعتبر عراقياً كل من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول لا جنسية له.

وفي حالة انعدام جنسية الأب أو عدم ثبوت النسب قانوناً كان يأخذ بحق الدم من جهة الأم، وبذلك إذا كانت الأم هي الأخرى عديمة الجنسية لأصبح هذا الطفل عديم الجنسية، ولكن المشرع المصري - تلافياً لانعدام الجنسية - قرر منح الطفل في هذه الحالة الجنسية الأصلية بناء على حق الإقليم.

المطلب الثاني

حق الإقليم

يمكن للفرد أن يكتسب جنسية الدولة التي ولد فيها بمجرد ميلاده، وهو ما تأخذ به بعض الدول، ولكن بشرط توافر عناصر إضافية تعزز حق الإقليم^(١)، مثل بقاء أسرة المولود في الدولة التي ولد فيها^(٢)، أو أن يكون الأب هو الآخر قد ولد في إقليم الدولة التي ولد فيها الطفل، وهو ما يعرف بالميلاد المضاعف^(٣)، أو أن يقيم الطفل في إقليم الدولة فترة معينة قبل اكتسابه جنسيتها أو عند بلوغه سن الرشد^(٤).

وتملك الدولة كامل الحرية في تقرير القواعد التي تستطيع من خلالها منح جنسيتها للأطفال المولودين على إقليمها، مع مراعاة قواعد العرف الدولي في هذا الإطار، مع التزامها طبقاً لهذا العرف بمنح جنسيتها لكل من يولد على إقليمها من أبوين مجهولين، وذلك تلافياً لحدوث ظاهرة انعدام الجنسية^(٥).

(١) د. أبو العلا النمر: المرجع السابق، النظام القانوني للجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، ص ٧٩.

(٢) د. عز الدين عبدالله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب)، الطبعة الحادية عشرة، ١٩٨٦، ص ١٣٨.

(٣) المادة ٢٣ الفقرة الثانية من تفتين الجنسية الفرنسية الصادر في ١٩٤٥ والتي تنص على أن "يكون فرنسياً الولد الشرعي الشرعي المولود في فرنسا لأب أجنبي ولد فيها". راجع في ذلك:

- BATIFFOL Henri et LAGARDE Paul: op.cit., n97.

وبالتفصيل راجع: د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، الجنسية المصرية، ص ٤١.

(٤) وقد يكون ذلك سبباً في اختلاط الجنسية الأصلية بالجنسية الطارئة. راجع د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، الجنسية ومركز الأجانب، ص ٨١.

(٥) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: الحق في الجنسية وأساسه في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الثالث الثالث والأربعون، ١٩٨٧، السنة الثالثة والأربعون، ص ١ وما بعدها، وعلى وجه التحديد ص ٥.

ولذلك إذا كان الأب والأم كلاهما عديم الجنسية فإن الطفل يستطيع اكتساب جنسية الدولة التي ولد على إقليمها، مع وجود احتمالية رفض الدولة منح جنسيتها لهذا الشخص، لأنه لا يوجد قانون ما يلزمها بذلك، وخاصة مع وجود مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها^(١).

^(١) حيث تعتبر كثير من التشريعات كل من ولد بإقليم الدولة من أبوين مجهولين وطنياً، ومنها الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المصري، وكذلك الفقرة الخامسة المادة الثالثة من التشريع الأردني، والفقرة ح من المادة الثالثة من تشريع الجنسية السوري الصادر في ١٩٦٩، والمادة ٦ من تشريع الجنسية الجزائري، المادة ٧ من تشريع الجنسية المغربي، والمادة ١٩ من تشريع الجنسية التونسي.

المبحث الثاني

أثر انعدام الجنسية على تطبيق

قواعد اكتساب الجنسية الطارئة أو اللاحقة

= = =

الجنسية الطارئة أو اللاحقة هي الجنسية التي يكتسبها الشخص في تاريخ لاحق على الميلاد حتى ولو كان الميلاد عنصراً من عناصر اكتسابها^(١)، وتشتط الجنسية المكتسبة ضرورة توافر قدر من الروابط الكافية بين الفرد والدولة، بحيث يتمكن هذا الفرد من الاندماج في مجتمع الدولة، لذلك نجد أن أغلب الوسائل التي تضعها الدول لاكتساب الجنسية الطارئة تهدف إلى الاستيثاق من وجود مثل هذه الروابط^(٢).

ومما لا شك فيه أن اتساع حركة التجارة والخدمات وتطور الحياة الخاصة الدولية، ونمو العلاقات والروابط بين مواطني الدول المختلفة، أدى إلى ازدياد حركة الهجرة والتنقل من دولة لأخرى، مع الرغبة في تغيير الجنسية الأصلية واكتساب جنسية طارئة أو لاحقة عن طريق التجنس.

أضف إلى ذلك انتشار حركة الزواج بين أشخاص يتمتعون بجنسيات مختلفة، وهو ما يقتضى منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها الوطني والعكس صحيح، كما أن تغيير السيادة الإقليمية على إقليم معين قد يكون أحد العوامل في اكتساب الجنسية الطارئة، من خلال اكتساب سكان الإقليم المضموم لجنسية الدولة الضامة أو بإصرارهم على التمسك بجنسيتهم الأصلية.

كما أن كثير من التشريعات قد أعطت الفرد دوراً في اكتساب الجنسية، مما أدى إلى منح هؤلاء الأفراد الحق في اختيار جنسيتهم الأولى، أو استردادها إذا ما فقدوها ورغبوا في العودة إلى التمتع بها^(٣).

ومن ذلك تكون وسيلة اكتساب الجنسية الطارئة هي التجنس، أو الزواج المختلط، أو تغيير السيادة الإقليمية، أو خيار الاسترداد، وهو ما يجعلنا نعرض لدور انعدام الجنسية على تطبيق القواعد المتعلقة بكل وسيلة من هذه الوسائل على النحو التالي:-

(١) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، الجنسية المصرية، ص ٤٥.

(٢) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، ١٩٩٣، ص ٨٧، ٨٨.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، ص ١١١، ١١٢.

المطلب الأول

أثر انعدام الجنسية على تطبيق قواعد التجنس

يستطيع الفرد من خلال اندماجه في شعب دولة أخرى أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية هذه الدولة، إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لاكتساب هذه الجنسية^(١)، لذلك فإن التجنس هو " كسب الجنسية كسباً لاحقاً للميلاد بناء على الطلب المقترن بتوافر شروط أخرى يحددها قانون الدولة، والذي تملك الدولة إزائه حرية التقدير"^(٢). وبذلك فإن إرادة الفرد ليست كافية بذاتها لاكتساب الجنسية، حتى ولو توافرت فيه كافة الشروط الأخرى المطلوبة للتجنس، وإنما لابد من موافقة الدولة، وهو ما قرره القضاء المصري حيث ذهب إلى أنه " لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض منح الجنسية للأجنبي الذي طلبها لمجرد الاحتجاج باستيفاء هذا الشخص لكافة الشروط المتطلبة قانوناً"^(٣).

وتختلف الدول فيما بينها في قدر الشروط المتطلبة لاكتساب جنسيتها عن طريق التجنس، ابتداء من شرط التوطن في إقليم الدولة لفترة معينة تختلف من دولة لأخرى بحسب مدى تشدد الدولة أو تساهلها في منح الجنسية^(٤)، إضافة إلى شروط تتعلق بالأهلية، والاندماج في الجماعة الوطنية، كما أن الدولة قد تشترط في الشخص مجموعة من الشروط السلوكية كأن لا يكون من المجرمين الخطرين أو ذوى العاهات، وانتهاء باشتراط أن يتنازل الشخص عن جنسيته الأصلية أو يفقدها^(٥).

والذي يهمنا في هذا الإطار الحديث عن أثر انعدام الجنسية على قدرة الشخص على اكتساب الجنسية عن طريق التجنس، ولكن يجب أن نشير بداية إلى ما نصت عليه اتفاقية جنيف للاجئين المبرمة في ٢٨ يوليو ١٩٥١ من ضرورة قيام الدول بوضع التسهيلات التي تمكن اللاجئين من التجنس

(١) وهو ما قرره المادة ٩ من تشريع الجنسية الأرجنتيني الصادر سنة ١٩٥٤، حيث قررت أن "الأجنبي الذي يكون قد أقام في الأرجنتين خمس سنوات بصفة مستمرة ولا يتوافر في شأنه مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة الحادية عشر يكتسب الجنسية الأرجنتينية بالتجنس تلقائياً" راجع في ذلك.. د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، القانون الدولي الخاص، ص ٨٩.

(٢) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص (الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع)، الطبعة الثانية، ١٩٩٢، مؤسسة الثقافة الجامعية، ص ٨٩.

(٣) حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٦ يونيو ١٩٥٢، مجموعة أحكام المحكمة، السنة السادسة، ص ١١٨٩.

حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١٢ أبريل ١٩٦٩، مجموعة أحكامها، السنة الرابعة عشر، ص ٥٩١.

(٤) يشترط المشرع المصري أن تكون تلك المدة إما خمس سنوات أو عشر سنوات، بالإضافة لشروط خاصة بكل مدة منها، ويشترط المشرع الفرنسي أن تكون هذه المدة خمس سنوات، ويشترط المشرع الكويتي أن تكون هذه المدة خمس عشر سنة، ويشترط المشرع الأيرني أن تكون هذه المدة سنتان.

(٥) د. محمد كمال فهمي: المرجع السابق، أصول القانون الدولي الخاص، ص ٩٠، ٩١.

جنسية الدولة التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى سرعة الإجراءات المطلوبة لذلك، وكذلك تخفيض الرسوم التي تفرض على الفرد في هذه الحالة^(١).

وأيضاً ما قرره اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بانعدام الجنسية، والمبرمة في نيويورك بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٥٤ من إقرار نفس القواعد^(٢).

وكذلك أصدر معهد القانون الدولي قراراً سنة ١٨٩٦ نص في المادة الخامسة منه على أن " الشخص لا يمكنه الحصول على جنسية دولة ما بطريق التجنس إلا إذا أقام الدليل على تجرده من جنسية دولته الأصلية، وكان قد أوفي بالتزام أداء الخدمة العسكرية وفقاً لقوانين هذه الدولة"^(٣).

أضف إلى ذلك ما تتطلبه بعض التشريعات من ضرورة تجرد الفرد من جنسية الدولة التي كان يتمتع بها قبل رغبته في اكتساب الجنسية الجديدة، مثل التشريع الألماني والتشريع الأسباني والتشريع الياباني^(٤).

ومما سبق يتضح لنا أن انعدام الجنسية قد يكون عاملاً من أهم العوامل التي تساعد الشخص على اكتساب جنسية جديدة عن طريق التجنس، لأنه إذا اشترطت الدول على الشخص التجرد من جنسيته أو فقدها قبل منحها له لجنسيتها، فالأولى هو منحها لعديم الجنسية، وإذا ما قررت الكثير من الاتفاقيات الدولية ضرورة التيسير على اللاجئين وعديمي الجنسية بصدد اكتساب الجنسية عن طريق التجنس فهذا بالطبع يمثل الدليل على المزايا التي يمنحها انعدام الجنسية لصاحبه بصدد اكتساب جنسية جديدة عن طريق التجنس.

(١) تنص المادة ٣٤ من تلك الاتفاقية على أن " تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن".

(٢) تنص المادة ٣٢ من تلك الاتفاقية على أنه " تسهل الدولة المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن". منشور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السابق الإشارة إليه، ص ٨٧.

(٣) انظر في هذا المعنى:

- HOTTELIER Michel: Le nouveau droit de la nationalité Suisse, Rev. int. dr. comp, 1971, n° 3, p.579.

(٤) د. أشرف وفا محمد: المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن والقانون المصري، ٢٠٠٢، دار النهضة العربية، ص ٧٩، ٨٠.

المطلب الثاني

أثر انعدام الجنسية على تطبيق قواعد الزواج المختلط

الزواج المختلط هو الزواج الذي ينعقد بين طرفين من جنسيتين مختلفتين، وهذا الاختلاف في الجنسية قد يكون معاصراً للزواج، وقد يحدث في تاريخ لاحق عليه، ويترتب على هذا الزواج بالتأكيد أثر على جنسية كل من الزوجين، فهو وسيلة لكسب هذه الجنسية، وفي المقابل قد يكون سبباً لفقدانها^(١).

وتنظيم مسألة أثر الزواج المختلط على الجنسية داخل الأسرة يتنازع اتجاهان أحدهما يذهب إلى وحدة الجنسية في العائلة^(٢)، والآخر يذهب إلى تعدد الجنسية في العائلة^(٣)، ويتوسط بين هذين الاتجاهين بعض التشريعات التي تبنت موقفاً وسطاً^(٤).

فمبدأ وحدة الجنسية في العائلة يقضى بفرض جنسية الزوج على زوجته بحكم القانون بمجرد انعقاد الزواج، وتظل محتفظة بتلك الجنسية طوال قيام رابطة الزوجية، وقد اعتنقته كثير من التشريعات مثل التشريع الإيطالي الصادر سنة ١٩١٢ في المادة العاشرة منه، والتشريع اللبناني الصادر سنة ١٩٢٥ في المادة الخامسة منه، والتشريع الأردني الصادر سنة ١٩٢٨ في المادة العاشرة منه، وكذلك المادة ٢٢ من القانون المدني الأسباني الصادر عام ١٩٣١، والمادة ٣ من تشريع الجنسية الفنلندي

(١) يعد الحصول على تصريح الإقامة أو حتى الحصول على الجنسية الفرنسية من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزواج المختلط بين فرنسية وأجنبي.

- GUIMEZANES Nicole: La situation en France des étrangers non communautaires à l'aube de l'année 1993, clunet, 1993, n.1. p.5. et s.spéc.p.36.

(٢) راجع في مبدأ وحدة الجنسية في العائلة د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، الجنسية ومركز الأجانب، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ١٩٨٤، ص ٧٣، ٧٤.

- CHAMPCOMMUNAL: Le ménage à nationalité différentes, clunet, 1929, p.1. et s.

(٣) في مبدأ تعدد الجنسية في العائلة راجع د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، الجنسية ومركز الأجانب، ص ١١٥.

- HEGI: La nationalité de la femme mariée, p.14. et s.

(٤) د. هشام علي صادق: المرجع السابق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، ص ١٣٧.

وراجع في ذلك:

- WALTZ Wald Emerson: The nationality of married women, published by the university of Illinois Aturbana, 1937, p.59, and s.

الصادر عام ١٩٤١، والمادة ٢١ من القانون المدني اليوناني الصادر عام ١٨٥٦ والمعدل عام ١٩٢٧^(١)، وتشريع الجنسية المصرية الصادر سنة ١٩٢٩^(٢).

أما مبدأ استقلالية الجنسية في العائلة فيقوم على استقلال كل من الزوج والزوجة بجنسيته داخل العائلة، ومن التشريعات التي أخذت بهذا المبدأ تشريع جنسية اليابان الصادر سنة ١٩٥٠، وتشريع الجنسية اليوغسلافية السابق الصادر سنة ١٩٤٥، وتشريع جنسية الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام ١٩٥٢^(٣).

وتذهب بعض التشريعات ومنها قانون الجنسية المصري رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، إلى تبني مذهباً وسطاً يقضى بدخول الزوجة في جنسية زوجها ولكن بشرط إبداء رغبتها في ذلك مع ضرورة توافر بعض الشروط الأخرى^(٤).

ومما سبق يتضح أنه على الرغم من ظهور الاتجاه الحديث الذي تنادى به المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية والذي يتجه إلى الاعتداد بإرادة المرأة وذلك بعدم فرض جنسية زوجها عليها، إلا أن توجد الكثير من التشريعات التي تشجع انضمام الزوجة الأجنبية إلى جنسية زوجها، لأن ذلك يحقق نوعاً من التآلف الروحي والفكري داخل الأسرة، ويعمل على تحقيق وحدتها وتماسكها، ويمتنع معه حدوث كثير من المشكلات السياسية والقانونية التي تنتج عن الأخذ بمبدأ استقلال الجنسية في العائلة^(٥).

وإذا كنا نبحث عن أثر انعدام الجنسية على إعمال قواعد الزواج المختلط كسبب لاكتساب الجنسية الطارئة، فإنه إذا كانت الزوجة عديمة الجنسية فإنه طبقاً لمبدأ وحدة الجنسية سوف تكتسب هذه الزوجة جنسية الزوج، إما طبقاً لمبدأ تعدد الجنسية في العائلة فإن الزوجة لن تكتسب جنسية الزوج، أما إذا كان تشريع جنسية الزوج يسلك مسلكاً وسطاً، فإن الأمر متوقف على إرادة الزوجة، فإذا عبرت عن رغبتها في اكتساب الجنسية، فسوف تكتسب هذه الجنسية بالفعل، أما إذا لم تعبر عن تلك الرغبة فلن تكتسب الجنسية في هذه الحالة.

(١) تنص تلك المادة على أن " المرأة الأجنبية التي تتزوج يوناني تكتسب الجنسية اليونانية بمقتضى الزواج".

(٢) راجع في تلك التشريعات د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، ص ١٤٧.

(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، ص ١٤٩، ١٥٠.

(٤) في ذلك تنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه " لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".

(٥) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، ص ٧٩.

أما إذا كان الزوج أيضاً عديم الجنسية فإن الزوجة عديمة الجنسية لن تستطيع اكتساب الجنسية الوطنية استناداً لواقعة الزواج المختلط حتى وأن عبرت عن رغبتها في اكتساب الجنسية في هذه الحالة لأن الزوج الوطني هو الأساس في منح الجنسية في هذه الحالة، ولكن يمكن لهذه الزوجة أن تكتسب الجنسية عن طريق التجنس.

أما إذا كان الزوج هو الطرف عديم الجنسية، وكانت الزوجة تتمتع بجنسية إحدى الدول، فإن اكتساب الزوج لجنسية زوجته متوقف على موقف قانون جنسية هذه الزوجة، وهل يترتب على زواج الأجنبي من وطنية من أثر أم لا؟ فإذا كان يترتب هذا الأثر فإن الزوج عديم الجنسية يمكنه اكتساب جنسية الزوجة في هذه الحالة إذا توافرت الشروط الأخرى التي يتطلبها هذا القانون، أما إذا كان قانون جنسية الزوجة لا يترتب على الزواج من وطنية من أثر على جنسية الزوج، فإن الزوج عديم الجنسية لن يمكنه اكتساب جنسية الزوجة في هذه الحالة.

فعلى سبيل المثال تذهب تشريعات بعض الدول العربية إلى عدم ترتيب أى أثر للزواج من وطنية على جنسية الزوج الأجنبي ومنه عديم الجنسية، ويمكن للزوج اكتساب تلك الجنسية عن طريق التجنس العادي مع عدم وجود أى تخفيف في الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية كأثر للزواج المختلط^(١)، بينما تذهب تشريعات أخرى إلى إعطاء الزوج الأجنبي الحق في الدخول في جنسية دولة الزوجة، بمجرد الطلب المعلق على السلطة التقديرية للدولة، كما هو الشأن في التشريع الإيرلندي، وتذهب تشريعات أخرى إلى إعطاء الزوج الحق في اكتساب جنسية زوجته بمجرد الزواج وإبداء الرغبة في ذلك متى توافرت الشروط المطلوبة للتجنس مع عدم إعطاء الدولة أى سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهو ما نص عليه دستور السلفادور الصادر سنة ١٩٥٠^(٢).

(١) د. فؤاد عبدالمنعم رياض: المرجع السابق، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، ص ٨٠.

(٢) د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، ص ١٥٥.

المطلب الثالث

أثر انعدام الجنسية على تطبيق

قواعد تغيير السيادة الإقليمية كسبب لاكتساب الجنسية

— — —

تغيير السيادة الإقليمية هو حلول دولة محل أخرى فيما يتعلق بالمسؤولية عن العلاقات الدولية بالنسبة لإقليم من الأقاليم^(١)، وبذلك فإن تغيير السيادة الإقليمية هو انتقال السيادة على إقليم ما من دولة إلى دولة أخرى، وهو يتطلب وجود دولتين يتم انتقال السيادة على إقليم ما من إحدهما إلى الأخرى، ولذلك فهو حق قاصر على الدول دون غيرها من أشخاص القانون الدولي^(٢).

وهناك من يضيق في تعريف تغيير السيادة الإقليمية ويقرر أن التوارث بين الدول يقتصر على الحقوق والالتزامات التي تتعلق بالدولة والناجمة من القانون الدولي^(٣)، وذلك على عكس التعريف الموسع والذي لا يعني فقط حلول شخص من أشخاص القانون الدولي محل آخر في السيادة على إقليم ما وإنما يعني كذلك انتقال فعلى للحقوق والالتزامات بينهما^(٤).

(١) ذلك ما قرره معاهدة فيينا لسنة ١٩٧٨ وكذلك معاهدة فيينا لسنة ١٩٨٣ حيث تقرر أن التوارث هو:

- La substitution d'un Etat á un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire.
وهو ما تبنته أيضاً المادة الثانية من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول.
وراجع في فكرة تغيير السيادة الإقليمية:

- EBENROTH (Corsten Thomas): Succession d'Etats et droit international privé, clunet, 1996, p. 28 et s.

(٢) راجع في ذلك:

- PARLAVANTZAS (Petros B.) : L'application de la succession d'Etats á l'établissement, la modification et la dissolution des liens fédératifs, Revue Hellénique de droit international, 1963, p.58.

(٣) راجع في ذلك:

- BARDONNET Daniel: La succession d'Etats á Madagascar, L.G.D.J. Paris, 1970, p.7. et s.

(٤) راجع في ذلك:

- PEREIRA (André Gonçalves): Le succession d'Etats en matière de traite, Editions A. pédone, Paris, 1969, p.4.

ويذهب بعض الفقه المصري^(١) إلى أنه يوجد مفهوم واحد للتوارث بين الدول يتمثل في انتقال السيادة على الإقليم من دولة إلى أخرى، أما فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المصاحبة للخلافة بين الدول فإنها تعد من قبيل الآثار التي تترتب على التوارث بين الدول.

وبذلك وحتى توجد فكرة تغيير السيادة الإقليمية لابد من وجود دولة تسمى الدولة السلف وهي التي حلت محلها دولة أخرى عند حدوث خلافة الدول^(٢)، وكذلك وجود دولة تسمى الدولة الخلف وهي التي حلت محل دولة أخرى عند حدوث خلافة بين الدول^(٣).

وتتنوع أشكال التوارث بين الدول إلى عدة أنواع هي^(٤):

- ١- انتقال جزء من أراضي الدولة السلف إلى الدولة الخلف، ويطلق على هذه الحالة التنازل أو الضم .
- ٢- توحيد دولتين أو عدة دول سلف في دولة واحدة هي الدولة الخلف ويطلق على هذه الحالة الاتحاد^(٥).
- ٣- تفكك الدولة السلف وانحلالها بحيث لا يبقى لها وجود فعلي وتحل محلها دولتان أو عدة دول خلف، ويطلق على هذه الحالة الإنحلال.

(١) د. أشرف وفا محمد: آثار التوارث بين الدول على إعمال قواعد القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥، دار النهضة العربية، ص٤٤.

(٢) استعملت المادة ١٢ الفقرة ب من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول هذا التعبير عندما قررت أن:

- " L'expression Etat prédécesseur s'entend de l'Etat auquel un autre Etat s'est substituée à l'occasion d'une succession d'Etats".

(٣) استعملت المادة ٢ الفقرة ج من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول هذا التعبير عندما قررت أن:

- L'expression Etat successeur s'entend de l'Etat qui s'est substituée à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats.

(٤) في مختلف صور نقل السيادة راجع:

- WEIS (P.): Nationality and statelessness in international law, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p.135.

(٥) د. هشام على صادق: آثار الاستخلاف الدولي في ضوء الوحدة المصرية الليبية سنة ١٩٧١، الإسكندرية، فقرة رقم ٥١، حيث يعرض سيادته لبعض المشاكل المتصورة في حالة الاستخلاف الشامل المترتب على اندماج دولتين في دولة واحدة.

٤- انفصال بعض الأجزاء من إقليم الدولة السلف وتكوين دولة خلف بهذا الجزء وتسمى تلك الحالة بالانفصال^(١).

وقد اهتمت كثير من المنظمات الدولية بمعالجة موضوع التوارث وأثره على الجنسية، فأصدرت الجماعة الأوروبية إعلان اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون سنة ١٩٩٦، والمعروف بإعلان فينسيا، وكذلك معاهدة الجنسية الأوروبية المبرمة في ٦ نوفمبر ١٩٩٧، والتي تحتوى بعض النصوص المتعلقة بخلافة الدول وجنسية الأشخاص الطبيعيين.

كذلك أصدرت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة التوارث بين الدول على الجنسية مشروع بعض المواد المتعلقة بالجنسية في حالة خلافة الدول، وذلك في اجتماعها المنعقد في يولييه ١٩٩٩، كما قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول.

ومما لاشك فيه أن انعدام الجنسية لا يخلو من أثر على تطبيق قواعد التوارث بين الدول، حيث إن الدولة صاحبة السيادة الجديدة على الإقليم وهي الدولة الخلف لها أن تفرض جنسيتها على الأشخاص المقيمين في هذا الإقليم والذين كانوا قبل تغيير السيادة تابعين لجنسية الدولة السلف، وتستند الدولة الخلف في ذلك على حق السيادة التي تتمتع به الدولة على إقليمها، وبذلك يكون اكتساب الأشخاص المقيمين في الدولة السلف جنسية الدولة الخلف أمراً طبيعياً، باعتبارهم جزء من شعبها ابتداءً من لحظة انتقال السيادة على الإقليم إليها^(٢)، كما أنه أحد مظاهر مبدأ حرية الدولة في مجال الجنسية، والذي قرره المادة الأولى من معاهدة لاهاي المبرمة سنة ١٩٣٠ والمنظمة لمسائل تنازع القوانين في مجال الجنسية^(٣).

إلا أن مبدأ حق الدولة في فرض جنسيتها على الأشخاص المتواجدين في إقليم الدولة السلف تعرض للتغيير، حيث إنه لا بد من وجود نوع من التوازن بين حق الدول النابع من سيادتها على إقليمها وبين حق الفرد في التمتع بجنسية ما، هذا التوازن يحدث في حالة قيام الدولة الخلف بمنح جنسيتها

(١) راجع في ذلك د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، آثار التوارث بين الدول، ص ٧، ٨.

(٢) ورد في تقرير لجنة فينسيا أن:

- Toute succession d'Etat implique une mutation territoriale que affecte nécessairement la nationalité des personnes, lesquelles avec le territoire passent d'une souveraineté à une autre.

(٣) تنص تلك المادة على أنه:

- Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quelles sont ses nationaux.

لرعايا الدولة السلف، في نفس الوقت الذي تتولد فيه الرغبة لدى هؤلاء الأفراد في اكتساب تلك الجنسية^(١).

هذا التوازن قد يفتقد في حالة الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك مراعاة للقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي من أهمها الحرص على تمتع كل شخص بجنسية معينة^(٢)، وهي جنسية الدولة التي يرتبط بها هذا الشخص من الناحية الفعلية

والواقعية^(٣)، أو ما يعرف بفكرة الجنسية الفعلية^(٤).

وبذلك يتحول حق الدولة في منح جنسيتها لمن تريد إلى التزام يقع على عاتقها بمنح تلك الجنسية إلى الأفراد عديمي الجنسية، لأن ذلك يحقق مبدأ حق الفرد في التمتع بالجنسية.

هؤلاء الأشخاص عديمو الجنسية يكون من حقهم التعبير عن رغبتهم في اكتساب جنسية الدولة الخلف، طالما كانوا مقيمين في الإقليم الذي انتقلت السيادة بشأنه إلى تلك الدولة، لأن عنصر الإقامة عنصر أساسي لمنح الجنسية في هذه الحالة، بل إن من حق الدولة الخلف أن تفرض جنسيتها على كل الأفراد المقيمين في إقليم الدولة السلف وخاصة إذا كانوا عديمي الجنسية^(٥).

(١) راجع في ذلك د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، آثار التوارث بين الدول على إعمال قواعد القانون الدولي الخاص، ص ١٧، ١٨.

(٢) راجع في ذلك:

- BIELIUNAS Egidijus: Approche des nouveaux Etats concernant la succession d'Etats et l'adhésion aux traités universels et aux obligations en matière de droit de l'homme: questions de nationalité, in: Nationalité et succession d'Etats, Actes du séminaire organisé à Vilnius (Lituanie), les 16 et 17 mai 1997 par la commission européenne pour la démocratie par le droit, Editions du conseil de l'Europe, 1998, p.113.

(٣) راجع في ذلك:

- Scharer Roland: Droit international et nationalité dans le contexte de la succession d'Etat, in: Nationalité et succession d'Etat, Actes du séminaire organisé à vilnius (Lituanie) les 16 et 17 mai 1997 par la commission européenne pour la démocratie par le droit, Editions du conseil de l'Europe, 1998, p.102.

(٤) راجع في فكرة الجنسية الفعلية د. أحمد عبدالكريم سلامة: المرجع السابق، المبسوط في شرح نظام الجنسية، ص ١٢٠ وما بعدها؛ د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن والقانون المصري، ص ٣٨ وما بعدها.

(٥) د. أشرف وفا محمد: المرجع السابق، آثار التوارث بين الدول على إعمال قواعد القانون الدولي الخاص، ص ٥٢.

وفي إطار العلاقات الدولية فقد استقرت قاعدة حق الخيار المقرر لسكان إقليم الدولة السلف، وذلك بحقهم في الاختيار بين جنسية الدولة الخلف والدولة السلف^(١)، ومما لاشك فيه أن معيار الإقامة يعتبر معياراً حاسماً في هذا المجال، حيث يملك الأشخاص المقيمون في إقليم الدولة السلف حق الخيار بشأن جنسيتهم، وذلك على أساس أن المواطن هو وحده الذي يقطع بتوافر الشعور بالولاء والانتماء من جانب الفرد تجاه الدولة^(٢).

وهو ما قرره المادة الخامسة من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، حيث قررت أنه " مع مراعاة أحكام هذا الإعلان يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذي يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة".

المطلب الرابع

أثر انعدام الجنسية على أعمال قواعد خيار الاسترداد

خيار الاسترداد هو عودة لاحقة إلى جنسية سابقة وعرف بأنه " رخصة خولها القانون للشخص الذي فقد جنسية الدولة يجوز له بمقتضاها أن يسترد جنسيته المفقودة"^(٣).

وبذلك فإنه يشترط في الشخص الذي يرغب في اكتساب جنسية الدولة أن يكون قد سبق له التمتع بها، ويتميز هذا الخيار بأنه يوفر نوعاً من التيسير أمام طالب الجنسية لسبق توافر صفة الوطنية فيه^(٤).

^(١) يذهب بعض الفقه إلى أنه يتعين الاعتراف بحق الخيار كقاعدة عامة في جميع حالات الخلافة بين الدول. راجع في ذلك:

- GIBRAN (Van Ert): Nationalité, state succession, and the right of option: the case of québec, canadian yearbook of international law, 1998, p.151. et s.

وتتطلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أن يمارس من له حق الخيار حقه بحرية تامة دون أن يخشى العقاب نتيجة هذه الممارسة في اختياره لجنسيته. راجع في ذلك:

- ECONOMIDES (Constantin P.) : Les effets de la succession d'Etats sur la nationalité des personnes physiques- Revue générale de droit international public, 1999, n.3, p.597.

^(٢) انظر في هذا المعنى:

- LAGARDE Paul: De quelques conséquences de la decolonisation sur le droit français de la nationalité, Mélanges savatier, Paris, Dalloz, 1965, p.530 et s.

^(٣) د. هشام على صادق: المرجع السابق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، ص ١٦١.

وتتعدد الصور التي قد يتخذها خيار الاسترداد فمنها الأولاد القصر الذين زالت عنهم جنسيتهم المفقودة عند بلوغهم سن الرشد، وكذلك المرأة التي تفقد جنسيتها نتيجة لزواجها من أجنبي ودخولها في جنسيته، أضف إلى ذلك الوطني الذي زالت عنه جنسيته الوطنية نتيجة لحصوله على جنسية أجنبية.

ومما لا شك فيه أن الشخص الذي يرغب في اكتساب جنسية دولة أجنبية تشتت شرط تنازله عن جنسيته الأصلية أولاً، سوف يقوم بالتنازل عن تلك الجنسية الأصلية بالفعل، وعندما يفشل في اكتساب جنسية الدولة الأجنبية يصبح عديم الجنسية، هذا الشخص سوف يصبح في حاجة إلى استرداد جنسيته الأصلية ليتجرد من حالة انعدام الجنسية التي هو فيها، ومما لا شك فيه أن إعمال قواعد خيار الاسترداد سوف يمكنه من العودة إلى هذه الجنسية، وبذلك فإن انعدام الجنسية سوف يكون مبرراً لاستخدام تلك القواعد، وخاصة أن الشخص المتمتع بجنسية دولة أجنبية يمكنه استرداد جنسيته الأصلية عن طريق نفس القواعد، فما بال عديم الجنسية وهو لا يتمتع بأية جنسية، من الأولى أن يتمكن عديم الجنسية من استخدام تلك القواعد.

ما سبق دعا بعض الدول مثل فرنسا إلى جعل خيار الاسترداد طريقاً عاماً للعودة إلى جنسية الدولة في جميع الفروض، باستثناء الحالات التي ينص فيها المشرع على عدم جواز الالتجاء إلى هذه الوسيلة من وسائل كسب الجنسية اللاحقة أو الطارئة، وذلك في الحالات التي ينعدم فيها السبب المبرر للاسترداد^(١).

ويذهب رأى فقهي إلى تطبيق قانون جنسية الدولة التي جرد منها الشخص بطريقة تعسفية، ومما لا شك فيه أن هذا الرأي ليس بعيداً عن النقد، فتحديد ما إذا كان تجريد هذا الشخص من جنسيته قد تم بطريقة تعسفية من عدمه يكون بالرجوع إلى قانون الجنسية المعنية، إضافة إلى أن هذا الرأي حتى مع فرض صحته يتناول القانون الواجب التطبيق في حالة واحدة وهي المتعلقة بتجريد الشخص من جنسيته بطريقة تعسفية، وبذلك يقتصر هذا الحل على الحالة التي يكون فيها للشخص جنسية سابقة تم تجريده منها، وبالتالي لن يمتد تطبيقه إلى حالات الانعدام المعاصرة للميلاد.

أضف إلى ذلك أن هذا الرأي يستند على رابطة لم يعد لها وجود من وجهة نظر الدولة التي كان ينتمي إليها الشخص، كما أن الدولة التي تنور أمام محاكمها المشكلة لا تملك تقدير سلوك الدولة

(١) بالتفصيل في استرداد الجنسية راجع: د. عنايت عبد الحميد ثابت: مبتدأ القول في أصول تنظيم علاقة الرعية، ١٩٨٩، ص ٦١ وما بعدها. وإن كان سيادته يفضل استخدام اصطلاح الرعية بدلاً من اصطلاح الجنسية.

(٢) راجع في ذلك:

- BATIFFOL Henri et LAGARDE Paul: Droit international privé, 7^{ème} edition, Tome. I.L.G.D.J. Paris, 1981, n.122.

التي كان ينتمي إليها عديم الجنسية، لتقدر ما إذا كان تجريده من جنسيته كان تعسفياً أم لا، وإذا قدرت ذلك فهي تجعل من نفسها سلطة عليا تحكم على الإجراءات التي تتخذها الدول في مواجهة مواطنيها، وهو ما يمثل مساس بسيادة تلك الدول^(١).

ومما سبق يتضح أن خيار الاسترداد قد يكون ذا أثر في حالة الشخص الذي سبق له التمتع بجنسية دولة معينة، ثم أصبح عديم الجنسية نتيجة لفقده إياها، أما الشخص عديم الجنسية، والذي لم يسبق له التمتع بأية جنسية على الإطلاق، فإن خيار الاسترداد لن يكون ذا تأثير على انعدام الجنسية في هذه الحالة.

(١) د. عكاشة محمد عبدالعال: المرجع السابق، أحكام الجنسية المصرية، ص ٣٨٨.

القسم الثاني

الموطن

مقدمة

يُعد المواطن من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص؛ فهو الآداة و الوسيلة التي تتولى إلى جانب الجنسية مهمة توزيع الأفراد جغرافياً عبر دول العالم، وهو الأسبق في هذا الدور من الجنسية .

وعلى الرغم من أن المواطن قد فقد أهميته في الوقت الحاضر بوصفه أساساً للعلاقات القانونية الدولية الخاصة في تشريعات العديد من الدول؛ إذ طغت فكرة الجنسية في تنظيم قضايا القانون الدولي الخاص، فإن المواطن لا يزال يحتفظ بمكانته وأهميته في تنظيم هذه القضايا في الدول الانجلوأمريكية ومنها إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول كالنرويج والدانمارك، وترجع هذه الأهمية إلى تزايد الهجرة إلى هذه الدول منذ الحرب العالمية الثانية، مما جعل للمواطن دوراً متميزاً يفوق في أهميته ضابط الجنسية .

ويلعب المواطن دوراً كبيراً ومؤثراً سواء على صعيد القانون الداخلي أو القانون الدولي الخاص :

فعلى مستوى القانون الداخلي يحتل المواطن أهمية كبيرة في إطار القانون الداخلي، مما دفع المشرع المدني لكي ينظم أحكامه في العديد من المواد، ولعل من أهم مظاهر اهتمام القانون الداخلي بالمواطن هي في جعله المعيار المحدد لاتخاذ بعض الإجراءات القانونية كاعتباره مكان للوفاء بالالتزامات أحياناً، واعتباره معياراً لتحديد الاختصاص القضائي أحياناً أخرى .

وعلى مستوى القانون الدولي الخاص فيختلف مفهوم المواطن في ظل القانون الدولي الخاص عن مفهومه في ظل القانون الداخلي، فالمواطن في ظل القانون الدولي الخاص يعني الدولة التي يُقيم فيها الشخص بصفة مستمرة وبنية الاستقرار فيها بحيث إذا تركها كانت لديه نية الرجوع إليها.

وتظهر أهمية المواطن في كل مجالٍ من مجالات القانون الدولي الخاص، ففي إطار تنازع القوانين كان المواطن من أهم ضوابط الإسناد التي تُشير في بعض الحالات إلى القانون الواجب التطبيق كما في حالة الأهلية والأحوال الشخصية، لكن الفقه الحديث أدى

إلى تغليب فكرة الجنسية على فكرة الموطن، أما في إطار الجنسية يلعب الموطن دوراً في اكتساب الجنسية أو فقدها؛ حيث تعتبر معظم الدول أن الإقامة والتوطن داخل إقليم دولة معينة لمدة زمنية معينة يؤدي إلى اكتساب هذا المتوطن أو المقيم جنسية هذا الإقليم المتوطن أو المقيم داخله، في حين تعتبر هذه الدول أن الإقامة خارج حدودها لمدة زمنية طويلة سبباً يؤدي إلى فقد الجنسية وزوالها بالنسبة لهذا الشخص، وكذلك للموطن أهمية في إطار الجنسية في حال تعدد الجنسيات؛ بحيث يتم تحديد الجنسية الفعلية من بينهما على أساس فكرة الموطن، وكذلك يُعد الموطن حلاً لمشكلة انعدام الجنسية كبديل عنها.

وفي إطار المركز القانوني للأجانب فإن المشرع الوطني يمنح الأجنبي المقيم في الدولة حقوقاً أكثر من الأجنبي غير المقيم .

كما يلعب الموطن دوراً محورياً في إطار القانون الدولي الخاص في مجال الاختصاص القضائي الدولي عند تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية؛ فقد أجمعت معظم الدول على عقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في كل دعوى تُرفع على من هو متوطن داخلها أي كانت جنسيته أو مركزه داخل الدعوى .

ويتميز الموطن بأنه ضابط شخصي، وفي ذات الوقت ضابط إقليمي يُستعان به في تحديد الاختصاص القضائي، ويرجع السبب فيما احتله من أهمية ومكانة إلى أنه ضابط يقوم ويُعبر عن الصلة الوثيقة بين الشخص وإقليم الدولة، ويتميز بالعمومية لكونه غير مقتصر على طائفة معينة من المنازعات.

ويتولى الموطن حل مشكلة التنازع في الاختصاص بتحديد المحكمة المختصة ويكون من السهل بعد ذلك تنفيذ ما تُصدره الدولة من أحكام على الأشخاص المتوطنين فيها، وهذا ما جعله الضابط الأكثر اتفاقاً عليه بين التشريعات المختلفة في تحديد الاختصاص القضائي.

وسنعرض ما ينطوى عليه الموطن من أحكام وأهمية وما يكتنفه من إشكاليات من خلال المطالب الآتية :

المطلب الأول: مفهوم الموطن وخصائصه .

المطلب الثاني: أركان الموطن وأنواعه .

المطلب الثالث: مشاكل الموطن وكيفية التغلب عليها .

المطلب الرابع: تنازع القوانين بشأن تحديد الموطن .

المطلب الأول

مفهوم الموطن وخصائصه

أولاً - المقصود بالموطن:

إزاء صمت غالبية مشرعي العالم عن التعرض لفكرة الموطن في العلاقات الخاصة الدولية واكتفائهم بتحديد الفكرة وبيان معالمها وأحكامها على مستوى العلاقات الخاصة الوطنية فقط أصبح واجباً الاستعانة بأحكام الموطن الواردة في القوانين الداخلية والخاصة بالعلاقات الخاصة الوطنية للتعرف على أحكام الموطن في إطار القانون الدولي الخاص، ففي قانون المرافعات المصري لا نجد تعريفاً خاصاً للموطن، مما يدعو إلى الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني والتي نصت المادة ٤٠ منه في فقرتها الأولى على أن " الموطن هو المكان الذي يُقيم فيه الشخص عادةً ".

أما المشرع الفرنسي فقد أورد تعريفاً صريحاً للموطن في القانون المدني الفرنسي باعتباره المكان الذي يُقيم به الشخص بشكلٍ دائمٍ أو تقع به محل الإدارة الرئيس للشخص المعنوي^(١)، و قد نظم المشرع الفرنسي مسألة الموطن بالمواد ١٠٢ من القانون المدني الفرنسي

(1) Léon Mazeaud, Jean Mazeaud et François Chabas, Leçons de Droit civil- 12e éd, Montchrestien, 2000, p. 98 « Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement.

بعد أن صادفت آخر تعديل لها بموجب القانون رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠١٤م حيث اعتبرت أن المواطن لكل فرنسي هم محل إقامته المعتادة^(١).

ولعل مفهوم المواطن في مجال القانون الدولي الخاص متميزاً عنه في القانون المدني، حيث يُشير اصطلاحه في الأول إلى توطن الشخص في أى دولة من دول العالم، بينما في الثاني يعنى توطن الشخص في دولة معينة بالذات دون غيرها من الدول^(٢).

ويختلف مفهوم المواطن الداخلى عن مفهوم المواطن الدولي؛ ذلك إن الأول هو مفهوم يُعبر عن الارتباط بين شخص ومكان معين في إقليم دولته ويترتب آثاراً قانونية في حياة الأفراد، أما المواطن الدولي فهو المكان التابع لإقليم دولة معينة يُقيم فيه الشخص بنية البقاء سواء أكانت هذه الدولة هي التي يحمل جنسيتها أم لا، فقد يرتبط الشخص روحياً وسياسياً بدولة معينة لكنه يتوطن أو يمارس عمله في دولة أخرى، وعندها تكون له جنسية الدولة الأولى وتكون الدولة الثانية موطناً له.

وعلى المستوى الفقهي لم يتم الاتفاق على تعريف واحد للمواطن الدولي (المواطن في إطار القانون الدولي الخاص)، فقد عرفه الفقيه " Savigny " بأنه " المحل الذي يختاره الشخص اختياراً حراً ليسكن فيه نهائياً أو ليكون مركزاً لصلاته القانونية ولأشغاله "، والملاحظ هنا تعريف المواطن على أنه الوطن الذي يتحقق فيه الاستقرار (التوطن مع الأهل) ونية الاستقرار (قصد العيش في الوطن)، أما الفقيه " Albert Venn Dicey " فقد عرفه بأنه: " الجهة أو البلد الذي هو في الواقع المأوى النهائي للشخص، ولكن يجوز أن يكون في بعض الأحيان الجهة أو البلد الذي يعتبره القانون مأوى له سواء أكان مقيماً فيه أم لا " ^(٣).

وقد ذهب الفقه إلى تعريف المواطن بصورة أكثر تحديداً وشمولية بأنه " رابطة تربط بين أجنبي وإقليم دولة معينة، وتلك الرابطة تنشأ من واقعة إقامته بهذا الإقليم بنية الاستقرار فيه

(1) Art 102 du code civil "Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ".

(٢) د.إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص " المواطن ومركز الأجانب "، ٢٠٠١م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٧.

(3) Sandrine Clavel: Droit international privé, op.cit, P. 350 et s.

"(١)، وإزاء كثرة التعريفات لفكرة المواطن لم يقف فقه القانون الدولي الخاص صامتاً^(٢) بل وضع مفهوماً عاماً للمواطن يقضى بأنه " هو رابطة مادية ومعنوية بين الشخص ومكان معين، فهو تعبير عن الوجود المادي للشخص في مكان ما، والمقترن بنية الاستقرار فيه على وجه الدوام"^(٣)، والتعريف الأخير كالسهم أصاب غرة الهدف لاحتوائه وشموله على أركان المواطن المادي والمعنوي.

ويرى البعض أن الاعتماد على مصطلح محل الإقامة^(٤) فقط كافٍ في حد ذاته دون حاجة لمصطلح خاص للتوطن، وأنه على الرغم من كون محل الإقامة عنصراً من عناصر التوطن الذي ينطوي على ربط الشخص وجنسيته حتى ولو كان مزدوج الجنسية، إلا أنه لا يُتصور أن يكون بلا محل إقامة لأنه أوثق صلة للشخص بالدولة لكونه المكان الذي يقطن فيه ويحتفظ فيه بمنزل ناوياً البقاء والاستقرار به وهو يُعد بمثابة عامل ربط يصل الشخص بنظام قانوني معين، بحيث يصبح قانون محل إقامته هو قانونه الشخصي.

(١) د. حسام الدين فتحي ناصف: المواطن في العلاقات الدولية للأفراد، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يوليو ١٩٩٤م، السنة السادسة والثلاثون، ص ٩، ويقترّب هذا التعريف من مفهوم فكرة المواطن في أحكام الفقه الإسلامي، فالمواطن عندهم هو " وطن الإنسان في بلده أو بلدة أخرى اتخذها داراً أو توطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل العيش فيها والتعيش بها " .

(٢) راجع كتابات فقه القانون الدولي الخاص الفرنسي:

Pierre Mayer et Vincent Heuze: Droit international privé, op.cit, p.184.

(٣) د. هشام صادق: الجنسية والمواطن مركز الأجنب، المجلد الأول " الجنسية والمواطن "، ٩٧٧م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ٧٢٣، بند ٢٦٤.

(٤) وقد شرح المقصود بمحل الإقامة تفصيلاً في نص المادة ١٠ من نظام المرافعات الشرعية السعودي والتي أشارت أنه "..... المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتقاد، وبالنسبة للبدو الرحل يُعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة للموقوفين والسجناء يُعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه، ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطار والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة، إضافةً إلى محل إقامته العام " .

الفرق بين الجنسية والموطن:

على الرغم من أن الجنسية والموطن وسيلتين للتركيز المكانى للأفراد على المستوى الدولى إلا أن كلا منهما يختلف عن الآخر فيما يلى:

١- الجنسية تعنى نسبة الفرد وانتماءه إلى إقليم دولة معينة باعتباره من الوطنيين على أرض هذا الإقليم فالدولة هى الوطن لمن يتمتعون بجنسيتها، أما الموطن فهو أمرٌ مسلمٌ به وسط التطور المعاصر للقانون الدولى الخاص فى وقتٍ أصبح فيه مجال الدولة مفتوحاً أمام الجميع وحدودها تسمح بدخول الأجانب والإقامة فيها والعمل بها وهو ما يُعرف بالتوطن .

١- الجنسية تفيد انتماء الشخص إلى دولة معينة إنتماءً أصيلاً وشاملاً، أما الموطن فيفيد انتماء الشخص إلى دولة معينة انتماءً طارئاً وناقصاً ومحدوداً.

٢- الجنسية لا يفقدها الفرد ولا تتأثر بمجرد تركه لإقليم الدولة حتى لو كان تركاً بنية عدم العودة، والعكس صحيح فيما يتعلق بالموطن؛ حيث إن مغادرة الفرد لإقليم الدولة الذى يستوطنه بنية عدم العودة يؤدى إلى فقده لهذا الوطن.

٣- الموطن يؤثر فى الجنسية وغيرها من موضوعات القانون الدولى الخاص أكثر من تأثيره فيها، فهو يقوم بدورٍ فعالٍ فى صياغة القواعد القانونية التى تُعالج هذه الموضوعات ومنها الجنسية وتسهم بشكلٍ واضحٍ فى حل منازعاتها ومشكلاتها.

ثانياً - خصائص الموطن:

يتميز الموطن كرابطة تربط الشخص بإقليم معين بعدة خصائص أهمها:

(١) **الموطن رابطة واقعية:** وهذه الصفة الواقعية للموطن يؤكدتها حق الشخص فى اكتساب الموطن فى حال توافر أركانه المادى والمعنوى حتى وإن لم يكن قد حصل على ترخيصٍ بالتوطن فى إقليم الدولة التى استقر فيها .

وذهب البعض إلى تأييد القول بأن الإقامة المعتادة للشخص فى إقليم دولة معينة بنية البقاء والاستمرار فيها هي " واقعة لا يمكن تجاهلها من قبل الدولة لكونها مسألة واقعية حدثت

بالفعل في مدة معينة " (١)، وهو ما دفع البعض الآخر إلى إضفاء صفة الواقعية على الموطن وجعلها سابقة في ترتيب الأوصاف والمزايا وأصبح الترتيب الوصفي للموطن بأنه " رابطة واقعية قانونية وليست سياسية " مع نفي الطابع السياسي لفكرة الموطن وتثبيت الصفة الواقعية له (٢).

(ب) الموطن رابطة صادقة: من الضروري أن تكون رابطة الموطن التي تربط الشخص بإقليم دولة معينة رابطة صادقة تُعبر فعلاً عن ارتباط حقيقي بين الأجنبي وإقليم الدولة يجعل من هذا الأمر أمراً صادقاً وليس افتراضياً.

وترجع حتمية وضرورة رابطة الصدق المتطلبة إلى أنها الحل الأمثل لما ظهر من مشاكل متعددة متعلقة بفكرة الموطن وأهمها مشكلتي الموطن الظاهر (٣)، والموطن التحايلي (٤).

(ج) الموطن رابطة ذات طبيعة وظيفية: بمعنى أن الموطن رابطة تستهدف تحقيق أهداف وأغراض معينة، وأن طبيعة الموطن الوظيفية هي التي استتبع اختلاف تصويره من نظام قانوني إلى آخر، وكذلك الآثار المترتبة عليه في كل نظام عن الآخر، والطبيعة الوظيفية للموطن تقتضي النظر إلى ما يربط الشخص المتوطن بالإقليم المتوطن فيه من صلات وروابط بنظرة تفحصية دقيقة ودراستها لمعرفة أهميتها وقيمتها ومكانتها الحقيقية كالروابط والصلات

(١) د. هشام صادق : المرجع السابق، ص ٧٤٢.

(٢) د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول " الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق "، مرجع سابق، ص ٥٥٤.

(٣) وقررت المحاكم الفرنسية حماية للغير حسن النية أن يقوم الموطن الظاهر مقام الموطن الحقيقي، وحسن النية هو أن يوجد ما يُبرر خطأ وهذا الخطأ يولد حقاً لمصلحته، ومثال ذلك أن يقوم شخص بإعلان المدعى عليه أمام محكمة المكان الذي يسكنه المدعى عليه حوالي السنة ويُباشر فيه مصالحه الحيوية، فيعترض المدعى عليه أمام هذه المحكمة ويدفع بأنه يتوطن مكاناً آخر .

(٤) ومضمون المشكلة أن توافر الإقامة الفعلية للأجنبي على إقليم الدولة دون أن تكون إقامته مشروعة لعدم صدور ترخيص بشأنها من السلطات المختصة في الدولة، وهنا نكون أمام موطن فعلي ولكنه ليس قانوني، ومن ثم تقوم الدولة بحرماته من الحقوق التي يتمتع بها من يقيم إقامة شرعية وقانونية ويكون لها حق إبعاده خارج البلاد .

الاجتماعية والعائلية والمهنية وحتى المالية والعاطفية والدينية، وخيراً مثال لتوظيف فكرة المواطن بالمفهوم الذى عرضناه هو توظيف المواطن في مجال تتنازع القوانين وخاصةً عند تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الميراث، فهو يركز على ما يربط الفرد بإقليم الدولة من صلاتٍ وروابطٍ ماليةٍ .

المطلب الثاني

أركان الوطن وأنواعه

أولاً - أركان الوطن:

من خلال التعريفات المختلفة لفكرة المواطن نستطيع استخلاص ركنين أساسيين للمواطن لابد من توافرها هما الركن المادى والركن المعنوى.

(أ) الركن المادى:

ونعنى به الإقامة المعتادة والتي تتطلب وجوداً مادياً فعلياً للشخص الأجنبى على إقليم الدولة^(١)، وهذا الوجود المادى قد يكون غير واقعى وغير مستمر ولا يتقيد بمدة زمنية معينة، ومثالاً للوجود المادى غير الواقعى للشخص الأجنبى على إقليم الدولة حالة المواطن القانونى أو الإلزامى، وهو المواطن الذي ينسب له القانون للشخص ولو لم يكن قد أقام فيه عادةً، مما يُضفى على المواطن فى هذه الحالة الطابع الحكمى.

ولا يُشترط لتحقيق الركن المادى للموطن استمرار إقامة الشخص الأجنبى المتوطن ولا امتدادها، فتُعتبر الإقامة مستمرة ولو تخللتها فترات غيبة طويلة أو قصيرة، ولكن الأهم هو تحقق شرط الاعتياد^(٢)، وأيضاً لا يُشترط قضاء الشخص المتوطن مدةً زمنيةً معينةً، وإذا كان من الضروري الوجود المادى للشخص الأجنبى على إقليم الدولة ابتداءً إلا أنه ليس حتماً

(1) Dominique Bureau et Horatia Muir Watt: Droit international privé, PUF, 2009, p. 177.

(٢) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص ٢٩٥.

وضرورة لاستمرار هذا التوطن، وهذا هو تبرير عدم فقد كل شخص موطنه بمجرد مغادرته إقليم الدولة لأي سبب من الأسباب.

ومن الواجب على القضاء والفقه ضرورة وضع مصطلح يعرف الإقامة المعتادة تعريفاً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض يُحدد شروطها ويُنظم معالمها بدلاً من المصطلح الغامض غير المحدد المعالم والمعروف لها حالياً وسط الفقه.

(ب) الركن المعنوي:

ونقصد بالركن المعنوي أن تتوافر لدى الشخص الأجنبي المتوطن نية الاستقرار والاستيطان في إقليم دولة معينة^(١)، وهو ركنٌ مكمل للركن المادي ولا يستقيم بدونه فلا بد من توافرها مجتمعين، ومن الثابت أن أمرى النية والقصد هما أمران داخليان يسيران في أغوار النفس الإنسانية ومن الصعب التعرف عليهما، ولكن يمكن استخلاصهما من عدة ظواهر واضحة قد تُرشد إليهما أهمها ظروف الشخص السكنية وعلاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والوظيفية والمالية بإقليم هذه الدولة^(٢).

وأنه على الرغم من عدم اشتراط مدة زمنية معينة للقول بتحقيق الوجود المادي أو الإقامة المعتادة إلا أنها تُعد قرينة كافية على توافر نية الاستقرار المُتطلب لتحقيق الركن المعنوي للموطن وتوافره.

ويتمثل هذا الركن بنية البقاء لمدة غير محدودة في المكان الذي اتخذ الشخص للإقامة، فهذا العنصر يكشف عن طبيعة العنصر المادي فيما إذا كان عبارة عن مجرد محل إقامة أو موطن، فإذا اقترن العنصر المعنوي بالوجود المادي للشخص، نكون أمام موطن، أما إذا لم يتحقق الاقتران فنكون أمام محل إقامة، ولا يُؤخذ بنظر الاعتبار طول أو قصر مدة الإقامة لتحقيق العنصر المعنوي؛ فالإقامة لمدة عشر سنوات لشخص سجن في فرنسا لا تفضي إلى

(1) Daniel Gutmann: Droit international privé, Dalloz, 2009, p. 121.

(٢) وقد استلزم القانون المدني الفرنسي ضرورة توافر هذه النية وهي نية الاستيطان والاستقرار فيه وذلك في المواد ١٠٤، ١٠٥ منه.

تحقيق هذا العنصر، لأن السجن في هذا الوضع لا تتحقق فيه الإقامة لمدة غير محددة لأن إقامته محددة ابتداءً وانتهاءً، وإزاء ذلك فإن استمرار إقامة مصرى في بريطانيا لأكثر من سنة تكفي لتحقيق هذا العنصر إذا قصد الشخص في الوضع الأخير الإقامة لمدة غير محددة ابتداءً، أى يقتضى أن لا تكون نية البقاء مدة معينة سلفاً وإلا انعدم الركن المعنوى.

وهناك ثلاث صور رئيسة للنية: صريحة وضمنية ومفترضة، ويكفى توافر صورة واحدة منها لتحقيق الركن المعنوى للموطن، وعلى عاتق القاضي يقع واجب البحث عن هذه النية واستخلاصها فيبدأ بالصريحة ثم الضمنية فإن لم تتكشف اتجه فى بحثه إلى النية المفترضة وافترض انصراف نية الشخص إلى التوطن في مكان معين وفقاً لمعايير يضعها، وذلك انطلاقاً من أهمية الموطن في تنظيم المركز القانونى للفرد^(١)، وهذه النية تقتضى أن يسلك الأجنبى المتوطن سلوكاً ايجابياً فى الإقليم يُستشف منه توافر النية والقصد لاستيطانه فيه، وبالتالي يمكن استنتاج هذه النية من ظروف إقامة الشخص فى الإقليم والكشف عن صلاته الاجتماعية وروابطه العائلية واندماجه الحقيقى فى مجتمع معين وتحقيقه منافع ومصالح مالية على أرض هذا الإقليم.

بيد أن هناك بعض التشريعات تعتبر تحقق الركن المادى قرينةً على توافر الركن المعنوى ومنهم المشرع المصرى الذي يعتبر عنصر النية عنصراً تبعياً يُستخلص من استقرار الإقامة، فيكفى أن تستقر الإقامة حتى تُفترض النية افتراضاً^(٢).

أهمية الركن المعنوي:

وللركن المعنوى أهمية خاصة في تأسيس الموطن ولا يمكن الاكتفاء بالركن المادى؛ حيث إن نية الفرد تُعد وسيلةً لتلافي مشكلة تعدد المواطن للشخص الواحد بتعدد محال إقامته المعتادة والمستقرة كالشخص الذى يُقيم إقامة عادية في الريف وفى الحضر، كما أن الركن المعنوى سيؤدى إلى عدم تغيير موطن الشخص من حينٍ إلى آخر بتغييره محل إقامته المعتادة

(١) د. حسام الدين فتحي ناصف : الموطن في العلاقة الدولية للأفراد، مرجع سابق، ص ٦٣٢ .

(٢) د. محمد كمال فهمي : أصول القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص ٢٥٩ .

ولن يتم الإعتداد إلا بالمكان الذى توافرت النية لدى الشخص ليكون موطناً مستقراً له، وعند حدوث قصور أو غموض في الركن المادى فإنه لا مناص من البحث عن النية التى تعادل واقعية الاندماج المتطلب.

فنية البقاء لمدة غير محدودة لا تكفى بذاتها إذا تخللها الإكراه، ويمكن الاعتداد بها إذا ارتفع الإكراه أى من الوقت الذى يرتفع فيه الإكراه، ومثال ذلك إقامة السجناء الهاربين من وجه العدالة و المرضى وغيرهم لا تؤدى طول إقامتهم وإن اقترنت بنية البقاء إلى كسب الموطن، لأن إرادتهم مشوبة بعيب الإكراه، ويمكن أن توصف إقامتهم بأنها عرضية أو طارئة قد تتحول إلى إقامة دائمة أو مؤقتة، ومن ثم تكون موطناً إذا ارتفع عيب الإكراه فيعتد بنية البقاء و الإقامة ابتداءً من هذا الوقت، ويختلف الوقت بحسب طبيعة الحالة؛ فالنسبة للسجين يكون وقت إطلاق سراحه، وللمريض وقت اكتسابه درجة الشفاء التام، وللهارب من وقت العفو أو براءة ذمته إذا كان مدين، فالشخص في الأوضاع المتقدمة لا يكون إلا أمام خيار واحد قبل ارتفاع الإكراه؛ فتوصف إقامته بأنها اضطرارية عرضية، ولكنها تصبح إقامة دائمة أو مؤقتة وقت ارتفاع الإكراه لأنه سيكون أمام خيارين: إما البقاء فى دولة إقامته الاضطرارية أو العودة إلى دولة إقامته الأصلية .

وفى الحقيقة أن اكتساب إقامة فى دولة ما يتطلب اكتمال أهلية الشخص وخلوها من أى عيب من عيوب الإرادة، وذلك حتى ينتج اختيار الشخص من الإقامة فى دولة ما أثره من كسب الموطن ويسمى الموطن المتحقق بهذه الآلية بالموطن الاختيارى أو المكتسب.

ثانياً - أنواع الموطن:

أنواع الموطن من حيث وقت التمتع به:

التمتع بالموطن على غرار التمتع بالجنسية له صورتان رئيستان:

الصورة الأولى- الموطن الأصلي:

وهو الذى يثبت للشخص منذ لحظة ميلاده بقوة القانون، أى بمجرد الميلاد، ولا يشترط الإقامة فيه، ويتحدد الموطن الأصلى بصلة الدم أو النسب أو بتحقيق الميلاد على إقليم دولة

معينة، وهذا المواطن لا يزول إلا باكتساب الشخص موطناً جديداً يدل دلالة واضحة على تنازله عن المواطن الأول.

الصورة الثانية- المواطن المكتسب(١):

وهو الذى لا يكون لإرادة الشخص دورٌ فى التمتع به ويتم اكتسابه فى تاريخ لاحق على الميلاد عند توافر الإرادة المُتطلبية قانوناً.

أنواع المواطن من حيث ظروف التمتع به:

يمكن تقسيم المواطن من ناحية ظروف التمتع به إلى أربعة أنواع:

(أ) **المواطن العام:** وهو المكان الذى يُقيم فيه الشخص عادةً، ويُستفاد ذلك من نص المادة ٤٠ من القانون المدنى والتي تُقرر أن موطن الشخص هو محل إقامته عادةً، وهو بهذا يختلف عن محل الإقامة، والفرق بينهما أن محل الإقامة هو محل السكن أما المواطن فهو محل الإقامة المعتادة^(٢).

ويترتب على ذلك أن السكن أو المأوى ليس موطناً للشخص إذا لم يكن الشخص قد اعتاد الإقامة فيه، وبالتالي فمحل الإقامة أو السكن العارض الذى ينزل به الشخص لظروف وأسباب طارئة كتلقى العلم أو العلاج وغيرهما لا يُعد موطناً لهذا الشخص^(٣).

(ب) **المواطن الخاص:** وهو المواطن الذى يتعلق بمباشرة نشاطٍ أو أنشطة معينة، وبالتالي فإن المكان الذى يُباشر فيه الشخص تجارةً أو حرفةً موطناً له بالنسبة إلى إدارة أعماله المتعلقة

(١) ويُسمى أيضاً بالمواطن الإرادى والمواطن الاختياري.

(٢) حيث تقول محكمة النقض المصرية أن " المواطن العام للشخص، ماهيته: المكان الذى يُقيم فيه الشخص عادةً ٤٠٢ مدنى، مؤداه أن المواطن حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون يصل به بين شخص معين ومكان معين، أثره جواز تعدد موطن الشخص أو إنتفاؤه على وجه الإطلاق " - انظر تفصيلاً الطعن رقم ٣٠٤٩ لسنة ٦٩ قضائية، جلسة ٢٠٠١/٦/٦م، مجلة المحاماة ٢٠٠٢م، العدد الثانى، ص ٥٧.

(٣) د. عبد الحكيم فودة: ضوابط الاختصاص القضائي (في المواد المدنية والجنائية والشرعية والإدارية)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٥م، ص ٣٧٨، بند ٢٧٣.

بهذه الحرفة أو التجارة^(١)، ويُستفاد هذا النوع من الموطن من نص المادة ٤١ من القانون المدني المصري^(٢) والتي اعتبرت أن الشخص الذي يُمارس حرفة معينة أو تجارة في مكان معين أنه قد اتخذ من هذا المكان موطناً له فيما يتعلق بإدارة هذه الحرفة وممارستها^(٣).

(ج) الموطن الحكمي أو القانوني: لقد بان لنا يقيناً فيما سبق أن من خصائص الموطن أنه اختياري يكون لإرادة الشخص دوراً مهمّاً في تحديد هذا الموطن واختياره ليستوطن فيه ويستقر به، ولكن ثمة أشخاص عديمو الأهلية وناقصوها لا تتوافر لهم القدرة على اختيار هذا الموطن بأنفسهم فجعل المشرع لهم موطناً حكماً وقانونياً هو موطن من ينوب عنهم، ويُستفاد هذا من نص المادة ١/٤٢ من القانون المدني^(٤)، والتي وفقاً لها يُعتبر الموطن، أي موطن من ينوب عنهم قانوناً هو الموطن الحكمي بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها^(٥).

وخليقاً بنا الإشارة إلى أن القاصر الذي بلغ ١٨ سنة يستطيع مباشرة بعض الأعمال والتصرفات القانونية وذلك بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة لمباشرة هذه الأعمال والتصرفات، وعليه يكون مكان هذه الأعمال هو الموطن الخاص بالنسبة للمنازعات الخاصة

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد : الوجيز في القانون الدولي الخاص ، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٥٥٠.

(٢) تنص المادة ٤١ من القانون المدني المصري أنه " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ".

(٣) حيث تقول محكمة النقض المصرية في ذلك أن " مباشرة الأجنبي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، أثره اعتبار مكان النشاط موطناً له فيما يتصل به..... " - انظر تفصيلاً الطعن رقم ٤٦٠٤ لسنة ٦٢ قضائية، جلسة ٢٠٠٠/٢/١م، مجلة المحاماة، العدد الأول، ٢٠٠١م، ص ٨٤.

(٤) تنص المادة ١/٤٢ مدني على أن " ١- موطن القصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً".

(٥) د. عكاشة محمد عبد العال: (الإجراءات المدنية والتجارية الدولية - الاختصاص القضائي الدولي - القانون الواجب التطبيق على الإجراءات - الأحكام الأجنبية)، مرجع سابق، ص ٥٧.

والمعلقة بهذه الأعمال والتصرفات والتي يعتبره القانون والمحكمة أهلاً لمباشرتها والقيام بها، أما موطنه الحكمي فيعتد به بالنسبة لغيرها من المنازعات^(١).

موطن الشخص الاعتباري: لما كان من الضروري وجود موطن للأشخاص الطبيعيين فإنه لا بد وأن يكون للأشخاص المعنوية (الاعتبارية) أيضاً موطناً، وهو المكان الذي يوجد به مركز إدارته الرئيس؛ لأنه يُعبر عن رابطة وطيدة بين الشخص الاعتباري وبين الدولة التي يوجد على أرضها، وهو ما يُنشئ حقاً طبيعياً لمحاكم تلك الدولة في اختصاصها القضائي بنظر المنازعات التي يدخل الشخص الاعتباري طرفاً فيها، وهو ما تقضي به القواعد العامة، وعند تعدد هذه المراكز تكون العبرة بالمركز الرئيس لها ما لم يكن هذا المركز خارج مصر وفي هذه الحالة يكون مركز إدارتها الرئيس بالنسبة لمنازعاتها داخل مصر هو مكان إدارة هذا الفرع الموجود لها في مصر متى كانت تُبأشر نشاطاً فيها، ويكون هذا هو موطنها، وإذا كان له أكثر من فرع وتعلقت المنازعة بفرع معين من هذه الفروع فالعبرة بمركز إدارة هذا الفرع، ويرى البعض - وبحق - أن عدم وجود مقر حقيقي ومركز رئيس للنشاط الذي يقوم به الشخص الاعتباري يجعل الشخص الاعتباري غير موجود؛ حيث إن القانون لا يشترط ضرورة أن تُبأشر هذه الأشخاص الاعتبارية لأعمالها من مكان معين أو محدد أو دائم .

وقد نصت المادة ٢/١١ من القانون المدني المصري على موطن الشخص الاعتباري بقولها " أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيه هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسرى " ^(٢).

(١) تنص المادة ٢/٤٢ مدني على أنه " ٢- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص - بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها " - انظر تفصيلاً د. عبد الحكيم فودة: ضوابط الاختصاص القضائي (في المواد المدنية والجنائية والشرعية والإدارية)، مرجع سابق، ص ٣٨٢ وما بعدها، بند ٢٨٦.

(٢) كما جاءت المادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية السعودي فنصت على أنه " تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة، أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها

(د) الموطن المختار: وهو المكان الذي تم اختياره ليكون محلاً لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هذا الموطن المختار هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل كإعلان الأوراق القضائية وإجراءات التنفيذ الجبري مع جواز اشتراط اقتصار دور هذا الموطن على أعمال معينة دون غيرها، ويستفاد هذا النوع من نص المادة ١/٤٣ من القانون المدني^(١).

ويلاحظ أنه لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا كتابة وفقاً لنص المادة ٢/٤٣ من القانون المدني^(٢)، ولا يعتبر موطناً مختاراً المكان الذي يتفق على مجرد حصول الوفاء فيه ولا يجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها.

المطلب الثالث

مشاكل الموطن وكيفية التغلب عليها

لما كان لكل دولة الحق في حرية التنظيم لمسألة الموطن في تشريعاتها الداخلية وتحديد مفهومه بحرية مطلقة، فقد أسفر ذلك عن ظهور مشكلتين شاذتين، إحداهما ظاهرة إيجابية تمثلت في تعدد المواطن، والأخرى سلبية تمخضت في انعدام الموطن^(٣)، مما كان له عظيم الأثر على المركز القانوني للأفراد خاصة في الأحوال التي يُعتمد فيها على الموطن لتحديد هذا المركز، وهذا يقتضي حتمية التعرف على هاتين المشكلتين:

مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع -.

(١) تنص المادة ١/٤٣ من القانون المدني على أنه " ١- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين -.

(٢) تنص المادة ٢/٤٣ مدني على أنه " ٢- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة " -.

(٣) ويُشبه هذا الوضع الوضع في مجال الجنسية؛ حيث إن لكل دولة الحق والحرية في تنظيم جنسيتها اكتساباً وفقداً واسترداداً، مما أسفر عن وجود مشكلتي تعدد الجنسيات وانعدام الجنسية.

أولاً - التنازع الإيجابي للموطن:

ونعنى بها تعدد المواطن للشخص الواحد، ولأن يكون له أكثر من موطن في وقت واحد وفي أكثر من دولة وفقاً لقانون كل دولة من هذه الدول، ويكمن السبب الرئيس في وجود هذه المشكلة في اكتساب الشخص موطناً جديداً دون أن يفقد موطنه السابق أو القديم.

وقد اعترف المشرع المصري بمشكلة تعدد المواطن، وذلك في المادة ٢/٤٠ منه والتي قرر فيها أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن "، ونستشف من هذا النص أن القانون المصري لا يعترف بتعدد المواطن كمشكلة وإلا ما أقرها، وهو ما أكدته القضاء المصري في بعض أحكامه والتي رأى فيها أن تعدد المواطن يعتد بالأمر الواقع ويستجيب لحاجة المتعاملين^(١).

ثانياً- التنازع السلبي للموطن:

ونقصد به عدم وجود موطن للشخص في أية دولة وفقاً لأحكام قوانين مختلف الدول، ووجود هذه المشكلة يرجع بصورة أساسية إلى فقدان الشخص لموطنه السابق الذي كان يتمتع به دون أن يكتسب موطناً جديداً ويصبح في هذه الحالة " منعدم الموطن".

وقد اعترف أيضاً المشرع المصري بتلك المشكلة الاستثنائية عندما نص في المادة ٢/٤٠ من القانون المدني على أنه "..... كما يجوز ألا يكون للشخص موطناً ما".

كيفية التغلب على مشكلتي الموطن بالنسبة لحالات التنازع الإيجابي:

فإنه لحل هذا التنازع لابد من أنه إذا كانت دولة القاضى من بين الدول التي يُعتبر الشخص متوطناً فيها وفقاً لقانونها فإن على القاضى أن يطبق قانون دولته باعتبار هذا الشخص متوطناً بدولته دون الالتفات لما تنص عليه القوانين المقارنة الأخرى والتي يُعتبر نفس الشخص متوطناً فيها طبقاً لها، أما إذا لم تكن دولة القاضى من الدول التي يُعتبر الشخص متوطناً فيها

(١) راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ٢٢ يونيو ١٩٨١م، منشور في مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٢ قضائية، ج ٣٤٢، ص ١٨٩٨ وما بعدها.

وفقاً لقانونها، فإنه على القاضي أن يُرجح موطناً واحداً من ضمن المواطن المتعددة للشخص وفقاً لقانون معين من ضمن القوانين التي يتمتع بعدة مواطن وفقاً لها^(١)، ولعل هذا التقدير والترجيح الذي يقوم به القاضي يندرج تحت السلطة التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومُستشفاً مما هو معروض أمامه من أوراق.

وبالنسبة لحالات انعدام الموطن:

فإنه لحل هذه المشكلة يتعين استخدام محل الإقامة كبديل للموطن، أما في حالة عدم ثبوت محل إقامة للشخص عديم الموطن في دولة معينة فإنه يجوز للقاضي تطبيق القانون الذي يرى أنه الأكثر ملاءمة للتطبيق على العلاقة المعروضة حتى ولو كان هذا القانون هو قانون القاضي.

المطلب الرابع

تنازع القوانين بشأن تحديد الموطن

لما اختلفت مفاهيم الموطن وتنوعت في القوانين والتشريعات المقارنة، وُجدَ التنازع بشأن القانون الذي يتوجب الرجوع إليه للتأكد من وجود الموطن، وانطلاقاً من اعتبار مسألة القانون الواجب التطبيق على تحديد الموطن من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها وبأولوية تامة حتى يصبح بعد ذلك أمراً تحديد موطن الشخص ومن ثم مركزه القانوني في المنازعة المثارة أمراً يسيراً، فقد تسابقت الاجتهادات الفقهية في الكشف عن القوانين التي تتنازع من أجل تحديد الموطن وأسفرت تلك الاجتهادات عن بزوغ الاتجاهات الآتية:

الاتجاه الأول- تطبيق قانون الإرادة:

ويُصور هذا الاتجاه الموطن بأنه المرآة العاكسة لإرادة الشخص؛ لأنه المُعبر الحقيقي عن ارتباط وثيق للشخص بمكان معين، ويدل على ذلك بقوله أن نية البقاء والتوطن والتي تمثل

(١) ولكن الحل الأمثل أن يعطى القاضي الأولوية لموطن الشخص في الدولة التي يقيم بها إقامة فعلية، لأن تلك الدولة هي التي يوجد فيها الموطن الذي يرتبط به الشخص أكثر من غيره من المواطن من الناحية العملية والواقعية .

ركناً أساسياً من أركان الموطن تُعبر عن نوع آخر من الإرادة، ويقتنع أنصار هذا الاتجاه بأن الموطن هو من صنع الإرادة، ومن ثم فالموطن يجب أن يتحدد وفقاً لأحكام القانون الذى اتجهت إرادة الشخص إلى اختياره وأن هذا القانون ما هو إلا كاشفٌ عن إرادة الشخص ومقررٌ لما يترتب عليها من آثار^(١).

ولكن أصبح هذا الاتجاه سيئ المنقلب نتيجة رفض غالبية الفقه له استناداً إلى:

١- أن هذا التطبيق لقانون الإرادة لا يصلح للتطبيق على كل حالات الموطن، فهناك الموطن الأصلي الذى يثبت للشخص منذ لحظة ميلاده استناداً إلى صلة الدم أو حق الإقليم، كالجنسية الأصلية تماماً التى يكتسبها الفرد على أساس حق الإقليم أو حق الدم، ويغيب فيهما أى دور لإرادة الفرد.

٢- أنه من غير المقبول تعليق مسألة مهمة ومؤثرة كمسألة تحديد الموطن بيد الأفراد، ويجب النظر إليها بنظرة أكثر وعى وتمعن وإدراك، والأخذ في الاعتبار ما يترتب على ثبوت الموطن من آثار مهمة وخطيرة أبرزها أن توطن الفرد في دولة معينة قد يؤدي إلى اكتسابه جنسية هذه الدولة أو قد يخضع لقانونها إذا ما كان طرفاً في منازعة وطبق القانون الشخصى لهذا الشخص أو قد يخضع للاختصاص القضائى الدولى لمحاكم هذه الدولة وغيرها.

٣- أن تطبيق قانون الإرادة بما يتضمنه من إطلاق الحرية للأفراد في اختيار القانون الذي يتحدد به موطنهم يمثل ذريعةً ووسيلةً لسيل من حالات الغش والتحايل نحو القانون واستغلال الأفراد التحايلى بهدف الوصول لأهداف غير مشروعة .

(١) د. هشام صادق : الجنسية والموطن مركز الأجنب، المجلد الأول " الجنسية والموطن " ، مرجع سابق، ص ٧٥٦.

الاتجاه الثاني- تطبيق القانون الشخصي:

ويؤمن أنصار هذا الاتجاه^(١) بأن الموطن عنصراً من عناصر الحالة، ومن ثم وجب إدراجه تحت مظلة مسائل الأحوال الشخصية وتحديده وفقاً للقانون الشخصي أى قانون الجنسية. ولكن لم يؤيد هذا الاتجاه بالتوفيق ولم يحالفه الصواب ولاقى انتقاداتٍ لاذعةً تمثلت في:

١- أن الأساس الذى بنى عليه هذا الاتجاه فكرته لا يؤبّه به، فالموطن ليس مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولا يخضع للقانون الذى يحكمها، ولكنه واقعة مادية يترتب على تحققها نشوء علاقة قانونية تربط الفرد بالدولة التى يتوطن بها ترتب مجموعة من الآثار القانونية، وهذه العلاقة القانونية هى إحدى علاقات القانون العام ولا يمكن اعتبارها علاقة من علاقات القانون الخاص، وأنه على افتراض أننا سلمنا بما يدعو إليه هذا الاتجاه فإن الموطن سيصبح جزءاً من حالة الشخص السياسية وليس حالته العائلية، ومن ثم فلا يكون هناك أى مجال لتطبيق القانون الشخصي.

٢- أن هناك حالات يتعذر تطبيق القانون الشخصي عليها لتحديد موطنها كحالة عديم الموطن والذي يحتاج إلى تحديد موطن له ليكتسب جنسية دولة الموطن لأنه أيضاً عديم الجنسية، فإذا طبقنا وفقاً لهذا الاتجاه القانون الشخصي فإنه إما سيكون قانون موطنه أو قانون جنسيته، وهو في هذه الحالة لا موطن له ولا جنسية.

(١) د. هشام صادق : المرجع السابق، ص ٧٥٧، ٧٥٨.

٣- أن هذا الاتجاه ليس اتجاهًا عامًا ومجردًا ، فهو صالحٌ للتطبيق في حالاتٍ وغيرٍ صالحٍ في أخرى، وملائمٌ للتطبيق في بعض الدول وغيرٌ ملائمٌ للتطبيق في دول أخرى كالدول الأنجلو أمريكية والتي تخضع الأحوال الشخصية فيها لقانون الموطن كالدنمارك والنرويج، فما الحل إذا أخضعت الموطن للقانون الذي يحكم الأحوال الشخصية كما يُنادى هذا الاتجاه ؟ وهو هنا قانون الموطن فإنه يلزم لمعرفة القانون الأخير أن نعرف أولاً أين الموطن ؟، ولمعرفة هذا الموطن يلزم أولاً أن نعرف القانون الذي يتحدد وفقاً له .

الاتجاه الثالث- تطبيق قانون القاضي:

وهو الذي يُركّز فكرة أن يتم تحديد الموطن وفقاً لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع، مُبرراً ذلك بأن مسألة التحديد للموطن هي مسألة تكييف، والتكييف مستقرٌ في مجال تنازع القوانين على خضوعه لقانون القاضي، وأن القاضي إذا أراد تحديد موطن الشخص ليُطبق بشأنه قاعدة تنازع القوانين فإن هذا التحديد يُعد بمثابة تجديد لهذه القاعدة، ويعتبر عنصراً أو شرطاً في تطبيقها وهي أمورٌ متصلةٌ بالسيادة يتعين خضوعها لقانون القاضي^(١).

ولكن واجه هذا الاتجاه معارضةً شديدةً نتيجةً لكثرة فتوقه واتساع خروقه ووجهت له عدة انتقاداتٍ تمخضت في:

١- أن فكرة الموطن ذاتها فكرةٌ قانونيةٌ، يُعتبر تعريفها وبيانها أمراً من الوصف أو التكييف، ولكن تحديد الشروط التي ينبغي توافرها لثبوت هذا الموطن ليست تكييفاً ولا وصفاً، أي أن الفكرة كلها ليست تكييفاً، وهذا يُشير إلى أن هذا الاتجاه انتزع وصف التكييف لجزءٍ من فكرة الموطن، وقام بخلعه على الفكرة برمتها.

٢- أن هذا الاتجاه اهتم فقط بما للموطن من دور في مجال تنازع القوانين، وأغفل ما يقوم به المواطن من دورٍ فعالٍ وأساسي في مجالاتٍ أخرى كالجنسية والاختصاص القضائي ومركز الأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

(١) د.عز الدين عبد الله : القانون الدولي الخاص، الجزء الأول (الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق)، مرجع سابق، ص ٥٦٠، بند ١٥٣.

٣- أن مسألة تحديد الموطن لا تُعد مسألة تكييفٍ لأبد من إجراءاتها لتحديد قاعدة الإسناد والوصول إلى القانون الواجب التطبيق إلا إذا تعلقت بمضمون الفكرة المسندة دون تعلّقها بظرف أو بضابط الإسناد، وأنه ليس ثمة قاعدة من قواعد الإسناد يظهر فيها الموطن كفكرة مسندة، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يخضع فيها الموطن لقانون القاضى هي حالة تحديد المقصود به كضابط إسناد؛ حيث إنها لا تتور إلا أمام قضاء الدولة التي تنتمى إليها قاعدة التنازع.

الاتجاه الرابع- تطبيق القانون الإقليمي:

وهو الذى يتبنى فكرة قياس فكرة الموطن على فكرة الجنسية باعتبارهم من روابط التوزيع الدولى للأفراد مع الفارق بينهما في طبيعة الرابطة، فالرابطة في الجنسية رابطةً روحيةً اجتماعيةً سياسيةً قانونيةً تربط الفرد بالدولة التي ينتمى إليها بجنسيته، أما الرابطة في حالة الموطن فهي رابطة إقليمية محضة، ومن ثم فإنه قياساً على حرية الدولة في تنظيم جنسيتها دون أدنى تدخل من أى دولة أخرى، فإنه يجب أيضاً أن يكون تحديد الموطن وفقاً لقانون الدولة التي يدعى الشخص التوطن في إقليمها دون أي تدخل من قوانين الدول الأخرى، أى أن تكون الكلمة العليا في مسألة وجود الموطن من عدمه للقانون الإقليمي^(١).

الاتجاه الخامس- تطبيق القانون الذى يُرتب على الموطن أثره القانونى:

ويرى أنصار هذا الاتجاه وجوب التعامل مع مسألة تحديد الموطن بقدرٍ من المرونة وعدم التعقيد عن طريق عدم التقيد بقانون معين لإجراء هذا التحديد^(٢)، ويستصوبون تطبيق القانون الذى يرتب على الموطن آثاره القانونية، بحيث إنه لو أثّرت مثلاً مسألة القانون الواجب التطبيق على الموطن بشأن الجنسية كما لو كان الموطن شرطاً لاكتساب الجنسية المصرية أو فقدها، فإن القانون المصرى الذى يُرتب هذا الأثر هو الذى يتولى وحده تحديد مفهوم الموطن.

(١) د.عز الدين عبد الله : القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص ٥٦١، بند ١٥٤.

د.هشام صادق : الجنسية والموطن مركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٧٦١.

(٢) د.هشام صادق : المرجع السابق، ص ٧٧١.

ولكن لم ينفذ هذا الاتجاه بوجهة نظره من دائرة النقد التي رأت أن:

١- هذا الاتجاه قد التبس عليه الأمر وأشكل، فمن غير المنطقي أن يتم تحديد الموطن بالقانون الذى يحدد آثاره، فمن المعروف أن السبب هو الذى يُحدد الآثار ولا يمكن للآثار أن تُحدد السبب، وبالتالي فإن تحديد الموطن (السبب) تحددت تبعاً لذلك آثاره، أما الآثار المترتبة على وجود الموطن (كإمكانية اكتساب الجنسية والتمتع ببعض الحقوق) فتُحدد بذاتها موطن الشخص الذى هو سبب لهذا الاكتساب أو التمتع.

٢- أن الحل الذى يدعو إليه هذا الاتجاه لم يثمر عن جديد ولم يقدم سوى نظرة تقليدية لا تختلف عما قدمته الاتجاهات السابقة؛ حيث إن القانون الذى يرتب على الموطن آثاره القانونية قد يكون قانون القاضى أو القانون الإقليمى أو القانون الشخصى.

الاتجاه السادس- الجمع بين قانون القاضى والقانون الإقليمى:

ويُلْقَى هذا الاتجاه على القاضى التزاماً يحتم عليه ضرورة الرجوع في البداية إلى قانون دولته (قانون القاضى) لبيان ما إذا كان للشخص المعنى موطناً في بلد القاضى من عدمه؟، وفى حالة ما إذا أسفر هذا عن عدم ثبوت وتحديد موطن معين لهذا الشخص فى بلد القاضى فإنه فى هذه الحالة يتعين الرجوع إلى قانون الدولة التي يدعى الشخص التوطن على إقليمها (القانون الإقليمى) ^(١).

ولكن رُصدت على هذا الاتجاه مأخذ نات به عن الصواب وتاهت به في غياهب التخبط والتي من أهمها:

١- أن هذا الاتجاه لا يعرف الرشد من الغي؛ فمحاولته الجمع بين قانون القاضى والقانون الإقليمى للوصول إلى حل توفيقى هي محاولة غير مُجدية وليس فيها من التوفيق سوى الاسم فقط؛ حيث إن التوفيق من ناحية يكون بين مختلفين للتقريب بينهما، ومن ناحية أخرى نجد أن تطبيق قانون القاضى في أول الأمر يكون ليس باعتباره القانون الذى يحكم التكيف ولكن باعتباره القانون الإقليمى.

(١) د.عز الدين عبد الله : القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص ٥٦٣، بند ١٥٥٥.

٢- أنه لا يمكن التطبيق العملي لهذا الاتجاه لعدم صلاحيته لتحديد الموطن في العديد من الحالات التي يقف أمامها عاجزاً، كحالة إثارة فكرة الموطن بصدد تطبيق قاعدة تنازع وطنية في قانون القاضي^(١)؛ حيث إنه في هذه الحالة يجب أن يتحدد مفهوم الموطن وفقاً لأحكام قانون القاضي لانتماء قاعدة التنازع لهذا القانون وتعلقها بسيادته^(٢)، وأيضاً حالة إثارة فكرة الموطن بصدد تطبيق قاعدة تنازع أجنبية^(٣)؛ حيث إنه في هذه الحالة يجب أن يتحدد فكرة الموطن وفقاً للقانون الأجنبي الذي تخضع لسيادته.

الرأي الخاص:

وقد حقق المراد لدينا الاتجاه الذي يُنادى بتطبيق القانون الإقليمي، وذلك لأنه مُطرد السياق مُنفق القرائن داعمين ذلك بالاعتبارات الآتية:

أولاً: أنه لما كان قد اعترف لكل دولة بالحق في تنظيم جنسيتها بكامل حريتها وكذلك الاستقرار على السلطة الكاملة لكل دولة في تنظيم الاختصاص القضائي لمحاكمها الوطنية، فإنه من الطبيعي والبدهي امتداداً لذلك أن يترك لقانون كل دولة الحق والحرية والسلطة في تحديد الأشخاص المتوطنين على إقليمها وما إذا كان إقليمها موطناً بالفعل لهؤلاء الأشخاص من عدمه؟، وأن مسألة الموطن من المسائل التي تدخل في صميم النطاق المتروك لمطلق تصرف الدولة ولا يجوز التدخل من أي سلطة أخرى في تحديده لإرتباطه ارتباطاً وثيقاً بإقليمها.

(١) ومثال ذلك ما تنص عليه المادة ١٩ من القانون المدني المصري والتي تخضع الالتزامات التعاقدية لقانون موطن المتعاقدين، وبالتالي فإن تحديد مفهوم الموطن سيكون وفقاً لنص المادة التي عرفت الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً، وكان المتعاقدان في هذا المثال يقيمان في تركيا، وبذلك يكون القانون التركي هو القانون الواجب التطبيق حتى ولو لم يكن للمتعاقدين موطناً هناك وفقاً لأحكام هذا القانون.

(٢) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص ٢٧٠.

(٣) ومثال ذلك حالة طلب تنفيذ حكم أجنبي في مصر، حيث إنه يجب التحقق أولاً من اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم الأجنبي، فلو كان اختصاصها مؤسساً على وجود موطن للمدعى عليه في الإقليم الأجنبي وفقاً لقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي فيها، فإنه يجب أن يتحدد الموطن وفقاً لأحكام القانون الأجنبي التي تطبق قاعدة تنازع القوانين المنتمية إليه.

ثانياً: أن القانون الإقليمي في تحديد الموطن يُرشد إلى أن الدولة هي صاحبة الكلمة العليا على إقليمها وليست إرادة الأفراد، فلا بد من إقرار قانون الدولة التي يتوطن بها الشخص بموطنه فيها، وأنه لا عبرة بادعاء الشخص التوطن في دولة معينة دون اعتراف وثبوت قانون هذه الدولة له.

ثالثاً: قلة المثالب والمآخذ التي يمكن رصدها للاتجاه القائل بتطبيق القانون الإقليمي، وإن كانت مثالب تفرزها كل الحلول ككونه قد يُسفر عن تعدد المواطن أو انعدامها وغيره، إلا أنها من إفرازات وضرورات العلاقات الخاصة الدولية.

القسم الثالث

مركز الأجانب

مقدمة

مركز الأجانب من المسائل الأولية المهمة في القانون الدولي الخاص، وتبرز أهميتها عند نشوب المنازعات الخاصة الدولية، أى المتضمنة عنصراً أجنبياً؛ حيث يتعين حينئذٍ بحث مدى تمتع الفرد بالحقوق وتحمله بالالتزامات خارج نطاق الدولة التى يحمل جنسيتها، وهى البذرة لنشوء العلاقات الدولية والتى لا يمكن أن تنشأ إلا إذا كان للأجنبى القدرة على التمتع بالحقوق خارج حدود دولته الوطنية والتى يتوقف تمتعه بها من عدمه على موقف المشرع الوطنى للدولة التى يُريد الأجنبى اكتساب الحق فيها.

هـب أن أجنبىً قام بالتمسك بممارسة حق معين من الحقوق سواء أكان هذا الحق من الحقوق العامة أم من الحقوق الخاصة كالحق فى تملك قطعة أرضٍ أو الزواج من مصريةٍ، وهنا يتعين الرجوع إلى القانون المصرى لمعرفة ما إذا كان من حق هذا الأجنبى التمتع بحق التملك للاراضى أو الزواج من مصرية، ويقع على عاتق القاضى الوطنى تحديد مدى تمتع الأجنبى بالحقوق المتنازع عليها عن طريق الرجوع إلى القواعد الخاصة بمركز الأجانب فى جمهورية مصر العربية والمنصوص عليها فى التشريعات المصرية المنظمة والمُحددة لحقوق والتزامات الأجانب فى مصر، وذلك قبل تحديد القانون الواجب التطبيق على الدعوى الأصلية المطروحة أمامه.

وجديرٌ بالإيماء بأن الاعتراف للأجنبى بالشخصية القانونية لم يعد مجرد تفضل وكرم وتسامح من جانب الدولة المعترفة، بل التزام مفروض عليها فى مواجهة المجتمع العالمى لدعم قيام المزيد من العلاقات الدولية والتعامل الدولى،

ويترتب على الاخلال به قيام المسؤولية الدولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، فالأجنبي عضو في المجتمع الدولي والذي يتمتع بعضويته أيضاً الوطني^(١).

وفي ضوء ما سبق ستكون دراستنا لأحكام مركز الأجانب في إطار المباحث التالية :

المبحث الأول : المقصود بالأجانب وفئاتهم .

المبحث الثاني : التنظيم القانوني لمركز الأجانب .

المبحث الثالث : نطاق المركز القانوني للأجانب .

المبحث الرابع: دخول الأجانب مصر وإقامتهم بها وخروجهم منها وإبعادهم عنها .

المبحث الخامس: أحكام الاستثمارات الأجنبية في مصر في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ م .

(١) حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل إنسان حق الاعتراف بشخصيته في كل مكان " .

المبحث الأول

المقصود بالأجانب وفئاتهم

وسنتناول فيه المقصود بالأجانب في مطلب أول، وتقسيمات فئات الأجانب في مطلب ثانٍ وفق التقسيم التالي:

المطلب الأول

المقصود بالأجانب

أولاً- تعريف الأجنبي :

يُعرف الأجنبي بأنه ذلك الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة الوطنية، أى لا يحمل جنسية شعب دولة معينة وفقاً لقانون الجنسية الوطنية الخاص بتلك الدولة^(١)، فإذا كانت هذه الدولة هي جمهورية مصر العربية مثلاً فإن الأجنبي هو كل شخص لا يحمل الجنسية المصرية.

وقد عرفه جانب من الفقه بأن الأجنبي هو " من لا يحمل جنسية الدولة سواء أكانت له جنسية دولة أجنبية أم كان عديم الجنسية، وسواء أكان عابراً أم مقيماً أم متوطناً في إقليم الدولة وسواء أكان لاجئاً إلى إقليم الدولة أم داخلاً إليه بمحض إرادته " ^(٢)، بينما عرفه البعض الآخر بطريقة أكثر بساطة بأنه " كل من لا يحمل جنسية الدولة وفقاً لأحكام الجنسية الوطنية "، بينما ذهب فريق ثالث إلى أن الأجنبي مصطلح

(1) Revtllard : Mariel ; droit international privé etpartique notarial , 3ed 1993,paris,p339

(٢) د.عز الدين عبد الله : القانون الدولي الخاص، الجزء الأول" الجنسية ومركز الأجانب "، مرجع سابق، ص٦

يُطلق على " كل فرد لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للتمتع بجنسية الدولة الوطنية " (١).

وهناك من يرى بأن تحديد مفهوم الأجنبي عادةً ما يتم بطريقة سلبية؛ حيث يقتصر مشرع كل دولة على بيان من هم الوطنيون، ويتم تحديد الأجنبي بمفهوم المخالفة وذلك بكونه كل شخص غير وطنى سواء أكان هذا الشخص حاملاً لجنسية دولة أخرى أم كان لا يحمل جنسية أى دولة على الإطلاق، وبناء عليه يُعتبر مزدوج الجنسية من الأجانب، إلا إذا كان ينتمى إلى الدولة الوطنية بإحدى الجنسيات التى يحملها، فيُعتبر بذلك من الوطنيين ويعامل معاملتهم سواء بسواء من حيث التمتع بالحقوق أو التحمل بالالتزامات، ما لم تكن من بين الجنسيات التى يحملها جنسية دولة معادية (٢).

وبالنسبة للمشرع المصرى فقد وضع تعريفاً للأجنبي فى المادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها والتى تصدت لتعريف الأجنبي بأنه " يُعتبر أجنبياً، فى حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة" (٣).

(١) د. عوض الله شبيبة الحمد السيد، مركز الأجانب والجنسية المصرية، مرجع سابق، ص ٣٤

(٢) "حيث قد يخول هذا الوضع للدولة فى وقت الحروب اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية فى مواجهته، مثل وضع أمواله تحت الحراسة، حرصاً على أمن الدولة وسلامتها".

(٣) وهذا النص مماثل لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر فى فرنسا فى ٢ نوفمبر ١٩٤٥م بشأن الأجانب والذى نص على أن الأجانب هم " كل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية سواء لكونهم من جنسية أجنبية أو لكونهم لا يحملون أية جنسية على الإطلاق ".

" Tous individus qui n'ont pas la nationalite francaise soit qu'ils aient une nationalite etrangere, soit qu'ils n'ils n'aient pas de nationalite"

هل يُعتبر مُتعدد الجنسية أجنبياً أم وطنياً ؟

بحسب الأصل لا يُعد متعدد الجنسية وهو الذي يحمل جنسية أكثر من دولة أجنبياً، بل يُعد وطنياً لكل منها، وعند تراحم قوانين هذه الدولة بشأنه فإنه ينبغي تغليب إحداها على الجنسيات الأخرى، ومن ثم تطبيق قانونها .

الموقف من عديم الجنسية : عديم الجنسية هو من لا يتمتع بأى جنسية، وللمعانة التي يحياها عديم الجنسية اتجه المجتمع الدولي إلى إبرام بعض المعاهدات لمناقشة المركز القانوني لعديم الجنسية كاتفاقية نيويورك المُبرمة في سبتمبر ١٩٥٤م، ويُعتبر عديم الجنسية بمركزٍ أسوأ من الأجنبى بالنسبة للدولة التي يُوجد على إقليمها؛ إذ أنه لا يُعامل معاملة الوطنى إلا في بعض الحالات التي وردت على سبيل الاستثناء.

المطلب الثانى

تقسيمات فئات الأجانب

لما كان الأجنبى هو كل شخصٍ غير وطنى، فإنه من البدهى أن يتساوى جميع الأجانب على اختلاف صفاتهم وأنواعهم من الناحية القانونية أمام الدولة الأجنبية، ولكن يشهد الواقع العملى خلاف ذلك؛ حيث توجد العديد من طوائف الأجانب تتميز كل طائفة منهم بنوعٍ معينٍ من المعاملة يختلف عن ذلك النوع الذى تتمتع به الطوائف الأخرى، وتتمثل هذا الطوائف فى ما يلى:

١- **الأجانب العاديون:** ويمثلون الوضع الشائع للأجانب فى القانون الدولى الخاص، وهم الأشخاص الطبيعيين الذين يدخلون إلى الإقليم الوطنى بغرض السياحة أو الدراسة أو العمل أو الاستشفاء.... إلخ من الأغراض المعروفة.

٢- **الأجانب ذوو الحصانة:** وهم تلك الطائفة من الأجانب الأشخاص التي يتمتع أشخاصها بحصانة دبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في القانون الدولي العام مثل رؤساء الدول الأجنبية والموظفين الدوليين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدول.

ويستهدف أشخاص هذه الطائفة تحقيق مصالح عامة لصالح الدولة أو المنظمة الدولية التي يمثلونها، وذلك بعكس الأجانب العاديون الذين يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة بهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، ولذلك لا تدخل عادةً معاملة الأجانب ذوي الحصانة في دراسة مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص باعتبار خضوعها للعرف الدولي والمعاملة الدولية إلى جانب الاتفاقيات الدولية، وبصفة عامة لقواعد القانون الدولي العام.

٣- **عديمو الجنسية:** وهم الذين لا يتمتعون بجنسية أية دولة على الإطلاق، لذا يعتبروا بهذا أجانب عن جميع الدول، فعديم الجنسية إنسانٌ مشردٌ ومنزوع الهوية لا يتمتع بجنسية دولة معينة، ولا توجد دولة تعتبره من رعاياها وتوفر له بالتالي الحماية القانونية اللازمة، وجديرٌ بالإيمان أن التشريعات الداخلية لكل دولة لا تولى مركز الأجانب من عديمي الجنسية على أراضيها اهتماماً تنظيمياً قانونياً مستقلاً، وهو ما يضع على عاتق كل دولة التزاماً بتوفير الحماية اللازمة لعديم الجنسية وأن تُقرر له التمتع بالحقوق التي تتناسب مع كونه إنساناً آدمياً، إذ ليس لعديم الجنسية من دولة لتحمية أو ترعى مصالحه إذا تم الاعتداء عليها (١).

(١) د. أحمد قسمت الجداوى: الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٣٢٧، بند ٣٦٢.

٤- **اللاجئون:** اللاجئ ليس شخصاً عديم الجنسية، بل يحمل جنسية دولة ما ولكنه يُريد الهروب من تلك الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته خوفاً من الاضطهاد^(١)، وقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف المبرمة في ٢٨ يوليو ١٩٥١م اللاجئ بأنه " كل شخص يخشى بسبب جدى أن يُعذب بالنظر إلى جنسه أو عقيدته أو انتمائه إلى تنظيم اجتماعي معين أو بسبب آرائه السياسية، ويوجد خارج الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته، ولا يستطيع ولا يريد ـ بالنظر إلى هذه الخشية ـ أن يطالب بحماية هذه الدولة".

وقد وضع البعض تعريفاً شاملاً جامعاً لطائفة اللاجئين بأنهم " تلك الطائفة من الأشخاص المعرضين للاضطهاد أو التعذيب لأي سبب من الأسباب من التنظيمات القائمة في الدولة سواء أكانت هذه التنظيمات حكومية أم غير حكومية والذين يؤثرون الهروب من تلك الدولة خوفاً على حياتهم ومستقبلهم"^(٢)، فاللاجئ يلجأ في الغالب إلى ما يُسمى بحق اللجوء ومن خلاله يهرب من دولته الأصلية التي يحمل جنسيته إلى دولة أخرى يشعر بالثقة والطمأنينة ناحية نظامها السياسى القائم طالباً حمايته، وتتمتع الدولة المطلوب اللجوء إليها وحمايتها الحق المطلق في قبول أو رفض طلب اللجوء وفقاً لظروفها السياسية وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية

(١) وعادةً ما تعود أسباب هذا الاضطهاد إلى بواعث سياسية أو دينية أو عرقية ناتجة عن الاختلاف في المعتقدات السياسية والاجتماعية والدينية، كما قد تعود إلى اختلاف الجنس أو النوع أو الإثنية الاجتماعى أو التعذيب لأي سبب من الأسباب من قبل التنظيمات القائمة في الدولة سواء أكانت هذه التنظيمات حكومية أم غير حكومية والذين يؤثرون الهروب من تلك الدولة خوفاً على حياتهم ومستقبلهم " أو التعذيب أو فراراً من حرب أهلية، وقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف المبرمة في ٢٨ يوليو ١٩٥١م اللاجئ بأنه " كل شخص يخشى بسبب جدى أن يُعذب بالنظر إلى جنسه أو عقيدته أو انتمائه إلى تنظيم اجتماعي معين أو بسبب آرائه السياسية ويوجد خارج الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته ولا يستطيع ولا يريد ـ بالنظر إلى هذه الخشية ـ أن يطالب بحماية هذه الدولة".

(٢) د. عبد المنعم زمزم : مركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، مرجع سابق، ص ٢٣

مع التزامها في حالة قبول طلبه بعدة التزاماتٍ أهمها التزام بتوفير الحماية القانونية اللازمة والتزامها بتسليم اللاجئين إلى دولته الأصلية.

وبالنسبة لارتكاب الجرائم الجنائية فتتبع الجاني فيها حقّ طبيعي للمجتمع في القصاص منه، ترتباً على ذلك لا يجوز لمرتكبي هذه الجرائم طلب اللجوء السياسي لدولٍ أخرى، ولا يجوز لهذه الأخيرة قبولهم على أراضيها، ويسعى اللاجئين عادةً إلى الهروب من دولتهم الأصلية إلى إقليم دولةٍ أخرى يطمنون إلى التنظيم السياسي القائم فيها ويثقون في قدرته على حمايتهم، ويُسمى طلبهم في الإقامة على إقليم هذه الدولة بحق اللجوء، وللدولة المطلوب اللجوء إليها الحق المطلق في قبول أو رفض طلب اللجوء وفقاً لما تقضى به مصالحها السياسية، غير أنه إذا تم قبول اللاجئين على إقليم تلك الدولة فإنها تلتزم تجاهه بتوفير الحماية القانونية اللازمة، ومن أهم الالتزامات التي تترتب على كاهل الدولة التزامها بعدم تسليم اللاجئين إلى دولته الأصلية^(١).

٥- الأشخاص الاعتبارية: تُمارس الأشخاص الاعتبارية الأجنبية على إقليم الدولة نشاطاً كبيراً يؤثر تأثيراً مباشراً على اقتصادها الوطني وتربطه علاقةً طرديةً

(١) وقد يعرف الواقع الدولي أوضاعاً شاذةً وغريبةً لبعض أنواع من اللاجئين الذين قد يقدر عددهم بالملايين أو بشعوب بأكملها مثل المسلمين الذين كانوا مضطهدين في جمهوريات البوسنة والهرسك والجبل الأسود وبقية الجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد اليوغسلافي السابق، وللأسف الشديد مازالت منطقتنا العربية تحيا هذا الواقع الأليم المتمثل في مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المحرومين بصفةٍ أساسيةٍ من حق الإقامة في دولتهم الأصلية، وكان الوضع مقلوباً بالنسبة لهم، فالوضع العادي أن يوجد الشخص المضطهد في دولته الأصلية ثم يطلب - بسبب هذا الاضطهاد - اللجوء إلى دولةٍ أخرى، ولكن المستعمر الصهيوني فرض على هؤلاء الفلسطينيين وضعاً شاذاً وغريباً، حيث جعلهم خارج إقليم دولتهم الأصلية وأصبح حقهم في الرجوع إلى ذلك الإقليم أملاً يراودهم، وإذا كانت الدول التي يوجد فيها اللاجئين الفلسطينيون قد سمحت لهم بالإقامة على أراضيها، فإن القانون الدولي لم يكفل لهم بالمقابل الحماية القانونية المنشودة .

معه فإذا كان نشاط الأشخاص الاعتبارية الخاصة الموجودة على أراضي هذه الدولة حيويًا ومؤثرًا كان اقتصادها القومي مُنتعشًا، خاصةً مع تبني الدول حديثاً سياسات تقوم على الخصخصة والاقتصاد الحر وتنشيط دور القطاع الخاص في مختلف دول العالم، لذا تهتم كل دولة بتنظيم المركز القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، وذلك عن طريق الاعتراف لها بالحقوق اللازمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها في مقابل إلقاء بعض الالتزامات على كاهلها لصالح الجماعة الوطنية لتلك الدولة.

المبحث الثاني

التنظيم القانوني لمركز الأجانب

نظراً لأن تحديد حقوق الأجانب والتزاماتهم في دولة ما أمرٌ يهم كل من الدولة التي ينتمون إليها والدولة التي يحلون على إقليمها ويُقيمون فيها، فقد حظيت هذه المسألة بعناية كل من المشرع الوطني والدولي، وأصبح هناك نوعين من التنظيم القانوني لمركز الأجانب:

(أ) التنظيم القانوني الدولي لمركز الأجانب:

لم يحظ الأجنبي في ظل العصور القديمة بأى نوع من الاهتمام؛ حيث إنه لم يكن أهلاً لاكتساب الحقوق فكان في حكم عديم الأهلية، فليس له أن يتزوج أو أن يمتلك، ولكن مع التطورات التي لحقت بالمجتمعات البشرية وتغير الظروف أصبح من الضروري الاعتراف بالشخصية القانونية للأجنبي، حيث أبرمت العديد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة في هذا الشأن نذكر منها :

١- الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أبرمت في عام ١٩٦٦م ، والتي جاء من ضمن نصوصها حق تمتع كل إنسان بالحق الطبيعي في الحياة وعدم جواز الخضوع للتعذيب ، وحرية المغادرة .

٢- الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

٣- الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي من نصوصها حق كل فرد في العمل وتشكيل النقابات وحق كل فرد في مستوى معيشة مناسب لهإلخ .

٤- اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ١٩٨٤ م .

٥- اتفاقية عام ١٩٨٥ م بشأن تنقل السجناء والأجانب.

(ب) التنظيم القانونى الوطنى لمركز الأجانب :

لقد أجمع فقه القانون الدولى الخاص على حق الدولة فى تنظيم مركز الأجانب على إقليمها واختصاصها بتحديد ما يتمتعون به من حقوق وما يقع على عاتقهم من التزامات وما يتحملونه من تكاليف، إلا أنهم قد اختلفوا فى الأساس الذى يُبنى عليه هذا الحق ويتقرر وفقاً له هذا الاختصاص.

ونقصد بالتنظيم القانونى لمركز الأجانب بيان وتوضيح أهم القواعد القانونية التى تقرر مدى أحقية الأجانب فى التمتع بالحقوق العامة أو الخاصة فى دولة معينة سواء أكان هذا الأجنبى شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً والتعرض للقيود التى ترد على الشخصية القانونية لهذا الأجنبى^(١)، وهو ما سنعرض له فى المطالب الآتية :

المطلب الأول

أساس سلطة الدولة فى تنظيم مركز الأجانب

ذكرنا آنفاً أن فقد القانون الدولى الخاص قد أجمع على حق الدولة فى تنظيم مركز الأجانب على إقليمها، ولكنهم انقسموا حول أساس ذلك الحق إلى اتجاهين: ذهب أحدهما إلى أن الدولة تتمتع بالسلطة المطلقة فى تنظيمها للمركز القانونى للأجانب، وذهب الآخر إلى أن سلطة الدولة ماهي إلا سلطة مقيدة ، وسنفصل ذلك على النحو التالى:

(1) Loussouarn et Bourel : droit international privé , 4 ed, précis dalloz-Paris, 1993. p632.

الاتجاه الأول - للدولة سلطة مطلقة في تنظيم المركز القانوني للأجانب :

ويُعرف باتجاه الفقه التقليدي القديم، ويؤسس حق الدولة في تنظيم مركز الأجانب على إقليمها على حق السيادة الذي تتمتع به وتُمارسه على إقليمها وعلى مواطنيها، وهو ما يعطيها الحق في ممارسة هذه السيادة على كل من يوجد على إقليمها من أشياء أو أشخاص سواء أكانوا وطنيين أم أجانب وفرض ولايتها الشخصية والعينية عليهم^(١).

ويترتب على ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه أن تحديد مركز الأجانب من المسائل ذات الاختصاص الداخلي لكل دولة، وأن ما يتمتع به الأجنبي من حقوق ليست حقوقاً في حد ذاتها خالصة له، وإنما هي منحة وتفضل من الدولة تحددها كيف تشاء دون أن تتقيد في ذلك بأى قيد^(٢)، وهو ما يتعارض مع ما بات عليه مركز الأجانب في الوقت المعاصر والذي يعتبر الأجنبي عضواً في المجتمع العالمي ويستمد حقوقه من قانون هذا المجتمع العالمي وليس من قانون دولة معينة^(٣).

الاتجاه الثانى - سلطة الدولة مقيدة في تنظيم مركز الأجانب :

وتبناه الفقه الغالب ويرى أنصاره أن تمتع الأجنبي بالحقوق على إقليم الدولة ليس تسامحاً ولا منحة منها، بل هو حق مقرر له وفقاً لأحكام القانون الدولي، وإذا

(١) د. شمس الدين الوكيل : الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الثالثة، ١٩٦٨م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ٣٣٥. د.إبراهيم أحمد إبراهيم : مركز الأجانب وتنازع القوانين، طبعة ١٩٩٢م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٢١.

(٢) وهو ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية في من ميثاق الأمم المتحدة بأنه " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما "

(٣) د. عوض الله شيبه الحمد السيد : مركز الأجانب والجنسية المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩م، ص ٣٨.

كانت الدولة تتمتع بحرية وسلطة في تحديد ما يمكن أن يتمتع به الأجنبي من حقوق على إقليمها، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة من كل قيد، فسلطة الدولة تدور في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تلزمها بالاعتراف للأجانب بحد أدنى من الحقوق يُعرف بالحد الأدنى في معاملة الأجانب^(١)، ويترتب على ذلك ما يلي :

١- أن الدولة مقيدة وملزمة بما تمليه الاتفاقيات أو التعهدات الدولية، ومن أهم الأمثلة على القيود التي ترد على حقها ما يأتي :

أ- لا تملك الدولة أن تضع تشريعاً فيه تعسف غير عادل بالنسبة للأجانب بأن تفرض عليهم مثلاً ضرائب فادحة أو أن تضع عليهم قيوداً غير عادلة يشتم منها رائحة التعسف من جانبها في مواجهتهم .

ب- لا تملك الدولة أن تسن تشريعاً فيه إخلال بقواعد القانون الدولي العام ، أو بمعاهدة من المعاهدات التي ارتبطت بها .

٢- أن الفرد حقيقة واقعية لها وجود واستقلال تام يجب أن يلقي المعاملة الإنسانية التي تليق به كإنسان دون الأخذ في الاعتبار الدولة التي يحمل جنسيتها، وهو ما يقتضى الاعتراف له ببعض الحقوق نصت عليها المواثيق الدولية والتي من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن شخصية الفرد القانونية شخصية لصيقة

(١) حول هذا الاتجاه راجع : د. شمس الدين الوكيل : الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق ، ص ٧٧ وما بعدها، د. هشام صادق : الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، المجلد الثاني " مركز الأجانب "، منشأة المعارف، الإسكندرية ، ص ١٩، د. عز الدين عبد الله : القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، الطبعة ١١، ١٩٦٨م، الهيئة المصرية للكتاب، ص ٦٠٩، د. فؤاد رياض : الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول " الجنسية ومركز الأجانب "، الطبعة السابعة ١٩٩٢م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٤٠٤.

وملازمةً تذهب معه أينما يذهب وتلازمه أينما وجد سواء أكان في دولته أو خارجها .

٣- أن الدول جميعها تتخبط في جماعةٍ واحدةٍ هي الجماعة الدولية، وبالتالي يقع على عاتق كل دولةٍ من هذه الدول مراعاة حقوق الدول الأخرى داخل الجماعة الدولية والتي من أهمها حق كل دولةٍ في مراعاة وحماية رعاياها خارج إقليمها، وهو ما يوجب على كل دولة أن تراعى وهي تقوم بتحديد مركز الأجانب على إقليمها المعقولية والعدالة والتشابه مع ما تُقرره الدول الأخرى^(١).

٤- أن حق الدولة في تنظيم مركز الأجانب سيصطدم حتماً باعتبارات التساند والتعاون الدولي وما أصبحت عليه التجارة الدولية من تطورٍ مستمرٍ يزداد يوماً بعد يومٍ يعتمد على العلاقات الخاصة الدولية وتبادل السلع والخدمات بين الدول والذي يقتضى تيسيرها توفير قدرٍ كبيرٍ من التمتع بالحقوق للأجانب على إقليم الدولة .

ونحن نتفق مع أستاذنا الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم فيما ذهب إليه من أن المشكلة تكمن في الجماعة الدولية وعجز المجتمع الدولي عن القيام بدور المنظم لسيادة الدول والتحديد التشريعي الدولي لحقوق الأجانب والتزاماتهم وإلزام جميع الدول بتضمين تشريعاتها الوطنية ما اجتمعت وافقت عليه الجماعة الدولية، وبالتالي فإن الدور السيادي للدول والسلطة المطلقة في تحديد مركز الأجانب على إقليمها إنما ينبع وينمو في ظل قصور المجتمع الدولي وعجزه، وبالتالي فإن سيادة الدولة وقصور المجتمع الدولي هما وجهان لعملةٍ واحدةٍ^(٢).

(١) د. عوض الله شيبه الحمد السيد :مركز الأجانب والجنسية المصرية، مرجع سابق، ص ٤٠ .

(٢) حول هذا الرأي تفصيلاً راجع د.إبراهيم أحمد إبراهيم : مركز الأجانب وتنازع القوانين، مرجع سابق، ص ٢٢ .

المطلب الثانى

الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تنظيم مركز الأجانب

هناك مجموعة من الاعتبارات يجب على الدولة مراعاتها عند قيامها بتنظيم مركز الأجانب على إقليمها تكون متفقة مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتعين أن تكون تلك الاعتبارات عامة مجردة بعيدة عن أهدافها ومصالحها العليا وتحقق نوعاً من التوازن بين مصالح الدولة العليا وبين حق الأجانب فى الإقامة على إقليمها، وتتمثل أهم هذه الاعتبارات فى:

أولاً - الاعتبارات الأمنية: يُعد نظام الدولة الأمنى هو المعيار الأهم الذى تحدد وفقاً له الدولة مدى استعدادها لاستقبال الأجانب على أراضيها وإقامتهم فيها، ولا يقتصر مفهوم الأمن على مفهومه الجنائى أو البوليسى المتعلق بارتكاب الجرائم، وإنما يكتسب معنى واسعاً يمتد ليشمل كل ما من شأنه أن يحدث اضطراباً داخل المجتمع، ويترتب على ذلك حق الدولة فى عدم قبول كل أجنبى ترى أن وجوده يهدد أهداف الضبط الإدارى المتمثلة فى المحافظة على الصحة العامة والآداب العامة والسكينة العامة.

ويترتب على ذلك حق الدولة فى عدم قبول رعايا الدول التى تنتشر فيها الأوبئة أو الأمراض المعدية كالإيدز، أو الأمراض الناتجة عن الإصابة بالفيروسات القاتلة. كذلك يكون للدولة الحق فى أن ترفض قبول الشواذ جنسياً، ذلك أن وجودهم على الإقليم يחדش الشعور العام لدى المواطنين، وينطوى على مخالفة للآداب العامة فى ذلك الإقليم، ولعل قيام الدولة بقبول استضافة الأجانب على إقليمها وإقامتهم فيها لا يعنى أنها تقبل جميع طوائفهم دون قيد أو شرط، وإنما يكون من حقها استبعاد كل أجنبى ترى أنه يشكل خطراً على نظامها السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى

وذلك حفاظاً على نظامها الأمنى واستقراراً للثقة داخل مجتمعها، فأى دولة من حقها أن تحمى مجتمعها من أن يتسلل إليه المجرمين دولياً والمسجلين على قوائم إجرامية أو المشهور عنهم الإجرام أو أولئك المطاردين دولياً^(١).

ولكن لابد من التمييز بين فرضين :

الفرض الأول: إذا كانت فئة الأجانب تنتمي إلى دولة معادية أو كانت في حالة حرب أو عداً مع دولة أخرى، فيكون للدولة الأخيرة اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد الأجانب كمنع دخولهم إلى أراضيهم، أو إبعادهم عن إقليمها إذا كانوا يقيمون عليه قبل نشوب الحرب، وذلك كما هو الحال بين إسرائيل ومعظم الدول العربية، وما هو معروف بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ولها أيضاً أن تمنع دخول هؤلاء الأجانب إذا ما استشعرت بخطرهم كأن يحملوا أفكاراً أو معتقدات دينية أو سياسية غير التي يحملها سكان الدولة الأصليين .

وتتجلى قيمة الاعتبارات ذات الطابع الأمنى فى حالة الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد كحالة الحرب مثلاً، حيث تتخذ الدولة فى هذه الحالة إجراءات صارمة وعاجلة أهمها عدم قبول دخول أى أجنبى الأجانب إلى أراضيها وإغلاق موانئها الجوية والبحرية ومنافذها البرية.

الفرض الثانى : إذا كان هؤلاء الأجانب ينتمون إلى دولة تربطها علاقات صداقة مع الدول التى يتواجدون على إقليمها، فمثل هذه الدولة قد تفضلهم عن غيرهم من

(١) وقد لا يكون الأجنبى مجرمًا بطبعه، ولكن قد يُشكل وجوده على الإقليم الوطنى خطراً على النظام الاقتصادى أو الاجتماعى للدولة، ويبدو ذلك فى الفروض التى تتبنى فيها الدولة الوطنية النظام الرأسمالى نظاماً اقتصادياً لها ويطلب بعض الاشتراكيين المتطرفين فكراً والمعروف عنهم الكره الشديد للرأسمالية الدخول إلى إقليمها، فقد يترتب على وجوده - نظراً لما هو معروف عنه من أفكارٍ حادة ومتطرفة - خطراً على نظام تلك الدولة الاقتصادى فيكون لها الحق فى عدم قبوله على إقليمها.

الأجانب في المعاملة، بأن تسمح لهم بالتمتع ببعض الحقوق والامتيازات غير تلك التي يتمتع بها غيرهم من الأجانب الذين ينتمون إلى دولة أخرى .

ثانياً - الاعتبارات الاقتصادية: أصبح عالم اليوم لا يعترف إلا بالأقوى اقتصادياً؛ لأن الأقوى اقتصادياً يكون الأقوى تكنولوجياً وعسكرياً، وبالتالي فالأوضاع الاقتصادية تكتسب درجة عالية من الأولوية والاهتمام، وتحرص معظم الدول كل تطوير نظامها الاقتصادي وتقويته وتنميته، وهو ما يترتب عليه حرص الدولة ويقتضيه فعلى عدم قبول أى عنصر أجنبي يمكن أن يهدد نظامها الاقتصادي ويؤصيه بالاختلال، وبذلك تأخذ الدولة في اعتبارها أوضاعها الاقتصادية عند تنظيمها لمركز الأجانب على أراضيها.

وترتيباً على ذلك نجد أن الدول الاقتصادية الكبرى التي تتمتع باستقرار في ميزان مدفوعاتها غالباً ما تتبع سياسة مرنة في شأن استقبال الأجانب، إلا أنها بالمقابل قد تتشدد في مواجهة الأيدي العاملة التي قد تريد التسلل إلى إقليمها بقصد البحث عن فرصة عمل، أما الدول التي تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية فإنها تعتمد إلى فتح أبوابها تجاه الأجانب، كما تعتمد إلى إتباع سياسة تشجيعية في سبيل جذب طوائف معينة منهم كالمستثمرين، وذلك عن طريق تقرير العديد من التسهيلات التشريعية والإعفاءات الجمركية، فمصر مثلاً تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية ومياه الأنهار ولكنها تفتقر إلى رؤوس الأموال فتفتح أبوابها تجاه المشروعات الاستثمارية الأجنبية التي تهدف إلى تعمير الصحراء^(١).

(١) وهناك من الدول التي تمتلك آباراً بترولية وثروات معدنية ضخمة كدول الخليج العربي الكويت والسعودية والامارات فتفتح أبوابها تجاه المستثمرين المتخصصين في مجال التنقيب واكتشاف الثروات البترولية وتمتلك الخبرة لاستخراج تلك الثروات.

ثالثاً - اعتبارات الكثافة أو الندرة السكانية: تؤثر كثافة أو الندرة السكانية تأثيراً فعالاً في مسلك الدولة وهي تقوم بتنظيم مركز الأجانب؛ حيث إن الدول المكتظة بالسكان غالباً ما تتشدد في قبول طوائف معينة من الأجانب والسماح لهم بالإقامة على أراضيها، كالأجانب الباحثين عن فرص عمل حفاظاً منها العمالة الوطنية، ولا يمنعها ذلك من الاستعانة بالأجانب كخبراء أو تقرير مبدأ المعاملة بالمثل والسماح لرعايا الدولة الأجنبية التي تسمح لرعاياها بممارسة العمل على إقليمها بممارسة العمل على الإقليم الوطنى كالصين ومصر، أما سياسة الدول ذات الندرة أو الكثافة السكانية المنخفضة والتي لا يتناسب عدد سكانها مع مساحتها الجغرافية فإنها تكون مرنة للغاية في شأن قبول الأجانب من خلال تقرير حزمة من المزايا والتسهيلات التشريعية كالسماح بالهجرة، أو منح الجنسية بشروطٍ ميسرةٍ مثل كندا وأستراليا.

رابعاً - النشاط السياحي: تسعى كل دولة من الدول التي تمتلك طبيعةً جغرافيةً متميزةً إلى استغلالها على النحو الذي يخدم استثماراتها ويؤدي إلى تطوير اقتصادها القومي، فالدول ذات الطبيعة الشاطئية تلجأ إلى إنشاء القرى السياحية، في حين تلجأ الدول التي تمتلك تراثاً حضارياً أو ثقافياً إلى استثماره بقدر الإمكان بغرض الحصول على دخلٍ نقديٍّ ممكن، وذلك من خلال فتح أكبر عدد ممكن من قنوات الاتصال والتعاون مع الشركات السياحية الكبرى وإنشاء المزيد من الفنادق السياحية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى توفير العملة الأجنبية وتحقيق الرواج الاقتصادي الوطنى المنشود، كمصر مثلاً التي أنعم الله عليها بطبيعةً جغرافيةً وتراثاً حضارياً وثقافياً والذي يحتاج إلى حُسن استغلالٍ ليُجعل مصر في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى.

المطلب الثالث

القيود الواردة على سلطة الدولة فى تنظيم مركز الأجانب

لما كان لكل دولة سيادة كاملة على إقليمها، فإن هذه السيادة تقتضى الاعتراف لها بممارسة كافة السلطات على الأشخاص الموجودين على ذلك الإقليم، وبالتالي فإن للدولة السلطة المطلقة دون قيد أو شرط فى تنظيم مركز الأجانب؛ فهى التى تحدد شروط دخولهم إلى إقليمها، وكيفية، وإجراءاته، كما أنها هى التى تقرر أن يحرم من دخولها كل من ترى أنهم يشكلون خطراً على أمنها القومى ومصالحها الداخلية، بل قد تصل الدولة بهذه السلطة إلى أقصى درجات التعسف فتقرر حرمان جنس معين أو كل من ينتمون إلى دولة معينة بالذات من دخول أراضيها، ولكن مع تطور العلاقات الخاصة الدولية لا سيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت كل دولة تنتظر لنفسها على أنها عضو فى الجماعة الدولية، وأنه كما يوجد أجانب على أراضيها، يوجد وطنيون لها على إقليم الدولة الأجنبية يُعاملون بدورهم معاملة الأجانب، لهذه الأسباب استقر العرف الدولى على مجموعة من القيود يجب على الدولة مراعاتها بصدد تنظيمها مركز الأجانب على إقليمها، وتتمثل هذه القيود فى :

أولاً - مبدأ الحد الأدنى فى معاملة الأجانب :

يتبلور مضمون الحد الأدنى فى معاملة الأجانب فى تلك الطائفة من الحقوق التى لا يستطيع الإنسان القويم الاستغناء عنها، والتى تستند إلى صفته البشرية كإنسانٍ لتحفظ له كرامته وتكفل له حياة كريمة كالاعتراف بالشخصية الإنسانية والقانونية، وما يترتب على ذلك من حقه فى مباشرة كل التصرفات القانونية، وكونه أهلاً لاكتساب الحقوق أو التحمل بالالتزامات، وحقه فى تكوين أسرة شرعية والحق فى الانتفاع بخدمات المرافق العامة.

وبذلك يذهب الحد الأدنى في معاملة الأجانب في مضمونه إلى تلك الحقوق التي يحتاج إليها الإنسان عادةً في نشاطه اليومي، والتي يتطلبها بوصفه عضواً فعلياً في الجماعة الوطنية للدولة التي يتواجد على أراضيها مثل حق الأمن وحُرمة الحياة الخاصة، والتمتع بالحرية الشخصية، وحق الانتفاع بالمرافق العامة وحق التملك، وغالباً ما يقتصر أداء الدولة بصدد ممارسة هذه الحقوق على القيام بدورٍ سلبي، حيث يكفي أن تُقرر هذه الحقوق في قوانينها الداخلية وتترك للأجانب حرية ممارستها، كحرية التنقل وحرية الاعتقاد والتعبير، غير أنه ليست جميع الحقوق من هذه الطبيعة، إذ توجد مجموعة أخرى من الحقوق تتطلب لممارستها ضرورة قيام الدولة بدورٍ إيجابي كذلك المتعلقة بالانتفاع بالمرافق العامة، حيث يجب عليها في مثل هذه الأحوال القيام على إشباع الحاجات التي تؤديها هذه المرافق.

ويُمثل الحد الأدنى في معاملة الأجانب قيداً حقيقياً على سلطة الدولة في تنظيم المركز القانوني لتلك الطائفة من الأشخاص، فقد أصبح من المسلم به دولياً أن كل بلد يلتزم في معاملة الأجانب الموجودين على أراضيهِ بمجموعة من الحقوق تُمثل حداً أدنى لا يجوز تجاوزه، ويتأسس على أن قيام أي دولة بقبول المشاركة في الحياة الدولية ينطوي بالضرورة على قبولها الالتزام بالعمل على كفالة أسباب الإطراد، بل الازدهار لظاهرة انتقال الأفراد عبر الحدود، وهو ما يترتب عليه ضرورة إلزام تلك الدولة بالاعتراف للأجنبي بالحقوق التي تكفل أسباب هذا الإطراد وتُساعد على ازدهار العلاقات الخاصة الدولية.

ولقد استقر العرف الدولي على إلزام الدولة كل دولة أياً كانت درجة تخلفها بمراعاة ذلك الحد في معاملة الأجانب، ويترتب على ذلك عدم أحقية أية دولة في النزول عن ذلك الحد الأدنى في معاملتهم وإلا كانت مسئولة دولياً أمام الدولة التي

ينتمى إليها ذلك الأجنبي بجنسيته، ويكون لهذه الأخيرة حق التدخل بكافة السبل لحماية أفرادها، سواء أكان ذلك باتباع الطرق الدبلوماسية كتقديم احتجاج رسمي للدولة المعتدية أو طلب تفسير أو اعتذار عما حدث أم باتباع طريق القضاء الدولي بتحريك دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عما أصاب رعاياها من ضرر، كما يترتب على ذلك أيضاً عدم قدرة الدولة الاحتجاج بمعاملتها السيئة للوطنيين للتصل من التزامها بمراعاة الحد الأدنى في معاملة الأجانب؛ حيث إن تنظيمها للمركز القانوني للأجانب مقيد بمراعاة الحد الأدنى المقرر دولياً في معاملتهم^(١).

وقد يتمتع الأجانب في بعض الدول بحقوق تفوق تلك التي يتمتع بها الوطنيون أنفسهم، ويظهر ذلك في الكثير من دول العالم الثالث، وبخاصة بعض الدول الإفريقية، وهو ما قد يضعها في وضع مشابه لذلك الوضع الذي كان موجوداً في مصر في ظل الامتيازات الأجنبية، وهو مما لا شك فيه وضعٌ شاذٌ وغريبٌ يجب تلافيه.

ثانياً - القيود الاتفاقية:

تتقيد الدولة بالمعاهدات التي تبرمها في شأن تنظيم مركز الأجانب^(٢)، حيث إن روابط الصداقة أو التعاون الوثيقة بين دولتين أو أكثر، قد تدفعهم إلى تقرير

(١) وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في النزاع بين ألمانيا وبولندا بشأن مصالح الرعايا الألمان في سيليزيا العليا البولندية بأنه " لا يجوز للدولة أن تفرض معاملة لا يقرها القانون الدولي على الأجانب المقيمين بإقليمها بحجة أنها تُقرر نفس المعاملة للوطنيين " .

(٢) وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن " حق الأجانب في الإقامة في إقليم الدولة من الحقوق التي تستقل هي بالتصرف فيها وتنظيمها وتعيين ما يترتب عليها من آثار، دون أن يرد على سلطانها قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعاً خاصاً في هذا الشأن " - انظر الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في ٣١ من مايو ١٩٥٣م، مجموعة أحكامها، ص ٧ ص ١٣٨٢م .

المزيد من الحقوق للأجانب عن رعايا باقى الدول، عن طريق الاتفاق فيما بينها على تقرير التمتع بحقوق أخرى تزيد عن تلك الحقوق التى يشملها الحد الأدنى المقرر دولياً فى معاملة الأجانب، وبذلك تلتزم الدول المتعاهدة فى مثل هذا الفرض بتقرير الحقوق الواردة فى هذه الاتفاقية، كما تلتزم بكفالة ممارستها، وقد تكون هذه الحقوق المقررة وفقاً للمعاهدة مجاوزة للحد الأدنى من الحقوق الواجب الاعتراف بها بمقتضى العرف الدولى أو مساوية لحقوق الوطنيين أنفسهم أو مجاوزة لحقوق الوطنيين بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسمى هذه المعاهدات بـ "معاهدات الإقامة"⁽¹⁾.

ويقصد بهذه القيود "الحقوق والمزايا التى تجاوز الحد الأدنى أو القانونى لحقوق الأجانب"، ذلك أن النص فى المعاهدة أو الاتفاق على مضمون الحد الأدنى يُعد مجرد تأكيد للالتزام الدولة فى معاملة الأجانب، وبذلك يتبلور القيد الاتفاقى بالحقوق الزائدة عن الحد الأدنى المقرر دولياً فى معاملة الأجانب، فإذا اقتضت الاتفاقية على ذكر الحقوق التى تدخل فى مضمون ذلك الحد الأدنى، فإن المعاهدة لا تُشكل قيداً حقيقياً على إرادة الدولة، لأنها ملتزمة ذاتياً ومن حيث المبدأ بهذه الحقوق التى ورد تعدادها، وذلك باعتبارها عضواً فى الجماعة الدولية، وبالتالي تكتسب الاتفاقية فى هذا الفرض أثراً كاشفاً وليس مُنشئاً للحق.

والغالب أن يقتصر أثر المعاهدة على مجال التمتع بالحقوق الخاصة، كحق تملك الأراضى الزراعية أو المنقولات ذات القيمة الاقتصادية الخاصة، إلا أنه من المتصور أن تتناول الاتفاقية تقرير التمتع ببعض الحقوق العامة، كأن تسمح كلا

(1) Loussouam et Bourel : Droit international privé précis , Dalloz 3éd 1988 ,n 666,p.927

الدولتين (طرفى الاتفاقية) لرعايا الدولة الأخرى بممارسة نوع معين من أنواع الوظيفة العامة على أراضيها، إلا أنه يصعب تصور أن تتناول مثل هذه الاتفاقية ممارسة بعض الحقوق السياسية مثل تحويل رعايا الدولة الأخرى ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية.

ومن أمثلة المعاهدات المنظمة لمركز الأجانب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الموقعة في روما في ٤ نوفمبر ١٩٥٠م، واتفاقية روما في ٢٥ مارس ١٩٥٧م، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لسنة ٢٠٠١م .

المطلب الرابع

ضوابط تنظيم مركز الأجانب

هناك مجموعة من الوسائل يمكن تلجأ إليها الدولة لوضع التنظيم الفنى لمركز الأجانب، وتهدف هذه الوسائل فى المقام الأول تطوير مركز الأجانب ورفع الحد الأدنى فى معاملتهم، وتتمثل هذه الوسائل فى:

أولاً – مبدأ مساواة الأجانب بالوطنيين:

مساواة الأجانب بالوطنيين يُعد أفضل وسيلة فنية لتقديم أفضل معاملة للأجانب، ولكن ما مضمون هذا المبدأ ؟ وما نطاقه ؟

أ- المقصود بشرط مساواة الأجانب بالوطنيين :

قد تلجأ الدولة فى سبيل رفع الحد الأدنى فى معاملة الأجانب إلى درجة مساواتهم الكاملة فى الحقوق مع الوطنيين، رغبةً منها فى اجتذاب طوائف معينة منهم، وهم الطوائف الذين ترى فى وجودهم على إقليمها مصلحة قوية ومباشرة فى

تطوير مرافقها التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويتأسس شرط تشبيه الأجانب بالوطنيين على الاعتراف للأجنبي بكافة الحقوق المدنية وبعض الحقوق العامة التي تجاوزت الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي عادةً باعتباره عضواً فعلياً في الجماعة الوطنية، كالسماح بممارسة نوع معين من أنواع الوظيفة العامة.

ويشهد الواقع العملي أن بعض الدول الكبرى تلجأ إلى اجتذاب النواخب من دول العالم الثالث خاصةً المعيّدين في الجامعات الذين لا يجدون في بلدانهم الأصلية مناخاً مناسباً للبحث العلمي، فتقوم بفتح ذراعيها لهم، وتوفر لهم المنح الدراسية، ثقةً منها في قدراتهم، وهي بذلك تمنحهم حقوقاً لا تمنحها للأجانب العاديين، وبعد فترة معينة تقوم هذه الدول بمساواة هؤلاء الأجانب بالوطنيين مساواةً تامةً، بل إنها قد تعتمد إلى منحهم جنسيتها ليُعتبروا بذلك من الوطنيين، وتُجف بذلك إلى حد بعيد صلة هؤلاء الأفراد بوطنهم الأصلي، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة لعلماء مصريين مروا بنفس الظروف ويعيشون حالياً في مختلف دول أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص وكان أبرزهم العالم الراحل أحمد زويل.

وهناك دول الاقتصاد الحر والتي تعتمد إلى مساواة كبار المستثمرين الأجانب بالوطنيين، رغبةً منها في اجتذاب رؤوس أموالهم لاستثمارها على أراضيها عن طريق تهيئة المناخ القانوني اللازم عن طريق مساواة الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الطائفة بالوطنيين، وتقرر لهم العديد من التسهيلات والضمانات الاقتصادية كمنح فائدة بنكية مرتفعة وفرض سرية الحسابات، وعدم إفشاء أسرار العملاء، وخيراً مثال على ذلك دولة سويسرا التي تجتذب نسبةً كبيرة من رؤوس الأموال العربية^(١)،

(١) حيث تنص المادة ١١ من القانون المدني السويسري على أن " لكل شخص بوصفه إنساناً التمتع بكافة الحقوق المدنية دون اعتبار لصفته الأجنبية" .

ويتقرر مبدأ المساواة بمقتضى اتفاقية دولية تُعقد بين مجموعة من الدول تربطها روابط وثيقة اقتصادية وتجارية، وقد يكون بمقتضى اتفاقية ثنائية تعقد بين دولتين فقط، ومن أمثلة تلك الاتفاقيات الاتفاقية الأوروبية الموقعة في باريس في ١٢ ديسمبر ١٩٥٥م، واتفاقية برن لحماية المصنفات الفنية والأدبية المبرمة في ٩ سبتمبر ١٨٨٦م، والاتفاقية الموقعة بين الإتحاد السوفيتي وإيطاليا في فبراير عام ١٩٢٤م^(١).

ب- نطاق تطبيق مبدأ مساواة الأجانب بالوطنيين:

بالنسبة للنطاق الشخصي لمبدأ مساواة الأجانب بالوطنيين، أى تحديده من حيث الأشخاص المتمتعين به، فيقتصر أثره على رعايا الدول الأعضاء في الاتفاقية المقررة له، ولا يمتد لرعايا الدول الأخرى غير الأعضاء^(٢)، ومن حيث النطاق الموضوعي، أى من ناحية الحقوق التى تُحدد موضوعه، فالأجنبي يجب مساواته بالوطنى فى الحقوق المدنية فقط دون الحقوق السياسية لكون الأجنبي عضواً فعلياً فى الجماعة الوطنية للدولة وليس عضواً سياسياً أو رسمياً فيها، وترتيباً على ذلك لا يجوز للأجانب ممارسة الحقوق السياسية على مختلف أنواعها كحق الانتخاب أو حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية، كما أن مساواة الأجانب بالوطنيين إنما يكون فى مجال التمتع بالحقوق فقط، ولا يمتد ذلك إلى مجال التحمل بالالتزامات.

(١) انظر د. عوض الله شبيبة الحمد السيد: مركز الأجانب والجنسية المصرية، مرجع سابق، ص ٤٢.

(٢) وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على هذا المبدأ اعتبار الأجنبي من الوطنيين، وإنما يظل الشخص أجنبياً دائماً، ذلك أن هدف شرط المساواة هو رفع الحد الأدنى للأجانب، أى تطوير مجموعة الحقوق التى يتمتعون بها إلى الحد الذى يصل بهم إلى درجة المساواة مع الوطنيين فى بعض المجالات، ومن ثم فإن هذا الشرط لا يكسب الأجنبي صفة المواطنة.

ثانياً - شرط الدولة الأكثر رعاية:

ويُقصد بشرط الدولة الأكثر رعاية أن تتعهد الدولة بتقديم أفضل معاملةٍ من الممكن أن تُقررها بصدد التمتع بحق من الحقوق سواء في الحال أو في المستقبل لرعايا دولةٍ أجنبيةٍ معينةٍ أو للدولة الأجنبية ذاتها، وتُسمى الدولة مانحة الشرط بالدولة المُتعهِدة أو المُلتزِمة، في حين تُسمى الدولة التي تستفيد أو يستفيد رعاياها من هذا الشرط بالدولة المُستفيدة.

ويختلف شرط الدولة الأكثر رعاية عن مبدأ مساواة الأجانب بالوطنيين من حيث مدى التمتع بالحقوق، حيث إن مبدأ المساواة يعمل على مساواة الأجانب بالوطنيين، أما في حالة شرط الدولة الأكثر رعاية فإن الأمر لا يصل إلى حد المساواة، وإنما التمتع بأفضل معاملةٍ منحتها أو يمكن أن تمنحها الدولة المُلتزِمة للدولة المُستفيدة، أو تمتع رعايا هذه الأخيرة بالمعاملة المتميزة التي تقدمها الدولة المُلتزِمة، وبذلك يقتصر نطاق شرط الدولة الأكثر رعاية على تقديم أفضل معاملةٍ في نطاق التمتع بالحقوق.

ثالثاً - مبدأ المعاملة بالمثل :

ونقصد بهذا المبدأ أن تقوم الدولة بمعاملة الأجنبي الموجود على إقليمها بنفس المعاملة التي يُعامل بها مواطنوها على أراضي الدولة التي ينتمي إليها ذلك الأجنبي بجنسيته، و لا يقتصر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على طائفةٍ معينةٍ من رعايا الدولة الأجنبية، وإنما يمتد - دون تمييز - إلى جميع رعاياها الموجودين على الإقليم الوطنى سواء أكانوا علماء أم مستثمرين أم أجانب عاديين، كأن تُقرر دولتان مثلاً على سبيل التبادل السماح لرعايا بعضهما البعض بممارسة نوع معين من أنواع الوظائف العامة أو ممارسة مهنة التجارة أو المهن الحرة.

ولضمان فاعلية مبدأ التبادل أو المعاملة بالمثل يجب أن يكون هناك تقارباً في عدد مواطني كل دولة على إقليم الدولة الأخرى، فلو تم الاتفاق بين دولتين على أن تمنح كلا الدولتين لرعايا الدولة الأخرى الموجودين على أراضيها حق ممارسة مهنة معينة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين عدد مواطني كل دولة من الدولتين والموجودين على إقليم الدولة الأخرى، والغرض من ذلك ألا تستفيد إحداهما بطريقة تفوق بكثير استفادة الدولة الأخرى^(١).

ويتأسس هذا الشرط على فكرة التطابق أو التماثل، أى التعادل في الالتزامات المتبادلة بين الدول، فمثلاً لو اتفقت كل من مصر والسعودية على أن تسمح كل منهما لرعايا الدولة الأخرى الموجودين على أراضيها بشغل نوع معين من أنواع الوظائف العامة، لأدى ذلك إلى استفادة مصر من هذا التبادل بطريقة تفوق تلك الاستفادة العائدة على السعودية، وذلك نظراً لما قد يكون معروفاً من زيادة عدد المصريين الموجودين على إقليم دولة السعودية مقارنة بعدد السعوديين الموجودين على إقليم الدولة المصرية، وبناء عليه يجب أن تراعى الدول المتعاهدة أن يكون هناك تقارباً في عدد مواطنيها على أقاليم بعضها البعض، وليس المقصود بالتقارب التساوى الحسابي بين عدد مواطني كل منهما، فتلك عملية يصعب تحديدها، وإنما المقصود هو التقارب النسبي، وإلا أدى ذلك إلى اختلال الأداءات المتبادلة بين الدول المتعاهدة^(٢).

(١) د. فؤاد رياض: الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٣١٥ وما يليها

(٢) د. هشام صادق: مركز الأجانب، مرجع سابق، ص ١٧٢، بند ٣٣٨، د. عبد المنعم زمزم: مركز الأجانب في القانون الدولي والمصري، مرجع سابق، ص ٦٩ بند ٤٦.

صور التبادل أو المعاملة بالمثل :

قد يتخذ التبادل صوراً متعددة سواء نوجزها في الآتي ^(١):

١- التبادل الاتفاقي أو الدبلوماسي : وهو التبادل الذي يرد في معاهدة دولية، بمقتضاها تقرر دولتان أو أكثر لرعايا بعضها البعض التمتع بحق أو مجموعة من الحقوق تفوق الحد الأدنى المُعترف به دولياً في معاملة الأجانب، ومثال ذلك فرنسا التي اعتنقت هذا النوع من التبادل حيث يتمتع الأجنبي في فرنسا بنفس الحقوق المدنية المقررة أو التي يُمكن أن تُقرر في المستقبل للفرنسيين بموجب معاهدات مع الدولة التي ينتمي إليها ذلك الأجنبي ^(٢).

٢- التبادل التشريعي: يتقرر هذا النوع من التبادل في التشريعات الداخلية لكل دولة، ويتم عادةً بالنص على جواز تمتع الأجنبي بحق معين يزيد عن الحد الأدنى في معاملة الأجانب، إذا كان ذات الحق مُقررًا لرعايا تلك الدولة في تشريعات الدولة التي ينتمي إليها ذلك الأجنبي؛ فإذا كانت الدولة الوطنية تعلق تملك الأجانب للعقارات على أراضيها على وجود معاملة تشريعية مماثلة في الدولة الأجنبية، فإنه يكفي الأجنبي الذي يُريد تملك عقار على إقليم

(١) حول صور التبادل أو المعاملة بالمثل راجع :

Batiffol et Lagarde : Traité de droit international privé , op.cit , n 186, p.313

(٢) حيث تنص المادة ١١ من القانون المدني الفرنسي على أن "

" L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra " .

الدولة الوطنية أن يثبت أن تشريعات دولته تُقرر ذلك الحق للأجانب الموجودين فيها.

٣- التبادل الواقعي: وهو التبادل الذي يتقرر بمقتضى العرف والممارسة الفعلية، وبمقتضاه تقوم الدولة الوطنية بمعاملة الرعايا الأجانب لدولة ما بنفس المعاملة الفعلية التي يلقاها مواطنوها على إقليم تلك الدولة، وعادة ما يسود هذا النوع من التبادل بين الدول المتجاورة التي يوجد بينها روابط مشتركة مثل وحدة الأصل واللغة والعادات والتقاليد، كما يسود أيضاً بين الدول التي يوجد بينها انتقال مستمر ومتبادل للأفراد عبر الحدود.

٤- تبادل الحق بالحق: وبواسطة هذه الصورة من صور التبادل تسمح الدولة الوطنية لرعايا الدولة الأجنبية بممارسة ذات الحق الذي يمارسه رعاياها على إقليم تلك الدولة الأجنبية. ويتميز هذا النوع من التبادل بالبساطة، إذ يكفي لوجوده ثبوت تمتع الأجنبي على إقليم الدولة الوطنية بنفس الحق وبذات الشروط التي يتمتع بها مواطنو الدولة الوطنية على إقليم الدولة الأجنبية.

٥- التبادل على أساس التعادل: بمقتضى هذا النوع من التبادل تُعلق الدولة الوطنية تمتع الأجانب بممارسة حقوق معينة على أراضيها على تمتع مواطنيها في إقليم دولة هؤلاء الأجانب بحقوق ترى أنها تُعادل نفس الدرجة من الأهمية وإن كانت لا تتطابق معها، ويتصور ذلك عندما تكون الدولة الوطنية دولة زراعية وتكون الدولة الأجنبية دولة تجارية أو صناعية، فتسمح الدولة الوطنية لرعايا الدولة الأجنبية بممارسة مهنة الزراعة على أراضيها

في مقابل السماح لرعاياها بالاستغلال بالتجارة أو الصناعة على إقليم الدولة الأجنبية^(١).

٦- التبادل بتعداد الحقوق: وتنهض هذه الصورة من التبادل على أساس التعداد الحسابي للحقوق التي تسمح الدول لرعايا بعضها البعض بالتمتع بها، فإذا أرادت دولتان أو أكثر تحقيق التبادل بالنسبة لحقوق معينة فإنها تقوم بحصرها في قائمة بهدف الاتفاق بشأنها، ويُشترط في الحقوق موضوع هذا النوع من التبادل أن تكون فوق الحد الأدنى المُعترف به دولياً في معاملة الأجانب، وترتيباً على ذلك لو قامت دولتان بالاتفاق على أن يكون لرعايا بعضها حقوق معينة كالحق في دخول الإقليم، والحق في الحصول على تأشيرة إقامة، والحق في التمتع بالشخصية القانونية، فإن ذلك لا يُعد تبادلاً أو رفعاً للحد الأدنى في معاملة الأجانب، وإنما يُعد تقريراً لواقع دولي، وحقوق مُعترف بها دولياً، وتمثل الحد الأدنى في معاملة الأجانب.

نموذج المجموعة الأوروبية الموحدة نموذج مثالي للوحدة الحقيقية :

وكانت البداية في ١٤ يونيو سنة ١٩٨٥م حينما وقعت كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا اتفاقية الشنجن بهدف إزالة إجراءات التفتيش في

(١) ويُشير البعض إلى أن تقرير التبادل على أساس التعادل وبطريقة تعادل الحقوق دون تطابقها يستجيب في مرونته إلى تحقيق مصالح الدولة؛ حيث يحول للأجانب التمتع بحق معين مقابل تمكين رعاياها من التمتع بحق آخر قد تظهر حاجتهم إليه في الخارج أو حاجتها هي أيضاً، إذا قررت ممارسة النشاط موضوع هذا الحق على أراضيها - انظر د. شمس الدين الوكيل: الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٣٥٥، بند ١٥٧.

الحدود المشتركة بينهم، وبعد خمس سنوات تقريباً وبالتحديد في ١٩ يونيو ١٩٩٠م وقّعت الاتفاقية المنفذة لهذا الاتفاق بهدف تحقيق الأهداف التالية :

- ١- إزالة الحدود وإلغاء إجراءات التفتيش بين الدول الأعضاء.
- ٢- السماح لأي شخص حاملٍ لجنسية أية دولةٍ عضوٍ بالعبور لبقية الدول الأعضاء دون الحصول على تأشيرة دخول (فيزا).
- ٣- التوفيق بين النصوص المتعلقة بدخول غير الأوروبيين وإقامتهم في منطقة الشنجن وذلك بإنشاء نظام فيزا الشنجن الموحدة، بحيث يكون لكل شخصٍ حاملاً لهذه الفيزا حق الدخول والبقاء في أي من الدول الأعضاء لمدة ٩٠ يوماً لكل ستة أشهر من مدة الفيزا.
- ٤- يكون للشخص غير الأوروبي المصرح له بالإقامة في إحدى الدول الأعضاء حق الإقامة في أية دولةٍ أخرى دون تطلب بطاقة إقامة جديدة، وذلك لمدة ٩٠ يوماً كل ستة أشهر.
- ٥- إنشاء نظام لتبادل المعلومات يُسمى نظام معلومات الشنجن، ويسمح هذا النظام للدول الأعضاء بتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الموجودة في منطقة الشنجن، أو تلك التي ترغب في دخولها أو ممارسة نشاط فيها، والغرض من هذا النظام هو تحقيق تعاون بوليسي وقضائي وتوحيد الجهود في مكافحة الإجرام عبر الحدود، وما يترتب على ذلك من رفض دخول كل من سبق وأن هدد وجوده النظام الأمني في إحدى الدول الأعضاء.

ولم تقتصر مظاهر الوحدة على النواحي الإجرائية فقط، وإنما امتدت أيضاً لتشمل النواحي الموضوعية. حيث استقرت الدول الأوروبية على الاعتراف بالمزيد من الحقوق للأجانب الأوروبيين الموجودين على أراضيها والتي تُجاوز بكثير ذلك الحد الأدنى المُعترف به دولياً في معاملة الأجانب، الأمر الذي قد يصل إلى حد المساواة مع الوطنيين في كثير من الأحيان، ولم يقتصر هذا الاعتراف على الحقوق الخاصة كحق تملك العقارات أو المنقولات ذات القيمة الاقتصادية الخاصة أو الحق في ممارسة النشاط التجاري والصناعي، وإنما امتد أيضاً ليشمل بعض الحقوق العامة التي تتسم بقدر من الحساسية مثل تولى وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات الوطنية.

دعوة الأمة العربية لتكوين نموذج عربي للوحدة الحقيقية :

كيف تستطيع الدول الأوروبية التي تختلف عن بعضها البعض في الدين واللغة والأصل والعادات والتقاليد أن تُكوّن نموذجاً فريداً ورائعاً للوحدة بينهما ولا تستطيع أمتنا العربية التي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكوين هذه الوحدة أن تُحقق وحدة عربية ؟ خاصة وأن :

- (أ) الدول العربية تدين بدينٍ رسمي واحدٍ لا تدين به أوروبا .
- (ب) تتكلم الدول العربية لغةً واحدةً لا تتكلم بها أوروبا التي تُوجد بها العديد من اللغات.
- (ج) يجمع الدول العربية أصلٌ مشتركٌ واحدٌ .
- (د) تقوم الدول العربية على عاداتٍ وتقاليدٍ واحدةٍ .

هـ) تجمعنا كأمةٍ عربيةٍ واحدةٍ آمالٌ وطموحاتٌ واحدةٌ، وجراحنا وألمنا واحدةً

.

المبحث الثالث

نطاق المركز القانوني للأجانب

إن دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة يُلقى على عاتقها التزاماً بالاعتراف له بمجموعة من الحقوق التي تضمن له حياةً كريمةً ويُقرها المجتمع الدولي وتدعمها القيم الإنسانية سواء أكانت هذه الحقوق حقوقاً عامة أم حقوقاً خاصة، كما يلتزم هذا الأجنبي بتحمل بعض الأعباء والتكاليف العامة، ومن ثم فإن الحديث عن نطاق المركز القانوني للأجانب يتطلب التعرف على أهم الحقوق التي يمكن أن يُمارسها الأجنبي وأهم التكاليف العامة التي يلتزم بها الأجنبي على النحو التالي:

المطلب الأول

الحقوق والحريات العامة

أولاً- اكتساب الشخصية القانونية والتمتع بالشخصية الإنسانية :

أي قيام الدولة التي يُقيم فيها هذا الأجنبي بالاعتراف له بالشخصية القانونية وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار، فالاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية من السمات اللصيقة بالإنسان، ومن الحقوق الأساسية المقررة له وفق ما استقرت عليه الجماعة الدولية وأقره القانون الدولي المعاصر والتي لا يجوز بأى حال من الأحوال تجريده منها^(١)، وبالتالي يكون الأجنبي صالحاً لأن يكون أهلاً لاكتساب الحقوق أو التحمل بالالتزامات ومباشرة كافة التصرفات القانونية كالبيع والشراء والرهن

(١) حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة السادسة منه على أن " لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية"، ونصت المادة ١٨ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن " الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان " .

وغيرها والتمتع بالحقوق العائلية كالزواج والطلاق والبنوة والنسب والإرث وغيرها، وذلك فى حدود القانون وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة^(١).

ثانياً - التمتع بالحريات الشخصية :

فالأجنبي يتمتع داخل الدولة بالحرية الكاملة لشخصه، حيث تضمن له الدولة سلامته، فلا تقوم بحبسه أو اعتقاله إلا وفقاً للقانون ، وتضمن له حرية التعبير عن رأيه، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم وحرية الاجتماع وغيرها من الحقوق الشخصية ، ولكن كل ذلك لا ينفي حق الدولة في تقييد ممارسة الأجنبي لهذه الحقوق إذا خالفت النظام العام أو الآداب العامة في الدولة^(٢).

ثالثاً - حق الانتفاع بالمرافق العامة (٣):

من المُستقرّ عليه دولياً حتمية السماح للأجنبي بالانتفاع بالمرافق العامة كمرافق المياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات والصحة والتعليم والقضاء والضمان الاجتماعى وغيرها، إلا أن بعض الدول تعلق حق الأجنبي فى الانتفاع بمرافق القضاء على دفع الأجنبي كفالة قضائية لضمان دفع التعويضات أو سداد

(١) د. عز الدين عبد الله: الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة العاشرة، ١٩٧٧م، ص ٦١٩ وما بعدها، د. فؤاد رياض: الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦م، ص ٢٨٧ وما بعدها .

(٢) حول هذه مدى تمتع الأجنبي بهذه الحريات انظر د. فؤاد رياض: الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٢٨٦، بند ٣٠٠، د. أحمد قسمت الجداوى : الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٧م، ص ٤٤٤ وما يليها، د. هشام صادق: المجلد الثانى " مركز الأجانب "، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧٧م، ص ٧٤ وما يليها، د. أشرف وفا محمد: المبادئ العامة للجنسية ومركز الأجانب فى القانون المقارن والمصرى، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٠م ، ص ٣٤٣ وما بعدها .

(٣) المادة ٢٦ من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان .

المصاريف اللازمة في حالة ما إذا أخفق الأجنبي وخسر دعواه ولسد الذرائع أمام الدعاوى الكيدية للأجنبي^(١).

وقد أقر المشرع المصري للأجنبي حق الانتفاع بالمرافق العامة دون قيدٍ أو شرطٍ، ولم يفرق في ذلك إلا بالنسبة لانتفاع الأجنبي بمرفق الضمان الاجتماعي حيث فرق المشرع بين نوعين من الأجانب^(٢):

- الأجانب العرب: ويستفيد أفراد هذه الطائفة من مرفق الضمان الاجتماعي بشرط المعاملة بالمثل .

- باقى الأجانب: يشترط لاستفادتهم من مرفق الضمان الاجتماعي بشرط المعاملة بالمثل والإقامة المستمرة في مصر لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب المعاش، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وإذا تعلق الأمر بمساعدات أو إعانات اجتماعية فلا تشترط مدة العشر سنوات .

المطلب الثالث

حق العمل وممارسة المهن الحرة وتقليد الوظائف

أولاً - حق تقليد الوظائف العامة:

بات مستقراً في القانون الدولي^(٣) والقانون المصري حرمان الأجنبي من تقليد الوظائف العامة، ولكن يجوز الاستعانة بهم على سبيل الخبرة والاستشارة^(٤)، وذلك

(1) Batiffol et Lagard : Traite de droit international privé , op.cit , p.307,n 184 .

(٢) انظر المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧م .

(٣) انظر :

فى أحوالٍ استثنائيةٍ وبعد أن يثبت أن الوظيفة تتطلب مؤهلاتٍ علميةً خاصةً لا تتوافر فى مصرى، وذلك بطريق التعاقد بإبرام عقد توظيف لا تزيد مدته عن سنةٍ واحدةٍ تبدأ من تاريخ استلام العمل ويجوز تجديدها بعد اخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ وذلك نظراً لما تتمتع به الوظائف العامة من طبيعةٍ حساسةٍ ومساسها المباشر بالمصالح العليا للبلاد^(٢).

ثانياً- الحق فى العمل :

لقد اعترف المشرع المصرى للأجبنى بالحق فى العمل على الإقليم المصرى وحدد فى سبيل ذلك فى المواد من ٢٧ إلى ٣٠ من قانون العمل الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م^(٣) قواعد ممارسة الأجبنى لحق العمل على الإقليم المصرى وأخضعه لعدة شروطٍ تتمثل فى:

- ١- شرط المعاملة بالمثل .
- ٢- أن يكون مُصرحاً للأجبنى بدخول البلاد .
- ٣- أن يكون مُصرحاً للأجبنى بالإقامة بقصد العمل .
- ٤- الحصول على ترخيص بالعمل من الوزارة المختصة .

Mayer et Heuze : droit international privé , paris, 7 édition ,2001 , p.642,n987.

(١) د. هشام صادق : مركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٨٣.

(٢) انظر المادتان ٢، ٤ من قرار وزير التنمية الإدارية رقم ٢ لسنة ١٩٧٩م والخاص بعمل الأجانب .

(٣) نصوص هذا القانون منشورة بالجريدة الرسمية فى ٧ أبريل ٢٠٠٣م، العدد ١٤ مكرر.

وبناء عليه أصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرار رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٣م فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب^(١)، وقد اتفق موقف المشرع المصرى مع ما استقر عليه دولياً بشأن السماح للأجانب بممارسة العمل على الإقليم الوطنى بشروط تهدف إلى المحافظة على العمالة الوطنية والحد من العمالة الأجنبية، ولكن يرى البعض أنه غالى فى سداد مبلغ ألف جنيه مصرى مقابل حصول الأجنى على ترخيص العمل^(٢)، وأغفل وضع حد زمنى لوصول الموافقة الأمنية على الترخيص، وكان عليه أن يحددها بشهر ولا يتركها مطلقة^(٣).

ثالثاً - ممارسة المهن الحرة :

لقد أعطى المشرع المصرى للأجنى حق ممارسة المهن الحرة ولكنه ميز بينهم ؛حيث أجاز للأجانب من رعايا الدول العربية ممارسة بعض المهن كالمحاماة^(٤)، والصيدلة^(٥)، ومنع الأجانب من غير رعايا الدول العربية من ممارسة هاتين المهنتين، بينما أجاز المشرع للأجانب من رعايا جميع الدول ممارسة العديد

(١) نصوص هذا القرار منشورة فى الوقائع المصرية، العدد ١٧٢ (تابع) فى ٢ أغسطس ٢٠٠٣م .

(٢) انظر المادة السابعة من القرار.

(٣) د. عبد المنعم زمزم : مركز الأجانب فى القانون الدولى والقانون المصرى، مرجع سابق، ص ١٨٧.

(٤) حيث اشترطت المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون مصرياً، كما قضت المادة ٤٢ من ذات القانون بأنه للمحامين من رعايا الدول العربية المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة بشروط محددة.

(٥) حيث يشترط وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون نقابة الصيادلة رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩م للقيد بالجدول العام للنقابة أن يكون طالب القيد مصرياً أو من إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وبعد موافقة الجهات المختصة.

من المهن الحرة الأخرى بشرط المعاملة بالمثل كالكيمياء الطبية^(١)، والطب^(٢)، والطب البيطري^(٣)، وطب الفم والأسنان^(٤)، والعلاج الطبيعي^(٥).

رابعاً - الحقوق السياسية:

الحقوق السياسية هي الحقوق التي يكون موضوعها المساهمة في التعبير عن إرادة الدولة والتي تتضمن ولو بشكل غير مباشر المشاركة في إدارة شئون الحكم في الدولة كالحق في الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب وغيرها، ويُحرم الأجنبي من التمتع بهذه الحقوق وتقتصر ممارستها على الوطني، وهو مبدأ من المبادئ المستقرة في القانون الدولي نظراً لتطلب ممارسة هذه الحقوق ارتباطاً صاحبها ارتباطاً سياسياً وثيقاً بالدولة وضمان ولاءه التام لها وهو ما يفترقه الأجنبي؛ لأن اشتراك الأجنبي في حكم الدولة التي يقيم بها وتمتعه بالحقوق السياسية ويتعارض مع ما يلتزم به من واجبات حيال دولته الأصلية^(٦).

(١) انظر نص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤م، والمنشور بالوقائع المصرية في الأول من يولييه سنة ١٩٥٤م، العدد ٥١ مكرر .

(٢) انظر نص المادة الأولى من القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤م بشأن مزاولة مهنة الطب، والمنشور بالوقائع المصرية في ٢٢ يولييه ١٩٥٤م، العدد ٥٨ مكرر .

(٣) انظر نص المادة الأولى من القانون رقم ٤١٦ لسنة ١٩٥٤م بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والمنشور بالوقائع المصرية في ٢٢ يولييه ١٩٥٤م - العدد ٥٨ مكرر .

(٤) انظر نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٥٤م في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، والمنشور بالوقائع المصرية في ١٤ أكتوبر ١٩٥٤م - العدد ٨٢ مكرر (أ) .

(٥) انظر المادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥م في شأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي، والمنشور بالجريدة الرسمية في ٢١/٣/١٩٨٥م - العدد ١٢ تابع .

(٦) انظر د. أحمد قسنت الجداوى : الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٣٩٢، دشمس الدين الوكيل : الموجز الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، ١٩٦٨م ، ص ٤٠٨ وما بعدها .

المطلب الثالث

حق تملك الأموال المادية

ولابد من التفريق بين المنقولات والعقارات ومدى أحقية الأجنبي في تملكها :

فيما يتعلق بالمنقولات: نجد أن غالبية دول العالم تُجيز للأجنبي تملك كافة المنقولات مالم يكن تملك هذا المنقول يمثل خطراً على الدولة بأمنها الداخلي والخارجي، كحظر تملك بعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الوطنية الرئيسية، كما تُقيد بعض الدول على الأجانب تملك الأسهم والسندات خشيةً من سيطرة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد القومي.

وبالنسبة للمشرع المصري فقد أجاز للأجانب تملك المنقولات التي تتفق مع كون الأجنبي عضواً فعلياً في الجماعة الوطنية، بينما حرم عليهم تملك المنقولات ذات القيمة الاقتصادية الخاصة بالسفن والطائرات وذلك على النحو التالي:

(أ) السفن : وفقاً للمادة الخامسة من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠م^(١) فإنه يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر الشرطين: أولهما أن تكون مسجلةً في إحدى الموانئ المصرية، وثانيهما أن تكون مملوكةً لشخصٍ طبيعي أو اعتباري مصري، وإذا كانت مملوكةً على الشيوع فيجب أن تكون أغلبية الحصص مملوكةً لمصريين، وبذلك يتعين التفرقة بين فرضين:

(١) حيث تنص المادة الخامسة من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠م على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلةً في أحد موانئها، وكانت مملوكةً لشخصٍ طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكةً على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكةً لمصريين " .

أولهما: عندما يكون مالك السفينة شخصاً طبيعياً، وهنا تقتصر الملكية على المصرى فقط دون الأجنبى.

ثانيهما: عندما تكون السفينة مملوكةً على الشيوع لشخص اعتبارى، وهنا يشترط المشرع لاكتساب السفينة للجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص مملوكةً لمصريين، ونص فى المادة ١٢ من قانون التجارة البحرية على ضمان لهذا الحظر وتحقيق فاعليته وفى فقرتها الثانية على جزاء مخالفة هذا الحظر^(١).

(ب) الطائرات: الطائرات كالسفن تماماً ذات قيمة اقتصادية عالية تمثل أساساً من أسس الاقتصاد الوطنى، ولذا فقد حظر المشرع المصرى على الأجانب تملك الطائرات وذلك فى المادة ٥٩ / ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦م بشأن الأحكام الخاصة بالطائرات^(٢)، وتطبيقاً لذلك أصدر وزير السياحة والطيران المدنى القرار رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٧٨م والمُعَدِّل بالقرار رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٢م واشترط فى المادة الثالثة منه لتسجيل الطائرة فى السجلات المصرية - وتمتعها الجنسية المصرية تبعاً لذلك - أن تكون مملوكةً بالكامل لمصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين^(٣)، وفى حالة مخالفة الحكم، أى بيع الطائرة لأجنبى، وبالتالي فقدان

(١) حيث نصت المادة ١٢ من قانون التجارة البحرية على أنه "

١- لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين، إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .

٢ - ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة . "

(٢) وقد نصت المادة ٥٩ / ٢ قد نصت على أنه " تنظم بقرار من الوزير المختص كيفية تسجيل الطائرات فى السجلات التى تُعد لذلك فى الجهة الإدارية، الهيئة العامة للطيران المدنى " .

(٣) حيث تنص المادة الثالثة من القرار على أنه " كل طائرة مملوكة لمصرى سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يجب تسجيلها فى السجل العام المصرى المنصوص عليه فى المادة الأولى " .

الطائرة لجنسيتها المصرية فقد نصت المادة التاسعة من القرار المذكور على أن " تُشطب الطائرة من السجل العام في حالة التصرف فيها إلى أجنبي ...".

تعقيب : لقد اتخذ المشرع المصري موقفاً غير مبرر بل وغير مفهوم ؛ فهو لم يساو بين السفن والطائرات في الحكم رغم احتلال الاثنين ذات القيمة الاقتصادية النفسية؛ حيث سمح للأجنبي بتملك السفن بطريقة جزئية إذا كانوا من المساهمين في تأسيس الشخص الاعتباري مع مصريين، بينما كان موقفه مغايراً بالنسبة للطائرات، وكان يجدر به المساواة بينهما في الحكم وحرمان الأجنبي من تملك السفن والطائرات بشكل مطلق وتام .

أما فيما يتعلق بالعقارات فنجد أن القانون الدولي لم يستقر على مبدأ موحد بشأن تملك الأجنبي للعقارات وترك الأمر خاضعاً لسلطة كل دولة وتشريعها الداخلي وفقاً لما يتفق وظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية^(١)، وبالتالي فهذا الأمر محل خلاف بين التشريعات المقارنة نظراً للأهمية القصوى لمثل هذه الأموال؛ حيث إنها تُعتبر جزءاً من الإقليم الترابي للدولة، ومن هنا نجد أن بعض الدول تحظر تملك الاجانب للعقارات كأصل عام، ومنها ما يسمح للأجانب بتملك العقارات بشروط محددة كضرورة الحصول على إذن سابق من الدولة، ومن الدول ما تقيد الأجنبي بتملك العقارات التي تقع في المناطق الصحراوية أو المناطق الحدودية القريبة من دول الجوار.

(١) فالدول الرأسمالية مثلاً منها ما يمنع مطلقاً تملك الأجنبي للعقارات، ومنهم من يسمح بتملك الأجنبي لأنواع معينة من العقارات، أما الدول الاشتراكية فتُحرم الملكية الفردية على الوطنيين انفسهم فمن باب أولى تحريمها على الأجانب .

وبالنسبة للمشرع المصرى فقد قرر فى البداية حرمان الأجانب من تملك العقارات فى مصر، ولكن مع تبنى الدولة المصرية لسياساتٍ جديدةٍ معتمدةٍ على الاقتصاد الحر وتشجيع وتحفيز رأس المال العربى والأجنبى، فقد تنازل المشرع عن قاعدة الحرمان التام للأجنبى من تملك العقارات وقرر بعض الاستثناءات بخصوص أنواع معينة من العقارات :

حظر تملك العقارات المتاخمة للحدود :

قرر المشرع المصرى حرمان الأجانب من تملك العقارات المجاورة للحدود سواء أكان هذا الأجنبى شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، ولعل العلة من وراء هذا الحظر تكمن فى ما تمثله هذه المناطق من أهمية بالغة؛ فهى منفذ الدولة على باقى الدول الأخرى الأجنبية، وبالتالي فملكيته لابد أن تكون قاصرةً على الوطنيين فقط، وذلك حمايةً للأمن القومى الوطنى، ويسرى هذا الحظر حتى فى حالة التملك لهذه العقارات بطريق الميراث؛ حيث تقوم الدولة بنزع ملكيتها مع دفع تعويضاتٍ مناسبةٍ لذوى الشأن .

حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وجواز تملكهم للأراضى الصحراوية:

يحظر المشرع المصرى على الأجانب وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م تملك الاراضى الزراعية وما فى حكمها^(١).

(١) حيث نصت المادة الاولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م على أنه " يحظر على الأجانب سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع، ولا تعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم

أولاً- نطاق حظر تملك الأجانب للأرض الزراعية :

(أ) نطاق الحظر من حيث الأشخاص:

ينصرف الحظر على الأجانب، وهو شرط بدهي يقوم على أساسه الحظر كله، والأجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

ويشمل الحظر الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على السواء، فكما ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الأجنبية: ولا يشترط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الأجنبية أن يكون الشخص المقصود مُتمتعاً بجنسية الدولة الأجنبية؛ إذ يُعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبياً، وبناءً على ذلك فالعبرة في اعتبار الشخص أجنبياً هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية.

وعند الخلاف في توافر الجنسية لدى شخص معين من عدمه، وكذا لدى جمعية معينة أو شركة معينة من عدمه، يجب الاعتداد بالشهادة التي تصدرها وزارة الداخلية، لاعتبار الشخص مواطناً مصرياً: فإذا كان الشخص مزوداً بهذه الشهادة الرسمية فإنه يتمتع بصفة المواطن المصري، إلى أن يتم إلغاء هذه الشهادة بقرارٍ مسبب من وزارة الداخلية، ويطبق نفس الحكم على الشركات والجمعيات .

ويلاحظ أيضاً أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر، والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقاً للقوانين المعمول بها في مصر، وبغض النظر عن جنسية

٥٢ لسنة ١٩٤٠م المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأرباح. ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتاً".

الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري قد اتخذ مصر مقراً لنشاطه الرئيسي.

ويلاحظ أن الجنسية المصرية لا تزول عن المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد حصوله على الجنسية الأجنبية الجديدة، وليس من تاريخ صدور القرار الجمهوري بالإذن له بالتجنس بهذه الجنسية، والحكمة من ذلك هي درء انعدام جنسية المأذون له في حالة تعذر اكتساب الجنسية الأجنبية أو تراخيه، والأثر المترتب على ذلك أنه متى ثبت أن التصرف قد تم خلال الفترة بين صدور القرار الجمهوري بالإذن بالتجنس وتاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية الجديدة، فإن المصري يكون بمنأى من الاستيلاء على أرضه بالتطبيق للقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م.

والمشرع المصري لم يقصر المنع من تملك الأجانب للأراضي الزراعية على الرقبة، وإنما عمم المنع لكي يشمل الرقبة وحق الانتفاع، وإذا كان المشرع قد منع الأجانب من تملك الرقبة فهذا أمرٌ منطقي وضروري، لأن ملكية الرقبة ملكية دائمة، أما قيام المشرع بمنع الأجانب من تملك حق الانتفاع وهو حق مؤقت بطبيعته، فهو وإن بدأ منطوياً على نوع من التشدد، إلا أن الرغبة في منع السيطرة الأجنبية على الأرض الزراعية تُعد دافعاً قوياً ومبرراً مقبولاً لهذا النص.

استثناء بعض الأجانب من قاعدة الحظر:

(أ) الاستثناء الأول - الفلسطينيون:

كان المشرع المصري يُجيز في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م للفلسطينيين أن يملكوا الأراضي الزراعية في مصر، وذلك

على سبيل الاستثناء، ثم ألغى هذا الاستثناء بمقتضى القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٥م.

ومعنى ذلك أن الفلسطينيين أصبح وضعهم في مصر في ذات الوضع بالنسبة للأجانب، وقد أوجب القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٥م على من يملك منهم أرضاً بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون، أي الأجلين أقرب.

ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينيين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية، وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضاً إذا بقي الشخص الفلسطيني حياً دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص.

وتجدر الملاحظة إلى أن الأثر المستقبلي لهذا القانون هو عدم جواز اكتساب ملكيات جديدة، أى ابتداءً من العمل بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٥م.

(ب) الاستثناء الثانى - الجمعيات الخيرية الأجنبية:

وقد ورد هذا الاستثناء في القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧١م وهو يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.

وقد قدر المشرع أن هذه الجمعيات تمارس نشاطاً إنسانياً، فأجاز أن تستثنى هذه الجمعيات من حظر تملك الأراضي الزراعية لغير المصريين، ولكن يشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاث شروط:

١- أن تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمةً في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢م، وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل فإنها تستمر، وإذا زادت عن مائتين فدان، فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويضٍ عادلٍ.

٢- أن تكون هذه الجمعيات قائمةً وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢م.

٣- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذا القانون.

(ج) الاستثناء الثالث - المجمع المقدس بروما:

وقد تم استثناء هذا المجمع من حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية بمقتضى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧١م، وعلة هذا الاستثناء هي المجاملات الدولية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ولأن دواعي الحظر المقررة في القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م غير متوافرة بالنسبة له.

ومضمون هذا الاستثناء أنه يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية، شريطة أن يلتزم بأحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري.

(د) الاستثناء الرابع - حكم خاص بالأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمتعين بجنسية إحدى الدولة العربية:

صدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٨م ونص في المادة الأولى منه على الآتي:
"ولا يفيد من التملك وفقاً لأحكام هذا القانون سوى المصريون، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسبابٍ يُقرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من

يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون"، ثم صدر القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩١م في شأن الأراضي الصحراوية.

(هـ) الاستثناء الخامس - حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا:

بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في ٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠م وصدق عليها مجلس الشعب في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٠م، يجوز لليبيين أن يملكوا الأراضي الزراعية في مصر.

وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي: "يتمتع مواطنو أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية، وذلك وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما".

وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية. فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

(ب) نطاق الحظر من حيث الموضوع:

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية، وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية.

(١) المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية:

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "إذا كان المشرع يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية، فإن المشرع لم يتعرض للمشروعات ذات الصبغة التجارية المملوكة للأجانب، ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات. " .

(٢) تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية:

أتى المشرع المصري بمقتضى القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحظر في هذا الخصوص، ولكن نظراً لما لوحظ من الاندفاع الشديد لدى غير المصريين إلى تملك أراضي البناء والعقارات المبنية، سواء لإقامة مشروعات، أو لاقتناء هذه الأراضي والعقارات بقصد إعادة بيعها للاستفادة من زيادة قيمتها في السوق، وبذلك زادت شيئاً فشيئاً رقعة أملاك غير المصريين، وتملكوا في أحسن المواقع، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف المباني، فقد حظر القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموماً، سوء أكانت هذه الأراضي أراضي زراعية أم أرض فضاء أم عقارات مبنية، وفي عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملاً للعقارات بكافة أنواعها.

وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الأجانب من تملكها، وبين الحظر الوارد في القوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب أراضي الفضاء والعقارات المبنية، وتتمثل هذه الأهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.

الاستثناءات التي ترد على القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ م هي كالتالي :

- ١- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث.
- ٢- إذا كان اكتساب الحق في نطاق أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
- ٣- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذها مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية.
- ٤- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء التي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ م.

وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٥ م سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبينة والأراضي الفضاء، ثم صدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٨ م ليحل محل القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ م.

ثانياً- تطبيق القانون (الأثر المباشر والفوري للقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ م

:(

إن أهم ما يتميز به القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ م الخاص بحظر تملك الأجانب للأرض الزراعية أنه يُطبق بأثر فوري أو بأثر مباشر، ومؤدي ذلك إلغاء الملكيات التي كانت قائمة للأجانب وعدم جواز تملك الأجانب لأي أراضي زراعية منذ لحظة العمل بهذا القانون في المستقبل، وذلك أيّاً كان سبب هذا التملك، أي سواء كان سبب التملك إرادياً أم سبباً غير إرادي، وذلك على النحو الآتي :

(١) الأسباب الإرادية للملك:

نصت المادة العاشرة من القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م على الآتي :
"يقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".

ويترتب على تطبيق حكم النص السابق أنه لا يجوز لأي أجنبي أن يملك أرضاً زراعية بطريق التعاقد، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون، حيث يقع التعاقد باطلاً وعديم الجدوى؛ إذ أن الملكية العقارية لا تنتقل إلى الشخص إلا بالتسجيل، وأيضاً قضى هذا النص بعدم جواز تسجيل أي تصرف ينقل الملكية إلى الأجنبي.

وبالبطلان المنصوص عنه في المادة العاشرة يُعدُّ بطلاناً مطلقاً، بمعنى أن التصرف يعتبر معدوماً من الناحية القانونية، وبناء على ذلك يجوز لكل ذي شأن وأيضاً يجوز للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، كما يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإذا كانت قواعد قانون الإصلاح الزراعي من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، فإن تقرير بطلان تملك الأجنبي للأراضي الزراعية يُعدُّ أمراً حتمياً ولازماً، ولا يجوز مخالفته.

(٢) الأسباب غير الإرادية للملك:

نصت المادة (١١) من القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م على أنه يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكل حالة تؤول فيها

ملكية أراضي زراعية أو ما في حكمها إلى أجنبي بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون.

كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابعة خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية، وتستولي الحكومة في هذه الحالة على تلك الأراضي مقابل التعويض المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

والمُعول عليه أن الأراضي الزراعية الموروثة وما يلحق بهاتمر بزمة الأجنبي الوارث أو الموصى له، ثم أنها لا تستقر في هذه الزمة، حيث تؤول ملكيتها إلى الدولة مقابل التعويض الذي تدفعه الدولة إلى الوارث أو الموصى له، وهذا الأمر غير متصور إلا إذا كان الأجنبي قد تسلم الأرض الزراعية بالفعل، وذلك كأثر مباشر للميراث أو للوصية التي تنقل الملكية مباشرة إلى الوارث أو الموصى له، أما إذا لم يكن الأجنبي قد تسلم الأرض الزراعية وما في حكمها بالفعل لكانت قد آلت ملكية الأرض الموروثة أو الموصى بها إلى الدولة وانتقلت إليها بمجرد وفاة المورث أو الموصى.

وأخيراً فإن الأرض التي يتم الاستيلاء عليها بعد انتقال ملكية الأرض إلى الأجنبي عن طريق الميراث أو الوصية يتم التعويض عنها، وهذا التعويض غير ممكن التصور إلا إذا كانت الأرض تؤول للأجنبي ويتسلمها بالفعل ثم تستولي الحكومة عليها.

وبناءً على ما تقدم كله فلا يجوز القول بأن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م يحظر التوريث للأجنبي، أو يحظر نقل الملكية للأجنبي عن طريق الوصية.

أيلولة ملكية الأجنبي إلى الدولة:

تقضي المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م بأنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها، ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة على أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦١م".

وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المشار إليها في المادة السابقة، وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢م".

ومن مقتضى النصوص السابقة أن ملكية الأرض تزول عن صاحبها من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م. فيصبح مجرداً من أي صفة في التعامل فيها بأي وجه كان .

وبناء على ذلك تؤول ملكية الأجنبي للأرض الزراعية والأرض البور والأرض الصحراوية إلى الدولة، كما تؤول ملكية ملحقات هذه الأرض إلى الدولة، وبعبارة أخرى تؤول ملكية الأجنبي للأرض الزراعية وما في حكمها وملحقاتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣م، وملحقات الأرض الزراعية التي تشمل المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمة الأرض.

كما تؤول إلى الدولة أيضاً حقوق الارتفاق المقررة لصالح الأرض التي انتقلت إليها ملكيتها على الأرض الأخرى، وبصفة عامة يؤول إلى الدولة ملكية كل حق يلحق بالأرض أو ارتفاق مقرر لمنفعة الأرض، سواء بحكم القانون أو بحكم الاتفاق، وكذلك كل ما يُعد عقاراً بالتخصيص وفقاً لأحكام القانون المدني.

التعويض المستحق للأجنبي :

سبق وأن قلنا أن الدولة تستولى على ملكية الأجنبي في مقابل تعويض، وهذا التعويض يجوز أن يؤدي عن طريق سندات اسمية ... إلخ .

ومن حيث قدر التعويض فقد أحال القانون ١٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تحديده على قواعد تحديد التعويض الواردة في المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والواردة في المادة ٥ من هذا المرسوم والتي كانت تنص على أن " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض يُعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافاً إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار، وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية " .

إلغاء التعويض المستحق وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وأثره على الأجانب :

صدر القانون رقم ١٠٤ لعام ١٩٦٤م لينص في مادته الأولى على أن " الأرض الزراعية التي تم الاستيلاء عليها تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل " .

صدور القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١م وإعادة الحق في التعويض :

صدر هذا القانون في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م ونص في مادته الأولى على أن " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض عادل يُعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافاً إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار، وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة

الأصلية المربوطة بها الأرض، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة في التقدير العام لضرائب الأقطان المعمول به منذ أول يناير ١٩٤٩م لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أرض الدولة، ولا يُعتبر هذا التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " .

(ج) تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء :

مر تملك الأجانب للمباني والأراضي الفضاء بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى- القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء(١):

ويُقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون : المباني والأراضي ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون في شأن ضريبة الأقطان، ويُقصد بالشركة غير المصرية : أى شركة أياً كان شكلها القانوني لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها .

شروط تملك الأجانب للمباني والأراضي الفضاء :

١- موافقة رئيس مجلس الوزراء على تملك الأجنبي للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء .

٢- أن يكون التملك لعقار واحد في إحدى المدن أو المصايف أو المشاتي بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته .

(١) نصوص هذا القانون منشورة بالجريدة الرسمية في ٩ / ٤ / ١٩٨٨م، العدد ١٤ مكرر.

٣- ألا تزيد مساحة هذا العقار المبنى بملحقاته والأرض الفضاء على ثلاثة آلاف متر مربع .

٤- ألا تكون ملكية العين حصّة شائعة مع مصرى .

٥- أن يُحوّل عن طريق أحد بنوك القطاع العام التجارية نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بسعر السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبى يُعادل الثمن الفعلى الذى يملك به العقار .

٦- ألا يكون العقار من العقارات المُعتبرة أثراً فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار .

الاستثناءات من الأحكام السابقة :

أجازت لمجلس الوزراء أن يعفى الأجنبى من بعض هذه الشروط ، وذلك فى الحالات التى تقتضيها مصالح البلاد القومية أو السياسية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الاجتماعية أو غير ذلك من اعتبارات الملاءمة، كما يجوز الاستثناء من الشرط الخاص بتحويل النقد الأجنبى على أن يصدر بهذا الاستثناء قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .

كما أن لمجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استثناء حالات التصرف لغير المصريين فى العقارات المبنية والأراضى الفضاء الثابتة التاريخ قبل العمل به من بعض أو كل الشروط الواجب توافرها للتملك ، وذلك فيما عدا الشرط الخاص بتحويل النقد الأجنبى، وإلى جانب ذلك فإن لمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجمعات العمرانية الجديدة التى يحددها

القيود الوقتية على ملكية الأجانب :

١- يجب على الأجنبي الذى اكتسب ملكية أرضٍ فضاءٍ أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تجاوز السنوات الثلاث لشهر التصرف .

٢- لا يجوز للأجنبي الذى اكتسب ملكية عقارٍ أن يتصرف فيه بأى وجهٍ من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية .

جزاء مخالفة أحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ م :

يقع باطلاً كل تصرفٍ يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ثانياً- القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء(١):

الشروط اللازمة لتملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضى الفضاء :

١- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، وبذلك يظهر التخفيف من ناحيتين : فقد أصبح للأجنبي الحقيقى تملك عقارين بدلاً من عقارٍ واحدٍ، كما أصبح للأجنبي تملك هذين العقارين فى جميع أنحاء الجمهورية، فى حين أنه كان يحق له تملك عقارٍ واحدٍ فى إحدى المدن أو المصايف أو المشاتى فقط.

(١) نصوص هذا القانون منشورة بالجريدة الرسمية، العدد ٢٧ مكرر، فى ١٤ يوليو ١٩٩٦ م .

٢- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر، وهذا بخلاف القانون السابق الذى كان يُحدد مساحة كل عقار بثلاثة آلاف متر مربع فقط .

٣- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .

٤- ألا يكون العقار من العقارات المُعتبرة أثراً فى حكم قانون حماية الآثار .

ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الأول والثانى وذلك فى الحالات التى يُقدرها، ويترتب على مخالفة هذه الشروط هو بطلان التصرف وعدم جواز شهره.

ثالثاً- القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار:

والغرض منه تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر من أجل استصلاح واستزراع المزيد من الأراضى، وزيادة الازدهار وتحقيقاً لهذا الغرض أجاز القانون لهذه الشركات والمنشآت الأجنبية تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه، ويُقصد بالشركات والمنشآت الأجنبية فى مفهوم هذا القانون تلك الشركات والمنشآت الأجنبية التى تزاوُل أحد الأنشطة الآتية :

١- استصلاح واستزراع الأراضى البور والصحراوية أو أحدهما .

٢- الانتاج الحيوانى والسمكى .

المطلب الخامس

الحق فى الملكية المعنوية

أولاً - حقوق الملكية الأدبية والفنية :

الإبداع الفكري له طابعٌ حضاري متميزٌ، ومن هنا تولد الحرص على ضرورة حمايته وتشجيعه، ولذلك قامت الدول بإعداد القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وانخرطت في العديد من الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية القانونية والقضائية لها، كما أنشئت من أجل ذلك المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي تقوم بدورٍ ريادي في هذا المجال، ويدل على ذلك عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وكذا العدد الكبير من المعاهدات الدولية التي تُديرها المنظمة، ولقد أدى التطور في ميدان حقوق الملكية الفكرية إلى تغيير النظرة إلى حقوق المؤلف، إذ أصبحت حقوقاً تكتسب أهميةً دوليةً، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، بل أصبحت هذه الحقوق الآن أداةً فعالةً في التنمية الاقتصادية، وما ذلك إلا بسبب القيمة الاقتصادية المهمة للابتكارات والاختراعات.

ينصرف معنى الملكية المعنوية كأصلٍ عامٍ الى الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية^(١)، وتشبه حقوق الملكية الفكرية غيرها من حقوق الملكية؛

(١) الملكية الفكرية هي ما يُنتجه ويُبدعه العقل والفكر، فهي الأفكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يُمكن حمايتها، وتشتمل حقوق الملكية الفكرية على: (حقوق الملكية الصناعية) و(حقوق الملكية الأدبية)، وتشمل الملكية الصناعية بنوداً متعددة: كالاختراع، والرسوم، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والدلائل (المؤشرات) الجغرافية، كما أن الملكية الأدبية تشمل عدداً من البنود منها: المؤلفات، وبرامج الكمبيوتر، والتصميمات للدوائر المتكاملة، المعلومات السرية، والفنون، والأشعار، والروايات، والمسرحيات، والأفلام، والمصنفات الفنية مثل: الرسوم واللوحات الزيتية، والصور الشمسية، والمنحوتات والتصاميم الهندسية،

فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حتى المؤلف بالاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه، كما تتقرر له حماية ضد أي تعدٍ من الغير ، وتعد هذه الحقوق جميعاً ذات قيمة مالية لمالكها التي هي نتاج إبداعه العقلي والذهني، فهي وإن كانت حقوقاً غير مادية أو غير ملموسة إلا أنها حقوق ذات قيمة مالية يدركها جل المتعاملين في التجارة الدولية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث تُعتبر عنصراً مهماً في أغلب هذه النشاطات .

حقوق الملكية الصناعية هي بشكلٍ عام حقوقٌ احتكاريةٌ تمنح لأشخاصٍ مُعينين دون الآخرين لاستغلال ابتكارٍ جديدٍ أو إشارة مميزة من الوجهة الاقتصادية والتجارية، لأن الأموال محل هذه الحقوق المحمية تتصل بالصناعة أو التجارة وتُسمى حقوق الملكية الصناعية، فحقوق الملكية الصناعية ظهرت وتطورت ولا زالت حتى الآن حقوقاً وطنيةً، بمعنى أن الحق المعني يتم إكتسابه والاعتراف به أساساً ضمن إقليم دولةٍ مُعينةٍ ومن قبل قانون هذه الدولة، والنصوص الأولى التي خلقت سياجاً من الحماية على عناصر الملكية الصناعية هي قوانين وطنية، والجهات التي تضمن الحماية وتنفذ هذه القوانين هي جهات وطنية، ومثال ذلك أن اكتساب الحق في براءة اختراع يتم أساساً بناء على منح صك براءة الاختراع من قبل الجهة المعنية في دولةٍ ما، ولكن هذا الصك المُسمى " براءة اختراع " له من حيث المبدأ مفعول قانوني محصور ضمن نطاق الدولة التي منحتة، ولا يمتد إلى إقليم الدول الأخرى، وكذلك الأمر عند اكتساب حقوق في علامة تجارية، فهذه الحقوق هي

والمعمارية . وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فنانِي الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية، والهيئات الإذاعية، في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.

بالأساس إقليمية أو وطنية، بمعنى أنها تُكتسب نتيجة لإستعمال العلامة أو تسجيلها في إقليم الدولة المعنية، وبناء على ذلك يتم الاعتراف بهذه الحقوق من قبل قانون تلك الدولة، ولكن هذا الاعتراف ليس له مفعول في أقاليم الدول الأخرى.

وكذلك الأمر بالنسبة لعناصر الملكية الصناعية الأخرى بناء على هذه الخاصة لقانون الملكية الصناعية كان يتوجب من أجل الحصول على حماية للملكية الصناعية في أكثر من بلد أن يتم إكتساب الحق على موضوع الحماية في كل من هذه البلدان، بمعنى أن يتم الحصول مثلاً على براءة لإختراع معين من كل البلدان التي يُراد حماية الاختراع فيها، وكذلك الأمر بخصوص تسجيل العلامة في كل بلد من بلدان العالم التي يُراد حماية العلامة فيها، وإذا اخذنا بعين الاعتبار اختلاف كل من قوانين البلدان المختلفة فيما يتعلق بطرق اكتساب هذه الحقوق وحمايتها لأدركنا مقدار التعقيدات للحصول على هذه الحماية في كل بلد من البلدان المختلفة، هذا إضافةً للصعوبات العملية الناجمة عن طبيعة بعض حقوق الملكية الصناعية، فمثلاً من أجل حماية اختراع في أكثر من بلد يتوجب أن يتم التقدم بطلبات تسجيل متعددة لهذا الاختراع في كل البلدان المراد حمايته فيها خوفاً من أن يؤثر تقديم الطلب والنشر للاختراع في بلد معين على جدة الاختراع في بلد آخر.

ولقد تفاوتت مواقف التشريعات المقارنة من تقرير هذا الحق للأجانب، فمن الدول من يُساوي بين الوطنيين والأجانب كالمشرع اللبناني، ومن الدول ما قيدته بضرورة نشر المصنف لأول مرة في الدولة كالتشريع الفرنسي، ومن الدول ما تشترط شرط المعاملة بالمثل كالتشريع الإيطالي، وغالباً ما تلجئ الدول إلى توقيع اتفاقيات ثنائية أو الانضمام على اتفاقيات جماعية أو اتحادية للمحافظة على هذا الحق كاتفاقية جنيف لعام ١٩٥٢م .

وبالنسبة للمشرع المصرى فقد أدرك أهمية حماية المؤلفين الأجانب على الإقليم المصرى وأهمية الدور الذى يؤديه المؤلف فى تثقيف الأمة والنهوض بها على المستوى الفكرى، ولذلك قرر بمقتضى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد الصادر فى ٢ يونيه ٢٠٠٢م سريان الحماية المقررة بأحكام هذا القانون على كل من المؤلفين المصريين والأجانب^(١)، وكذلك حق الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن ينتمون لإحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تُعامل مصر معاملة بالمثل فى التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع لأى مكتب من مكاتب براءات الاختراع فى الجمهورية أو لتسجيل العلامات التجارية^(٢).

حق الدولة فى تجريد الأجنبي من الملكية الخاصة :

يكون للدولة أن تقوم بتجريد الأجنبي من الملكية الخاصة عن طريق الاستيلاء على أمواله والتأميم والمصادرة و نزعها للمنفعة العامة، ويختلف إجراء التأميم عن نزع الملكية عن المصادرة عن الاستيلاء عندما تتخذ الدولة لنزع ملكية اموال الأجنبي الخاصة :

- فالتأميم لا يرد على عقارٍ معين، وإنما يرد على مجموعة من الحقوق المادية أو المعنوية، ولا يكون إلا بقانون .

(١) انظر المادة ١٣٩ من القانون .

(٢) انظر نص المواد ٤ و ٦٦ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر فى ٢ يونيه ٢٠٠٢م .

- المصادرة هي إجراء عقابي يستهدف نقل ملكية مال معين إلى الدولة نتيجة لارتكاب مالكة جريمة جنائية أو سياسية تنطوي على إخلال بالنظام السياسي للدولة .

- الاستيلاء لا يترتب عليه نقل الملكية، وإنما هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة وتحصل بمقتضاه على حق الانتفاع ببعض الأموال الخاصة لهدف يتعلق بالمصلحة العامة، وذلك في مقابل تعويض لاحق .

- نزاع الملكية يرد على الأموال العقارية ويتم بقرارٍ ويُعبر ذلك عن سيادة الدولة الإقليمية على أراضيها، ولكن اتفق الفقه الدولي على شرعية هذه الوسائل وحق الدولة في اتخاذها ولكن مع مراعاة عدة شروطٍ تتمثل في:

١- عدم تعسف الدولة في استعمال حقها وعدم لجوئها لهذه الوسائل والإجراءات إلا في حدود المصلحة العامة .

٢- أن يتم التعويض العادل عن أي إجراءٍ من هذه الإجراءات عدا المصادرة؛ لأنها تكون بناء على حكم قضائي وتحمل معنى العقاب^(١)، ويقتضي ذلك أن تقوم الدولة بتعويض الأجانب تعويضاً عادلاً دون أن تكون ملزمة بتحديد الحالة التي يجوز فيها الاستيلاء على أموال الأجانب والوطنيين لهذه الغاية.

وقد اختلف الفقهاء في مسألة التعويض ما بين أنه يجب على الدولة وتكون ملزمة بالتعويض تعويضاً عادلاً، وما بين أن يكون للدولة السلطة المطلقة في أن تعوضهم أو تحرمهم من ذلك ، وما يترتب على ذلك بأنه لا يجوز للأجنبي أن

(١) انظر حول هذه الشروط د. شمس الدين الوكيل : الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٤١٨ وما بعدها، د. عز الدين عبد الله : الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مرجع سابق، ص ٦٣٥ وما بعدها ، د. فؤاد رياض: الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٢٨٨ وما بعدها.

يعترض على عدم قيام الدولة بتعويضه تعويضاً شاملاً، وبالنسبة للمشرع المصرى فقد اتخذ موقفاً متماشياً مع المبادئ المستقرة فى القانون الدولى والتي تعطى للدولة الحق فى مصادرة أموال الأجانب كعقوبة فى أحوال معينة وعدم جواز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى وحظر المصادرة الإدارية، وأجاز تأميم أموال الأجانب أو نزع ملكيتها أو الإستيلاء عليها تحقيقاً للمصلحة العامة مع مراعاة عدم التعسف فى استعمال الحق من جانب الدولة وضرورة حصول المضرور على تعويض عادلي (١).

المطلب السادس

التزامات الأجنبي

كما سبق وأن أشرنا إلى أنه بمجرد دخول الأجنبي للإقليم الوطنى يُعتبر عضواً فعلياً فى الجماعة الوطنية للدولة الموجود على أراضيها، وكما تنقرر له مجموعة من الحقوق تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات والتي لا تصل درجتها إلى الالتزامات التى يتحملها الوطنى الأصل الذى يتحمل كافة الالتزامات وليس جزءاً منها بصفته العضو الرسمى فى الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته، وهو ما نصت عليه المادة ١/٢٩ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التى فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل"، وتتمثل أهم الالتزامات الموضوعية على الأجنبي فى :

(١) انظر تفصيلاً د. هشام صادق : مركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٢٧٤ وما بعدها .

أولاً - الالتزام باحترام دين الدولة الرسمي :

يلتزم الأجنبي في مصر باحترام الدين الإسلامي باعتباره الدين الرسمي للدولة واحترام لغتها العربية وعدم الإساءة إليها باعتبارها اللغة الرسمية في البلاد^(١)، كما يحرم عليه محاولة انتهاك الديانات الأخرى التي قد تعتقها فئات أخرى من الشعب المصري كالديانة المسيحية مثلاً باعتبارها الديانة الثانية في البلاد وعدم الإساءة إليهم بأي قول أو فعل أو إشارة.

كما يلتزم الأجنبي باحترام عادات وتقاليد المجتمع المصري ونظامه الاجتماعي السائد، وذلك مهما كانت فئة هذا الأجنبي أو وظيفته أو نوع إقامته في مصر أي سواء أكان مبعوثاً دبلوماسياً أو قنصلياً أو أجنبياً عادياً .

ثانياً- الالتزام باحترام النظام القانوني والسياسي والاقتصادي للدولة :

يلتزم الأجنبي بضرورة احترام النظام القانوني والسياسي والاقتصادي للمجتمع المصري والخضوع لسلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية واحترام ما يصدر عنهم من قرارات وأحكام وتشريعات، كما يلتزم الأجنبي بضرورة احترام نظام الحكم في الدولة فلا يجوز له الإنتماء لأي تنظيم سياسي معارض أو اعتناق مذهب متطرف، ولا يجوز له تبني الأفكار والترويج للمذاهب التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي للدولة والاعتداء على مقومات المجتمع الثقافية والخلقية والفلسفية.

(١) انظر المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. " .

ثالثاً- الالتزام بعدم الانحراف عن غرض الإقامة :

تقضى المادة ٢٣ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م على أنه " لا يجوز للأجنبي الذى رُخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يُخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذنٍ بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية "، وفى حالة مخالفة الأجنبي لهذا الغرض المرخص له بالإقامة من أجله دون ترخيصٍ من السلطة المختصة اعتبرت اقامته غير مشروعة^(١)، ويلتزم وفقاً لنص المادة ٤٢ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م والمُعتمدة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٦م بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً^(٢).

رابعاً- الالتزام بالخضوع للتكاليف العامة :

يلتزم الأجانب بالخضوع للتكاليف العامة فى مصر، ومن حق الدولة أن تكلفهم بالمشاركة فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى قد تتعرض له البلاد كالكوارث الطبيعية الزلازل والبراكين والسيول والفيضانات والأوبئة، وذلك تطبيقاً لمبدأ التضامن الاجتماعى باعتبارهم أعضاء فى الجماعة الوطنية المصرية .

وقد نصت المادة الأولى من قانون التعبئة العامة رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠م والمعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٩م على أن " تُعلن التعبئة العامة بقرارٍ من رئيس

(١) د. هشام صادق : مركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٢١٤ .

(٢) وهو ما أكدته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى ٧ يونيو ١٩٥٥م والذى قضت فيه بأنه " ليس للأجنبي الذى رُخص له بإقامة مؤقتة لغرض معين أن يُخالف هذا الغرض بدون ترخيص وإلا انقلبت إقامته إقامة غير مشروعة " - انظر مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة التاسعة، ص ٤٣٦، الحكم الصادر فى ٧ يونيو ١٩٥٥م .

الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي"، كما خولت المادة ٢٤ من ذات القانون لرئيس الجمهورية أو من يُفوضه حق الاستيلاء على المواد الأولية والغذائية المملوكة للأفراد أو على عقاراتهم ومحلّاتهم التجارية والصناعية وغيرها من المواد اللازمة لمواجهة هذه الكوارث مع تعويض هؤلاء الأفراد عن ذلك بتعويضات مناسبة.

خامساً - أداء الخدمة العسكرية :

حرص المشرع المصري على إقصاء الأجانب من أداء الخدمة العسكرية وقصرها على الذكور من المصريين الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً على الأقل، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠م من أن "تُفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصري من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمره"^(١)، وبذلك يكون المشرع المصري قد اتفق على ما استقر عليه دولياً من أن الجيش الوطني لكل دولة هو وسيلة دفاعها الأساسية ودرع حماية نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنيع، وهو ما يتطلب ضرورة توافر الولاء المطلق فيمن يتم تجنيده داخل هذا الجيش، وبالتالي استقرت الدول على ضرورة إقصاء الأجانب عن أداء الخدمة العسكرية وقصر أدائها على الوطنيين فقط^(٢).

(١) نصوص هذا القانون منشورة الجريدة الرسمية في ١٨ / ٧ / ١٩٨٠م، العدد ٢٨ تابع .

(٢) ويضيف البعض أن خضوع الأجنبي للتعينة العامة بوصفه عضواً فعلياً في جماعة الدولة الوطنية لا يعني إلزامه بأداء الخدمة العسكرية لأنه ليس عضواً رسمياً في الجماعة الوطنية حتى يلتزم بذلك، حيث إنه من العسير أن يُضحى الأجنبي بحياته وبذل دمايته في سبيل دولة غير الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، لأن ذلك يتعارض مع رابطة الولاء المتطلبية بين الدولة وحامل جنسيتها، إضافة إلى ما يُشكله ذلك من خطورة

سادساً - الخضوع للضرائب :

من المُستقرّ عليه التزام الأجنبي بدفع الضرائب المباشرة التي تفرضها عليه الدولة كالضريبة على العقارات المبنية والضرائب على الأرباح والضرائب على الدخل وغيرها، وأن الأجنبي يتساوى مع الوطني في ذلك لتساويهما في الانتفاع بالمرافق العامة للدولة، ولعل خضوع الفرد للضريبة لا يعتمد على تبعيته السياسية للدولة ولكن يقوم في المقام الأول على التبعية الاقتصادية⁽¹⁾، أى عند فرض الضريبة على الشخص لا يتم النظر لجنسيته ولكن يؤخذ في الاعتبار إقامته في الدولة وانها مصدر دخله وأمواله، وهو ما حدا بالبعض إلى ضرورة فرض ضرائب خاصة إضافية على الأجنبي وحده دون الوطني كمقابل لتمتعه بالاقامة في الدولة وحمايتها له وعدم خضوعه لتكاليف خاصة يخضع لها الوطني فقط كأداء الخدمة العسكرية.

وبالنسبة لظاهرة الازدواج الضريبي أى خضوع الأجنبي للضرائب في وطنه الأصلي وفي الدولة المُعتَبَر فيها أجنبياً، وبالتالي يدفع الأجنبي الضريبة مرتين عن نفس الدخل، وهو ما يتعارض مع اعتبارات العدالة الضريبية، ولكن يكمن حل هذه المشكلة في الاتفاقيات الدولية التي تحدد نصوصها أسس وقواعد منع الازدواج الضريبي بشأن الضرائب المباشرة كأن يتضمن نص الاتفاقية فيما يتعلق بالضريبة

جسيمة وتهديد صارخ لأمن الدولة القومي وسلامة قواتها المسلحة - انظر د. هشام صادق: الجنسية والموطن ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٣٧٢ وما بعدها.

(1) Batiffol et Lagard : droit international prive , op.cit , n 184 , p209.

وانظر أيضاً د. هشام صادق: الجنسية والموطن ومركز الأجانب، مرجع سابق، ص ٣٢٥. د. أحمد قسمت الجداوى : الجنسية ومركز الأجانب، مرجع سابق ، ص ٤٥٧، د. فؤاد رياض : الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة السابعة، ١٩٩٢م ، ص ٤١٩

على الأجور والمرتببات إخضاع الفرد للضريبة في الدولة التي يتقاضى منها راتبه أو أجره .

المبحث الرابع

دخول الأجانب مصر وإقامتهم بها وخروجهم منها وإبعادهم عنها

لاشك أن من أهم الأمور التي تعنى الدولة بتنظيمها، كما تهتم الأفراد هي مسألة الدخول إلى إقليم الدولة ويرتبط بذلك مسألة حق الفرد الأجنبي في الخروج من إقليم الدولة وحق الأخيرة في إبعاده عن هذا الإقليم، لذا سوف تكون دراسة هذا الفصل إلى ثلاثة مطالب على النمط التالي:

المطلب الأول: دخول الأجانب إلى مصر.

المطلب الثانى: إقامة الأجانب بمصر.

المطلب الثالث: خروج الأجانب من مصر وإبعادهم عنها.

المطلب الأول

دخول الأجانب إلى مصر

من المعلوم أن الدول غير المستوردة للسكان كجمهورية مصر العربية تميل للحد من دخول الأجانب بإقليمها، ولعل ذلك ما يُبرز حرص التشريع المصرى السماح للأجانب بالدخول والإستقرار بإقليم الجمهورية- النص على ضرورة تحقق الشروط التالية:

١- أن يكون الأجنبى حائزاً لجواز سفر:

فقد نظم المشرع في القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م (المُعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٨م) كيفية دخول الأجانب إلى إقليم جمهورية مصر العربية، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه لا يجوز دخول إقليم الجمهورية إلا لمن كان

حاملًا جواز سفرٍ سارى المفعول صادر من السلطات المختلفة في الدولة التابع لها أو أية سلطةٍ أخرى مُعترفٌ بها، أو لمن يحمل وثيقةً تقوم مقام الجواز وتكون صادرةً من إحدى السلطات المذكورة.

ويُشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى الدولة التي أصدرتها، ويُشترط بطبيعة الحال أن يكون جواز السفر سليماً ومُستوفٍ لجميع الشروط القانونية لصحته، وأن يكون سارى المفعول ولم تنتقض مدته بعد، ويعتد في هذا الصدد بجوازات السفر الصادرة من السلطات الأخرى المعترف بها كاليئات الدولية مثل الأمم المتحدة؛ حيث تعطى لموظفيها وثائق سفر صالحة للإنتقال بها بين الدول.

وقد يستعصى على الأجانب في بعض الأحوال الحصول على جواز سفره بالمعنى المعروف، وخاصةً إذا كان عديم الجنسية، وهنا يعترف المشرع بكل وثيقةٍ مشابهةٍ لجواز السفر، ما دامت صادرةً من جهةٍ مختصةٍ مُعترفٌ بها، بقصد تيسير الانتقال دولياً، ومثال ذلك تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدولة لعديم الجنسية أو اللاجئين المقيم على أرضها، ويشترط للإعتداد بهذه الوثائق أن تتضمن تأشيرةً تُجيز لحاملها العودة إلى البلد الذي أصدرت الوثيقة، والحكمة من هذه الشروط هي عدم إحراج السلطات المصرية في استقبال أجنبي قد ترى في المستقبل إبعاده، ولا تكون على وثيقة سفره تأشيرةً تسمح له بالعودة إلى البلد التي أتى منها^(١).

(١) دششمس الدين الوكيل: مرجع سابق، ص ٣٦٩ .

وتجدر الإشارة إلى أن وثائق السفر التي تخول دخول الأراضي المصرية قد تصدر من السلطات المصرية ذاتها في بعض الحالات، وبطبيعة الحال فإنه يُشترط أن تكون الوثيقة التي تصدر في هذه الحالة من وزارة الداخلية سارية المفعول^(١).

٢- أن يكون مؤشراً على جواز السفر من السلطات المصرية بالدخول:

يُشترط ثانياً لإستقبال الأجنبي أن يكون جواز السفر أو الوثيقة المشابهة مؤشراً عليها بالإذن بالدخول من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية لجمهورية مصر العربية أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض.

وقد نص المشروع في المادة ٣٢ من القانون السالف الذكر على أن صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها أو الإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها يصدر بشأنها جميعاً قرار من وزير الداخلية رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠م والمعدل بالقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٨ م في شأن أنواع التأشيرات، ويمكن تقسيم هذه الأنواع بعد استبعاد ذوى الإقامة الخاصة والعادية إلى خمسة أنواع:

(١) حددت المادة الثالثة من القانون رقم ١٧٩ لسنة ١٩٦٤ م والخاص بتنظيم وثائق السفر الأحكام الخاصة بوثائق السفر التي تصرف لبعض فئات الأجانب فنجدتها تنص على أن يكون صرف وثائق السفر وتجديدها للفئات الآتية:

- ١- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوى الجنسية الثابتة.
- ٢- اللاجئون الذين يُعترف لهم بهذا الوصف.
- ٣- الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحصول على وثائق سفر من الدولة التي ينتمون إليها أو يوجدون بها لأسباب تُقدرها وزارة الداخلية.
- ٣- زوجات أفراد الهيئات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة وأولادهم القصر دون السادسة عشر إذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.

١- **التأشيرات الدبلوماسية:** وهي تشمل التأشيرات التي تعطى لرجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وتختص بمنحها وزارة الخارجية عن طريق إدارة المراسم بالقاهرة، و بالنسبة لتأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية فتختص بمنحها البعثات الدبلوماسية بالخارج.

٢- **التأشيرات العادية:** وتختص وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة وايضا القنصليات المصرية في الخارج) بمنحها، وهذه التأشيرات قد تمنح للدخول إلى مصر أو لمجرد المرور بها، ولا تمنح أى تأشيرة على جوازات السفر الصادرة من دولة لم تعترف بها الحكومة المصرية أو على وثيقة صادرة بناء على اتفاقية لم تنضم إليها مصر، كما لا تمنح أى تأشيرة لأى من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بقوائم الممنوعين من دخول مصر.

٣- **التأشيرات السياحية:** نظراً لما تمثله السياحة من أهمية في إنعاش إقتصاديات البلاد، فقد أجاز قرار وزير الداخلية رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠م للقنصليات المصرية في الخارج أن تمنح تأشيرات دخول لطالبيها في حالات السياحة، ما دامت أسماؤهم غير مدرجة بقوائم الممنوعين من دخول البلاد، وتكون هذه التأشيرة صالحة للاستعمال خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها، وصالحة في نفس الوقت للإقامة في مصر لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أشهر دون حاجة للرجوع إلى وزارة الداخلية.

ويرى البعض _ وبحق _ أنه إذا كان الغرض من منح التأشيرة في هذه الحالة هو تشجيع السياحة فإنه كان يجب تقييد منح تأشيرة وإقامة الأجانب الوافدين بغرض السياحة بشرط احترام النظام العام والآداب العامة، فتشجيع النشاط السياحي

يجب ألا يتعارض مع المبادئ الأولية المتعارف عليها في مصر والمستمدة أساساً من الشريعة الإسلامية الغراء^(١).

٣- تأشيرات لطلب العلم: يجوز منح هذه التأشيرة من القنصليات المصرية بالخارج إذا قدم الأجنبي إقراراً كتابياً من إحدى المدارس أو الجامعات المصرية يفيد قبوله بين صفوف طلابها، أو فيما لو كان موفداً من حكومته لتلقى العلم، أما في غير هذه الحالات فإنه يحاول طلب التأشيرة إلى وزارة الداخلية مشفوعاً بما يكون لدى الطالب من مستندات تؤهله للالتحاق بالمدرسة أو الكلية التي يقصدها.

٥- تأشيرة العمل: هذه التأشيرات تختص بالموافقة عليها وزارة الداخلية أولاً قبل صدورها من القنصليات المصرية بالخارج بهدف تنظيم العمالة الأجنبية الوافدة للبلاد بما يتفق مع الحاجة الفعلية لمصر من القوى العاملة الأجنبية ذات الخبرات المعينة، وقد استثنى القرار الوزاري بعض الفئات منها موظفو شركات الطيران العالمية في حدود معينة، وقد تشدد القانون في منح تأشيرات للعمال في مصر على أساس حماية سوق العمل الوطنية من المنافسة الأجنبية في وقتٍ يُعاني فيه المجتمع المصري من بطالةٍ مزمنةٍ بين أفرادها، لذلك فإنه لا يجوز للقنصليات المصرية في الخارج منح هذه التأشيرات إلا في حالاتٍ محددةٍ كما هو الحال بالنسبة للموظفين الأجانب في الحكومة المصرية.

وبناء على ما سلف فإنه يُمكن القول بأن القاعدة العامة لدخول الأجانب إلى مصر هو وجوب حمل الأجنبي لجواز سفر، وأن يحصل على تصريح بالدخول من

(١) د. أشرف وفا: المرجع السابق، ص ٣٨٥.

السلطات المصرية متمثلاً في تأشيرة صادرة من وزارة الداخلية أو من إحدى القنصليات في الدول الأجنبية إلا أن المشرع المصرى أدخل على هذه القاعدة استثنائين رئيسيين :

الاستثناء الأول: أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠م التي تنص على أنه "يجوز بإذنٍ خاصٍ لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يُعفى الأجنبي من أحكام المادة السابقة"، أى أنه يجوز وفقاً لهذه المادة إعفاء أحد الأجانب من شرط الحصول على تأشيرة دخول أو حتى من شرط حمل جواز سفر، وذلك بإذنٍ خاصٍ من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والحكمة من هذا الاستثناء هي احتمال وجود ظروف خاصة تُبرر إعفاء أحد الأجانب من حمل جواز سفر، كصلةٍ قويةٍ تربطه بالدولة المصرية ، أو قدومه لتحقيق مصلحة قومية للدولة أو حالة تعرضه لحادثٍ سلب منه فيه جواز سفره، أو ما إلى ذلك من اعتبارات تُقدرها سلطات الدولة^(١).

الاستثناء الثانى: وقد نصت عليه المادة الخامسة والتي جاء في سياقها " يجوز لوزير الداخلية بقرارٍ منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر" .

وكما هو ملاحظ يتعلق هذا الاستثناء بطائفةٍ من الاجانب نظراً لما لهم من روابطٍ وثيقةٍ بالمجتمع المصرى، وهم المُنتمون إلى الدولة العربية، ويجوز إعفاؤهم من شرط الحصول على تأشيرة دخول أو حتى من شرط حملهم جوازات سفر، ويكون ذلك بقرارٍ من وزير الداخلية.

(١) د.إبراهيم أحمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٣٧٣ .

هذا وقد ألزمت المادة السابعة من القانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠م ربابنة السفن والطائرات عند وصولهم إلى أراضي مصر بأن يُقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يُبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر، أو الذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوا من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.

وهكذا فإنه لايجوز دخول الأجانب إلى الأرض المصرية إلا من الأماكن المُخصصة ذلك وبإذن من الموظف المختص كما تقضى بذلك المادة الرابعة من القانون السالف الذكر.

ولاشك أن الغرض من ذلك هو تنظيم دخول الأجانب للأراضي المصرية وخلق الرقابة على هؤلاء الأجانب لمعرفة وقت دخولهم وعددهم والتأكد من حصولهم على إذن من سلطات الدولة قبل الدخول.

وقد نصت المادة ٤١ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠م والمُعدّلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٦م على الجزاءات التي يتعرض لها الأجنبي عند مخالفته لأحكام المواد ٢، ٤، ٧ من عين القانون المذكور والتي تتمثل في الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد شدد المشرع الجزاء في بعض الحالات^(١).

(١) د. عوض الله شيبه الحمد: مرجع سابق، ص ٣١ .

نظام تسجيل الأجانب:

من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص حق كل دولة في وضع تنظيم تشريعي وإداري خاص بالأجانب يكفل إخضاعهم لرقابتها، ويُسمى هذا التنظيم بضبطية الأجانب أو نظام تسجيل الأجانب، وقواعد هذا التنظيم تتلخص عادةً في وجوب تسجيل الأجانب أو نظام تسجيل الأجنبي لنفسه خلال مدة معينة بمكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في جهة إقامته، وعليه بيان حالته الشخصية ومحل إقامته والغرض من حضور البلاد، وكذلك من قواعد ضبطية الأجانب أيضاً أنه يجب على كل شخص يأوى أجنبياً أو يُلحقه بالعمل لديه إخطار الجهات المختصة بذلك كما توضح جزاءات جنائية للمخالفين لهذه القاعدة^(١).

وفي مصر كان العمل سائداً وفق هذه القواعد المنظمة لتسجيل الأجانب بمقتضى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م ، وكذلك القرار الوزاري رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، إلا أنه تشجيعاً على الإستثمار والسياحة فقد تم إلغاء نظام تسجيل الأجانب في مصر بصورة جذرية بصور القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٦م والذي نص على إلغاء نظام تسجيل الأجانب كقاعدة عامة بالنسبة لجميع الأجانب.

ومع ذلك فقد رأى المشرع عند تعديل المادة الثامنة بمقتضى القانون السالف الذكر الإبقاء على نظام تسجيل الأجانب بالنسبة لرعايا بعض الدول حفاظاً على أمن

(١) د. بدر الدين عبد المنعم شوقي: مرجع سابق، ص ٣٠٥ .

البلاد^(١)، وأما بالنسبة لغير هؤلاء الأجانب فيُكتفى بالبيان الذي يثبتته الأجنبى عند وصوله للبلاد على بطاقة الوصول.

المطلب الثانى

إقامة الأجانب في مصر

إن قبول الأجنبى في إقليم الدولة على نحو ما بيناه في المطلب السابق هو الخطوة الطبيعية نحو التصريح له بالإقامة فيها، ذلك أن استقبال الأجنبى وفقاً للقواعد التي تضعها الدولة يقتضى بالضرورة السماح له بالإقامة، وإلا كان قبوله من قبيل العبث على حد تعبير بعض فقه القانون الدولي الخاص^(٢).

وتمكن الأجنبى من دخول الإقليم المصرى لا يعنى أن من حقه الاستقرار في هذا الإقليم، بل هو يُقيم فيه لمدة محدودة، وتعين له الدولة الحد الأقصى لهذه المدة و يتعين عليه بالتالى مغادرة الإقليم المصرى عند انتهائها.

وفى هذا الصدد تنص المادة ١٦ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م في شأن دخول وإقامة الأجانب على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي جمهورية مصر العربية عند إنتهاء مدة

(١) وفى هذا الصدد فقد صدر وزير الداخلية رقم ٧٠٦٧ لسنة ١٩٩٦م ونص في مادته الأولى على أنه " يتعين على رعايا الدول الموضحة فيما يلى إتخاذ إجراءات التسجيل المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م والمعدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٦م : إسرائيل- الصومال- العراق- السودان- اليمن- فلسطين- لبنان- زائير- تشاد- غانا- ليبيريا- رواندا- بورتندس- أريتريا- الهند- باكستان- أفغانستان- سريلانكا- الفلبين- أثيوبيا- الدول المستقلة عن الإتحاد السوفيتى" - والقرار منشور في جريدة الوقائع المصرية، العدد رقم ٢٣١، في ٣١ أكتوبر ١٩٩٦م.

(٢) د. شمس الدين الوكيل مشار إليه لدى د. هشام صادق: مرجع سابق، ص ٣٨ .

إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته،^(١) ويترتب على مخالفة الأجانب لذلك اعتبار إقامته غير مشروعة، وتكون العقوبة في هذه الحالة وفقاً للمادة ٤٢ من القانون هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعادةً ما تمنح الدولة الترخيص بالإقامة لمدة معينة تحدد في تأشيرة الدخول التي يحصل عليها الأجنبي وتكون هذه المدة قابلةً للتجديد بناءً على طلب الأجنبي المقيم، وهو طلب يخضع بحسب الأصل لمطلق تقدير السلطات المختصة في الدولة، وهو ما حكمت به محكمة القضاء الإداري في ٣١ مايو ١٩٥٣ م من أن "حق الأجانب في الإقامة في إقليم الدولة من الحقوق التي تستقل هي بالتصرف فيها وتنظيمها وتعيين ما يترتب عليها من آثار دون أن يرد على سلطانها قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعاً خاصاً في هذا الشأن".

كما قرر المشرع في المادة ٢١ من القانون أن وزير الداخلية يُحدد بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها، والأصل أن الترخيص بالإقامة لا ينصرف أثره إلا للشخص الذي يحصل عليه، ومع ذلك فقد استثنى المشرع في المادة ٢٤ من القانون الأجانب ذوو الإقامة الخاصة مؤكداً أن أثر الترخيص يمتد إلى الأولاد القصر المرخص له لحين بلوغهم سن الرشد، وكذلك الزوجة إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في مصر سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة.

(١) أشار إليه د. عز الدين عبدالله : مرجع سابق، ص ٦٧٥.

هذا ويُراعى أن الترخيص بالإقامة يتضمن تحديد الغرض من دخول الأجنبي وإقامته في إقليم الدولة، وهو ما يتعين على الأجنبي أن يتقيد به، فإذا دخل للعلاج فعلاً أو للسياحة في مصر فليس له أن يعمل بها، وإذا اضطر إلى تغيير الغرض من دخوله مصر فلا بد وأن يحصل على إذن بذلك من سلطات الدولة وإلا تعرض للعقوبة المقررة بمقتضى المادة ٢٤ سالفه الذكر؛ نظراً لاعتبار إقامته غير مشروعة في هذه الحالة^(١).

ويلُحظ أن دخول الأجنبي بطريق مشروع إلى مصر لا يلزم السلطات الإدارية منحه ترخيص إقامة، إذ أن ذلك يخضع للسلطة التقديرية للإدارة طالما أنها تستند إلى أن وجوده على إقليمها يُشكل خطراً على النظام العام والآداب العامة، فتتعرض لذلك أن تمنحه ترخيصاً، وبعد أن بسط المشرع في المادة ١٦ السالفه الذكر القاعدة العامة في كون الترخيص في الإقامة شرطاً لإقامة الأجنبي في مصر، أورد في المادة ١٧ من القانون ببيان فئات الأجانب من حيث الإقامة وهي تقضى بأن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات على النحو التالي:

أولاً- الأجانب ذوو الإقامة الخاصة:

تُمنح الإقامة الخاصة في جمهورية مصر العربية لطوائف معينة من الأجانب نستعرضها فيما يلي وفقاً للترتيب الذي جاء به نص المادة ١٨ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م :

أ- الأجانب الذين ولدوا في الإقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ م ولم تنقطع إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٣٧٥ .

ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢م، ولم تنقطع إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريقة مشروعة.

ج- الأجانب الذي مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع.

وكذلك الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للإقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وتعيين هذه الأعمال والخدمات يكون بقرار من وزير الداخلية.

د- العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.

ويتضح من ذلك أن هذه الطوائف من الأجانب ترتبط بمصر بصلة وثيقة، ناتجة إما عن الميلاد في مصر، أو الإقامة فيها مدة طويلة، أو نتيجة لتأدية خدمات جليلة للبلاد، وفي الواقع فإن المشرع المصرى يُجيز للسلطة التنفيذية منح الجنسية المصرية لمن يؤدى لمصر خدمات جليلة، كما يجعل الميلاد في مصر والإقامة فيها ضمن الأسباب التى تمكن الأجنبى من طلب الجنسية المصرية.

وهكذا منح المشرع لوزير الداخلية فى الحالة الأخيرة سلطة واسعة فى التعبير عن اعتراف مصر بفضل الأجانب من أهل العلم والمعرفة تقديراً لخدمات جليلة يسدونها للبلاد، وهو لا يتقيد فى منح هذه الإقامة الخاصة بسبق توافر إقامة

مستمرة للأجنبي في مصر، بل يكفي أن يكون الأجنبي قد أسدى للبلاد خدمةً جليةً في ميدان العلم والمعرفة لتعبر الدولة له عن عرفانها بالجميل عن طريق منحة إقامة خاصة تمتد إلى عشر سنوات تقبل التجديد بمجرد الطلب ما لم يتوافر في حقهم بسبب من أسباب الإبعاد^(١).

والملاحظ أن هذه الطوائف من الأجانب ترتبط بمصر بصلة وثيقة ناتجة إما عن الميلاد في مصر، أو الإقامة فيها مدة طويلة، أو نتيجة لتأدية خدمات جلية للبلاد، ولذلك رخص المشرع لهم بالإقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون، كذلك قرار أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات أخرى بمجرد الطلب، وهو ما دعى البعض إلى القول أن إقامة الأجانب المنتمين إلى هذه الفئة هي في الواقع من قبيل الإقامة الدائمة؛ نظراً لأن الترخيص بالإقامة وتجديدها يتم بقوة القانون دون نظر أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الصدد^(٢).

ولا تقتصر الإفادة من الإقامة الخاصة على الأجنبي وحده، بل قرر المشرع في المادة ٢٤ مد الإنتفاع بهذه الإقامة للأولاد القصر للأجنبي الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغهم سن الرشد، وكذلك زوجته كما سبق ذكره.

وقد خول المشرع للسلطة التنفيذية رفض الترخيص بالإقامة أو تجديدها إذا ما توافرت في الأجنبي حالة من حالات الإبعاد المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م ومن هذه الناحية يتميز الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، إذ لا بد لإبعادهم من توافر شروط خاصة، وإتخاذ إجراءات معينة تختلف عما هو يتبع بالنسبة لسائر الأجانب كما سنرى، ويرى أن بعض الفقه أن امتناع الإدارة عن

(١) دشمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص ٣٨٣.

(٢) د. فؤاد رياض: المرجع السابق، ص ٤٧٦.

تجديد الإقامة هو في حقيقة الأمر إيعاد للأجنبي المتمتع بالإقامة الخاصة، وذلك على أساس أن رفض التجديد للأجنبي ذى الإقامة الخاصة وإنهاء هذه الإقامة الدائمة كالإبعاد سواء بسواء، لذا يتعين تعليق رفض تجديد مدة الإقامة بالنسبة لهذه الفئة على موافقة اللجنة المشروط أخذ رأيها بصدد حالات الإبعاد نظراً لوحدة النتيجة في الحالتين^(١).

وباستقراء نص المادة ٢٢ من القانون نجد أن الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية أن يتغيب في الخارج لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ولا يحول تغيبه لهذه المدة دون احتفاظه بحقه في الإقامة المرخص له بها، فإذا كان ينوى التغيب لمدة تزيد عن هذا الحد وجب عليه أن يحصل على إذن بذلك قبل سفره وقبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا السفر، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، ويسقط حقه في الإقامة كذلك إذا حصل على الإذن بالتغيب في الخارج وأمتد تغيبه لمدة تزيد على سنتين.

وقد راعى المشرع في ذلك أن الأجنبي الذى يتغيب في الخارج لمدة تربو على سنتين تكون علاقته بمصر قد أصابها الوهن والانحلال، مما يستتبع زوال حقه في الإقامة المرخص له بها^(٢)، ولكن يُستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو الخدمة الاجبارية إذا قدموا ما

(١) د. فؤاد رياض: المرجع السابق، ص ٤٧٧.

(٢) د. محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، ١٩٩٢م، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص ٢٨٩.

يُثبت ذلك، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى ٢٢ ديسمبر ١٩٥٢م^(١).

ثانياً- الأجانب ذوو الإقامة العادية :

بالإضافة إلى فئة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة توجد فئة أخرى من الأجانب ترتبط بالمجتمع المصرى- إلا أنهم أقل ارتباطاً من الطائفة السابقة- وهى طائفة الأجانب ذوو الإقامة العادية، وهم الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢م ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وليس للسلطة التنفيذية أن ترفض منح هذه الطائفة من الأجانب هذه المدة للإقامة فى مصر، ولكن إذا انتهت هذه المدة فلا تلتزم السلطة التنفيذية بتجديدها، إذ جعل المشرع تجديد المدة جوازياً، فإذا ارتأت رفض تجديد مدة الإقامة فيمكنها ذلك ويخضع الأمر للسلطة التقديرية التى لا يقيد بها القضاء إلا من حيث ضرورة عدم الانحراف فى استعمال السلطة، وعلى هذا فيجب على جهة الإدارة ألا ترفض الإقامة للأجانب دون مسوغ معقول تقتضيه المحافظة على سيادة الدولة وأمنها ونظامها العام، وإلا جاز للقضاء تقويم هذا الانحراف فى استعمال السلطة^(٢).

وقد نص المشرع كذلك بالنسبة للأجانب ذوى الإقامة العادية على عدم جواز الغياب فى الخارج مدة لا تزيد على ستة أشهر ما لم يحصلوا قبل سفرهم على إذن

(١) الحكم منشور فى مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى، ص ١٧، ص ١٩٤.

(٢) انظر حكم محكمة القضاء الإدارى فى ١٨/١٢/١٩٤٦، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى، السنة

١١، ص ٩٧، مشار إليه لدى د. إبراهيم أحمد إبراهيم: المرجع السابق، ص ٣٨٢.

من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها، ولا يجوز بأى حالٍ من الأحوال أن تزيد مدة الغياب بالخارج عن سنتين، ويستثنى من ذلك حالة التغيب فى الخارج لطلب العلم أو الخدمة العسكرية الاجبارية أو بسبب قوة قاهرة، كذلك يقتصر الانتفاع بالإقامة العادية على الأجنبى الذى رخص له فيها دون من عداه من أفراد أسرته .

ثالثاً- الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة :

وأما الفئة الثالثة والأخيرة منهم الأجانب الذين لا ترتبطهم بالجماعة الوطنية أى من الصلات التي رأيناها بالنسبة للأجانب الداخلة في الفئتين السابقتين، وبالتالي فصلتهم بالدولة تعتبر صلةً عابرةً، ولا تقوم إقامتهم بإقليم الدولة إلا على مجرد التسامح، وقد نص المشرع في المادة ٢٠ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م على أنه " يجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها".

ويندرج تحت فئة الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة كل من لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتمتع بالإقامة الخاصة أو العادية، ويمكن القول بصفة عامة أن هذه الفئة تشمل الغالبية العظمى من الأجانب الذين يفدون إلى إقليم جمهورية مصر العربية كالقادمين بقصد السياحة أو طلب العلم أو لأى من الأغراض التي لا تستلزم الاستقرار بإقليم الدولة.

والأصل أن مدة الإقامة سنةً واحدةً، يجوز للسلطة التنفيذية تجديد هذه المدة عند انتهائها، إلا أنه في عام ١٩٨٠م صدر القانون رقم ١٢٤ الذي يقضى بتعديل المادة ٢٠ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م بحيث يجوز الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات يجوز تجديدها لنفس المدة، وذلك للأجانب المرتبطين

بمصر ارتباطاً وثيقاً بسبب العمل أو للاعتبارات العائلية أو الإنسانية أو السياسية التي يوافق وزير الداخلية على مبدأ الأخذ بها^(١).

غير أنه بصدور القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٦ م صار من حق وزير الداخلية منح بعض الأجانب إقامة مؤقتة على الأراضي المصرية لمدة خمس سنوات مع جواز تجديدها بنفس المدة، وذلك وفقاً للحالات التي يصدر بها قرار من هذا الوزير^(٢) وبناء على ذلك فقد أضيف إلى نص المادة ٢٠ من القانون رقم ٨٩ لسنة

(١) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: مرجع سابق، ص ٣٨٣ وما بعدها .

(٢) أولاً- الأجانب أصحاب الإقامة المؤقتة الخماسية:

نصت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم ٨١٨٠ لسنة ١٩٩٦م على أن يكون الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية:

١-المستثمرون.

٢- المصري الذي فقد جنسيته نتيجة الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكذلك أولاده القصر الذين شملهم هذا الإذن.

٣-الأبناء وهم: أ- أبناء الأم المصرية. ب- الأبناء الذين منح أبائهم الجنسية المصرية.

ج-الأبناء البالغون سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب.

٤-الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاماً واستقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش.

٥-الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.

٦-زوجات وأرامل المصري.

٧-زوجات الأجانب المرخص لها في الإقامة العادية.

٨-زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات في الحالات السابقة.

ثانياً- الأجانب أصحاب الإقامة المؤقتة الثلاثية:

هؤلاء الأجانب الذين أجاز لهم وزير الداخلية في قراره رقم ٨١٨٠ لسنة ١٩٩٦ م الإقامة في الأراضي المصرية لمدة ثلاث سنوات حددتهم المادة الثانية من القرار المذكور كالآتي:

١- الأجانب أزواج المصريات.

٢- الأبناء وهم:

أ- الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوةً بوالدهم في حالة وفاته.

ب- الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لأبائهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود موارد تعيش لهم. ج- الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة أو المحالين منهم إلى المعاش الذين أنهوا دراستهم ولا يعملون.

٣- العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع الاعمال العام.

٤- الفلسطينيون العاملون بإدارة الحكم العام لقطاع غزة والمحالون منهم إلى المعاش.

٥- الفلسطينيون حاملو وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية فقط الذين استقرت أوضاعهم وإقامتهم في جمهورية مصر العربية لمدة عشر سنوات سابقة.

٦- الأجانب الذين يتقاضون معاشاً شهرياً من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

٧- الأجانب من نزلاء الملاجئ من العجزة وكبار السن.

٨- اللاجئين المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

٩- اللاجئين السياسيون.

١٠- أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة أو العادية.

١١- المصرية التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج من أجنبي ودخلت جنسيتها.

١٢- زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة.

١٣- الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.

١٤- الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية.

١٥- الأجانب الذين تقضى الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.

١٦- الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة لمدة ثلاث سنوات في الحالات السابقة.

١٩٦٠م فقرةٌ جديدةٌ تقضى بأن " ومع ذلك يجوز بقرارٍ من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارٌ منه^(١).

وبإمعان النظر في مواد هذا القرار نجد أن وزير الداخلية قد مايز في صدد الإقامة المؤقتة بين فئتين من الأجانب : الأولى منح أصحابها الإقامة لمدة خمس سنوات مع جواز تجديدها، في حين أن الفئة الثانية منح أصحابها الإقامة لمدة ثلاث سنوات مع جواز تجديدها.

هذا وقد قرر المشرع في المادة ٣٧ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠م بعض الإعفاءات من القواعد المتعلقة بدخول الأجانب بصفةٍ عامةٍ إلى الإقليم المصرى وإقامتهم به في حالة وجود ما يُبرر ذلك كأن تقتضى طبيعة عمل الأجنبي إقامته في مصر كالممثلين الدبلوماسيين، أو أن يكون وجود الأجنبي في مصر بغرض العبور إلى دولةٍ أخرى كرجل السفن والطائرات أو ركبائها التي ترسو أو تهبط في مصر بصفةٍ مؤقتةٍ.

المطلب الثالث

خروج الأجانب من مصر وإبعادهم

رأينا أن للدولة حق منع الأجنبي من دخولها في بعض الفروض واشتراطها على الأجنبي توافر عدة شروط للسماح له بدخول إقليمها، وذلك كله على خلاف الوطنى الذي لا يحق للدولة التي ينتمى إليها أن تحرمه من دخول إقليمها، والأمر شبيه ذلك بالنسبة للخروج من إقليم الدولة؛ حيث إن للأجنبي حق الخروج من الدولة

(١) د. عوض الله شيبه الحمد: مرجع سابق، ص ٣٩ وما بعدها.

اختياراً، وللدولة حق اخراجه قسراً، أما الوطنى فله حق الخروج اختياراً ولكن لا تملك الدولة إبعاده.

ولما كان الأمر كذلك فندرس فيما يلى وعلى التوالى خروج الأجانب من مصر بمحض إرادتهم، وخروجهم قسراً أو ما يُسمى بنظام الإبعاد.

أولاً- خروج الأجانب من مصر باختيارهم:

الأصل أن الأجنبى حرٌّ في مغادرة إقليم الدولة ما دام غير مدين في مواجهتها بالتزاماتٍ أو أعباءٍ معينة، أو غير متهم في جريمةٍ لم تتم محاكمته عنها، أو لم يكن هارباً من عقوبةٍ لم يكتمل تنفيذها، وبصفةٍ عامةٍ تتوافر للأجنبى هذه الحرية حينما لا يكون للدولة حقٌّ تطالبه بها^(١).

إذ لا يجوز للدولة بداهةً أن تمنع رعايا الدول الأخرى من الخروج من إقليمها، لما في ذلك من إعتداء على حرية الأفراد في التنقل من دولةٍ إلى أخرى.

ومع ذلك فقد نص المشرع المصرى في المادة السادسة من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ م على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم أراضي جمهورية مصر العربية الحصول على إذنٍ خاصٍ "تأشيرة"، وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على الإذن، ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يُرخص لها في منحه صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل".

وبالتالى لا يجوز لأحد من الأجانب أن يغادر أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كان حاصلاً على إذنٍ بذلك، وهو ما يُسمى " تأشيرة الخروج" التي توضع على وثيقة السفر، وينطبق هذا الحكم على الأجانب كقاعدةٍ عامةٍ، وقد استثنى

(١) دشمس الدين الوكيل: مرجع سابق، ص ٣٩٨ .

قرار وزير الداخلية من حكم الحصول على تأشيرة الخروج الأجنبي الذين لم تزد مدة إقامته في مصر على ستة شهور وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب وموظفو الأمم المتحدة الأجانب الذين يشغلون وظائف في مكتب الأمم المتحدة.

ويتعرض الأجنبي الذي يُغادر الأراضي المصرية دون الحصول على الإذن أو يُبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبةً أو قدم أوراقاً غير صحيحة لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج من مصر للعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٤٣ وهي عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويرى بعض الفقه أن هذا القيد وإن كان يستهدف الرقابة على كل أجنبي طالت إقامته بالبلاد على نحو قد يجعله مديناً بأعباء أو تكاليف معينة، إلا أن تقييد حرية مغادرة الدولة لا يتفق مع الأصول العامة في القانون الدولي، إلا إذا دعت إليه ضرورة قصوى كظروف الحرب أو الأحوال الاستثنائية^(١).

ثانياً- الإبعاد Expulsion :

لاشك أنه إذا كان للأجنبي الحق في مغادرة إقليم الدولة، فإن الأخيرة يمكن لها أن تخرجه من إقليمها جبراً وقهراً ولو قبل إنتهاء مدة إقامته بها، وذلك إذا كان في بقائه ما يهدد سلامة المجتمع أو أمنه.

ومن هذا المنظور يختلف الإبعاد عن بعض المفاهيم الأخرى كالرد والتسليم والنفي، حيث يمكن تعريف الإبعاد باعتباره قراراً تصدره السلطة العامة في الدولة

(١) د. شمس الدين الوكيل: مرجع سابق، ص ٤٠١ .

لأسباب تتعلق بسلامتها وأمنها الداخلي أو الخارجي، وتطلب بمقتضاه من الأجنبي المقيم فيها مغادرة إقليمها خلال مدة محددة وعدم العودة إليه وإلا تعرض للجزاء والإخراج بالقوة^(١).

أما الرد **Repoulement** فهو إجراء يلحق الأجنبي عند دخول إقليم الدولة أو عقب دخوله مباشرة ويقضى إلى إخراجه فوراً دون أية مهلة للتنفيذ، و يجوز للدولة أن تقوم برد الأجنبي في هذه الحالة إذا تبين أن دخوله إلى إقليمها قد تم على نحو يخالف نصوص تشريعاتها المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات أو ضرورة الدخول من أماكن معينة كما رأينا، أو كان من الأشخاص غير المرغوب فيهم بسبب أو لآخر.

أما التسليم **Extradition** فهو تسليم المجرم الأجنبي للدولة التي ارتكب جريمته على إقليمها لتمكينها من محاكمته وفرض العقاب عليه، فهو إجراء تتخذه الدولة لمصلحة المجتمع الدولي في مجموعه، في حين أن الإبعاد يُعبر عن سلطة الدولة التي تمارسها المصلحة الجماعية الوطنية.

وأخيراً فإن النفي **Bannissement** يُعتبر إجراء من الإجراءات التي قد تتخذها الدولة في مواجهة أحد مواطنيها أوقات الاضطرابات الداخلية أو باعتباره عقوبة جنائية قد تقضى بها المحاكم في فروض استثنائية، وعندما يرتكب أحد الوطنيين جريمة من الجرائم السياسية التي تستدعي توقيع مثل هذه العقوبة، وهكذا فإن النفي يقع على أحد الوطنيين، في حين أن الإبعاد يتم في مواجهة الأجانب^(٢).

(١) في تفصيل راجع د. هشام صادق: مرجع سابق، ص ٤٠ ومابعداها، وحول نظام الإبعاد بصفة عامة راجع د. جابر عبدالرحمن: إبعاد الأجانب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ١٩٣٩ م.

(٢) د/فؤاد رياض: مرجع سابق، ص ٤٨٤.

وقد ترتب على إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر استرداد الحكومة المصرية سلطتها الشرعية في جواز إبعاد الأجانب، وعلى ذلك أصدر المشرع المصري المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ م والذي سمح بموجبه للسلطة التنفيذية بإبعاد الأجانب وفقاً لما تقتضيه اعتبارات الصالح الوطني، وقد نقل القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م والمُعدل بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٦م غالبية الأحكام الخاصة بالإبعاد التي كان يتضمنها الرسوم بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٥٢ م .

ومن ثم فقد نص المشرع المصري في المادة ٢٥ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠م على أنه لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب، أصبح من حق السلطة التنفيذية إبعاد من ترى من الأجانب وفقاً لما تقتضى به اعتبارات ومصالح البلاد والمحافظة على أمنها وسلامتها.

وقد أكدت الأحكام القضائية حق الدولة في إبعاد الأجانب غير الجديرين بالإقامة في البلاد وعلى تمتع الإدارة في ذلك بسلطة تقديرية واسعة، ففي حكمها الصادر في ٢١ / ٢ / ١٩٨٧ أكدت المحكمة الإدارية العليا أن " ولا جدال في حق الدولة في إبعاد الأجانب بلا معقبٍ عليها مادام قرارها قد خلا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، كما أن سلطتها في إبعاد الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة سلطة مطلقة تمارسها تحقيقاً للمصلحة العامة بأوسع معانيها، فيكفى أن تتحقق في الأجنبي من ذوى الإقامة المؤقتة الحالة التي تجعله غير مرغوب فيه ليقوم المقتضى لإبعاده خارج البلاد بناء على حق الدولة الأصيل في عدم الإبقاء على الأجنبي الذي ترى في وجوده ما يضر بأمنها أو ينال من مصالحها على أى وجه من الوجوه"^(١).

(١) انظر الطعن رقم ١٧٨٦ لسنة ٣١ قضائية، جلسة ٢١ / ٢ / ١٩٨٧ م ، الموسوعة الإدارية الحديثة، ج ٢٥، ص ٣٣٢ .

ونظراً لأن الأجانب ذوى الإقامة يرتبطون بالإقليم المصرى أكثر من غيرهم من الأجانب فقد قيد المشرع سلطة الإدارة في إبعادهم، حيث لا يجوز إبعادهم إلا بعد مراعاة أمرين يُمكن الكشف عنهما بمطالعة نص المادة ٢٦ من القانون السالف الذكر والتي نصت على أنه " لا يجوز إبعاد الاجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يُهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالةً على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٩ وموافقتها".

وهكذا فلا بد من توافر أمرين لإبعاد الأجانب ذوى الإقامة الخاصة عن مصر:

١- استلزام عرض قرار الإبعاد على لجنة تُشكل خصيصاً لهذا الغرض وضرورة موافقتها على ذلك ^(١)، على خلاف القانون القديم الذي كان يجعل رأى هذه اللجنة استشارياً، وجديرٌ بالذكر أن أخذ رأى هذه اللجنة هو فقط بالنسبة لطائفة ذوى

(١) حيث تنص المادة ٢٩ من القانون على أنه " تشكل لجنة الإبعاد على الوجه التالى :

(١) وكيل وزارة الداخلية رئيساً .

(٢) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة..... عضواً.

(٣) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة..... عضواً

(٤) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضواً

(٥) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية عضواً

(٦) مندوب عن مصلحة الأمن العام عضواً

وتتخذ اللجنة بناء على طلب رئيسها، وبشروط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل - وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الذى منه الرئيس، ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه ، وتبدي اللجنة رأياها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة . -

الإقامة الخاصة؛ إذ لا يُشترط ذلك بالنسبة للأجانب ذوى الإقامة العادية أو ذوى الإقامة المؤقتة^(١).

٢- أن يكون قرار الإبعاد مبنياً على الأسباب المذكورة في نص المادة ٢٦ المذكورة بعاليه، وفي هذا الصدد يرى بعض الفقه أن هذه الأسباب من المرونة بحيث يُمكن أن تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للإبعاد، ومن ثم يُمكن القول بأن الضمان الذي أراد المشرع توفيره بالنسبة للأجانب ذوى الإقامة الخاصة- بتحديد الأسباب المسوغة إبعادهم- لا يعدو أن يكون ضماناً شكلياً؛ إذ تستطيع الإدارة في الغالبية العظمى من الحالات أن تحتج بوجود الأجنبي في أى من الحالات الواردة بالنص، وأن الضمان الحقيقي يتمثل في تعليق إبعاد الأجنبي على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية وقضائية (مادة ٢٩) مما يكفل جعل الإبعاد بعيداً عن الأهواء والتسرع.

كما أن البعض ذهب إلى أن تحديد أسباب إبعاد الأجانب ذوى الإقامة الخاصة ليس بذى بالٍ لعموم عبارة النص، ولأن السلطة التنفيذية غالباً ما لا تلجأ إلى إبعاد الأجانب لأمرٍ لا يندرج تحت هذه الأسباب^(٢).

أما بالنسبة لغير هذه الطائفة من الاجانب فلم يضع المشرع أى تحديدٍ للأسباب المبررة لإبعادهم، وبالتالي فيمكن للسلطة التنفيذية عدم التقيد بهذه الأسباب، ولكن هل يعنى هذا أن يعمل الأمر إلى حد إبعاد الأجنبي بدون سببٍ معقولٍ يُبرر ذلك، وهل تُعتبر السلطة التنفيذية مطلقة في هذا الشأن؟

(١) واعتبرت محكمة القضاء الإداري أن ضرورة أخذ رأى لجنة الإبعاد " إجراءً جوهرى لما فيه من ضمان للشخص المراد إبعاده، ويترتب على إغفاله بطلان قرار الإبعاد" - راجع الحكم الصادر عن المحكمة فى ٢١ مايو ١٩٥٣ م ، مجموعة أحكام مجلس الدولة، س٧، ص ٢٨٢ .

(٢) د. عز الدين عبدالله : مرجع سابق، ص ٦٨٧.

رقابة القضاء على قرارات الإبعاد:

الحق أنه إذا كان من المسلم به أن من حق الإدارة إبعاد الأجانب إلا أن ذلك يجب أن يخضع لرقابة القضاء، ذلك أن القرار الصادر بالإبعاد لا يُعد عملاً من أعمال السيادة وإنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري، وقد استقر القضاء على ذلك^(١)، ومن ثم للحكومة الحق في إبعاد الأجانب بلا معقبٍ عليها ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون^(٢).

وقد قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في ٨ أبريل ١٩٥٢ م بأن "قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وليس من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاصها، وإنما هي أوامر إدارية عادية، مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها وطلبات التعويض المترتبة عليها".

وقضت ذات المحكمة في حكم لها بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٥٢ م بأن "للدولة حق إبعاد الأجانب صيانةً لكيانها وحمايةً لأفراد شعبها من أي ضررٍ أو خطرٍ، ولها في هذا الصدد سلطة واسعة في تقدير ما يضرها ولا يضرها، على أن يكون الإبعاد صادراً عن حسن نية بغرض المحافظة على الصالح العام ودرء الضرر أو الخطر عن الدولة، وبعبارة أخرى ألا تصدر قرارات الدولة في إبعاد الأجانب عن سوء استعمال السلطة"^(٣).

(١) د. عز الدين عبدالله : مرجع سابق، ص ٦٩١، د/فؤاد رياض: مرجع سابق، ص ٤٨٧ .

(٢) انظر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ١٢ ديسمبر ١٩٥٠ م ، مجموعة مجلس الدولة للأحكام، س ٥، ص ٢٦٦.

(٣) مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، س ٧، ص ٣٣١.

كما قضت بأن الأمر بحجز الأجنبي مؤقتاً حتى يتم إجراءات الإبعاد قراراً إدارياً يخضع بدوره لرقابة القضاء الإداري^(١)، وحرى بالذكر أن الأصل أن قرار الإبعاد لا يصيب إلا من صدر في مواجهته دون بقية أفراد أسرته، وهكذا فإنه إذا لم يكن في إقامة الأجنبي ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها أو الصحة العامة أو الآداب العامة فلا مبرر لإبعاده^(٢)، وبناء عليه فإن الإدارة عند إبعادها للأجانب تلتزم بعدم التعسف في استعمال سلطاتها في الإبعاد والانحراف بهذه السلطة وإلا جاز الطعن في القرار الصادر بالإبعاد.

إجراءات وآثار الإبعاد:

تقرر المادة ١٢ من قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ م (الخاص بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ م) والذي تم تعديله بقرار رقم ٥٨٥ لسنة ١٩٦٩ م بأن تقوم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإبلاغ الأجنبي قرار إبعاده بالطريقة الإدارية وتمنحه مهلة في حدود خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ لمغادرة أراضي الجمهورية ما لم تنص في القرار على غير ذلك، وللمبعد أن يختار جهة الحدود التي يريد الخروج منها، ما لم تعين المصلحة المذكورة جهة معينة يغادر منها البلاد، ويجوز النص في قرار الإبعاد على إرساله إلى تلك الجهة مخفوراً.

وبمقتضى قانون سنة ١٩٦٠ م فإنه يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتاً حتى تتم إجراءات الإبعاد (المادة ٢٧)، وجدير بالإيماء أن حبس

(١) راجع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢٥ ديسمبر ١٩٥١ م مجموعة المجلس للأحكام، ص ٦، ص ٢٢٠.

(٢) راجع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢٨ يناير سنة ١٩٥٣ م مجموعة المجلس للأحكام، ص ٧، ص ٣٣٠.

حرية الأجنبي في هذه الحالة يجب ألا يكون إلا بالقدر الضروري لتنفيذ الإبعاد الذي يجب أن يتم بسرعة^(١).

وفي بعض الحالات قد يتعذر تنفيذ قرار الإبعاد، كما لو صدر ذلك القرار ضد أجنبي عديم الجنسية إذا لم توجد دولة تقبل إستقباله إليها، وقد واجهت المادة ٣٠ من القانون مثل هذه الأوضاع حيث نصت على أنه "لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار، وذلك إلى حين إمكان إبعاده.

هذا وقد يترتب الإبعاد بطريقة غير مباشرة في الحالة التي تنتهي فيها مدة الإقامة الخاصة بالأجنبي وترفض الإدارة تجديدها له، إذ أن ذلك يؤدي إلى ضرورة خروجه من إقليم الدولة بعد أن أصبحت إقامته غير مشروعة.

وهكذا فإنه علاوة على وجوب رحيل المبعد عن أراضي جمهورية مصر العربية فإنه يمنع من الدخول إلى الإقليم المصري حيث نصت المادة ٣١ من القانون على أنه "لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية إلا

(١) وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن للحكومة وهي بسبيل تنفيذ الإبعاد "أن تحجز الشخص الأجنبي إلى أن يتم إبعاده، على أن يكون هذا الحجز بالقدر اللازم لهذا الغرض، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكومة رأت إبعاد المدعي على اعتبار أنه أجنبي وليست له في مصر إقامة شعرية فخبرت القنصلية اليونانية ظنا بأنه من رعايا اليونان لتمنحه جواز سفر يوناني وحجزته الحكومة خلال ذلك على ذمة إبعاده، وإذا أجابت القنصلية اليونانية أن المدعي لا ينتمي إليها فإنها لا تكون قد حجزته على ذمة الإبعاد إلا بالقدر الذي تستلزمه الإجراءات في مثل هذه الظروف." - انظر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ٧ ديسمبر ١٩٤٧م.

بإذن من وزير الداخلية"، ويتعرض الأجنبي العائد بلا سند مشروع للعقوبة الواردة في المادة ٣٩ التي تنص على مُعاقبته بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

المبحث الخامس

أحكام الاستثمارات الأجنبية في مصر

في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م

وسنحاول التعرض في هذا المبحث وبإيجازٍ شديدٍ لأهم الأحكام الخاصة بمعاملة الاستثمارات الأجنبية في القانون المصري، ولاسيما التي تقررّت أخيراً بعد صدور قانون الاستثمار المصري الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م^(١) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧م، والذي بناءً عليه أُلغى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون^(٢).

وفي تناولنا لهذه الأحكام سنتعرض لمفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه (مطلب أول)، وضمنات الاستثمار الأجنبي التي قررها هذا القانون (مطلب ثان)، وما وضعه المشرع من حوافز لتشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في مصر (مطلب ثالث)، وكذلك الجهات القائمة الجهات القائمة على شئون الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م، وذلك على الوجه التالي :

(١) صدر قانون الاستثمار المصري الجديد في ٣١/٥/٢٠١٧م، وهو منشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم ٢١ مكرر «ج» الصادر في الواحد والثلاثين من شهر مايو لعام ٢٠١٧م، أما لائحته التنفيذية فقد صدرت في بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ م .

(٢) حيث نصت المادة الثامنة من قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م على أنه " يُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعدلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. " .

المطلب الأول

مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه وأهدافه ومبادئه

أولاً - تعريف الاستثمار الأجنبي:

بات الاستثمار أكثر الموضوعات التي حظيت باهتمام فقهاء القانون الدولي بفرعيه الخاص والعام، ورغم هذا الاهتمام الفقهي إلا أن الفقه لم يتفق على تعريف قانوني موحد للاستثمار حيث جاءت معظم التعريفات التي قيلت في هذا الصدد متعلقةً بالنواحي الاقتصادية دون القانونية، ويرجع ذلك إلى تشابك الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تفرض نفسها عند محاولة إيجاد تعريف جامع ومانع للاستثمار .

وقد عرف الفقيه الفرنسي "Fouchard" الاستثمار بأنه " الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تهدف إلى إنشاء أو التوسع في مشروع قائم "، بينما عرفه جانباً من الفقه المصري بأنه " توجيه جانب من أموال المشروع الأجنبي أو خبرته التكنولوجية إلى العمل في مناطق جغرافية خارج حدود دولته الأصلية " ^(١)، بينما فضل البعض الآخر من الفقه تعريف الاستثمار بأنه " انتقال أحد عوامل الإنتاج عبر الحدود الدولية للمساهمة في الاستغلال الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد تحقيق ربح نقدي متميز " ^(٢) .

(١) د. محسن شفيق: المشروعات ذات القوميات المتعددة من الناحية القانونية، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العددان الأول والثاني، ١٩٧٨م، ص ٢٣٨.

(٢) د. حازم جمعة: المشروعات الدولية العامة وقواعد حمايتها في القانون الدولي، ١٩٨٠م، ص ١٥٧، وقد عرفته اللجنة المنبثقة من مؤتمر اتحاد القانون الدولي الحادي والخمسين والمنعقد بمدينة طوكيو بأنه " تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر " .

كما عرفه البعض بأنه " انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بغية تحقيق ربح للمستثمر الأجنبي وبما يكفل زيادة الإنتاج والتنمية في الدولة المضيفة " ^(١)، ولكن يُقصد بالاستثمار بصفة عامة " أى زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع نتيجة إقامة المصانع والمباني والمزارع والطرق وغيرها من المشروعات التي تُعد تنميةً للرصيد الاقتصادي للمجتمع " ^(٢).

ونتيجة عدم إجماع الفقه على تعريف موحد للاستثمار فقد آثرت جميع تشريعات الاستثمار المتلاحقة التي أصدرها المشرع المصري الابتعاد عن هذا الخلاف عن طريق تحديدها الهدف فقط من الاستثمار دون التعرض لتعريفه ^(٣).

وبالنسبة لقانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م فقد وضع في المادة الأولى منه تعريفاً للاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري، في خطوة منه نحو التأكيد على الأخذ بمعيار رأس المال دون الاعتماد بجنسية أصحابه بغرض تحقيق

(١) د.جميل الشرقاوى : المقاصد الأساسية لقوانين ضمان الاستثمار في البلاد العربية، معهد البحوث والدراسات العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، ١٩٧٨م، ص ٣٣، د.صفوت أحمد عبد الحفيظ : دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة عين شمس، ١٩٩٩م، ص ١٥ وما بعدها .

(٢) د.حازم جمعة : المرجع السابق، ص ١٥٧، د.محمد سلطان أبو على: مبادئ الاقتصاد التجميعي، ١٩٧٩م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٧٦ وما بعدها .

(٣) قانون الاستثمار الملغى رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩م كان ينص في مادته الأولى على أن " يكون الاستثمار وفق أحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "، وكذلك القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الملغى بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م اكتفى بتحديد مجالات الاستثمار في مصر، بمعنى أنه لكي تسرى أحكامه على أى مشروع يكون لزاماً على هذا المشروع مباشرة أحد الأنشطة التي حددتها المادة الأولى من هذا القانون والتي نصت على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، التي نشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية" .

تنمية اقتصادية شاملة عن طريق جذب رؤوس الأموال وتشجيعها على الوفود من الخارج نظراً لعدم كفاية راس المال داخل الدولة للقيام بالمشروعات الاستثمارية، وقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

المستثمر: استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً أياً كان النظام القانوني الخاضع له يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المشروع الاستثماري: مزاوله أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا..... " .

أما المادة الثانية من القانون فقد تولت بيان أهداف الاستثمار حين نصت على أنه " يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية..... " .

ثانياً - أنواع الاستثمار :

ينقسم الاستثمار إلى نوعين رئيسيين: أولهما يُسمى بالاستثمار المباشر؛ حيث يقوم المستثمر بنفسه وبأمواله الخاصة بإنشاء مشروع أو توسيع مشروع قائم ويُطلق عليه أيضاً الاستثمار المادى أو الفنى استناداً إلى قيام المستثمر فيه بتقديم المساهمة المالية والفنية والتكنولوجية للدولة المضيفة، وثانيهما يُطلق عليه الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار المالى؛ حيث يقتصر دور المستثمر فيه على تقديم المساهمة المالية والذى يتم غالباً بتقديمه القروض اللازمة لتمويل المشروع المراد إنشاؤه .

وخلقاً بنا للإيماء بأن مفهوم الاستثمار تطور بشكل ملحوظ في الوقت الحاضر لم يعد قاصراً على الصور التقليدية التى أشرنا إليها، بل ظهرت أنواع وصور جديدة للاستثمار أبرزها المشروعات المشتركة التى يشارك فيها رأس المال الوطنى المستثمر الأجنبى فى المشروع المراد إنشاؤه على إقليم الدولة المضيفة للاستثمار .

ثالثاً - أهداف الاستثمار ومبادئه :

لقد أوضح المشرع بطريقة صريحة وواضحة أهداف الاستثمار مع إيراد مجموعة من المبادئ التى تحكم الاستثمار فى جمهورية مصر العربية تلتزم بها الدولة المضيفة للاستثمار بجميع أجهزتها الإدارية وكذلك المستثمر الأجنبى، وذلك فى المادة الثانية من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م والتى نصت على أنه " يهدف الاستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة." .

ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

- ١- المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييزٍ بسبب الجنس.
 - ٢- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
 - ٣- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
 - ٤- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
 - ٥- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
 - ٦- العمل على استقرار السياسات الإستثمارية وثابتها.
 - ٧- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
 - ٨- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.
- وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه".

المطلب الثانى

ضمانات الاستثمار الأجنبى فى مصر

وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م

تحتاج معظم الدول خاصةً النامية منها إلى الاستثمار الأجنبى لكونه يستطيع أن يقوم بدورٍ أساسى وفعال فى دفع عجلة التنمية بها، فهو بلا شك يُمكنها من استغلال مواردها الطبيعية والبشرية فى تحقيق تنميةٍ سريعةٍ وشاملةٍ فى جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق منها بالبنية التحتية كالصحة والتعليم والاتصالات وشبكات الطرق ومرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحى .

ولتحقيق ذلك يحتاج الاستثمار إلى توفير بيئةٍ استثماريةٍ مناسبةٍ ومشجعةٍ من خلال توفير الضمانات الاقتصادية والقانونية الكفيلة لتوفير عنصرى الأمان والاطمئنان للمستثمر الأجنبى لتحقيق توازنٍ مطلوبٍ بين أطراف عقد الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدة على تمكين الاستثمارات الوطنية من التوطن والثبات على إقليم الدولة .

فالمستثمر بطبيعة الحال يبحث عن البيئة الخصبة التى تُقدم له أفضل الفرص التى تُحقق له أكبر قدرٍ من الاطمئنان على أمواله من المخاطر، ولاسيما غير التجارية منها كالمصادرة والتأميم وغيرها من الإجراءات التى من شأنها التأثير على مشروعه الاستثمارى، وهو ما جعل الدول تتنافس على تضمين قوانين الاستثمار العديد من الضمانات الكفيلة بيبث الطمأنينة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار على إقليمها، وفى طليعة هذه الدول مصر والتى أصدرت فى الآونة الأخيرة قانون

الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م والذي تضمن إلى جانب العديد من المزايا^(١) مجموعة من الضمانات للاستثمار في مصر سنسردها على النحو التالي :

أولاً - توفير مناخ استثماري مطمئن وجوٍ منصفٍ وبيئةٍ قانونيةٍ عادلةٍ للمستثمر الأجنبي:

حيث تنص المادة الثالثة من قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م على أنه " تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملةً مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

(١) سعي قانون الاستثمار الجديد الي توفير الحوافز و تحقيق الحوكمة و تسهيل التجارة عبر الحدود و توفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية و يأتي بأدوات و إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار و بدء و مزاولة النشاط.

و من مميزات قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م :

- ١- الحد من البيروقراطية و السماح بالحوافز الجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمالٍ متطورةٍ و عصرية.
- ٢- لأول مرة، يمكن للمستثمرين التقديم علي الخدمات و دفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت.
- ٣- تم تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية وبتعين على السلطات الحكومية أن تستجيب الي المستثمرين في خلال تلك الفترة.
- ٤- تم تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة و الممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات و الطلبات المقدمة، فلا يحتاج المستثمر الي جمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت و التكلفة و يسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية و استثمارية في مصر.

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز. وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذور الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُعبّر نص تلك المادة عن رغبة الدولة في إزالة الخوف الذي يُمكن أن يمتلك المستثمرين الأجانب ومنحهم قدرًا من الطمأنينة للاستثمار بها ومراعاة اعتبارين رئيسيين: أولهما يتمثل في قلق المستثمر الأجنبي من ضياع رأس ماله، وثانيهما عدم اطمئنانه إلى إمكان قيامه بمشروع ناجح يُدر عائداً يوازى ما قام به من مجهود وما تعرض له من مخاطر.

وبالتالى كان لزاماً على الدولة إزالة ما أصاب المستثمرين من قلق وخوف خاصة في ظل التعقيد والجمود الذى تتسم به الإجراءات الإدارية، والتعسف الذى يُمكن أن يشوب القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية التابعة للدولة المضيفة للاستثمار، وبناء عليه أعطت هذه المادة للمستثمر الأجنبي مجموعة من الحقوق تتمثل في :

- (أ) الحق في المعاملة العادلة والمنصفة بعيدة عن أى تعسف أو جور .
- (ب) حق المساواة بينه وبين المستثمر الوطنى وعدم التمييز بينهما .
- (ج) الحق في الإقامة على إقليم الدولة حتى انتهاء مشروعاته الاستثمارية .
- (د) الحق في تبليغه وإخطاره بكل القرارات الإدارية المتعلقة بمشروعاته الاستثمارية، مع وجوب تسببها كضمانة مهمة من ضمانات عدم تعسف جهة الإدارة تجاهه.

ثانياً – عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها بالطريق الإدارى أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها :

وتم النص على هذا الحظر فى المادة الرابعة من قانون الاستثمار الجديد والتي نصت على أنه " لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق

الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تُبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباءً مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى. " .

وبناء على نص هذه المادة فقد أقر المشرع للمستثمر الأجنبي ضماناً تُعد من أهم الضمانات التي يمكن تقريرها للمستثمر الأجنبي وهي عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروع الاستثماري، وهو ما دعا البعض إلى التقرير بأن " الضمان الأساسي الذي يتصور بدونه إقدام الأجنبي على استثمار رأس ماله بالدول النامية هو تأمينه ضد تأميم الدولة المضيفة لأمواله أو على الأقل تأمينه ضد أى تأميم لماله دون تعويض عادل، لذلك اضطرد العمل في الدول النامية على النص في تشريعاتها الداخلية أو اتفاقياتها مع دولة المستثمر الأجنبي على عدم تأميم رأس مال المستثمر خلال المدة المحددة للمشروع الاستثماري، أو التعهد بدفع تعويض عادل في حالة إجراء مثل هذا التأميم ^(١)، كما يرى البعض الآخر أن " الدولة عندما تمنح امتيازاً لشركة أو فرد فلا يُعقل أن تتنازل عن حقها في السيادة على مصادر الثروة القومية وفي اختيار النظام الاجتماعي الذي ترتضيه واستخدامها لحق لصيق بسيادتها معترف به دولياً وتُبرره اعتبارات المصلحة العامة، ولا يمكن أن يُعتبر في حد ذاته عملاً غير مشروع، فالتأميم يُمثل للدول النامية خطوة لازمة، وكثيراً ما تكون عاجلة

(١) د. فؤاد عبد المنعم رياض: المرجع السابق، ص ٤٠٠، ٤٠١.

لا تحتمل التأجيل في سبيل تصفية الميراث الاستعماري والتخلص من آثاره الاقتصادية، ويستتبع هذا التسليم بحق الدولة في إعادة تنظيم أوضاعها " (١) .

وقد حرص المشرع المصري في الدستور المصري الحالي على النص في المادة ٣٥ منه على أن " الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تُزَع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضٍ عادلٍ يدفع مقدماً وفقاً للقانون. "، ولكن ما الحل إذا كان الحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الاستثمار يتعارض مع أحكام الدستور التي تُقرر للدولة حق التأميم تحقيقاً للمصلحة العامة ؟ نرى من جانبنا أن في حال حدوث هذا التعارض فإن المشرع يكون قد تنازل صراحةً عن حق الدولة في التأميم بما يدعو للتساؤل هل يستحق بالفعل تشجيع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في مصر أن تتنازل الدولة عن سيادتها ؟

في رأينا أنه لا مناص من تطبيق نص المادة الصريح وأنه لا اجتهاد مع صريح النص القانوني، وبالتالي فواجب تطبيقه وإعماله مع قناعتنا التامة في أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يؤدي إلى جذب وتشجيع قدوم رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار على إقليم الدولة دون أن يكتنفها خوفٌ أو قلقٌ من مثل هذه الإجراءات، ومن شأنه أيضاً أن يُعيد ما فقدته الدولة المصرية في الأعوام السابقة من ثورات

(١) فالتأميم يعني نقل المشروع من إطار الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، بحيث يتحقق قانوناً بمجرد إسقاط حقوق الملاك السابقين ونقل السيطرة إلى الجماعة الوطنية، أي للشعب في مجموعه، أما المصادرة فهي تُطلق على أخذ الملكية دون تعويضٍ أو مقابل تعويضٍ غير كافٍ - للمزيد انظر د. أحمد القشيري: التأميم في القانون الدولي الخاص، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، عام ١٩٦٣م، ص ٢٣٣، ٢٥٢.

وانتفاضات واضطرابات عطلت عجلة التنمية الاقتصادية وباتت مصر في أمس الحاجة لمثل هذه الاستثمارات على أراضيها حتى تستطيع النهوض مرة أخرى ومواكبة عصر النهضة الذي بات في عجلة من أمره ولا ينتظر الدول النامية التي ما زالت تشريعاتها تحتاج إلى التعديل والتحديث لتلحق بركب التقدم السريع.

كما قرر المشرع وفقاً لنص المادة عدم جواز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية أو التحفظ عليها أو الحجز على أموالها أو مصادرتها أو تجميدها بالطريق الإداري رغبةً منه في بث الطمأنينة والثقة في نفوس المستثمرين تجاه رؤوس أموالهم، ولكن يجوز أن توقيع كل ما سبق من إجراءات بموجب الأوامر القضائية أو الأحكام القضائية النهائية^(١)، وهو ما يتفق ونص المادة ٤٠ من الدستور المصري الحالي ٢٠١٤م والتي نصت على أن "الحماية من المصادرة العامة للأموال محظورة"، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".

ثالثاً- عدم جواز إلغاء أو إيقاف التراخيص الصادرة للمشروعات الاستثمارية أو سحب ترخيص العقارات المخصصة لها :

تنص المادة الخامسة من قانون الاستثمار الجديد على أنه " لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

(١) وهو ما قرره محكمة الإسكندرية في حكمها الصادر في ٢٣ فبراير ١٩٨٨م حيث قالت ".....أنه إذا كان البادئ من ظاهر الأوراق أن الشركة المدعية تخضع لأحكام قانون الاستثمار، ومن ثم فإنها تتمتع بضماناته ومزاياه، ولا يجوز بالتالي اتخاذ إجراءات الحجز على أموالها بغير الطريق القضائي وإلا وقع الحجز باطلاً بطلاناً مطلقاً، فإذا اتبع الدائن غير هذا الطريق القضائي كان الحجز باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، فيكون لكل ذي مصلحة التمسك به، كما يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها " - الحكم مشار إليه بموسوعة الاستثمار للدكتور عبد الفتاح مراد، الطبعة الثانية، ص ١٦٤ - ١٦٦.

وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المُشار إليها في الفقرة الأولى، وتُبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مُستوفياً جميع الإجراءات القانونية المُقررة.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة " ٨٣ " من هذا القانون.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها. "

ووفقاً لنص تلك المادة يبين لنا رغبة المشرع المصرى الأكيدة فى تأكيد حرصه على تشجيع الاستثمار الأجنبى وتهيئة المناخ الملائم له، وبناء عليه فقد قرر عدم جواز قيام الجهات الإدارية بإلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع الاستثمارى إلا بعد قيامها بإخطار المستثمر بمخالفاته المنسوبة إليه ومنحه مهلة مناسبة للدفاع وسماع أقواله وإزالته لأسباب المخالفة .

وبما أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً إدارياً فقد أعطى المشرع للمستثمر حق التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٨٣ من القانون، وبناء عليه يجوز له فى حال رفض التظلم أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال المدة المحددة قانوناً وفقاً للمادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م وهى ستين يوماً .

رابعاً- ممارسة المستثمر جميع الحقوق على مشروعه الاستثمارى دون قيود أو شروط:

تنص المادة السادسة من قانون الاستثمار الجديد على أنه " للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلباً بذلك مرفقاً به المستندات اللازمة، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركات تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . " .

وبموجب نص تلك المادة يكون المشرع قد سمح للمستثمر الأجنبي بممارسة جميع الحقوق المشروعة على مشروعه الاستثمارى دون تقييده بقيد أو شرط ؛ فمنحه الحق فى إقامة المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج وبالعملة الأجنبية، كما أعطاه حق التملك لهذا المشروع الاستثمارى وإدارته واستخدامه والتصرف فيه، بل

وتحويل أرباحه إلى الخارج كيفما يشاء، كما أنه في حال التصفية لهذا المشروع الاستثمارى يحق له تحويل ناتج التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك كله بعد تحمل الالتزامات المفروضة عليه والواجب عليه تنفيذها للدولة في إطار هذا القانون .

خامساً- حرية الاستيراد والتصدير :

تنص المادة السابعة من قانون الاستثمار الجديد على " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقاً لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال. " .

ووفقاً لنص تلك المادة يكون المشرع قد أقر للمشروعات الاستثمارية الحق فى استيراد جميع المواد الخام والآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ووسائل النقل دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، كما منحها الحق فى تصدير منتجاتها للخارج دون حاجة إلى ترخيص أو القيد فى سجل المصدرين مع التزامها

فقط بضرورة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بكميات وأنواع هذه المنتجات المصدرة أو المستوردة .

سادساً- استعانة المشروعات الاستثمارية بالعمالة الأجنبية :

تنص المادة الثامنة من قانون الاستثمار الجديد على أنه " للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (١٠ %) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (٢٠ %) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدھا قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .

وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج. " .

ووفقاً لنص تلك المادة فقد رخص المشرع للمشروعات الاستثمارية حق الاستعانة بالعمال الأجانب حتى ٢٠ % من العدد الاجمالى للعاملين بالمشروع الاستثمارى، ولكن اشترط المشرع لذلك عدم وجود عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة والتى يحتاجها المشروع الاستثمارى، كما أنه رغبةً منه فى القضاء على البطالة ورفع كفاءة العمالة الوطنية والاستفادة من وجود هذه المشروعات الاستثمارية على أراضي الدولة أجاز لبعض المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى عدم الالتزام بالنسب الموضحة بالفقرة الأولى من المادة

وتجاوزها بشرط التزامها بتدريب العمالة الوطنية ورفع كفاءتها، كما سمح المشرع وفقاً لنص المادة للعمالة الأجنبية بامكانية تحويل مستحققاتها للخارج دون أى قيود أو شروط .

سابعاً- عدم خضوع شركات المساهمة الاستثمارية لأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٥م وعدم خضوع الشركات التجارية الاستثمارية لأحكام قانون الشركات رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣م :

تنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد على انه " تُستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣م بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها". .

وبنص تلك المادة يكون المشرع المصرى قد أدرك أن الاستثمار الأجنبى يتطلب فى أغلب الأحيان عمالةً مدربةً على درجاتٍ عاليةٍ من الكفاءة والمؤهلات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وهو ما لا يتوافر فى العمالة الوطنية، مما دفع المشرع إلى حتمية إعفاء المستثمر الأجنبى من الخضوع لقوانين العمل الوطنية عن طريق إعفاءه شركات المساهمة من الخضوع لأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٥م، كما أعفى الشركات التجارية الاستثمارية الخاضعة لهذا القانون من

مجموعة القيود التي تلتزم بها الشركات وفقاً لقانون الشركات رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣م

.

المطلب الثالث

حوافز الاستثمار الأجنبي في مصر

وفقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م

أورد قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م العديد من الحوافز للمستثمرين الوطنيين والأجانب على السواء بهدف تشجيعهم على الاستثمار في مصر، وتتمثل هذه الحوافز في :

أولاً- الإعفاء من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر والتسجيل والرسوم الجمركية :

تنص المادة العاشرة من قانون الاستثمار الجديد على أنه " تُعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .

كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة(٤) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣م، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطوانات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها إلى الخارج .

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تُسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. " .

ويتضح من نص المادة أن المشرع المصرى فى سبيل تشجيع الاستثمار على الأراضى المصرية قد أجاز للمشروعات الاستثمارية التمتع بالإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر والتسجيل المقررة على عقود تأسيس تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على عقود تسجيل الأراضى اللازمة للمشروعات لمزاولة أنشطتها الاستثمارية، كما أعفى المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الرسوم الجمركية المقررة على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جانبها لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، فى حين أنه قرر خضوع الشركات والمنشآت الاستثمارية لضريبة جمركية مخفضة مقدارها ٢% على جميع ما تستورده هذه المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة ولوازم إنتاج .

ثانياً- حوافز استثمارية خاصة :

تنص المادة ١١ من قانون الاستثمار الجديد على أنه " تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي :

١- نسبة (٥٠ %) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تُبنيه اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع(ب).

٢ - نسبة (٣٠ %) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) :

ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة .
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها .
- المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى .
- المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى .

- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي تصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .

- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية .

- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها .

- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية .

- صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل .

- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية .

- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (٨٠ %) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ م .

كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرضٍ مشتركٍ من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية والنطاق

الجغرافى للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها

أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره .

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. "

ولكن يُشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بهذه الحوافز الخاصة وفقاً لنص المادة ١٢ من هذا القانون ما يلي :

- ١- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
- ٢- أن تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
- ٣- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
- ٤- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحوافز أياً من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند " ٢ " من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحوافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ثالثاً- حوافز إضافية بقرارٍ من مجلس الوزراء :

أعطى المشرع لمجلس الوزراء وفقاً لنص المادة ١٣ من قانون الاستثمار الجديد سلطة تقرير حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية إلى جانب الحوافز الخاصة التي أشرنا إليها سابقاً في المادة ١١ من هذا القانون، بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر؛ حيث نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القانون، وذلك على النحو التالي:

- ١- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو ووارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
 - ٢- تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
 - ٣- تتحمل الدولة لجزءٍ من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
 - ٤- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
 - ٥- تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
- كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة
وضوابطه وشروطه. " .

المطلب الثالث

تسوية منازعات الاستثمار فى قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ م

تنص المادة ٨٢ من قانون الاستثمار الجديد على أنه " مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، يجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة".

كما تنص المادة ٩٠ من ذات القانون على أنه " تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتفق عليها المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ م .

كما يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقاً للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي "الحر"، أو التحكيم المؤسسي".

ويتضح من نص المادتين ٨٢ و ٩٠ من قانون الاستثمار الجديد أن المشرع المصرى يرغب فى إزالة أى خوف لدى المستثمرين من عدم إمكان حصولهم على حقوقهم فى حال نشوب النزاع بينهم وبين الدولة المضيفة أمام قضاء هذه الدولة، حيث إن المستثمر الأجنبي قد يساوره القلق والشك فى عدالة وحيادية وإنصاف القاضى الوطنى له ضد دولته الوطنية، أو خضوع هذا القاضى لتأثير دولته لحماية مصالحها، أو مشاركته دولته فى المبادئ والأفكار القانونية والاقتصادية التى تتبناها دولته وتحتج بها فى مواجهة المستثمرين الأجانب بصفة عامة، وبناء عليه فقد أراد المشرع أن يبعث رسائل طمأنينة وسكينة إلى هؤلاء المستثمرين؛ حيث أتاح لهم

تسوية منازعاتهم الاستثمارية مع الحكومة المصرية بالعديد من الطرائق والوسائل أهمها :

١- المفاوضات بين المستثمر الأجنبي والحكومة المصرية، في خطوة من المشرع نحو وأد هذه المنازعات قبل نشوبها وتفاقمها وتلافى الدخول في مراحل التسوية لهذه المنازعات حتى لا تتعطل هذه المشروعات الاستثمارية عن تنفيذ خططها والمساعدة في دفع عجلة التنمية بالدولة المضيفة للاستثمار .

٢- الطريقة المتفق عليها بين المستثمر الاجنبى والحكومة المصرية، وبالتالي يكون المشرع قد أعطى المستثمر الحق في تسوية النزاع بعد الاتفاق مع الحكومة المصرية عن طريق اللجوء إلى المحكمة المختصة أو محكمة محددة بذاتها أو تسوية النزاع بطريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، وذلك كله حسبما يسفر عنه الاتفاق بين المستثمر والحكومة .

٣- وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م، وقد صدر هذا القانون فى ١٨ أبريل ١٩٩٤م ونص فى مادته الأولى على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيمياً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه علي إخضاعه لأحكام هذا القانون"، ومن خلال النص يبين لنا أن التحكيم يتم تطبيقه بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع وسواء أكان أطرافه من

أشخاص القانون العام أم الخاص، وسواء أكان تحكيمياً مدنياً أو تجارياً، وطنياً أم دولياً، وبذلك فإن نصوصه تشمل التحكيم بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار^(١).

٤- اللجوء إلى التحكيم سواء أكان التحكيم المؤسسى أم التحكيم الحر" غير المؤسسى"، بعد أن ظهر الملل والضيق من اللجوء إلى القضاء العادي لحل منازعاتهم، وإزاء تعدد المشاكل والمنازعات والتي يقابلها في الوقت نفسه عجز القضاء وبطئه في حلها وتسويتها، ظهرت الحاجة إلى وسيلة أخرى أكثر كفاءة وقدرة على حل منازعات الأطراف، ومن ثم أضحت التحكيم الوسيلة السريعة والعادلة التي يسوى بها أطراف النزاع منازعاتهم.

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار :

تشكيلها وكيفية عملها: يتم إنشاؤها وتشكيلها وفقاً لنص المادة ٨٨ من قانون الاستثمار الجديد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة في حضور جلساتها.

(١) حول أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م راجع : د.أحمد السيد الصاوى : التحكيم طبقاً للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م وأنظمة التحكيم الدولية، ٢٠٠٢م، د.عاشور مبروك : النظام الإجرائى لخصومة التحكيم، الطبعة الثانية، ١٩٩٨م، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، د.ناريمان عبد القادر : اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤م، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، دار النهضة العربية، القاهرة .

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعندى تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصاتها: طبقاً لنص المادة ٨٩ من قانون الاستثمار الجديد تختص اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار بما يلى :

١- بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

٢- تتولى _ متى لزم الأمر _ إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يُحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.

وتقوم اللجنة بدورٍ مؤثرٍ فى تسوية منازعات الاستثمار؛ حيث يتوجب على اللجنة أن تعرض تقريراً مفصلاً بما نتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبةً النفاذ وملزمةً للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.

المركز المصرى للتحكيم والوساطة :

تشكيله : نصت المادة ٩١ من قانون الاستثمار الجديد على إنشاء مركزٍ مستقلٍ للتحكيم والوساطة يُسمى " المركز المصرى للتحكيم والوساطة " يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره محافظة القاهرة .

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قراراً من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات عمله وفقاً للنظام الأساسى للمركز.

ويتولى أعضاء مجلس الإدارة اختيار الرئيس من بينهم، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاملته المالية قراراً من مجلس الإدارة، و يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه و القواعد المهنية و الإجراءات المنظمةة له و مقابل الخدمات التى يقدمها و قوائم المحكمين و الوسطاء و أتعابهم قراراً من مجلس إدارة المركز و يُنشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية .

اختصاصاته: وفقاً لنص المادة ٩١ من القانون يتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامةً أو خاصةً، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

موارده المالية : بموجب نص المادة ٩١ من القانون تتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لما يُحدده النظام الأساسي له، و توفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون موارد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، و لا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموالٍ من الدولة أو إحدى أجهزتها.

المطلب الرابع

الجهات القائمة على شئون الاستثمار

فى قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م

أولاً- المجلس الأعلى للاستثمار:

تم إنشاؤه بموجب نص المادة ٦٨ من قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م، ويختص بما يلى :

- ١- اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخٍ أفضلٍ للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
- ٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
- ٣- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
- ٤- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

٥- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

٦- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

٧- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.

٨- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولية.

٩- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.

١٠- تفعيل المسؤولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها.

١١- حل الخلافات والتشابكات التي قد تنشأ بين أجهزة الدولة في مجال الاستثمار، ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ثانياً- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقاً لنص المادة ٦٩ من قانون الاستثمار الجديد هي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص، وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شؤونه والترويج له، على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقرها

الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة .

تشكيلها :

وفقاً لنص المادة ٧٣ من قانون الاستثمار الجديد يكون للهيئة مجلس إدارة يضم فى تشكيله كل من :

- ١- الوزير المختص..... رئيساً.
 - ٢- الرئيس التنفيذى للهيئة..... عضواً .
 - ٣- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة عضواً .
 - ٤- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة..... عضواً .
 - ٥ - اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص، والثانى فى مجال القانون..... عضواً .
- ونصت المادة أيضاً أن يكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرار يصدر من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللمجلس الاجتماع مرة شهرياً على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنوياً من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

الاختصاص الأصيل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة :

نصت المادة ٧٠ من قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢م والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥م فى شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١م، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣م، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩م بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١م.

ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤م بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من أملاك الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية .

ومن النص يبين لنا أن المشرع قد أوكل مهمة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها، كما أنه لم يفرض عليها فى المسائل المالية والإداري التقيد بالنظم والقواعد

الحكومية، ورخص لها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وأجاز لها فى سبيل تنفيذ عملها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال و تخصيص عقارات لها من أملاك الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.

الاختصاصات الأخرى للهيئة :

أضافت المادة ٧١ من قانون الاستثمار الجديد للهيئة مجموعة من الاختصاصات الأخرى تمثلت فى :

- ١- إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
- ٢- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
- ٣- إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.
- ٤- إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

٥- وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

٦- توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار والتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

٧- وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

٨- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكلٍ دوري.

٩- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخلياً وخارجياً.

١٠- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.

١١- إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة :

وفقاً لنص المادة ٧٤ من قانون الاستثمار الجديد والتي أوردت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي :

١- وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.

- ٢- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.
- ٣- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- ٤- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
- ٥- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
- ٦- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قراراً من الرئيس التنفيذي للهيئة.
- ٧- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
- ٨- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ٩- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه في هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار.

١١- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التي تقدم من خلال الهيئة.

١٢- وضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

١٣- وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.

موارد الهيئة :

طبقاً لنص المادة ٧٥ من قانون الاستثمار الجديد تتكون موارد الهيئة مما يلي

:

١- الاعتمادات المالية التي تُخصصها لها الدولة.

٢- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة عدا تلك التي تحصلها لحساب الجهات الأخرى.

٣- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٤- مقابل تشغيل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.

٥- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.